การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและที่รโหฐาน

โดย

นางสาว จิรสุดา ถาวรสุขสิริ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายอาญา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2554

Search of persons in public place and in private place

By

Miss Jirasuda Thavornsuksiri

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

Criminal Law

Faculty of Law

Thammasat University

2011

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยานิพนธ์

ของ

นางสาวจิรสุดา ถาวรสุขสิริ

เรื่อง

การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและที่รโหฐาน

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ _____

(รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ)

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและในที่รโหฐานตามมาตรา 93 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมุ่งศึกษากระบวนการค้นตัวบุคคลตั้งแต่ผู้ใช้อำนาจในการค้น เหตุอันควรสงสัยอันเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน กระบวนการค้นตั้งแต่กระบวนการก่อนการค้น กระบวนการระหว่างการค้น กระบวนการหลังการค้น ตลอดจนผลของการค้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เนื่องจากการค้นตัวบุคคลเป็นการใช้อำนาจของรัฐที่กระทบต่อสิทธิในร่างกายซึ่งประกอบด้วยสิทธิในการเคลื่อนไหวและสิทธิที่จะไม่ถูกลำลาย อีกทั้งกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกประติบัติ โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของประเทศไทยต่อไป

จากการศึกษาพบว่าศาลและเจ้าพนักงานผู้ใช้อำนาจในการค้นยังเข้าใจหลักการเรื่องเหตุอันควรสงสัยคลาดเคลื่อนอยู่มาก อีกทั้งหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน มาตรา 93 ยังมีข้อบกพร่องที่ควรได้รับการแก้ไขเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ถูกตรวจค้นไปพร้อมกับการสอบสวนอาชญากรรม ผู้เขียนจึงมีขอเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. **หลักการ “ เหตุอันควรสงสัย ”**

แนวทางของเจ้าพนักงานในการตัดสินข้อเท็จจริงก่อนทำการตรวจค้นว่ากรณีใดเพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ หรือแนวทางของศาลในการพิพากษาคดี ผู้เขียนเสนอว่าศาลไทยควรใช้แนวทางการตัดสินของคำพิพากษาต่างประเทศมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานและพิพากษาคดี เพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานอ้างอำนาจกฎหมายในการเข้าค้นตัวบุคคลโดยง่ายและตามอำเภอใจ เนื่องจากเหตุอันควรสงสัยต้องมีมาก่อนการค้นและการค้นที่ไม่มีเหตุอันควรสงสัยจะเป็นการค้นที่มิชอบด้วย ส่งผลให้ศาลไม่อาจรับฟังพยานหลักฐานได้

2. แก้ไขเพิ่มเติม**ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา มาตรา 93** ให้มีหลักการดังต่อไปนี้

2.1 เงื่อนไขของเหตุค้นตัวบุคคล ควรให้ค้นกรณีที่เจ้าพนักงานสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของซึ่ง “ได้ใช้ ” หรือ “ พยานหลักฐานที่อาจเป็นพิสูจน์ความผิดที่ได้ซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องสงสัยนั้นได้ ”

2.2 กระบวนการค้นตัวบุคคล ผู้เขียนเสนอว่าควรเพิ่มหลักเกณฑ์ในมาตรา 93 ทั้งกระบวนการก่อนค้น ระหว่างการค้นและหลังการค้นให้มีความสมบูรณ์และเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ถูกค้นตัวมากยิ่งขึ้นตามแนวทางของต่างประเทศ ดังนี้

1. การค้นต้องกระทำด้วยสุภาพ ไม่กระทบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เลือกปฏิบัติ

2.เจ้าพนักงานต้องแจ้งให้ผู้ถูกค้นทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานและใช้อำนาจตามกฎหมายใด อธิบายเหตุแห่งการใช้อำนาจ เหตุใดจึงมีเหตุอันควรสงสัย และในกรณีที่ไม่สวมเครื่องแบบต้องแสดงบัตร

3.การตรวจค้นตัวในเบื้องต้นทำได้เพียงการแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธเท่านั้น แต่เจ้าพนักงานสามารถตรวจค้นอย่างละเอียดได้ในกรณีที่มีเหตุอันควรจำเป็นแต่จะต้องทำในที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ

4.ต้องกระทำโดยเจ้าพนักงานหญิงหรือบุคคลอื่นที่เป็นเพศหญิง เว้นแต่ไม่อาจทำได้

5.การตรวจค้นต้องกระทำ ณ บริเวณที่เรียกให้หยุดและในระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้ความสงสัยหมดไป ต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคน และให้ผู้ตรวจค้นแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการค้น

6.เจ้าพนักงานควรจัดทำบันทึกการตรวจค้นและส่งมอบบันทึกให้แก่ผู้ถูกตรวจค้นทันทีหรือภายใน 14 วันดังหลังทำการตรวจค้น และแจ้งแก่ผู้ถูกตรวจค้นว่าเขามีสิทธิได้รับสำเนาก่อนทำการค้น

3. **การค้นตัวบุคคลในที่รโหฐาน** กรณีนอกขอบเขตของหมายค้นหรือนอกขอบเขตของการค้นโดยไม่มีหมาย เจ้าพนักงานไม่สามารถตรวจค้นตัวโดยใช้วิธีการตามมาตรา 100 วรรคสองได้ ผู้เขียนขอเสนอว่าให้นำหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานตามมาตรา 93 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ในกรณีนี้ด้วย เนื่องจากการค้นตัวบุคคลแม้อยู่ในที่รโหฐานก็กระทบกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในร่างกายของผู้ถูกค้นเช่นกัน เจ้าพนักงานจึงไม่สามารถค้นบุคคลในที่รโหฐานได้ตามอำเภอใจ เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรสงสัยเสียก่อนเช่นเดียวกับกรณีค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน

Abstract

This research aims to study search of persons in public place and in private place pursuant to Criminal Procedure Code section 93. Researcher emphasizes on search of person which is divided in several issues such as an officer is empowered to search, the interpretation of reasonable suspicion, the protocol of search before the search, during the search, after the search including the legal sanction of search without reasonable suspicion. Search of person is legal measure which affects right of the body. Right of the body consist of right to move and right to be safe from harm or deprive human dignity , right to freedom from discrimination. The methodology of this thesis is to compare Thai law with foreign law in order to finding proper solution for Thai law.

From the study, the researcher found that Thai judges and the officers who conduct the search still misunderstand the core principle of reasonable suspicion. Moreover, the process of search person in public place is still ineffective. In order to guarantee the right of people, the researcher suggests that the law should be revised as follows:

1. The principle of " reasonable suspicion "

There should be a protocol for officers for deciding which facts are sufficient to be reasonable suspicion or the precedent case. Researcher suggests that Thai court should fulfill Thai judicial interpretation with foreign judicial ruling or apply it in the process of search. For preventing officer from abuse the search or use the power without boundary, the officers must have reasonable suspicion before conduct the search. If officers don't have the reasonable suspicion, this will be illegal search and the evidence will be inadmissible.

2. Revised Criminal Procedure Code section 93 by providing principles as follows:

2.1 Requirement of the search. In case an officer has reasonable suspicion that the suspect possesses things that is used in committing an offences and aforesaid evidence which is hidden in the suspect's clothing may prove him guilty.

2.2 In the process of search, researcher suggests that section 93 should be revised. The law should provide a principle which protects the right of the person who is searched in accordance with the foreign principles

(1) The search must be conducted in a gentle manner, without discrimination, and respect for human dignity.

(2) An officer has a duty to identify himself to person searched, explain the reason of the search and the reason of reasonable suspicions. If an officer does not wear a police uniform, an officer shall identify himself by officer identification

(3) In preliminary search, an officer can only pat down the suspect in order to find evidence. If it is necessary, the officer can perform the search thoroughly in undisclosed place.

(4) In case of female suspect, the search of person must be performed by female officer or other female citizens unless it is unable to conduct the search by female officer.

(5) An officer shall conduct search at the place and the time where he stop the suspect. The officer shall conduct the search at the presence of the third- party witness at least one person. Before commencing a search the official must manifest that he has nothing concealed on his person.

(6) The officer must record the search and give a copy to searched person after the search or within 14 days after the day on which he exercise the power and notify the searched person that he has right to have a copy's officer before the search.

3.In case of searching person in private place, an officer can not search the suspect pursuant to section 100 paragraphs 2 because the materials do not cover by search warrant or search without warrant. In this case, researcher suggests that the law shall apply the process of search person in public place of section 93 because search

person in private place affects the right of privacy and right of the body. Therefore, the officer can't search the person arbitrarily but he must use a reasonable suspicion standard as well as search person in public place.

กิตติกรรมประกาศ

ความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความเมตตาและแรงสนับสนุนจากบุคคลและผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายดังต่อไปนี้

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ที่เมตตารับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เขียน อาจารย์ณรงค์ ใจหาญ ที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้ในทุกๆอย่างเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทั้งด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบ แม้อาจารย์จะมีงานล้นมือ อาจารย์ก็สละเวลาให้คำแนะนำ และให้ความรู้ อธิบายอย่างอดทนกับความเข้าใจยากของผู้เขียน อาจารย์ให้ความเมตตาและช่วยเหลือทุกอย่างจนทำให้ผู้เขียนเข้าใจวิธีการทำวิทยานิพนธ์มากขึ้นจนสำเร็จวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ที่รับเป็นที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ปกป้องให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือและให้ความสนับสนุนโดยเฉพาะความรู้ทางกฎหมายฝรั่งเศสกับผู้เขียน

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร. จิรนิติ หะวานนท์ ที่เมตตารับเป็นกรรมการสอบ ท่านทั้งสองให้ความรู้ แง่คิด สอนให้วิเคราะห์และเปิดมุมมองใหม่ๆทางกฎหมายให้กับผู้เขียน

ขอขอบคุณมิตรภาพ ความมีน้ำใจและความห่วงใยของเพื่อนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ , เพื่อนๆสมัยเรียนเนติบัณฑิตยสภา ,เพื่อนๆสมัยเรียนปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญาทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้ผู้เขียนเสมอมา

ขอขอบพระคุณครอบครัวที่แสนอบอุ่น นายภูสิทธิ ถาวรสุขสิริ นางอารีย์ ถาวรสุขสิริ คุณพ่อ คุณแม่ อันเป็นที่รักยิ่งของผู้เขียน ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูผู้เขียนตั้งแต่เล็กจนเติบโต ให้กำลังใจ ห่วงใย สนับสนุนผู้เขียนในทุกๆเรื่อง และคอยมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอมา , ขอขอบพระคุณนาย จิรายุ ถาวรสุขสิริ พี่ชายที่คอยดูแลและคอยรับฟังปัญหาต่างๆ ,ขอขอบพระคุณ นายหลู่ย้วก แซ่โหล่ย คุณตา ที่คอยทำอาหารอร่อยๆให้ทาน , ขอขอบพระคุณนายชาตรี ส่งสัมพันธ์ เป็นผู้แนะนำการวิธีการเรียนตั้งแต่ระดับเนติบัณฑิตเรื่อยมาจนกระทั่งจบปริญญาโท คอยให้ความช่วยเหลือทางการสืบค้น การแปลภาษาอังกฤษความรู้ทางกฎหมาย เป็นกำลังใจอันสำคัญในยามที่ผู้เขียนท้อแท้ คอยอยู่เคียงข้างและ

แก้ปัญหาในทุกๆเรื่องไปพร้อมกับผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนคงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าขาดแรงสนับสนุนและกำลังใจสำคัญจากบุคคลกลุ่มนี้

สุดท้ายนี้หากวิทยาพนธ์ฉบับนี้พอจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการแก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้าง ขออุทิศคุณความดีให้แก่ครูบาอาจารย์ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆที่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลงได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว

นางสาวจิรสุดา ถาวรสุขสิริ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2554

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ..... (1)

กิตติกรรมประกาศ..... (5)

บทที่

1 บทนำ..... 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา..... 1

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา..... 4

1.3 สมมุติฐาน..... 5

1.4ขอบเขตของการศึกษา..... 5

1.5 วิธีการศึกษา..... 6

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... 6

2 แนวคิดและทฤษฎีการค้นตัวในที่สาธารณสถาน..... 7

2.1 สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการค้นตัวบุคคล 7

2.1.1 สิทธิในร่างกาย 7

2.1.2 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 12

2.1.3 สิทธิไม่ถูกเลือกปฏิบัติ..... 17

2.2 ทฤษฎีรูปแบบกระบวนยุติธรรมทางอาญา 23

2.2.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม 23

2.2.2 ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย 24

3 หลักกฎหมายต่างประเทศ 28

3.1ผู้ใช้อำนาจในการค้น..... 28
3.1.1 สหรัฐอเมริกา..... 28
3.1.2 อังกฤษ..... 28
3.1.3 นิวซีแลนด์..... 28
3.1.4 ฝรั่งเศส..... 29
3.2 เงื่อนไขในการค้น 30
3.2.1 สหรัฐอเมริกา..... 31
3.2.2 อังกฤษ..... 37
3.3.3 นิวซีแลนด์..... 38
3.3.4 ฝรั่งเศส..... 45
3.3 กระบวนการค้น..... 50
3.3.1 กระบวนการก่อนตรวจค้น 50
3.3.1.1สหรัฐอเมริกา..... 50
3.3.1.2 อังกฤษ..... 53
3.3.1.3 นิวซีแลนด์..... 53
3.3.1.4 ฝรั่งเศส..... 56
3.3.2 กระบวนการระหว่างการตรวจค้น..... 57
3.3.2.1 สหรัฐอเมริกา..... 57
3.3.2.2 อังกฤษ 65
3.3.2.3 นิวซีแลนด์ 67
3.3.2.4 ฝรั่งเศส..... 73
3.3.2 กระบวนการหลังการตรวจค้น..... 76
3.3.3.1 อังกฤษ..... 76
3.3.3.1 นิวซีแลนด์..... 79
3.4 ผลของการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย..... 80
3.4.1 ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานในชั้นพิจารณา..... 80
3.4.2 เจ้าพนักงานผู้ทำการโดยมิชอบได้รับโทษทางวินัย..... 88
3.4.3 เจ้าพนักงานอาจถูกฟ้องทางแพ่งและทางอาญา..... 88

4 หลักเหตุอันควรสงสัยและแนวทางวินิจฉัยของศาล..... 91

4.1 ความหมายของ “ เหตุอันควรสงสัย ”..... 91
4.2 ความเห็นของนักวิชาการ..... 95
4.3 แนวคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ..... 96

5 หลักเกณฑ์การค้นที่เหมาะสมของไทยและแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง..... 121

5.1 หลักเกณฑ์การค้นตัวที่เหมาะสมในที่สาธารณสาธารณสถานตาม
กฎหมายไทย..... 121
5.1.1 ผู้ใช้อำนาจในการค้น..... 123
5.1.2 เงื่อนไขการใช้อำนาจ..... 124
5.1.3 กระบวนการในการค้น..... 134
5.1.4 ผลของการค้นโดยมิชอบ..... 138
5.2 หลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่รโหฐานตามกฎหมายไทย..... 141
5.3 เปรียบเทียบกับต่างประเทศ..... 148
5.4 แนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย..... 155

6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ..... 165

6.1 บทสรุป..... 165
6.2 ข้อเสนอแนะ..... 168

บรรณานุกรม..... 170

ประวัติการศึกษา..... 177

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายอันเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิดและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการตระหนัก จึงมีการบัญญัติเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ว่า บุคคลทั้งหลายที่ถูกริดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมนุษยธรรมและได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์[1] ดังนั้นรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่สามารถกระทำการอันเป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในสิทธิเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายไว้เช่นเดียวกันในมาตรา 32 จากหลักการดังกล่าวการค้นตัวบุคคลโดยหลักจึงไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจ[2] ซึ่งในปัจจุบัน

---

[1] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10

[2] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 บัญญัติว่า

บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้ แต่การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับ

กฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การค้นตัวบุคคลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน การค้นตัวบุคคลในที่รโหฐาน และการค้นตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ถูกจับ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานตามมาตรา 93 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[3] มีหลักการว่าเมื่อบุคคลนั้นยังไม่ใช่ผู้ถูกจับ ตำรวจจึงไม่มีอำนาจเรียกให้หยุดและตรวจค้นตัวบุคคลผู้นั้นได้ หากว่าตำรวจเชื่อว่าผู้นั้นจะไปกระทำความผิดหรือกระทำความผิดไปแล้ว ตำรวจจะใช้อำนาจใดเพื่อค้นตัวบุคคลนั้นเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรม ดังนั้นตำรวจจึงต้องมีมาตรการในการสอบสวนการกระทำที่ต้องสงสัยในเบื้องต้นก่อน จากหลักเกณฑ์ของมาตรา 93 มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาในลำดับแรกคือ อย่างไรเป็นเหตุอันควรสงสัย (reasonable suspicion) ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้ให้คำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาว่าข้อมูลเพียงใดที่จะสนับสนุนให้เป็นเหตุอันควรสงสัย ความสงสัยระดับใดพอเป็นเหตุอันควรสงสัย แหล่งที่มาของข้อมูลมีส่วนสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของเหตุอันควรสงสัยหรือไม่

มี**คำพิพากษาศาลฎีกาที่** 1082 / 2527 เคยตัดสินเกี่ยวกับประเด็นนี้คือตำรวจติดตามคนร้ายปล้นทรัพย์ที่เข้ามาในท้องที่ ได้พบจำเลยทั้งสองยืนซุบซิบกันอยู่หลังสถานีรถไฟเป็นพิรุธ จึงเดินเข้าไปหาแล้วขอค้นกระเป๋าซิบที่หนีบอยู่ ได้พบอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียน ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในลำดับแรกคือ การค้นนั้นชอบหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการค้นที่ชอบเพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย จึงทำการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น[4]

หรือเพิกถอนการกระทำเช่นว่านั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

[3] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด

[4] คนึง ฦาไชย , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา ,พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548), น. 273.

ความเห็นของนักวิชาการ ให้ข้อสังเกตไว้ในคำพิพากษาฎีกาเรื่องนี้ว่า " เหตุอันควรสงสัย " ต้องมีอยู่"**ก่อน**" การค้น สิ่งของที่ได้มาจากการค้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือยืนยันถึงความถูกต้องของสิ่งนั้นตามหลักที่ว่า "The end does not justify the means" ซึ่งหมายความว่า แม้จะเผอิญได้ของผิดกฎหมาย ก็มิได้หมายความว่าการ"ค้น" ตั้งแต่ต้นเป็นการค้น "โดยมีเหตุอันควรสงสัย" เพราะ " เหตุอันควรสงสัย " ต้องมีอยู่ " ก่อน " การค้น เพียงแต่ตำรวจเห็นคนสองคน **พูดจาซุบซิบกันมีพิรุธ** เพียงเท่านี้ไม่น่าจะถือว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเข้ากรณีตามมาตรา 93 แม้จะติดตามคนร้ายปล้นทรัพย์ที่หลบหนีมาก็ตาม[5]

ปัญหาประการต่อไปคือ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยแล้ว ตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองจะมีอำนาจในการค้นตัวบุคคลนั้นในขอบเขตของการค้นเพียงใดเป็นต้นว่า ก่อนทำการค้นเจ้าพนักงานต้องแสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานและแสดงความบริสุทธิ์ก่อนทำการค้นหรือไม่ ขณะทำการค้นเจ้าพนักงานจะเรียกให้ถอดเสื้อออกมาได้หรือไม่ ถ้าผู้ถูกค้นเป็นผู้หญิงเจ้าพนักงานชายควรทำการค้นหรือไม่ หรือขอตรวจค้นสัมภาระที่ติดตัวมาด้วยได้หรือไม่ แล้วของที่พบระหว่างการตรวจค้นสามารถยึดได้หรือไม่ในขณะที่บุคคลนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ถูกจับ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 ยังไม่มีการกำหนดขั้นตอนรายละเอียดการตรวจค้นตัวบุคคลไว้ มาตรา 93 *ให้อำนาจ*เจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้กำหนดหรือจำกัดขอบเขตการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานของต่างประเทศ เช่น

แนวทางของกฎหมายสหรัฐอเมริกา พบว่ามีการตัดสินเกี่ยวกับหลักการและขอบเขตการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนว่า "เหตุอันควรสงสัย" ต้องไม่เกิดจากลางสังหรณ์(hunch)หรือความสงสัยทั่วไป(general suspicion) แต่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางภาววิสัยคือสถานการณ์แวดล้อมเป็นกรณีๆไป[6] และการเรียกให้หยุดและการตรวจค้นตัวบุคคลมีวัตถุประสงค์ต่างกันไม่ใช่ว่าเมื่อมีอำนาจหยุดแล้ว จะสามารถที่จะตรวจค้นตัวได้เสมอไป การหยุดความเคลื่อนไหวของบุคคลมีไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามพฤติกรรมเพื่อยืนยันหรือทำให้หมดไปซึ่งสิ่งที่ตนสงสัยว่าผู้นั้นจะไปกระทำความผิดหรือได้กระทำความผิดไปแล้ว หากความสงสัยหมดสิ้นไปไม่สามารถค้นตัวได้ การตรวจค้นตัวจะกระทำได้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อพบ

---

[5] เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , <u>คำอธิบายว่าหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา</u> ,พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : หจก. สำนักพิมพ์ พลสยาม พริตติ้ง(ประเทศไทย), 2553), น. 455.

[6] คดี U.S. v.Cortez , 449 U.S. 411 (1981).

อาวุธที่ผู้ต้องสงสัยนำติดตัวมา และการตรวจค้นทำได้เพียงการแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธ(pat down) เท่านั้น ดังนั้นถ้าเจ้าพนักงานไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะมีอาวุธเช่นสงสัยว่าจะมีของที่ถูกลักทรัพย์มาก็ไม่สามารถตรวจค้นตัวได้[7]

แนวทางของกฎหมายอังกฤษ มีการบัญญัติถึงกระบวนการที่เจ้าพนักงานจะต้องกระทำทั้งก่อนและหลังการตรวจค้นคือ ก่อนการตรวจค้นกำหนดให้เจ้าหน้าที่บอกชื่อของเจ้าหน้าที่ (ยกเว้นในกรณีที่สอบสวนการก่อการร้ายหรือกรณีที่ถ้าบอกชื่อไปแล้วบุคคลนั้นจะได้รับอันตราย) ผู้กระทำการค้น ชื่อสถานีตำรวจ เหตุแห่งการใช้อำนาจตรวจค้นอธิบายให้ชัดว่าเป้าหมายในการตรวจค้นคืออะไร มีเหตุอันควรสงสัยเรื่องอะไร และต้องมีมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นโดยกำหนดให้เจ้าพนักงานต้องแจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับสำเนาบันทึกการตรวจก่อนการตรวจค้น[8] นอกจากนี้กฎหมายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีหลักเกณฑ์ให้เจ้าพนักงานหญิงเป็นผู้ทำการตรวจค้นผู้ถูกค้นที่เป็นหญิง[9]

ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลสาธารณสถานของไทยยังขาดความชัดเจนในกระบวนการค้นตัวบุคคล ทำให้การใช้อำนาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานผู้ค้นอันอาจจะทำให้กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วไปจนเกินขอบเขต ยกตัวอย่างเช่น หากผู้หญิงเดินไปบนถนนคนเดียว ตำรวจขอค้นตัวเพราะสงสัยว่ามีของที่ถูกลักทรัพย์ไว้ในครอบครอง ข้อเท็จจริงเท่านี้เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยได้หรือไม่ และถ้ามีเหตุอันควรสงสัยแล้วเจ้าพนักงานมีวิธีการค้นอย่างไร จะเรียกให้ถอดเสื้อได้หรือไม่ จึงเห็นว่าหลักเกณฑ์ในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานตามมาตรา 93 ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากสมควรที่จะได้รับการแก้ไข จึงมีแนวความคิดว่ากระบวนการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจควรมีหลักเกณฑ์ ขอบเขต และ กระบวนการที่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานเพื่อไม่ให้เกิดการใช้อำนาจเป็นไปตามอำเภอใจ กลั่นแกล้งหรือเป็นไปในทางเสื่อมเสียแก่ผู้ถูกตรวจค้น เพราะการตรวจค้นตัวบุคคลไม่เพียงแต่กระทบสิทธิทางเนื้อตัวร่างกายและการเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่ยังกระทบชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือที่จะถูกสังคมตราหน้าอีกด้วย

---

[7] ดคี Terry v Ohio , 392 U.S. 1, (1968)

[8] Police and Criminal Evidence Act 1984 , Code A

[9] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการค้นตัวบุคคลศึกษาเปรียบเทียบกับนานาประเทศ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา ,2553),, น.66-67.

1.2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและที่รโหฐาน

2. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์เรื่องเหตุอันควรสงสัยโดยศึกษาในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส

3. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ว่าด้วยการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน กระบวนการการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจหรือฝ่ายปกครองในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะ โดยศึกษาหลักเกณฑ์ในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส

4. เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมที่จะนำไปปรับใช้กับการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลพร้อมกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

1.3. สมมติฐาน

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานในกฎหมายไทยไม่มีหลักเกณฑ์ที่เพียงพอในการประกันสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของบุคคลดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ เกิดความไม่เป็นธรรม ในการใช้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานจึงควรมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานให้มีความชัดเจน แน่นอน ว่าควรมีกระบวนการ ขอบเขต การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในขอบเขตเพียงใด

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและในที่รโหฐาน โดยศึกษาถึงหลักทั่วไปที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ และหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งพระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและในที่รโหฐาน ได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยพิจารณาแนวคิด หลักเกณฑ์ ขอบเขตการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเปรียบเทียบกฎหมายไทย กับประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้มีความแน่นอน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 วิธีการศึกษา

ศึกษาหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคล และการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน โดยวิธีวิจัยเอกสาร(Documentary Research) จากกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ โดยการค้นคว้ารวบรวมจากขั้นปฐมภูมิ (Primary Document)และทุติยภูมิ (Secondary Document) เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของไทยและของต่างประเทศ เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร หนังสือต่างๆ รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์ เอกสารทางราชการและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต คำพิพากษาศาลฎีกาทั้งของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ โดยการนำเอาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบให้เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ให้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและในที่รโหฐาน

2.ให้ทราบหลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน ว่ามีหลักเกณฑ์ของการควบคุมการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะ กระบวนการ การควบคุมอำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจหรือฝ่ายปกครองในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะ และเมื่อมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายของจะมีมาตรการใดที่เหมาะสมในการเยียวยาผู้เสียหาย โดยศึกษาทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

3.ให้ทราบแนวทางที่เหมาะสมที่จะนำไปปรับใช้กับการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลพร้อมกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีการค้นตัวในที่สาธารณสถาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีของสิทธิเสรีภาพในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและทฤษฎีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2 รูปแบบ คือ Crime Control Model และ Due Process Model

2.1 สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน

2.1.1 สิทธิในร่างกาย

1) ความหมายของสิทธิในร่างกาย

สิทธิในชีวิตร่างกายเป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิด เป็นสิทธิที่ปัจเจกบุคคลที่มีอยู่ในสภาวะธรรมชาติ สิทธิในชีวิตร่างกายดังกล่าวไม่อาจถูกพรากไปจากบุคคลได้ แต่ในทางตรงกันข้ามอาจทำให้ได้รับหลักประกันโดยบัญญัติของกฎหมายของรัฐได้ สิทธิในชีวิตร่างกายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีอิสระที่จะกำหนดเจตจำนงของตนเองได้ตามที่ตนประสงค์ จากการที่มนุษย์มีเจตจำนงโดยอิสระที่จะสร้างสภาพแวดล้อมของตนเองหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนี้ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเคารพในสิทธิชีวิตและร่างกายของบุคคล บุคคลทุกคนจึงต้องเคารพในขอบเขตปริมณฑลส่วนบุคคลของแต่ละคน และด้วยเหตุนี้สิทธิในชีวิตร่างกายจึงเป็นรากฐานสำคัญของ “ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์[1]”

สิทธิในชีวิตร่างกาย สามารถกล่าวได้เป็น 2 นัย[2] คือ

---

[1]ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยการติดตามและการประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ความเป็นมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), น.15.

[2] จิรนิติ หะวานนท์ , สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน,2544), น. 15-16.

1.ชีวิตร่างกาย คือ สรีระทั้งหมดของบุคคล ตลอดทั้งเส้นผม เล็บ เป็นต้น การกระชากผมจึงเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย การเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดเป็นการทำให้ชีวิตร่างกายของเคลื่อนไหวไม่ได้ปราศจากเสรีภาพเป็นการกระทบสิทธิในร่างกาย หรือ

2.ชีวิตร่างกาย รวมถึงสิ่งที่อยู่นอกสรีระของคนด้วย เช่น เสื้อผ้าที่กำลังสวมใส่อยู่ในเวลาที่เจ้านักงานกำลังตรวจค้นร่างกาย ถ้าล้วงเข้าไปตรวจค้นในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกง ดูของที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงก็ถือว่ากระทำต่อสิทธิในชีวิตร่างกาย ความหมายของชีวิตร่างกายจึงรวมถึงสิ่งที่อยู่นอกร่างกายแต่อยู่ติดตัวกับเรา การค้นในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงว่ามีอาวุธ มียาเสพย์ติด มียาบ้าหรือไม่ ถือว่าเป็นการตรวจค้นร่างกาย หรือ

3.ชีวิตร่างกาย รวมถึงสิ่งที่อยู่ในร่างกายด้วย การเอาเลือดไปตรวจ DNA ตรวจแอลกอฮอล์ เอาปัสสาวะไปตรวจเพื่อหาว่า มียาอีอยู่ในปัสสาวะหรือไม่ ถือว่ากระทบต่อสิทธิในชีวิตร่างกาย แม้บังคับให้เราเป่าลมหายใจเพื่อตรวจก็กระทบต่อสิทธิในร่างกาย แอลกอฮอล์ในลมหายเท่าใดก็กระทบต่อสิทธิในร่างกาย

ความหมายของชีวิตร่างกายจึงไม่ใช่เฉพาะสรีระ แต่รวมถึงสิ่งที่อยู่ข้างนอกร่างกายและสิ่งที่อยู่ในร่างกายด้วย การกระทำที่เข้ามากระทบต่อสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทบต่อสิทธิชีวิตร่างกาย แต่การที่เจ้าพนักงานบอกให้หยุดแล้วถามว่าคุณชื่ออะไร บ้านอยู่ที่ไหน เพื่อให้ตอบ คำตอบที่ออกมาเป็นคำพูด กรณีอย่างนี้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกาย การสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบออกมาหรือการสื่อสารด้วยเสียงพูดไม่เกี่ยวกับสิทธิในชีวิตร่างกาย แต่ถ้าพูดกันแล้วเกิดเจ้าพนักงานไปได้ยินเฉยๆ อย่างนี้ไม่ได้กระทบกับสิทธิอะไร แต่ถ้าเขาพูดกันในที่ลับภายในบ้านแล้วเจ้าพนักงานเอาเครื่องอิเลคทรอนิคส์เข้าไปดักฟัง ศาลในอเมริกา ตัดสินว่า คำว่าสิทธิในชีวิตร่างกายคุ้มครองไปถึงการที่จะไม่ถูกดักฟังด้วย (คดี Katz v. U.S, 389 U.S.347,1967)

2) แนวความคิดทั่วไปในการคุ้มครองสิทธิในร่างกาย

John Locke (ค.ศ. 1632-1704) นักคิดคนสำคัญของอังกฤษ กล่าวถึงอำนาจของรัฐที่เกี่ยวกับสิทธิในร่างกายไว้ว่า มนุษย์มีสิทธิต่อชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน ซึ่งรัฐจะเข้ามารบกวนโดยอำเภอใจไม่ได้

สิทธิในร่างกาย ได้นำไปสู่หลักการใหญ่สองประการ ประการแรก ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการล่วงล้ำสิทธิในทางกายภาพที่เกิดแก่ร่างกาย ซึ่งเป็นสิทธิในเชิงรับและสิทธิเรียกร้องในเชิงรุกที่จะเรียกร้องต่อรัฐ ไม่ให้ทำการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ประการที่สอง ประชาชนมีสิทธิความเป็นส่วนตัวที่จะตัดสินใจ ไปจนถึงการควบคุมร่างกายของตนเอง โดย

ปกติแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ประชาชนจะขอให้รัฐไม่ทำการแทรกแซงการกระทำของประชาชน เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสิทธิความเป็นส่วนตัว [3]

สิทธิร่างกายประกอบด้วย 2 สิทธิ คือ สิทธิในการเคลื่อนไหวและและสิทธิที่จะไม่ถูกทำลาย ซึ่งการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานเกี่ยวข้องโดยตรงกับกับสิทธิในการเคลื่อนไหว เพราะการค้นเป็นการจำกัดอิสระของบุคคลไม่ให้เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายที่รัฐธรรมนูญได้รับรอง รวมทั้งละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย แต่เพื่อรักษาความสงบและผลประโยชน์ของส่วนรวมและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนการกระทำที่ต้องสงสัยจึงจำเป็นต้องมีการกระทบกับสิทธิของบุคคลบ้าง กฎหมายจึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐค้นตัวบุคคลได้อันเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไป ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานในขณะนี้ คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 ดังนั้นในการกระทำของเจ้าหน้าที่จึงต้องมีเหตุผลชัดเจน การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นหาและตรวจสอบให้ได้ความจริงในคดีอาญา ต้องเป็นไปโดยถูกต้องและสมควรตามหลัก due process ด้วยการตระหนักก่อนว่ามนุษย์เป็น “ผู้ทรงสิทธิ” ไม่ใช่ “วัตถุแห่งสิทธิ” มิใช่แต่เพียง “ มนุษยธรรม ” แต่เป็น “ ความชอบธรรม ” ที่บุคคลในฐานะมนุษย์พึงได้รับการปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและสมเหตุสมผลจากกระบวนยุติธรรมทางอาญา[4] การค้นตัวบุคคลจึงต้องระวังไม่ให้ล่วงล้ำร่างกายมากจนเกินไป จนกลายเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอาชญากรรมเพราะการกระทำที่ละเมิดสิทธิในร่างกายจนเกินควรเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้รับรอง ซึ่งหมายถึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐใช้ดุลยพินิจของตนได้ตามอำเภอใจ รัฐจึงมีหน้าที่ระมัดระวัง 2 ประการคือ การระมัดระวังมิให้ความยุติธรรมเกิดผิดพลาดขึ้น และระมัดระวังมิให้การค้นตัวบุคคลก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ต้องสงสัยเกินความจำเป็น เพราะกฎหมายที่ให้อำนาจทางอาญาของเจ้าหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และการที่ผู้นั้นยังไม่ได้เป็นผู้ถูกจับหรือจำเลย รัฐจึงยิ่งต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นการประกันสิทธิสิทธิในร่างกายของบุคคลเหล่านี้ให้มากกว่าผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ถูกจับหรือจำเลย

---

[3] Helen Fenwick , Civil Liberties ,2 ed,(London : Cavendish Pub, 1996),p.140.

[4] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์, กฎหมายสิทธิมนุษยชน, (นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), น 89.

การค้นตัวบุคคลที่เป็นหลักประกันสิทธิของบุคคล ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้[5]

1. กฎหมายที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพต้องมีความชัดเจน คือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทำได้เท่าที่มีกฎหมายกำหนดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น มาตรา 93 การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานกระทำได้ถ้ามีเหตุอันควรสงสัย การให้อำนาจประเภทนี้ต้องอาศัยสถานการณ์ที่เป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินอันเป็นหลักในการยกเว้นมากกว่ายกเว้นโดยอาศัยเหตุตัวบุคคลหรือสถาบันเป็นหลัก[6]

2. การละเมิดสิทธิและเสรีภาพจะทำได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายให้อำนาจและภายใต้ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยต้องยึดรัฐธรรมนูญ[7] เป็นหลักอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการประกันสิทธิของบุคคล การค้นตัวจึงต้องมีความชัดเจนในเหตุแห่งการควบคุมและกำหนดเวลาของการควบคุม และแม้กฎหมายจะใช้อำนาจก็ควรใช้อำนาจเท่าที่จำเป็น กฎหมายพิเศษมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการปราบปรามอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้นทุกที จึงต้องบัญญัติให้อำนาจพิเศษเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และหากการใช้อำนาจตามกฎเกณฑ์ในปกติในเงื่อนไขพิเศษแล้วทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ก็มิได้หมายความว่า การใช้อำนาจตามกฎหมายเฉพาะมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษเสมอไปทุกครั้ง[8]

3. ต้องมีระบบการตรวจสอบใช้อำนาจอย่างรัดกุม พอที่จะสร้างสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าพนักงานกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน[9]

---

[5] รุ่งนภา แสนละมะ, “การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายผู้ต้องหา : ศึกษากรณีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น.8.

[6] สัมภาษณ์ ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ **ใน** ไพโรจน์ พลเพชร, และคณะ, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 1* , น.123.

[7] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 26 และมาตรา 29

[8] ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 1* , น.128.

[9] สัมภาษณ์ ชาญเชาวน์ ไชยนุกิจ **ใน** ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่1* , น.128.

การตรวจสอบภายหลังการใช้อำนาจแล้ว จำเป็นต้องให้องค์กรภายนอกตรวจสอบโดยให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าเหตุในการเข้าจับกุม คุมขัง และตรวจค้นตามที่เจ้าพนักงานได้ใช้อำนาจไปนั้น เป็นเหตุจำเป็นตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ และหากศาลเห็นเป็นอื่นก็ให้ปล่อยตัวหรือคืนพยานหลักฐานสิ่งของให้ผู้นั้นไป แต่หากศาลเห็นด้วยก็ชอบแล้วที่เจ้าพนักงานจะได้ดำเนินการต่อไป ไม่จำเป็นว่าการที่รัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพแล้วจะทำให้ต้องลดความเข้มข้นจนกระทบกับความสงบสุขในสังคมเพราะสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นจึงอยู่ที่ว่ารัฐจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ได้หรือไม่จึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบโดยศาล ถ้าศาลเห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าพนักงานทั้งหมด จะไม่มีองค์กรภายนอกอื่นคอยตรวจสอบอีกต่อไป[10]

การค้นตัวบุคคลจึงต้องปฏิบัติทั้งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ ซึ่งขอบเขตดังกล่าวเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คือ การประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความสำคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเป็นเอกสารหลักของสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2491 โดยประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนในการจับ ควบคุม คุมขังของเจ้าพนักงาน ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้นตัวบุคคลมีดังนี้[11]

ข้อ 1 มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระเท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรี และสิทธิทุกคนได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง

ข้อ 2 บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิต ในเสรีธรรมและในความมั่นคงแห่งร่างกาย

ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑ์ซึ่งทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือการหยามเกียรติไม่ได้

ซึ่งต่อมามีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิในร่างกายปรากฏทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและของประเทศไทยบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในร่างกายไว้ ดังนี้

---

[10] *เพิ่งอ้าง*, น.128.

[11] รุ่งนภา แสนละมะ, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 5*,น.8-9.

3) มาตรการในการคุ้มครองสิทธิในร่างกายตามกฎหมายระหว่างประเทศ

การคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966(International Covenant on Civil and Political Rights)

ข้อ 9 " บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพและความปลอดภัย จะต้องไม่มีบุคคลใดถูกตัดรอนเสรีภาพเว้นแต่โดยเหตุผลและตามหลักที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย "

การคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามกติกาสากลฯเน้นไปที่การจำกัดอำนาจรัฐและผู้ใช้อำนาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามิให้มาคุกคาม และล่วงล้ำเสรีภาพของบุคคลโดยอำเภอใจหรือเกินสมควรเพื่อให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปอย่างชอบธรรม[12]

4) มาตรการคุ้มครองตามกฎหมายไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550

มาตรา 32 บัญญัติว่า " บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ"[13]

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 93 ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด

2.1.2 **ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์** (Human Dignity)

เริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ได้ยุติลงเมื่อ พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) โดยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เป็นผู้นำนั้น ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความทารุณโหดร้ายของพรรคนาซีเยอรมันที่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหลายล้านคน และกระทำการย่ำยีสิทธิสตรี เด็ก ถือเป็นการทำลายศักดิ์ศรีมนุษย์อย่างชัดเจน หัวหน้ารัฐบาลประเทศพันธมิตรต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรมป้องกันมิให้มีการ

---

[12] *เพิ่งอ้าง* ,น. 99.

[13]รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32

ทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นอีก จึงได้มีการลงนามยกร่างปฏิญญาและประกาศเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค.ศ. 1948[14](Universal declaration of human rights 1948) ซึ่งมีหลักการที่สำคัญที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิว่า บุคคลทุกคนมีอิสระและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย สิทธิในการเคลื่อนไหว ไม่ถูกสอดแทรกโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือไม่ถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียง[15]

" ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ " หมายถึง คุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะ และเป็นคุณค่าที่มีความผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์ ซึ่งบุคคลที่ได้รับคุณค่าดังกล่าวโดยไม่ต้องคำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอื่นของบุคคล เพื่อให้มนุษย์มีอิสระในการพัฒนาและรับผิดชอบตนเองโดยถือว่า " ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ " เป็นคุณค่าที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้ ซึ่งประกอบด้วยรากฐานสำคัญ 2 ประการ คือ สิทธิในชีวิตร่างกายและสิทธิที่จะได้รับความเสมอภาค[16] นอกจากจะเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองในสถานะเดียวกับสิทธิและเสรีภาพแล้ว ในทางทฤษฎีกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองเสรีประชาธิปไตย เช่น ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส ยังถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานซึ่งเป็นที่มาของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง เป็นแดนแห่งสิทธิที่รัฐไม่อาจล่วงละเมิดได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติคุณค่านี้อยู่ในหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญ[17] รัฐจึงมีหน้าที่ให้ความระมัดระวังและปกป้องมิให้มีการละเมิดล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และต้องปฏิบัติต่อประชาชน โดยถือว่าประชาชนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง รัฐจะปฏิบัติต่อประชาชนเสมือนหนึ่งประชาชนไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้ จะปฏิบัติต่อคนเสมือนหนึ่งคนเป็นสัตว์หรือสิ่งของไม่ได้ เช่น รัฐจะตรากฎหมายเอาคนลงเป็นทาสมิได้ เพราะการปฏิบัติเช่นนี้เสมือนหนึ่งบุคคลเป็นสิ่งของที่ซื้อขายกันได้ ต่างเป็นการกระทำที่ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์[18]

---

[14] สืบค้นจาก http://www.statelessperson.com.

[15] ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ข้อ 1 ข้อ 3ข้อ 7ข้อ12ข้อ 13

[16] บรรเจิด สิงคะเนติ , หลักพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540,(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543) , น. 47.

[17] ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 1*, น.15-16.

[18] มานิตย์ จุมปา,คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 พร้อมข้อเสนอสำหรับ

มีผู้ให้ความเห็นว่า “ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ” เป็นมูลฐานหนึ่งของสิทธิมนุษยชน มีนัย 2 ประการ ดังนี้[19]

ประการแรก “ ธรรมชาติของมนุษย์ ” คือลักษณะที่แท้จริงของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจและความต้องการจำเป็นที่จูงใจให้มนุษย์กระทำการใดๆโดยทฤษฎี มนุษย์น่าจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด แต่ในทางปฏิบัติมนุษย์ย่อมอยู่ภายใต้อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมด้วย

ประการที่สอง “ ศีลธรรม ” ได้แก่ หลักที่ว่าด้วยความรับผิดชอบชั่วดีที่สังคมหนึ่งกำหนดให้สมาชิกปฏิบัติโดยไม่มีศีลธรรมสากลให้ยึดถือ นอกจากอนุมานเอาจากส่วนที่กำหนดไว้เหมือนในความประพฤติบางเรื่อง

1)มาตรการในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

การคุ้มครองตาม European Convention on Human Right

มาตรา 3 บัญญัติว่า “ ไม่มีใครอยู่ภายใต้การทารุณหรือการลดค่า หรือการลงโทษการปฏิบัติที่ลดค่าความเป็นมนุษย์ “

มาตรา 10 บุคคลทั้งหลายที่ถูกริดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมนุษยธรรมและได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

รัฐจึงมีหน้าที่ 4 ประการดังนี้

(1) หน้าที่ในการระงับการทารุณ หรือการลดค่ามนุษย์หรือการลงโทษหรือปฏิบัติที่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(2) หน้าที่คุ้มครองบุคคลจากการปฏิบัติที่ทารุณ หรือการลดค่ามนุษย์หรือการลงโทษหรือปฏิบัติที่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(3) หน้าที่สืบสวนการกระทำที่ถูกกล่าวหา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ,พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2549),น.22.

[19] อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ ,การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2524, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2544), น.9.

(4) หน้าที่จัดทำหลักเกณฑ์ทางกฎหมายแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการถูกทรมาน การกระทำที่โหดร้ายหรือการกระทำที่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์[20]

2)มาตรการการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมายไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพิ่งมีการบัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นครั้งแรกซึ่งแนวคิดนี้ประเทศไทยรับมาจากรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน แม้มีการแก้รัฐธรรมนูญในพ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยังคงหลักการเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ” เป็นการวางหลักทั่วไปอันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐที่ให้ความรับรอง คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ก่อให้เกิดความผูกพันต่ออำนาจรัฐ โดยถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นตัวกำหนดและเป็นตัวจำกัดวัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่ของรัฐ จากพื้นฐานดังกล่าวก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องต่อรัฐเพื่อให้รัฐกระทำการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้สิทธิเสรีภาพ[21]

มาตรา 26 บัญญัติว่า “ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ” เป็นการมุ่งหมายให้การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องผูกพันให้ความคุ้มครองในการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ โดยองค์กรผู้ใช้อำนาจของรัฐจะไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อ สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล [22]

---

[20] David Fledman , Civil Liberties and Human Rights in England and Wales, 2 nd (Oxford : Oxford University Press, 2002), p. 243.

[21] อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ , *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 19*, น. 153-154.

[22] *เพิ่งอ้าง* , น.161.

มาตรา 28 วรรคแรกบัญญัติว่า “ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ” ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเท่ากับว่าบุคคลที่ถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อาจใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีได้ แต่การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องอยู่บนขอบเขตที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน[23]

มาตรา 29 วรรคแรกบัญญัติว่า “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบันได้กำหนดอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าอยู่ในฐานะใด ย่อมมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าของความเป็นคน รัฐย่อมจะคุ้มครองเสมอกัน[24]การบัญญัติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยแยกต่างหากจากสิทธิอื่นเช่นมาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28 ทำให้เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญไทยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะให้การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยแยกออกจาก“สิทธิและเสรีภาพ” ถือได้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าในทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่แยกออกต่างหากจากสิทธิและเสรีภาพ และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550[25]

*ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์*ได้รับรองและความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอื่นโดยชัดแจ้งหรือปริยาย เพื่อให้บุคคลใช้เสรีภาพของตนได้ตามใจปรารถนาและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมดังศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังให้ความคุ้มครองราษฎรโดยให้องค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จะต้องให้ความเคารพและให้ความคุ้มครองเสรีภาพของราษฎร จะต้องถือว่ามนุษย์มิใช่เป็นวัตถุแห่งการกระทำของรัฐ หากการใช้อำนาจของรัฐได้กระทำไปในลักษณะที่ถูกลดค่า การกระทำของรัฐจะขัดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำให้บุคคลสามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลได้เพื่อให้รัฐดำเนินการปกป้องคุ้มครองหรือให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นได้

---

[23] *เพิ่งอ้าง* , น.175.

[24] รุ่งนภา แสนละมะ, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 5*, น.5-6.

[25] อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ , *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 19*.

จะเห็นได้ว่ากฎหมายและกฎหมายต่างประเทศยอมรับโดยทั่วไปว่าการดำเนินการของเจ้าพนักงานของรัฐ โดยเฉพาะการใช้อำนาจของรัฐจะต้องต้องระมัดระวังการใช้อำนาจมิให้กระทบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคุณค่าที่สำคัญสูงสุดอีกคุณค่าหนึ่ง ซึ่งกฎหมายตระหนักว่าคุณค่านี้ไม่สามารถละเมิดได้เพราะเป็นสิทธิที่อยู่ในตัวบุคคลที่มีมาตั้งแต่เกิด ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนไม่สามารถทำลายคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ได้ การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ แม้เจ้าหน้าที่มิได้ล่วงละเมิดร่างกายใดๆ บุคคลนั้นก็สูญเสียเสรีภาพและชื่อเสียงซึ่งเป็นสิทธิที่รวมอยู่ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว การใช้อำนาจของตำรวจ พนักงานอัยการ หรือแม้แต่ศาลสถิตยุติธรรม ล้วนแล้วแต่อยู่ในบังคับของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 26 ทั้งสิ้น กล่าวคือต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลตลอดเวลา[26]

แต่ในการสืบสวนการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดหรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสงสัยว่าบุคคลกำลังกระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย การค้นจึงไม่เป็นการลดค่าความเป็นมนุษย์เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐในการสืบสวนการกระทำความผิด พิจารณาอีกทางหนึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการสืบสวนนั้นเอง จึงกล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกิดจากการกระทำของบุคคลนั้นเอง ดังนั้นหากการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะเกิดขึ้นโดยเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว การค้นตัวจึงไม่ใช่การปฏิบัติที่ลดค่าอันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่เมื่อใดก็ตามที่การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะได้กระทำโดยมีลักษณะเป็นการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะโดยมิชอบหรือใช้วิธีการค้นที่เกินสมควร การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจเป็นละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้[27] อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่ออกตามอำนาจกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้นบทบัญญัติจึงไม่สามารถที่จะขัดกับรัฐธรรมนูญได้ การดำเนินการค้นตัวบุคคล จึงจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการที่ให้การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในระดับที่เพื่อให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย

---

[26] คณิน บุญสุวรรณ, คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2547),น.21.

[27] David Fledman , *supra note20* , p. 260.

2.1.3 <u>สิทธิไม่ถูกเลือกปฏิบัติ</u>[28]

หลักความเสมอภาค คือ ทำให้เกิดความเท่าเทียม หลักความเสมอภาคถือเป็นรากฐานของประชาธิปไตย และยังเป็นหลักที่ควบคุมไม่ให้รัฐใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำให้รัฐต้องอธิบายเหตุผลในการกระทำอันก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหากรัฐไม่สามารถอธิบายการกระทำนั้นได้หรือเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถรับฟังได้ย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ ยกตัวอย่างเช่น กรณีตำรวจขอค้นตัวบุคคลหนึ่งโดยไม่สามารถอธิบายเหตุที่ให้อำนาจในการค้นได้ว่าทำไมถึงไม่ตรวจค้นตัวอีกบุคคลหนึ่ง ย่อมขัดหลักความเสมอภาค

ก่อนที่จะอธิบายความหมายของคำว่า “ เสมอภาค ” ขอทำความเข้าใจกับคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันก่อน

“ ความเท่ากัน ” ไม่ได้หมายถึงความเหมือนกันหรือเท่ากันทุกประการ หรือแทนกันได้ทุกอย่าง แต่หมายถึงความเหมือนกันในบางลักษณะโดยเฉพาะขนาดหรือปริมาณ เช่น เอ สูงเท่าดับ บี

“ ความเท่าเทียมกัน ” อาจเป็นความเหมือนกันหรืออาจไม่เหมือนกันและอาจไม่ต้องเท่ากันก็ได้ เทียบกันได้ใกล้เคียงในเรื่องของคุณค่า เช่น แม่ซื้อตุ๊กตาให้ลูกสาว แต่ซื้อรถให้ลูกชาย ถือได้ว่าแม่ให้ของขวัญลูกสองคนอย่างเท่าเทียมกันเพราะให้ด้วยความรัก ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ลูกทั้งสองเท่าเทียมกันถึงจะเรียกว่าเท่าเทียมกัน

ส่วนคำว่า “ เสมอภาค “ หมายความถึง “ ความเหมือนกัน “ ดังนั้นคำพูดที่ว่า ทุกคนเกิดมาโดยเสมอภาค จึงไม่ได้หมายความว่า ทุกคนเกิดมามีหน้าตาที่เหมือนกัน บุคลิกเหมือนกันซึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่ให้ถือว่าทุกคนเกิดมามีความเป็น “ มนุษย์ ” เหมือนกันทุกคน จึงควรที่จะได้รับการปฏิบัติที่ “ เท่าเทียม “ กัน คือ สิทธิอะไรที่ในฐานะความเป็นมนุษย์ มีสิทธิจะมี ก็ต้องมีเท่ากัน

แต่เนื่องจากมนุษย์แตกต่างในหลายลักษณะทั้งในด้านสรีระ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ เพศ ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์ทางตรรกวิทยาที่เรียกว่า “ กฎแห่งเอกลักษณ์ ” (law of identity) หรือกฎแห่งการเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายถึง การที่กำหนดว่า

---

[28] ฉัตรชัย สลักคำ, “การเลือกปฏิบัติต่อสตรีศึกษาการห้ามสตรีเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของพุทธศาสนสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550),น.38.

สิ่งใดต้องเป็นอย่างนั้น จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นำไปสู่แนวความคิดที่จำแนกสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่ม ซึ่งมีนักกฎหมายได้ให้ความหมายของคำว่าเสมอภาคไว้ดังนี้[29]

1. การที่บุคคลเหมือนกันในสาระสำคัญต้องๆได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันและบุคคลที่ต่างกันในสาระสำคัญ ต้องได้รับการปฏิบัติที่ต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน[30]

2. ในสถานการณ์ที่เหมือนกันต้องปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน หากมีการเลือกปฏิบัติในสถานการณ์ที่เหมือนกันถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและขัดแย้งกับหลักความเสมอภาค[31]

3. การไม่ปฏิบัติต่อสิ่งที่เหมือนกันในสาระสำคัญให้แตกต่างกันตามอำเภอใจ โดยอำเภอใจในที่นี้หมายถึงการปราศจากเหตุผลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ประเภทของหลักความเสมอภาค[32] จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. หลักความเสมอภาคทั่วไป[33] ถือเป็นสิทธิเบื้องต้นของบุคคลเป็นพื้นฐานของหลักความยุติธรรม อันมีลักษณะเป็นสิทธิเรียกร้องของบุคคล หลักความเสมอภาคมีข้อเรียกร้องว่าบุคคลจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากการกระทำของรัฐ ในขณะเดียวกันหลักความเสมอภาคยังมีข้อเรียกร้องในทางปฏิเสธเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อบุคคลตามอำเภอใจ แต่อย่างไรก็ตามหลักความเสมอภาคหรือหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันมิได้เรียกร้องให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือมิได้หมายความว่า บุคคลทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยมิได้คำนึงถึงข้อแตกต่างอย่างใดๆ บุคคลทุกคนต้องเสียภาษีเท่ากันหมดโดยไม่ได้คำนึงถึงรายได้ ดังนั้นเรื่องของหลักความเสมอภาคจึงต้องเป็นกรณีที่มี 2 ข้อเท็จจริง โดยนำ

---

[29] *เพิ่งอ้าง*, น.40.

[30] แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของนักปรัชญาเสรีนิยมทางการเมือง John Locke และคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

[31] แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของนักปรัชญาเสรีนิยมทางการเมือง Herbert Spencer และ Adam Smith และคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส 1789

[32] ภาคภูมิ โกกะอินทร์, “หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น.21-29.

[33] ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 1*, น.62.

ข้อเท็จจริงทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน แต่การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงทั้งสองข้อเท็จจริงจะต้องคำนึงว่าไม่มีข้อเท็จจริงใดเหมือนกันทุกประการ ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงมีความหมายเพียงการเปรียบเทียบในสาระสำคัญเท่านั้นซึ่งหมายความว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอีกข้อเท็จจริงหนึ่งโดยนำลักษณะที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องนั้นเป็นจุดยึดโยงในการเปรียบเทียบ[34]

2. หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง เช่น กรณีชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน มาตรา 30 วรรค 2

3. หลักข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานสัมพันธ์กับหลักข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ

หลักข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ หมายความว่า บุคคลไม่อาจได้รับการเลือกปฏิบัติอันทำให้บุคคลนั้นได้เปรียบหรือเสียเปรียบเนื่องมาจากคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และเหตุที่กำหนดไว้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตา 30 วรรค 3 ที่ว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้ ซึ่งตรงกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 2 วรรคแรกที่ระบุว่า

“ ข้อ 2 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพประดาที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่มีการจำแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่นใด ..... ”

นอกจากนี้การเลือกปฏิบัติอันทำให้เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบอาจเกิดจากการกระทำหรือการละเว้นกระทำก็ได้

กล่าวได้ว่าสาระสำคัญของ “ ความเสมอภาค ” ไม่ใช่ทุกคนต้องได้รับทุกอย่างเท่าเทียมกัน แต่ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าในข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน บุคคลนั้นได้รับการปฏิบัติเหมือนกับบุคคลอื่นหรือไม่ กล่าวคือการปฏิบัติต่อสิ่งที่เหมือนกันในสาระสำคัญให้เหมือนกัน และการปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่เหมือนกันในสาระสำคัญให้แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อสิ่งที่เหมือนกันให้แตกต่าง

---

[34] *เพิ่งอ้าง*, น.27.

กันจะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีเหตุผลสมควรในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานของรัฐจึงต้องใช้โดยยึดหลักความเสมอภาคซึ่งกลไกที่จะทำให้การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปอย่างเสมอภาค คือ การออกกฎหมาย แม้บุคคลจะแตกต่างกันในหลายมูลเหตุหลายปัจจัย ต้องเสมอภาคกันในทางกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งหมายให้บุคคลได้รับการปฏิบัติให้เหมือนกันโดยไม่คำนึงความแตกต่างใดๆ ทำให้บุคคลได้รับความเสมอภาคอย่างสมเหตุสมผลเหมาะไปตามสภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ปัญหาที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน คือ การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตรวจค้นบุคคลในที่สาธารณะโดยใช้หลักเกณฑ์ในการเรียกตรวจบุคคลนั้นๆด้วยเหตุเพราะความแตกต่างทางกายภาพ เช่น สรีระ เพศ เชื้อชาติ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถบอกเหตุผลได้ว่าไม่เรียกตรวจค้นตัวอีกบุคคลหนึ่งเพราะอะไร ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการเลือกปฏิบัติสร้างความเสียหาย เดือดร้อน หรือทำให้บุคคลต้องเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ หรือสร้างความทุกทรมานให้แก่ผู้ใด ซึ่งรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม[35]

1) มาตรการการคุ้มครองทางกฎหมายระหว่างประเทศ[36]

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right)

ข้อ 1 กำหนดว่า “ มนุษย์เกิดมามีอิสระเสรีภาพและเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ .....” และข้อ 2 กำหนดว่า “ บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพบรรดาที่ระบุในปฏิญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่มีการจำแนกความแตกต่างๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นทางอื่น แหล่งกำเนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่น ”

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(International Covenant on Civil and Political Rights)

---

[35] คณิน บุญสุวรรณ, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 26*, น.27-29.

[36] ชาติ ชัยเดชสุริยะ , มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา,2549), น. 121 – 122.

ข้อ 1 กำหนดว่า “ รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้แต่ละรัฐรับที่จะเคารพและดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบรรดาบุคคลทั้งหลายภายในอาณาเขตและภายในขอบอำนาจของตนมีสิทธิทั้งหลายที่ยอมรับแล้วในกติกาฉบับนี้ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆไม่ว่าเพศ เชื้อชาติ ผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นทางอื่น แหล่งกำเนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่นใด..... ”

2)มาตรการการคุ้มครองทางกฎหมายไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550[37]

ปรากฏในมาตรา 5 ซึ่งเป็นหลักทั่วไปว่า “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าแหล่งกำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน ” ให้ความคุ้มครองกับประชาชนชาวไทยเท่านั้น เพื่อมิให้มีการใช้อำนาจอย่างอำเภอใจ โดยไม่พิจารณาเนื้อหาในเรื่องนั้นและไม่อาจค้นหาเหตุผลอันรับฟังได้จากการพิจารณาหรือการตัดสินใจดังกล่าว

และที่กำหนดเฉพาะเรื่องในมาตรา 30 ที่บัญญัติว่า

“ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้ ”

หมายความว่า บุคคลไม่อาจได้รับการเลือกปฏิบัติอันทำให้บุคคลนั้นได้เปรียบหรือเสียเปรียบอันเนื่องมาจากคุณสมบัติที่กำหนดไว้ได้ และเหตุที่กำหนดไว้นั้นได้แก่เหตุตามมาตรา 30 วรรค 3

โดยสรุป หลักข้อห้ามการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากปัจจัยหรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้เหล่านั้นจะถูกนำมาอ้างเพื่อให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลมิได้ เว้นแต่การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างอันเนื่องมาจากปัจจัยหรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้เหล่านั้น ปรากฏ

---

[37] ภาคภูมิ โกกะอินทร์, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 32*, น.105.

เหตุผลอันหนักแน่นสมควร ก็อาจทำให้การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมเป็นกรณีที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความเสมอภาคได้ [38]

2.2 ทฤษฎีรูปแบบกระบวนยุติธรรมทางอาญา

แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบันนั้น อยู่ระหว่างการพยายามคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับความพยายามในการควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

แนวความคิดดังกล่าว ศาสตราจารย์ เฮอร์เบิร์ต แพกเกอร์ (Herbert Packer) ได้แยกแบบทฤษฎีว่าด้วยความยุติธรรมทางอาญา เป็น 2 รูปแบบ คือทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) และทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) [39]โดยรูปแบบทั้งสองนี้ แตกต่างกันทั้งแนวความคิดและขัดแย้งกันในคุณค่า สองประการดังนี้

2.2.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model)

ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) เป็นรูปแบบที่เน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมโดยมุ่งควบคุม ระงับ ปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการที่รัฐไม่สามารถปราบปรามหรือควบคุมอาชญากรรมได้ ย่อมเป็นการกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและเสรีภาพของประชาชนผู้สุจริตถูกคุกคามจากอาชญากรรม[40] ดังนั้นกระบวนยุติธรรมทางอาญาที่ดีต้องมีสถิติการจับผู้กระทำความผิดสูง และผู้ที่ถูกจับกุมนั้นต้องเป็นผู้ที่กระทำความผิดจริง การดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การสืบสวนก่อนการจับกุม การดำเนินการจับกุม การสืบสวนภายหลังการจับกุม การ

---

[38] *เพิ่งอ้าง* , น.112.

[39] Herbert L,Packe,The limits of the criminal sanction, (California: Stanford University Press, 1968), pp.152-153.

[40] ปิยวรรณ ดีนาน, “การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญามิให้ต้องรับสารภาพโดยไม่สมัครใจ,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) , น. 189.

เตรียมคดีเพื่อฟ้องยังศาล การพิจารณาคดี การพิพากษาเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด และการปล่อยจำเลย โดยมีผู้เรียกขั้นตอนนี้ว่า กระบวนการกลั่นกรอง (screening process[41]) ทำให้ผู้ต้องหาที่เป็นผู้บริสุทธิ์ถูกกลั่นกรองออกไป ส่วนผู้ที่กระทำความผิดถูกพิจารณาอย่างรวดเร็ว

ความมุ่งหมายของทฤษฎีนี้คือ เน้นประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม โดยมุ่งหมายที่จะควบคุม ระงับ ปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก โดยเชื่อว่าการทำงานอย่างรวดเร็วจะคืนความยุติธรรมให้สังคมเร็ว ทฤษฎีนี้เชื่อว่าตำรวจและอัยการสามารถจะวินิจฉัยความถูกผิดของขั้นตอนได้[42] ข้อดีของทฤษฎีนี้คือ สามารถปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็ว แต่ข้อบกพร่องคือเจ้าหน้าที่มีอำนาจมากเกินไป เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้อำนาจเกินที่ตนมีอยู่ในสังคม ทำให้ประชาชนอาจได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทฤษฎีนี้อาจใช้กับประเทศที่มีอาชญากรรมสูง[43]

รูปแบบนี้จะเน้นหนักที่การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องรองลงไป หากประเทศใดให้ความสำคัญกับแนวความคิดควบคุมอาชญากรรมนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาหรือกระบวนพิจารณาความอาญาของประเทศนั้นก็เน้นหนักไปที่การสร้างกฎเกณฑ์อันเป็นการให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานในการทำการสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยความเฉียบขาดและรวดเร็ว โดยอาจไม่คำนึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้บริสุทธิ์มากนัก เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจจับบุคคลได้อย่างกว้างขวาง การให้อำนาจในการควบคุมตัวบุคคลได้นาน การให้การประกันตัวเป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานโดยอิสระ เป็นต้น[44]

---

[41]อารีรัตน์ วงศ์ศักดิ์มณี, “รายงานการวิจัยส่วนบุคคลเรื่องปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ,”สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ, น.7.

[42]มโน ซอศรีสาคร, “การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ ค้น ยึด โดยมิชอบศึกษาเฉพาะกรณีพยานวัตถุหรือพยานเอกสาร,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), น.19.

[43]ยุพาภรณ์ วงศ์วิกรานต์, “การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,”(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547) , น.13.

[44]อิศราวุธ อ่อนน้อม, “ หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540) , น.26.

2.2.2. ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model)

ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) หมายถึง รูปแบบที่ยึดกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นสำคัญ หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีกระบวนการทางนิติธรรม

ความมุ่งหมายของทฤษฎีนี้คือ คำนึงกฎหมายบ้านเมืองเป็นหลัก ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายต้องโปร่งใส ชอบธรรมและถูกต้องเจ้าพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อยกว่าทฤษฎีแรก[45]

รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่คำนึงถึงคุณค่าในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก และต่อต้านการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ โดยมีรูปแบบตรงกันข้ามกับรูปแบบแรกเพราะการควบคุมอาชญากรรมนั้นต้องการให้การควบคุมอาชญากรรมได้ผล จึงอาจเกิดการใช้อำนาจเกินสมควรได้เสมอ ทั้งไม่เชื่อว่าแนวคิดในการควบคุมอาชญากรรมจะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการค้นหาความจริงซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานฝ่ายปกครองหรือพนักงานอัยการเป็นการปฏิบัติการในที่รโหฐาน ซึ่งอาจใช้วิธีการล่อวง ขู่เข็ญ และสร้างพยานหลักฐานขึ้นใหม่ได้[46] ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการและต้องการให้มีการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการและเปิดเผย[47]

ดังนั้นประเทศที่ให้ความสำคัญกับแนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกระบวนพิจารณาความอาญาของประเทศนั้นเน้นหนักไปในทางกระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์ มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าพนักงานของรัฐ สิทธิส่วนตัวของบุคคลได้รับการคุ้มครอง กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนจะถูกจำกัดและถ่วงดุล การสืบสวน สอบสวน การป้องกันอาชญากรรม การรับฟังพยานหลักฐาน จะต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนยิ่งกว่าความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

จะเห็นได้ว่าแนวความคิดทั้งสองแนวมีความแตกต่างกัน คือ ถ้าหากกระบวนพิจารณาใดยึดถือแนวความคิดในการควบคุมอาชญากรรม ย่อมส่งผลให้เจ้าพนักงานของรัฐมีสิทธิล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้โดยง่ายเพราะเจ้าพนักงานได้รับอำนาจกว้างขวางใน

---

[45] ยุพาภรณ์ วงศ์วิกรานต์, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 43*,น.13.

[46] อิศราวุธ อ่อนน้อม, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 44*, น.26.

[47] มโน ซอศรีสาคร, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 42*, น.20.

การใช้มาตรการบังคับต่างๆเพื่อประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม แต่ถ้าหากกระบวนการพิจารณาใดยึดถือคุณค่าของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว ย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมลดน้อยลงได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานมีอำนาจอย่างจำกัด

แต่อย่างไรก็ตามแม้แนวความคิดทั้งสองแนวแตกต่างกัน แต่เป้าหมายของทั้งสองรูปแบบตรงกันคือ มุ่งประสงค์ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม เพียงแต่วิถีทางที่จะไปถึงเป้าหมายแตกต่างกัน

แม้มีการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาออกเป็นสองแนว แต่ก็ไม่มีกฎหมายของประเทศใดที่ปฏิบัติตามแนวความคิดแบบใดแบบหนึ่งอย่างเคร่งครัด[48] โดยรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ใช้กันอยู่จริงมักเป็นการผสมผสานของสองรูปแบบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศทางคอมมอนลอว์ (common law)เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (civil law) เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้พยายามที่จะแสวงหาหนทางที่จะประสานแนวความคิดทั้งสองแนวให้มีดุลยภาพเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมควบคู่ไปกับการคุ้มครองและเสรีภาพของประชาชน[49]

สำหรับกฎหมายไทยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสมัยก่อนยึดหลัก crime control กล่าวคือ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง เช่น พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจสามารถออกกหมายจับ หมายค้นได้เองโดยเน้นการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วเด็ดขาดโดยมุ่งปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก แต่นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีความพยายามที่จะให้การความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น (due process) บางประเด็นมีการคุ้มครองไว้อยู่แล้วแต่อาจถูกละเลยหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่ครบถ้วนจึงมีการนำหลักการนั้นมาบัญญัติชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญเพื่อยกระดับความสำคัญ เช่น บุคคลย่อมเสมอกันและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน (มาตรา 30) การตรวจค้นตัวบุคคลจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย (มาตรา 31) และมีทั้งหลักเกณฑ์ที่พึ่งปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ เช่น การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

---

[48] *เพิ่งอ้าง* , น.22.

[49]ปวีณา พันธุ์ธนุสร, “ปัญหาการรับฟังถ้อยคำของผู้ถูกจับในชั้นจับกุม,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551) , น.21.

(มาตรา 4 ,26.28) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องใดๆนั้นจะกระทำมิได้ (มาตรา 30) การทรมาน ทารุณด้วยวิธีการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้ (มาตรา 31) แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองยึดหลักการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำผู้กระทำความผิดมารับโทษ (crime control) เป็นสำคัญ ทำให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันทำให้ไม่สามารถรักษาสิทธิของบุคคลได้สมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

บทที่ 3

หลักกฎหมายต่างประเทศ

ในกฎหมายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์ มีความพยายามในการสร้างกระบวนการในการตรวจค้นตัวบุคคลทั้งก่อนการตรวจค้น ระหว่างการตรวจค้นและหลังทำการตรวจค้น เพื่อเป็นหลักการประกันสิทธิของบุคคลพร้อมไปกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จึงขอนำเสนอโดยแยกออกเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส โดยแยกหัวข้อดังนี้ ผู้ใช้อำนาจ เงื่อนไขการใช้อำนาจ กระบวนการตรวจค้น ผลของการตรวจค้นตัวบุคคลที่มิชอบด้วยกฎหมาย

3.1 ผู้ใช้อำนาจในการค้น

3.1.1 **สหรัฐอเมริกา** ได้แก่ เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจบังคับเป็นไปตามกฎหมาย[1]

3.1.2 **อังกฤษ** ได้แก่ ตำรวจ หรือ ตำรวจชุมชน (police community support officer)[2]

3.1.3 **นิวซีแลนด์**[3] ได้แก่

1) Arm Act 1983 : ตำรวจ[4]

2) Aviation Crimes Act 1972 : ตำรวจ เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยทางการบิน เจ้าพนักงานศุลกากร ลูกจ้างหรือ

---

[1] คดี Terry v Ohio , 392 U.S. 1, (1968)

[2] Police and Criminal Evidence Act 1984 , Code A(แก้ไข ค.ศ. 2008)

[3] New Zealand Law Commission,Search and Survillance Powers,(Wellington 2007,)Chapter 8,pp238-267.

[4] Arm Act 1983 section 60,section 60 A

ตัวแทนของผู้ขนส่งที่ผู้ขนส่งมอบอำนาจ[5]
ผู้บังคับบัญชาการบิน (aircraft commander) หรือลูกเรือที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บังคับการบิน[6]

3) Crimes Act 1961 : ตำรวจ (constable) [7]

4) Customs and Excise Act 1996 : เจ้าพนักงานศุลกากร หรือ ตำรวจ (constable)[8]

5) Misuse of Drugs Act 1975 : ตำรวจ (constable)[9]

6) Misuse of Drugs Act 1978 : เจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจ(police) [10]

3.1.4 ฝรั่งเศส

1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส : ตำรวจ[11]

2) ประมวลกฎหมายศุลกากรฝรั่งเศส : เจ้าพนักงานศุลกากร[12]

3) ประมวลกฎหมายการเดินอากาศฝรั่งเศส : เจ้าพนักงานศุลกากร หรือ ตำรวจระดับปฏิบัติงานหรือชั้นสัญญาบัตร[13]

4) คำพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส : ตำรวจ[14]

---

[5] Aviation Crimes Act 1972 section 12

[6] Aviation Crimes Act 1972 section 17

[7] Crimes Act 1961 section 202A

[8] Customs and Excise Act 1996 section 149A ,149B,149BA

[9] Misuse of Drugs Act 1975 section 18(3)

[10] Misuse of Drugs Act 1978 section 12A

[11] Serge Guinchard,JacquesBuisson,Procedure Penale,4ed(Paris : Litec,2008),p.511.

[12] ประมวลศุลกากรฝรั่งเศส มาตรา 60

[13] ประมวลกฎหมายการเดินอากาศฝรั่งเศส มาตรา 282-8

จากการศึกษาพบว่าการตรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานนั้น กฎหมายเกือบทุกประเทศให้อำนาจแก่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานเฉพาะเรื่องเป็นผู้มีอำนาจในการตรวจค้นตัวบุคคล ไม่ให้อำนาจแก่บุคคลธรรมดาเพราะการตรวจค้นตัวบุคคลโดยหลักการเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน แต่กฎหมายทั้งระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ยอมรับว่าการตรวจค้นตัวบุคคลเป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในร่างกายโดยมีเหตุผลเพื่อรักษาผลความสงบของสังคมส่วนรวม จึงต้องเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เพราะรัฐมีหน้าที่ในการรักษาความสงบของประชาชน

นอกจากนี้มีบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ที่มีอำนาจในการตรวจค้นตัวบุคคลให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐที่ไม่ใช่ตำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาชญากรรมเฉพาะเรื่องตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นๆ การให้อำนาจเจ้าพนักงานของรัฐประเภทนี้จึงให้ได้ในสถานการณ์ที่จำกัด[15]

ส่วนกรณีที่กฎหมายให้อำนาจผู้ช่วยเหลือ(ผู้ที่ไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับใด)ให้สามารถช่วยเจ้าพนักงานทำการตรวจค้นตัวบุคคลได้นั้น ประเทศนิวซีแลนด์วางหลักการว่า ควรมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ว่าหน่วยงานนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยเหลือและผู้ที่ถูกตรวจค้นตัวต้องยินยอมให้ผู้ช่วยเหลือซึ่งไม่ใช่เจ้าพนักงานทำการตรวจค้นตัวผู้นั้น[16] ดังนั้นกรณีที่ให้ผู้ช่วยเหลือสามารถตรวจค้นตัวบุคคลได้ต้องใช้ในสถานการณ์ที่จำกัดและในกรณีที่จำกัดเท่านั้น เช่น ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะบังคับการตามกฎหมายได้ หรือไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจได้ทันในเวลาอันสมควรและเป็นกรณีเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตหรือการเกิดอันตรายสาหัสแก่ผู้อื่น[17]

3.2 เงื่อนไขในการตรวจค้น

---

[14] คำพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1988 **ใน** สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการค้นตัวบุคคลศึกษาเปรียบเทียบกับนานาประเทศ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา,2553),น.29.

[15] New Zealand Law Commission,*supra note* 3,p.258.

[16] *Ibid*, p. 266.

[17] Aviation Crimes Act 1972 section 12

3.2.1 สหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้อำนาจตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดแต่ต้องอยู่ภายใต้ **รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแก้ไขฉบับที่** 4 (Fourth Amendment) โดยบัญญัติไว้ตอนหนึ่งว่า “สิทธิของประชาชนที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และสิ่งของจากการจับ ตรวจค้น หรือ ยึดโดยไม่มีเหตุอันควรนั้นจะถูกล่วงละเมิดมิได้และจะออกหมายเพื่อกระทำการดังกล่าวใดๆมิได้ เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อแน่ว่ามีการกระทำความผิด ซึ่งได้มาจากการสาบานหรือปฏิญาณและหมายจะต้องระบุให้แน่ชัดถึงสถานที่ที่จะถูกตรวจค้น บุคคลที่จะถูกจับ หรือสิ่งของที่จะถูกยึด”[18]

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ได้ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐในการตรวจค้นและยึดในทุกกรณี แต่ห้ามเฉพาะการตรวจค้นและยึดที่ไม่มี “ มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าจะกระทำความผิด ” (probable cause) บทบัญญัตินี้จึงคุ้มครองเคหสถาน เอกสาร และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ปัจเจกบุคคลสามารถแสดงได้ถึง “ความคาดหวังความเป็นส่วนตัวตามสมควร”[19] แม้การเรียกให้หยุดและการตรวจค้นตัวบุคคลจะไม่ใช่การจับ (arrest) ที่ต้องใช้มาตรฐาน “ มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าจะกระทำความผิด ” (probable cause) แต่การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานของรัฐในการเรียกให้หยุดและตรวจค้นตัวบุคคลก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นกัน[20]

ประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งการใช้อำนาจการตรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานออกเป็น 2 ช่วง คือการเรียกให้หยุด(stop) และการตรวจค้นตัวบุคคล (frisk) และเงื่อนไขในการ

---

[18]“The right of the people to be secure in their persons,houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated; and no warrants shall issue but upon probable cause, supported by Oath or Affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized”.

[19]ยุพาภรณ์ วงศ์วิกรานต์, “การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,”(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), น.45-46.

[20]John N. Ferdico,J.D.,Criminal Procedure for the Criminal Justice Professional,8th ed(Belmont, California, U.S.A. : Wadsworth/Thomson Learning, 2002),p.309.

ใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน คือ เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรสงสัย(reasonable suspicion)ทั้งการเรียกให้หยุดและการตรวจค้นตัวบุคคล

1) การเรียกให้หยุด (stop)

1.1)ความหมายตาม Black's Law Dictionary[21]

" การเรียกให้หยุดและการตรวจค้นตัวบุคคล "[22] หมายถึง การควบคุมตัว การถามคำถาม และการตรวจค้นตัวบุคคลในเวลาสั้นโดยตำรวจเพื่อหาอาวุธที่ซ่อนอยู่เมื่อเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลได้กระทำความผิดหรือกำลังจะไปกระทำความผิด การเรียกให้หยุดและการตรวจค้นตัวบุคคลสามารถทำได้โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะกระทำโดยไม่มีหมายหรือไม่มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าจะกระทำความผิด(probable cause) ตามคำพิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาที่วินิจฉัยในคดี Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 88 S.Ct. 1868 (1968)

1.2)ความหมายตามคำพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา

ศาลได้ให้ความหมายของคำว่า "เรียกให้หยุด" ว่า "เมื่อใดก็ตามที่เจ้าพนักงานตำรวจทำให้วิญญูชน (reasonable person) เชื่อว่าเขาปราศจากอิสรภาพที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเขาได้ทำการหยุดหรือควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้แล้ว[23]

---

[21]Retrieved fromกhttp://international.westlaw.com/result/default.wl?vr= 2.0&tf=507&sv=Split&cxt=RL&utid=17&fmqv=s&rlti=1&ss=CNT&tc=1&rs=WLIN10.10&eq=search&db=BLACKS&cnt=DOC&fn=_top&rlt=CLID_QRYRLT9783193521810&n=1&scxt=WL&spa=THAMM2002&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rltdb=CLID_DB6388301621810&origin=Search&mt=WLIGeneralSubscription&service=Search&query=%22REASONABLE+SUSPICION%22&method=TNC.

[22] stop and frisk, n. (1963) A police officer's brief detention, questioning, and search of a person for a concealed weapon when the officer reasonably suspects that the person has committed or is about to commit a crime. • The stop and frisk, which can be conducted without a warrant or probable cause, was held constitutional by the Supreme Court in Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 88 S.Ct. 1868 (1968). — Also termed investigatory stop; investigatory detention; Terry stop; field stop. See under reasonable suspicion. [Cases: Arrest %4E63.5.]

[23] คดี Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 88 S.Ct. 1868 (1968)

จึงเห็นได้ว่าการเรียกให้หยุดไม่ใช่การจับเพราะการจับ(arrest) หมายถึง การนำตัวบุคคลเข้าอยู่ในความควบคุมเพื่อฟ้องต่อไปและเจ้าหน้าที่จะทำการจับได้ต้องอาศัยมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าจะกระทำความผิด(probable cause) ทำให้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่มีหมายจับหรือไม่สามารถระบุได้ชัดแจ้งว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดในการกระทำความผิดครั้งก่อน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการสอบสวนได้จนกว่าจะมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าจะกระทำความผิด(probable cause) ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคขัดขวางการกระทำความผิด ยังทำให้ผู้ต้องสงสัยหลบหนีโดยเฉพาะในความผิดร้ายแรงหรือความผิดที่กระทบกับความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้นศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาจึงได้พัฒนาหลักการเรียกให้หยุด (stop) และตรวจค้นตัวบุคคล (frisk) ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาระหว่างความสมดุลของเจ้าหน้าที่การในการยับยั้งและสืบสวนอาชญากรรมและปกป้องตนเองและผู้อื่นจากอันตรายกับสิทธิของปัจเจกชนที่รัฐธรรมนูญได้รับรองในความเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล ความมั่นคงในชีวิต และอิสระในการเคลื่อนไหว[24] เจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจเรียกให้หยุดและกักตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้ แต่ว่าการกักตัวก็ไม่เกินขอบเขตในกรณีที่กำลังจะมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น[25]

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการที่เจ้าพนักงานตำรวจได้มีการพูดคุย หรือปฏิสัมพันธ์กับประชาชนจะทำให้เป็นการ “เรียกให้หยุด” หรือ “ควบคุมตัว”(seizure) เสมอไป การเรียกให้หยุดหรือควบคุมตัวนั้นจะต้องเป็นการใช้กำลังทางกายภาพ หรือการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ในการเหนี่ยวรั้งเสรีภาพของประชาชน[26] ดังนั้นถ้าเป็นการถามคำถามที่บุคคลนั้นอาจจะเดินหนีไปได้ก็จะไม่ใช่การเรียกให้หยุด และการถามคำถามก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนการกระทำ

และนอกจากนี้ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา เคยให้ข้อสังเกตว่าเมื่อเจ้าพนักงานตรวจดูสิ่งของ เช่น หนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ใบขับขี่ ในความเป็นจริงบุคคลนั้นก็ไม่มีอิสระที่จะออกไปได้ แม้ว่าในทางเทคนิคจะบอกว่าเป็นการยึดถือสิ่งของ ไม่ใช่ควบคุมตัวบุคคลก็ตาม ศาลได้พิเคราะห์จุดนี้อย่างละเอียดว่าการยึดถือสิ่งของแท้จริงคือการควบคุมตัวบุคคลนั่นเอง[27]

---

[24] *Supra note20,* p.309.

[25] *Ibid*, p.273.

[26] *Ibid*, p.268.

[27] *Ibid*, p.307.

การใช้สุนัขดมกลิ่น(sniff dog) ปกติไม่ใช่ค้นตัวบุคคล(search) เพราะไม่มีการล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคล แต่การเรียกให้หยุดเพื่อรอนำตัวสุนัขดมกลิ่นมาเป็นการเรียกให้หยุด(stop)แล้ว เพราะมีการควบคุมตัวบุคคลแล้ว[28]

สถานการณ์อื่นๆที่เป็นการเรียกให้หยุด เช่น เจ้าพนักงานตำรวจเรียกแก็งค์ซิ่งมอเตอร์ไซค์ให้หยุดรถ หรือการที่เจ้าพนักงานตำรวจใส่กุญแจมือก็เป็นการหยุดเพื่อการจับกุมแล้ว[29]

โดยสรุปจะเป็น การเรียกให้หยุด และการควบคุมตัวตาม Fourth Amendment เมื่อ[30]

(1) พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เป็นการแสดงอำนาจ(show of authority)ตามคดี Mendenhall หรือไม่

(2) ภายใต้สถานการณ์ทั้งหมดวิญญูชนเชื่อหรือไม่ว่าเขาไม่มีอิสระที่จะจากไป บุคคลนั้นยอมจำนนต่อเจ้าพนักงานเพราะเจ้าหน้าที่ได้เจตนาที่จะแสดงอำนาจ

1.3)คำพิพากษาศาลที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นการเรียกให้หยุดและควบคุมตัวบุคคล

บุคคลถูกควบคุมตัวต่อเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดรอบตัวทำให้วิญญูชนเชื่อว่าเขาไม่มีอิสระที่จะจากไป หรือ อาจถูกข่มขู่เพราะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่หลายคน หรือการที่เจ้าหน้าที่ได้แสดงตนว่ามีอาวุธหรือการสัมผัสร่างกายของบุคคล หรือการใช้น้ำเสียงที่ทำให้บุคคลต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับบุคคลที่ไม่มีความสงสัยว่าบุคคลนั้นได้มีการกระทำความผิด ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นการควบคุมตัวได้[31]

การที่เจ้าหน้าที่ไม่สวมเครื่องแบบ ไม่มีอาวุธ ไม่ได้เรียกให้ผู้ถูกกล่าวโทษแสดงตั๋วโดยสารหรือบัตรประชาชน จึงไม่มีการละเมิดสิทธิที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ การที่เจ้าหน้าที่เดินเข้าหาและแค่ถามคำถาม จึงไม่ใช่การควบคุมตัว(seizure)[32]

---

[28] คดี United Stated v. Hardy, 375 U.S. 277 (1964)

[29] John L.Worrall ,Criminal procedure from the first contact to appeal, 2 ed,(Boston : Pearson/Allyn and Bacon, 2007), pp.170-171.

[30] *Supra note 20* p.272.

[31] คดี United States v.Mendenhall, 446. U.S. 544 (1980).

[32] *Supra note* 20, p.269.

จำเลยหลบหนีแต่ถูกตำรวจวิ่งไล่ตาม จำเลยโยนหินใส่ในทันทีและโดนตำรวจภายหลังพบว่าก้อนหินเป็นโคเคน ศาลวินิจฉัยว่าไม่มีการสัมผัสทางร่างกาย ไม่มีการยอมจำนนต่ออำนาจของเจ้าหน้าที่ จึงไม่เป็นการควบคุมจนกว่าจะมีการจะมีการเข้าจำกัดสิทธิในการเคลื่อนไหวของจำเลย ดังนั้นการทิ้งโคเคนขณะวิ่งของจำเลย จึงไม่ใช่ผลของการควบคุมตัว และไม่อยู่ภายใต้หลัก Exclusionary Rule[33]

โดยสรุป การเรียกให้หยุดตาม Fourth Amendment หมายถึง ควบคุมตัวในเวลาสั้น(นาที)หรือเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดรอบตัวทำให้บุคคลผู้นั้นเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าเขาไม่มีอิสระที่จะออกไปในบริเวณที่ที่ถูกเรียกให้หยุด นอกจากนี้การเรียกให้หยุดต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดหรือเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำความผิดได้เกิดไปแล้ว การเรียกให้หยุดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น หาพยานหลักฐาน จะเป็นการเรียกให้หยุดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[34]

ถ้าไม่ใช่การเรียกให้หยุดตามความหมายของ Fourth Amendment ผลคือ ศาลไม่อาจทบทวนการกระทำนั้นของเจ้าพนักงานได้ กล่าวคือ ศาลไม่สามารถเข้าไปวินิจฉัยการกระทำของเจ้าหน้าที่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

ถ้าการกระทำเป็นการเรียกให้หยุดตามความหมายของ Fourth Amendment จะต้องมีการวิเคราะห์ต่อไปว่าการเรียกให้หยุดชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งความชอบด้วยกฎหมายต้องพิเคราะห์ถึงความสมเหตุสมผล(reasonableness) ว่ามีเพียงพอหรือไม่

ข้อเท็จจริงที่จะก่อให้เกิดเหตุอันควรสงสัย ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท[35]คือ

1.ข้อมูลโดยตรง คือ ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆที่เจ้าพนักงานเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น สัมผัสด้วยตนเอง

2.ข้อมูลที่ได้รับการบอกกล่าวต่อๆกันมา คือ ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆที่เจ้าพนักงานได้รับจากผู้เสียหาย พยาน เจ้าพนักงานอื่นๆ

ข้อมูลทางตรงหรือการบอกเล่าที่ศาลฟังว่ามีความสมเหตุสมผล(Reasonableness)

---

[33] คดี California v, Hodari , 499 U.S. 621 (1991)

[34]Joel Samaha ,Criminal Procedure ,7 ed,(Belmont, California : Thomson/Wadsworth,2008),p.93.

[35] *Ibid* , p.101.

ข้อมูลทางตรง	ข้อมูลที่รับการบอกเล่า
ผู้ต้องสงสัยเคลื่อนไหวที่ลับๆล่อๆ	คำกล่าวของผู้เสียหาย
มีการซ่อนตัว	คำกล่าวของประจักษ์พยาน
มีความพยายามที่จะทำลายพยานหลักฐาน	คำกล่าวของเพื่อนของเจ้าพนักงาน
การหลีกเลี่ยงการตอบคำถาม	คำกล่าวของผู้ที่ให้ข้อมูล
การตอบคำถามที่ขัดแย้งกัน	คำบอกล่าวของผู้นิรนาม
มีอาวุธหรือของที่ผิดกฎหมายที่ได้ชัด	

ข้อมูลที่เจ้าพนักงานมีไม่จำต้องเป็นข้อมูลที่ยืนยันถึงการกระทำความผิด เพียงแค่ข้อมูลที่ " อาจเป็นไปได้ "เท่านั้น แต่การสรุปจากสัญชาตญาณเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือความเห็นของลูกขุนในฐานะผู้ตรวจค้นหาข้อเท็จจริง ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้หยุดได้[36] ในการประเมินความชอบด้วยกฎหมายของการเรียกให้หยุด ศาลพิจารณาภาพรวมของเหตุการณ์โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำการควบคุมตัวต้องมีสมมติฐานที่เฉพาะเจาะจง (particular basis) และเป็นภาวะวิสัย (objective) ในการสงสัยบุคคลที่จะถูกเรียกให้หยุด การวิเคราะห์ต้องมาจากการสังเกตสภาพแวดล้อม ข้อมูลจากการรายงานของตำรวจ และคำนึงถึงลักษณะของผู้กระทำในความผิดบางประเภท จากข้อมูลเหล่านี้หากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการฝึกมาอย่างดีอาจเข้าใจข้อมูลที่ได้รับมาแตกต่างกันออกไป[37] ความสมเหตุสมผลของการเรียกให้หยุดศาลจึงวางมาตรฐานของข้อเท็จจริงไว้ว่าต้องเป็นระดับเหตุอันควรสงสัย(reasonable suspicion)

" **เหตุอันควรสงสัย** "(reasonable suspicion) หมายความว่าอะไร ศาลไม่ได้ให้คำนิยามไว้ชัดเจน เพียงแต่บอกว่าความรู้สึก ปริมาณ เนื้อหา ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะมีระดับต่ำกว่า probable cause (มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าจะกระทำความผิด) และไม่สามารถอยู่บนพื้นฐานของลางสังหรณ์(hunch) หรือพื้นฐานของความสงสัยทั่วไป(general suspicion) เพราะการตรวจค้นตัวเป็นการกระทบสิทธิทางชีวิตร่างกายของบุคคล ดังนั้นเหตุอันควรสงสัยต้องมาจากข้อเท็จจริงทางภาวะวิสัยที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายคดีไป[38]

มีแนวคำพิพากษาของศาลได้ตัดสินไว้หลายเรื่องว่าสถานการณ์ใดเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้หยุดซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4

---

[36] คดี United v. Cortez , 449 U.S. 411 (1981)

[37] *Supra note* 20, p.272

[38] คดี Terry v. Ohio , 392 U.S. 1 (1968).

ตามที่กล่าวไปข้างต้น ก่อนที่จะทำการตรวจค้นตัวบุคคลศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาพิพากษาว่าเจ้าพนักงานต้อง

1) เรียกให้หยุดก่อน เมื่อเป็นการเรียกให้หยุดแล้ว

2) ต้องพิจารณาต่อว่าการเรียกให้หยุดนั้นสมเหตุสมผล(reasonableness)หรือไม่ โดยความสมเหตุสมผลของการเรียกให้หยุดต้องมีระดับเหตุอันควรสงสัย

3) นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาขอบเขตของการเรียกให้หยุดมีอย่างไร ขอบเขตของการเรียกให้หยุดประกอบด้วย เวลา และสถานที่

3.2.2 **อังกฤษ**

กฎหมายอังกฤษแบ่งอำนาจในการตรวจค้นตัวบุคคลออกเป็น 2 กระบวนการเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การใช้อำนาจในการเรียกให้หยุด (stop) และการตรวจค้นตัวบุคคล (search) ทั้งสองกระบวนการเป็นการดำเนินการเพื่อให้ตำรวจมั่นใจว่ามีสิ่งของที่ต้องสงสัยอยู่ในตัวของผู้ถูกตรวจค้นจริง และเป็นกระบวนการที่กระทำก่อนที่จะมีการจับ ดังนั้นการกระทำที่นอกเหนืออำนาจตามหลักการดังกล่าว นอกจากจะทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้ว ตำรวจผู้นั้นจะต้องมีความรับผิดทางวินัยด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจึงต้องอยู่ในกรอบอำนาจของกฎหมาย ดังนั้นการเรียกให้หยุดและการตรวจค้นตัวบุคคลจึงมีการวางกรอบไว้ว่าต้องมี “ เหตุอันควรสงสัย ”

” **เหตุอันควรสงสัย** ” (reasonable ground for suspicion) กำหนดเงื่อนไขในการค้นตัวบุคคลไว้ใน PACE มาตรา 1(2)-(5)[39] ดังนี้

1. พนักงานตำรวจผู้ค้น จะต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นจะมีสิ่งของที่ได้ลักมาหรือมีสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่ระบุไว้ในมาตรา8(A)ซึ่งเป็นสิ่งของที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิดหรือกำลังกระทำความผิด หรือจะกระทำความผิดตามมาตรา 139 แห่ง Criminal Justice Act 1988 หรือมีสิ่งของที่มีไว้เพื่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

สิ่งของต้องห้าม หมายถึง สิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

---

[39] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่14*, น.41-42.

(1) สิ่งของซึ่งเป็นอาวุธ(มาตรา1(7)(a))ที่ได้ทำเพื่อใช้เป็นอาวุธหรือสิ่งของซึ่งได้นำมาเพื่อประทุษร้ายอย่างอาวุธ หรือเป็นสิ่งของซึ่งบุคคลนั้นได้มีเพื่อตนได้ใช้หรือให้ผู้อื่นได้ใช้เพื่อประทุษร้าย (มาตรา 1(9))

(2) สิ่งของซึ่งทำหรือปรับปรุงเพื่อใช้ในการกระทำหรือเกี่ยวพันกับความผิดซึ่งกำหนดไว้ในวรรคนี้ ซึ่งเป็นความผิดฐาน burglary theft ความผิดฐานใช้รถยนต์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดฐานยักยอก (มาตรา 1(7)(8)) หรือ

(3) สิ่งของที่ผู้กระทำเจตนาที่จะมีเพื่อตนเองใช้หรือให้ผู้อื่นใช้ในการกระทำความผิด (มาตรา 1(7)(b))

2. ในกรณีที่บุคคลผู้จะถูกค้นตัวอยู่ในสวนหรือสนามซึ่งใช้ในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือในที่ดินซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตำรวจจะทำการค้นไม่ได้ เว้นแต่

(1) บุคคลนั้นมิได้อยู่ในที่พัก

(2) บุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ซึ่งผู้เป็นเจ้าของที่พักสงวนในการใช้ที่ต้องขออนุญาตในการเข้าพัก (มาตรา 1(4))

3. ในกรณีที่ตำรวจจะทำการค้นตัวบุคคลในยานพาหนะซึ่งจอดในสวนหรือสนามซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือในที่ดินซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตำรวจจะทำการค้นไม่ได้ เว้นแต่

(1) บุคคลนั้นมิได้อยู่ในที่พัก

(2) ยานพาหนะนั้นมิได้อยู่ในสถานที่ซึ่งจะต้องขออนุญาตเพื่อเข้าพัก (มาตรา 1(5))

4. ในการค้นตัวบุคคลเพื่อหาสิ่งของตามที่กฎหมายกำหนดตำรวจมีอำนาจในการดำเนินการดังนี้

(1)มีอำนาจค้นตัวบุคคล หรือยานพาหนะ

(2) สิ่งของที่ยู่ในตัวบุคคลหรือยานพาหนะ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ระบุไว้ในข้อ(1)

ส่วนแนวทางการพิจารณาตามกฎหมายว่ากรณีใดถือว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพื่อพบสิ่งของตามกฎหมายนั้น ประเทศอังกฤษได้กำหนดไว้ใน Code A แนบท้าย PACE มาตรา 1 ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4

3.2.3 **นิวซีแลนด์**

กฎหมายของนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญต่อการค้นตัวบุคคลมากและมีข้อจำกัดในการที่ตำรวจเข้าค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานไว้เข้มงวด เพราะถือว่าการค้นตัวบุคคลเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางร่างกายของบุคคลและมีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยจึงต้องมีหลักประกันที่คุ้มครองมากกว่าการค้นที่รโหฐานหรือยานพาหนะ ดังนั้นในกฎหมายนิวซีแลนด์จึง

ไม่มีหลักการที่ว่าเจ้าพนักงานจะมีอำนาจค้นตัวบุคคลเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับความผิดหรือมีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด แต่ในกฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายพิเศษของนิวซีแลนด์จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้อำนาจเจ้าพนักงานในการค้นตัวบุคคลอย่างจำกัดและเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยสาธารณะหรือการติดตามทรัพย์ที่ถูกลักไปเพื่อคืนให้แก่เจ้าของที่แท้จริง[40]

ผู้เขียนมุ่งศึกษากฎหมายเฉพาะของนิวซีแลนด์ดังต่อไปนี้

1) Arm Act 1983 เงื่อนไขในการค้นตัวแบ่งออกเป็น 2 กรณี

1.1)เหตุอันควรสงสัย(reasonable grounds to suspect)ในการตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยและยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด สิ่งเทียมอาวุธปืน แบ่งออกเป็น

บุคคลที่อยู่ใน**ที่สาธารณะ** *(public place)*ถือหรือครอบครองอาวุธปืนขนาดเล็ก ปืนอัดลม ปืนพก เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด สิ่งเทียมอาวุธปืน หรือ

บุคคลที่อยู่**ในสถานที่ใดๆ** *(in any place)* มีอาวุธหรือปืนขนาดเล็ก ปืนอัดลม ปืนพก เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืนในความครอบครองหรือภายใต้การควบคุมและบุคคลนั้นเป็นคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางกายหรือสภาวะทางจิตใจที่ไม่อาจควบคุมอาวุธได้อย่างเหมาะสม[41]

1.2)เหตุอันควรสงสัยในการตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยและยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด สิ่งเทียมอาวุธปืน*กรณีความรุนแรงในครอบครัว*

(1)บุคคลนั้นครอบครองหรือมีอาวุธปืนขนาดเล็ก ปืนอัดลม ปืนพก เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด สิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง และ

(2)มีมูลเหตุตามกฎหมาย Domestic Violence Act 1995 และกรณีที่บุคคลนั้นร้องขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองแล้ว หรือ คำสั่งนั้นได้มีผลบังคับใช้แล้วตามกฎหมาย Domestic Violence Act 1995[42]

---

[40]สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่14* , น.55-56.

[41] Arm Act 1983 มาตรา 60(1)(2)

[42] Arm Act 1983 section 60A

2) Aviation Crimes Act 1972[43] : เงื่อนไขในการตรวจค้นตัวแบ่งตามผู้อำนาจตรวจค้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

2.1)กรณีที่ ตำรวจ เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยทางการบิน เจ้าพนักงานศุลกากร ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งหรือที่ผู้ขนส่งมอบอำนาจ เป็นผู้ทำการตรวจค้นตัวผู้โดยสาร กระเป๋าเดินทาง พัสดุ แบ่งออกเป็น 2 กรณี

(2.1.1) ไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย แต่ต้องเป็นไปเพื่อป้องกันวัตถุอันตรายที่บุคคลมีไว้บนยานบินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่ได้รับอำนาจจากผู้ที่ปฏิบัติการบนยานบินให้มีหรือพยายามจะมีวัตถุดังต่อไปนี้[44]

(1) อาวุธปืน

(2) อาวุธอันตรายหรือร้ายแรงหรือสิ่งเทียมอาวุธซึ่งมีรูปและลักษณะเป็นอาวุธโดยสภาพ

(3) เครื่องกระสุนปืน

(4) วัตถุระเบิด หรือวัตถุที่เป็นพิษ หรือวัตถุที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานและผู้ที่ถูกตรวจค้นให้ความยินยอมถึงจะทำการตรวจค้นได้[45]

ถ้าไม่ยินยอมให้ตรวจค้นตัวบุคคลหรือสิ่งของ ผู้ขนส่งปฏิเสธที่จะให้ผู้นั้นหรือสัมภาระของพวกเขาขึ้นเครื่องได้[46]

2.1.2) เจ้าพนักงาน ***มีเหตุอันควรสงสัยว่า*** เขาเป็นผู้กระทำความผิด หรือกำลังจะกระทำความผิด หรือมีแนวโน้มว่า จะกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้[47] และบุคคลนั้นไม่ยินยอมให้ตรวจค้นตัวบุคคล[48]

---

[43] แก้ไขเพิ่มเติมค.ศ. 2008

[44] Aviation Crimes Act 1972 section 11 (1)

[45] Aviation Crimes Act 1972 section 12 (1)

[46] Aviation Crimes Act 1972 section 12 (2)

[47]ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับสลัดอากาศ ความผิดเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด เป็นต้น

[48] Aviation Crimes Act 1972 section 13

2.2) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาการบิน (aircraft commander) ของแต่ละเที่ยวบิน เป็นผู้ใช้อำนาจ เพื่อความปลอดภัยของยานบินหรือของบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลในยานบิน หรือเพื่อรักษาความสงบและกฎระเบียบบนยานบินโดยมี " ***เหตุอันควรสงสัย*** " ว่าความผิดที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้เกิดหรือจะเกิดบนยานบินหรือเกี่ยวข้องกับยานบิน[49]

3) Crimes Act 1961 แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

3.1)กรณีที่ตำรวจมี**เหตุอันควรเชื่อ**ว่า(reasonable for believing)ว่าบุคคลใดกำลังกระทำความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรา202(4)(a) คือ ผู้ใดมีอาวุธร้ายแรง(offensive weapon)[50]หรือ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททำให้ผู้เสพไม่รู้สึกตัว(disabling substance) อยู่ในความครอบครองโดยปราศจากความชอบด้วยกฎหมายหรือปราศจากเหตุผลที่สมควร[51]

อาวุธร้ายแรง ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้[52]

(1) อาวุธร้ายแรง หมายถึง วัตถุที่ทำหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ก่อให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือมีไว้เพื่อทำอันตรายแก่กาย

(2) อาวุธร้ายแรง หมายถึง วัตถุที่ถูกใช้เพื่อก่อให้เกิดอันตรายแก่กาย

(3) วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททำให้ผู้เสพไม่รู้สึกตัว หมายถึง ยาสลบ หรือสารอื่นที่ถูกใช้เพื่อทำให้ไม่สามารถขัดขืนหรือตั้งใจที่จะมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์นั้น

3.2)กรณีขโมยสินค้าที่อยู่ระหว่างการเดินทาง (in transit) เมื่อตำรวจมี"**เหตุอันควรเชื่อ**"ว่าบุคคลนั้นมีของที่ลักขโมยหรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(1)อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดๆ หรือ

(2) อยู่ในตู้ , หีบห่อ , ภาชนะ หรือ

(3) อยู่ในหรือบนเครื่องบิน เรือ เรือเฟอรี่ เรือเดินสมุทร รถไฟ ยานพาหนะซึ่งอยู่ใน

(3.1)สนามบิน ท่าเรือ หรือในแม่น้ำใดๆ หรือ

---

[49] Aviation Crimes Act 1972 section 17

[50] Crimes Act 1961 section 202(a)(1)

[51] Crimes Act 1961 section 202(b)(1)

[52] Crimes Act 1961 section 202 a

(3.2) อยู่ในหรือบนทางรถไฟหรือทางเดินรถไฟหรือสถานีรถไฟ หรือ อู่รถ หรือ ป้ายรถ หรือ สนามรอบๆ หรือ

(3.3) ในหรือบนยานพาหนะในระหว่างการเดินทาง ในการขนส่งสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาบำเหน็จเป็นสำคัญ[53]

4) Customs and Excise Act 1996

กฎหมายฉบับนี้มุ่งบังคับใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้[54]

(1)บุคคลที่อยู่บนยานบิน(craft)ที่มาถึงหรือจะออกจากนิวซีแลนด์

(2)บุคคลที่กำลังขึ้นจากยานบิน(craft)หรือพึ่งจะขึ้นตาม(1)

(3)บุคคลได้เข้ามาในนิวซีแลนด์ ณ จุดตรวจศุลกากร หรือยังคงอยู่

แบ่งการตรวจค้นตัวบุคคล แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การใช้อุปกรณ์ในการตรวจค้นเบื้องต้น(preliminary search of persons by use of aids) และการตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง

4.1) การใช้อุปกรณ์ในการตรวจค้นเบื้องต้น (preliminary search of persons by use of aids)

การตรวจค้นตัวเบื้องต้น หมายถึง (1) การสัมผัสทางกายเพียงเล็กน้อยหรือการไม่สัมผัสเลยระหว่างผู้ตรวจค้นและผู้ที่ถูกตรวจค้นตัว หรือ (2) ทำการตรวจค้นโดยใช้เครื่องมืออย่างเดียวหรือหลายอย่าง เช่น สุนัข สารเคมี การเอ็กซเรย์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์เมคคานิคอื่นๆ ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดทางร่างกายมากกว่าที่กล่าวไป[55]

เจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจอาจตรวจค้นตัวบุคคลเบื้องต้น ***ไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย*** แต่หลังจากการตรวจค้นตัวเบื้องต้นไปแล้วหากตำรวจหรือเจ้าพนักงานศุลกากรมี**เหตุอันควรสงสัย**(reasonable cause to suspect) ว่าบุคคลนั้นได้หลบเลี่ยงในเรื่องหรือเกี่ยวกับสินค้าที่มิได้เสียภาษี ของต้องห้าม ของต้องกำกัด สินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านด่านศุลกากร หรือ

---

[53] Crimes Act 1961 section 224

[54] Customs and Excise Act 1996 section 149

[55] Customs and Excise Act 1996 section 149A

พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าต่างๆดังกล่าว หรือสิ่งของใดๆที่เป็นหรืออาจเป็นพยานหลักฐานของการฝ่าฝืน

หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้(มาตรา149B) จึงนำวิธีการการตรวจค้นตัวเฉพาะเรื่อง มาใช้ (มาตรา 149 B ถึง D)

ในทางตรงกันข้าม ถ้าตำรวจตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง สามารถทำการตรวจค้นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่ามีเหตุอันควรสงสัยที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ในการตรวจค้นตัวเบื้องต้นมาก่อนหรือไม่ [56]

4.2)การตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง

4.2.1) ตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาวัตถุที่ถูกซ่อน

(1) เจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจอาจควบคุมตัวบุคคลและตรวจค้นเมื่อ***มีเหตุอันควรสงสัย***(reasonable cause to suspect) ว่าบุคคลนั้นได้หลบเลี่ยงในเรื่องหรือเกี่ยวกับ[57]

(1.1) สินค้าที่มิได้เสียภาษี ของต้องห้าม ของต้องกำกัด สินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านด่านศุลกากร หรือ

(1.2) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าต่างๆดังกล่าว หรือ

(1.3)สิ่งของใดๆที่เป็นหรืออาจเป็นพยานหลักฐานของการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้

(2) เจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจอาจควบคุมตัวบุคคลและตรวจค้นเมื่อ***มีเหตุอันควรเชื่อ*** (reasonable cause to believe)ว่าบุคคลนั้น 1)นำของที่เข้ามาหรือออกนอกนิวซีแลนด์เป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยยังไม่ได้ผ่านด่านศุลกากร หรือ กำลังจะออกจากนิวซีแลนด์จากที่อื่นโดยไม่ผ่านศุลกากร และ 2) ซ่อนของหรือหลบเลี่ยงสิ่งของตาม มาตรา 149B(1)(A)(B)(C) โดยมีเจตนาที่จะฉ้อค่าภาษี[58]

(3) เจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจอาจควบคุมตัวบุคคลและตรวจค้นเมื่อ***มีเหตุอันควรเชื่อ***ว่า(reasonable cause to believe) บุคคลนั้น 1) นอกเหนือจากกรณีตาม 149B(2) หรือ

---

[56] Customs and Excise Act 1996 section 149B(7) 149BA(4)

[57] Customs and Excise Act 1996 section 149B(1)

[58] Customs and Excise Act 1996 section 149B(2)

149 และ2)บุคคลนั้นอยู่ในศุลกากรและ3)ซ่อนของหรือหลบเลี่ยงสิ่งของตามมาตรา 149B(1)(A)(B)(C)[59]

4.2.2) การตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาวัตถุอันตราย

เจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจอาจควบคุมตัวบุคคลและตรวจค้น*เมื่อ****มีเหตุอันควรเชื่อ***(reasonable cause to believe)ว่าบุคคลนั้น[60]

(1) ซ่อนหรือเห็นได้ชัดว่ากำลังซ่อนวัตถุอันตราย และ

(2) วัตถุนั้นกระทบกับความปลอดภัยของเจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่น และ

(3) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรักษาความสงบ และ

(4) การตรวจค้นภายใต้มาตรา 149 A หรือ 149B(1) จะทำให้เจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจหรือบุคคลใดๆได้รับความไม่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

5) Misuse of Drugs Act 1975

ในกรณีที่ตำรวจมี***เหตุอันควรเชื่อ*** (reasonable ground for believing) ว่าบุคคลนั้นครอบครองยาเสพย์ติดที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด เช่น โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามีน มอร์ฟีน กัญชา เป็นต้น และบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำความผิดหรือสงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพย์ติดหรือสารเสพย์ติด[61]

6) Misuse of Drugs Amendment Act 1978

6.1)กรณีที่ตรวจค้นตัวบุคคลภายใต้การขนส่งยาเสพย์ติด เมื่อเจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจมี***เหตุอันควรเชื่อ****(*reasonable ground for believing)ว่าบุคคลนั้นครอบครองยาเสพย์ติดที่ถูกควบคุมหรือสารที่ใช้ผลิตยาเสพย์ติด (precursor substance) หรือพัสดุที่เจ้าพนักงานศุลกากรได้แทนที่ยาเสพย์ติดหรือสารที่ใช้ผลิตยาเสพย์ติดทั้งหมดหรือบางส่วนหรือ

---

[59] Customs and Excise Act 1996 section 149B(3)

[60] Customs and Excise Act 1996 section 149BA(1)

[61] Misuse of Drugs Act 1975 section 18(3)

พยานหลักฐานที่คณะกรรมการของการกระทำความผิดภายใต้ตาม Principal Act มาตรา 6(1)A หรือ มาตรา12AB[62]

3.2.4 ฝรั่งเศส

ความหมายของการค้นตัวบุคคล(fouille)[63]

หมายถึงการค้นหาพยานหลักฐานในตัวบุคคลในสถานที่อื่นที่มิใช่รโหฐาน และหมายรวมถึงการค้นยานพาหนะด้วย

แบ่งการค้นตัวบุคคล(la fouille corporel)ออกเป็น 2 ประเภท คือการค้นตัวบุคคลเพื่อการสอบสวน(measure d'investigation) กับการค้นตัวบุคคลเพื่อความมั่นคง(measure de securite) ซึ่งการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานเป็นประเภทเดียวกับการค้นตัวบุคคลเพื่อความมั่นคง การค้นตัวลักษณะดังกล่าวเป็นการค้นเพื่อป้องกันอาชญากรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย การค้นในรูปแบบนี้มีจึงวัตถุประสงค์เพื่อหาวัตถุที่มีไว้เป็นความผิดหรือเป็นวัตถุอันตรายที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด เช่น ยาเสพย์ติด อาวุธปืน มีด ระเบิด ผู้เขียนได้ทำการศึกษาการค้นตัวในที่สาธารณสถานในกฎหมายดังต่อไปนี้

1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส[64]

ความผิดซึ่งหน้า เมื่อเจ้าพนักงานมี***เหตุอันควรสงสัย***ว่าผู้ขับขี่รถหรือผู้โดยสารได้กระทำความผิดหรือครอบครองวัตถุที่ครอบครองเป็นความผิดไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้กระทำความผิดเองหรือผู้ร่วมกระทำความผิด ตำรวจตรวจค้นได้ทันที

กรณีมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ตำรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานจะได้ต้องขอ***ความยินยอม***จากผู้ตรวจค้น มิฉะนั้นต้องไปขอหมายจากศาล

2) ประมวลกฎหมายศุลกากรฝรั่งเศส เจ้าพนักงานศุลกากรค้นตัวบุคคลได้โดย***ไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย*** เนื่องจากฝรั่งเศสเห็นว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำของผิดกฎหมาย หรือของหนีภาษีเข้าในประเทศเป็นความผิดที่มีความร้ายแรง[65]

---

[62] Misuse of Drugs Amendment Act 1978 section 12A

[63] Serge Guinchard,Jacques Buisson,*supra note 11,*p.510.

[64] *Ibid* ,p.511.

3) ประมวลกฎหมายการเดินอากาศ เจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจระดับปฏิบัติงานค้นตัวบุคคลได้โดย***ไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย*** เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินอากาศทั้งภายในและภายนอกประเทศ[66]

4) การค้นตามคำพิพากษาของศาลฎีกาฝรั่งเศส กรณีนี้เป็นกรณีที่ตำรวจสามารถค้นเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของสังคมโดยแนวคำพิพากษาฎีกาฝรั่งเศสให้อำนาจค้นในที่สาธารณะเพื่อหาวัตถุผิดกฎหมายหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวมโดย ***มีเหตุอันควรสงสัย*** [67]

โดยสรุป หลักเกณฑ์ของ**ประเทศสหรัฐอเมริกา**แยกการตรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานออกเป็น 2 กระบวนการคือ การเรียกให้หยุด(stop)และการตรวจค้นตัวบุคคล(frisk) หมายความว่า การหยุดไม่เป็นเหตุให้มีการตรวจค้นตัวบุคคลโดยอัตโนมัติ แต่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจค้นตัวบุคคลเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก แต่การตรวจค้นตัวบุคคลจะกระทำได้ต้องเกิดหลังการเรียกหยุดโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และทั้ง 2 กระบวนการกำหนดเงื่อนไขในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน คือ เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรสงสัย(reasonable suspicion) ทั้งกรณีการเรียกให้หยุดและก่อนการตรวจค้น *ก่อนการเรียกให้หยุด*เจ้าพนักงานจึงต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้นั้นได้จะกระทำ กำลังกระทำความผิด หรือการกระทำความผิดได้เกิดไปแล้ว *กรณีก่อนการตรวจค้นตัวบุคคล* เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีอาวุธซึ่งอาจใช้ทำร้ายเจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นในบริเวณนั้น

มาตรฐาน “ เหตุอันควรสงสัย ” แม้ไม่ได้มีการกำหนดนิยามไว้เฉพาะ ศาลพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยรวมทั้งหมดแล้วนำมาพิเคราะห์ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดีสามารถเป็นเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้หยุดบุคคลนั้นได้หรือไม่ แต่เป็นที่แน่นอนว่าเหตุอันควรสงสัยไม่สามารถเกิดจากลางสังหรณ์(hunch)หรือความสงสัยโดยทั่วไป(general suspicion) หรือบุคลิกลักษณะที่เหมือนกับบุคลิกของผู้ที่เคยกระทำความผิดมาก่อน เช่น พวกที่แต่งตัวมอซอ พวกผิวดำ เป็นต้น และแม้เป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดมาก่อนก็ไม่ใช่เหตุอันควรสงสัยเพราะเหตุ

---

[65] ประมวลศุลกากรฝรั่งเศส มาตรา 60

[66] ประมวลกฎหมายการเดินอากาศฝรั่งเศส มาตรา 282-8

[67] คำพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1988

อันควรสงสัยต้องเกิดจากพฤติกรรมที่น่าสงสัยของตัวผู้ต้องสงสัยในขณะนั้น ประกอบกับต้องมีข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงที่มีความสมเหตุสมผลหรือข้อเท็จจริงแวดล้อมที่น่าเชื่อถือเนื่องจากการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานกระทบกับสิทธิในร่างกาย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และผู้ถูกค้นต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ดังนั้นการกำหนดว่าข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยไว้ตายตัวทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะการกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อให้เกิดความยากลำบากในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายคือมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การกำหนดกรอบกว้างๆของเหตุอันควรสงสัยโดยปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานเป็นรายคดีไปจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานมากกว่า การพิจารณาว่าข้อเท็จจริงใดเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือไม่สามารถศึกษาได้จากคำพิพากษาของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา

ประเทศอังกฤษ แยกหลักเกณฑ์การตรวจค้นตัวบุคคลออกเป็น 2 กระบวนการเช่นเดียวกัน คือ การเรียกให้หยุด(stop) และ การตรวจค้นตัว(search) และทั้งสองกระบวนการมีการกำหนดเงื่อนไขการให้อำนาจของเจ้าพนักงานในการตรวจค้นตัวบุคคลไว้ใน PACE โดยละเอียดโดยกำหนดเงื่อนไขของเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นจะมีสิ่งของที่ได้ลักมาหรือมีสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิดหรือกำลังกระทำความผิด หรือจะกระทำความผิดหรือสิ่งของที่มีไว้เพื่อทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงแต่กำหนดกรอบกว้างๆ เมื่อเจ้าพนักงานมีความสงสัยว่าการกระทำความผิดจะเกิด กำลังเกิด หรือเกิดการกระทำความผิดไป และเพื่อค้นหาอาวุธเท่านั้น แต่อย่างไรเป็นเหตุอันควรสงสัยนั้นPACE วางหลักการเป็นรูปธรรมโดยกำหนดเป็นกรอบกว้างๆให้เจ้าพนักงานพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายคดีไปซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจอาจประสบด้วยตนเองหรือได้รับมาจากการสืบสวนสอบสวนก็ได้ การกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมมีข้อดีคือทำให้เจ้าพนักงานมีแนวทางที่ถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

ประเทศฝรั่งเศส พิจารณาประเภทของการกระทำความผิดเป็นสำคัญว่า หากประเทศฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะใด จะให้อำนาจเจ้าพนักงานในการตรวจค้นตัวบุคคลโดยไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย[68] ทำให้เห็นแนวคิดในการดำเนินนโยบายทางอาญาว่าเป็นแบบcrime control แต่กรณีการสืบสวนสอบสวนการกระทำ

[68] ประมวลกฎหมายศุลกากรฝรั่งเศส และ ประมวลกฎหมายการเดินอากาศฝรั่งเศส

ความผิดทั่วไปคำพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศสมีแนวว่า เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรสงสัย[69]ว่าบุคคลนั้นครอบครองอาวุธหรือวัตถุอันตราย โดยให้พิจารณาการกระทำของผู้ต้องสงสัย ณ เวลาสถานที่ที่เกิดการกระทำที่ต้องสงสัยซึ่งหลักการนี้สอดคล้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานตรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานเพราะเจ้าหน้าที่สงสัยว่าบุคคลนั้นมีอาวุธที่สามารถทำอันตรายเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่นที่อยู่ ณ บริเวณนั้น ข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศซีวิลลอว์บังคับใช้กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรศาลไม่สามารถสร้างกฎหมายโดยผ่านทางคำพิพากษาได้ แต่ในการตรวจค้นตัวบุคคลศาลได้วางหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลไว้เป็นกรณีทั่วไปไว้ว่าก่อนการค้นเจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรสงสัย

ประเทศนิวซีแลนด์กำหนดเงื่อนไขในการค้นตัวบุคคลไว้หลากหลาย ดังนี้

1)NEW ZEALAND BILL OF RIGHTS ACT 1990(BORA) กำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำไว้ในมาตรา 21 ว่า การค้นตัวบุคคลจะต้องใช้มาตรฐาน " *เหตุอันสมควร* "reasonableness (แต่หากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นตัวบุคคลเฉพาะเรื่องที่ใช้มาตรฐานสูงกว่า ต้องใช้มาตรฐานตามกฎหมายเฉพาะเรื่องเพราะ BORA เป็นเพียงแต่วางมาตรฐานขั้นต่ำในสิทธิที่จะไม่ถูกค้นตัวอย่างไม่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น[70]

2)กรณีการกระทำความผิดใดมีลักษณะก่ออันตรายต่อสังคมหรือมีความร้ายแรงมากและเจ้าพนักงานไม่มีเวลาที่จะทำการสอบสวนได้ทัน เจ้าพนักงานทำการตรวจค้นตัวได้ *"ไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย"* (reasonable suspicion)[71]

3)ลักษณะการกระทำความผิดใดไม่ได้ก่ออันตรายสังคมหรือมีความร้ายแรงทันทีเจ้าพนักงานสามารถทำการสอบสวนพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยได้ใช้มาตรฐาน *" เหตุอันควรสงสัย "*[72]

4)ลักษณะการกระทำความผิดใดก่ออันตรายสังคมหรือมีความรุนแรงน้อย ใช้มาตรฐาน *" เหตุอันควรเชื่อ "(reasonable to believe)*[73]

---

[69] รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1903 มาตรา 307 วรรค 1 และ วรรค 2

[70] Scott Optican, "Lessons From Down Under:A Dialogue on Police Search and Seizure in New Zealand and the United States," OHIO STATE JOURNAL OF CRIMINAL LAW ,Vol 3:257,pp.261-262 (2005).

[71] New Zealand law commission , *supra note 3,* p.244.

[72] *Ibid*.

[73] *Ibid.*

แม้ว่าประเทศนิวซีแลนด์จะตระหนักว่าการตรวจค้นตัวบุคคลเป็นการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวมากกว่าการตรวจค้นสถานที่ และยังกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์[74] แต่กรณีที่มีความจำเป็นกฎหมายบางฉบับยอมให้ตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาพยานหลักฐานเนื่องจากการยึดหลักไม่ตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาพยานหลักฐานต่อไปทำให้เสียเจตนารมณ์ของการตรวจค้น ทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถเก็บพยานหลักฐานไว้กับตัวได้ตลอดเวลา เจ้าพนักงานจึงไม่สามารถสืบสวนการกระทำที่ต้องสงสัยได้อย่างเต็มที่ กฎหมายประเทศนิวซีแลนด์จึงยอมรับว่าการให้อำนาจเจ้าพนักงานในการตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเป็นผลดีมากกว่าผลเสียซึ่งเป็นเหตุผลที่สมควรเมื่อชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับการจำกัดสิทธิของปัจเจกชน[75]

กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาพยานหลักฐาน[76] ได้แก่

(1) มาตรา 18(3) Misuse of Drugs Act 1975 ที่เกี่ยวกับยาเสพย์ติดบางประเภท

(2) มาตรา 12A Misuse of Drugs Amendment Act 1978 ที่เกี่ยวกับการควบคุมการขนส่งยาเสพย์ติดบางประเภท

(3) มาตรา 202 B Crimes Act 1961 ที่เกี่ยวข้องกับมีด อาวุธที่ร้ายแรง และ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททำให้ไม่รู้สึกตัว(disabling substance)

(4) มาตรา 224 Crimes Act 1961 การขโมยสินค้าในระหว่างการเดินทาง

(5) มาตรา 13 Aviation Crimes Act 1972 ในกรณีที่บุคคลไม่ยินยอมให้ตรวจค้นตัว

(6) มาตรา 60 และ 61 Arm Act 1983 เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน

(7) มาตรา 149B(2) Customs and Excise Act 1996

นอกจากนี้ Newzealand Law Commission เสนอว่าเจ้าพนักงานควรมีอำนาจในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานโดยไม่มีหมายในกรณีที่เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นครอบครองพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีอัตราโทษจำคุก 14 ปีหรือมากกว่านั้น[77] อย่างไรก็ตามถ้าผู้ถูกตรวจค้นให้ความยินยอมในการตรวจค้น ตำรวจน่าจะใช้

---

[74] *Ibid*, p. 238.

[75] *Ibid*, p. 248.

[76] *Ibid*, pp. 243-244.

[77] *Ibid*, p. 248.

อำนาจได้แม้ไม่มีเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเชื่อ[78] ต่างจาก**ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา**ที่ไม่ยอมให้ "ความยินยอม" ของผู้ถูกตรวจค้นเป็นเหตุผลเดียวที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการตรวจค้นตัวบุคคล ทำให้การตรวจค้นที่ไม่ชอบกลายเป็นการตรวจค้นที่ชอบด้วยกฎหมายหรือทำให้กลายเป็นไม่มีเงื่อนไขในการจำกัดอำนาจของเจ้าพนักงาน

3.3.กระบวนการตรวจค้น

3.3.1 กระบวนการก่อนตรวจค้น

3.3.1.1 **สหรัฐอเมริกา**

1) ความหมายการค้นตัวบุคคล

1.1)ความหมายตาม Black's Law Dictionary[79]

"การค้นตัวบุคคล"[80]หมายถึง การแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธที่ซุกซ่อนในร่างกาย

1.2)ความหมายตามคำพิพากษา

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนได้ตรวจตั๋วบนรถโดยสารว่าเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายหรือไม่ ขณะที่เดินตรวจได้จับกระเป๋าใบหนึ่งด้านนอกที่วางอยู่บนชั้นวางของเหนือที่นั่งของผู้ต้องสงสัย เจ้าพนักงานรู้สึกเหมือนภายในบรรจุก้อนหินอยู่ หลังจากผู้ต้องสงสัยได้ยอมรับว่าเป็น

---

[78] *Ibid*, p. 240.

[79]Retrieved from http://international.westlaw.com/result/default.wl?vr=2.0&tf=507&sv=Split&cxt=RL&utid=17&fmqv=s&rlti=1&ss=CNT&tc=1&rs=WLIN10.10&eq=search&db=BLACKS&cnt=DOC&fn=_top&rlt=CLID_QRYRLT49354354721810&n=1&scxt=WL&spa=THAMM2002&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rltdb=CLID_DB6388301621810&origin=Search&mt=WLIGeneralSubscrtion&service=Search&query=%22STOP+AND+FRISK%22&method=TNC.

[80] frisk,*n*. (18c) A pat-down search to discover a concealed weapon. — Also termed *pat-down*. See STOP AND FRISK. Cf. SEARCH (1). [Cases: Arrest 63.5(8); Automobiles 349.5(10); Searches and Seizures 70.]

เจ้าของกระเป๋าใบนั้นและได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจพบก้อนยาบ้า ศาลวินิจฉัยว่า การจับกระเป๋าของบอนด์เป็นการตรวจค้นตัวบุคคลแล้ว (frisk of his person) แม้เจ้าพนักงานจะไม่ได้ตรวจค้นตัวก็ตาม เพราะกระเป๋าไว้ใช้ใส่ของส่วนตัว ดังนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้เดินทางย่อมต้องหวงกันสัมภาระของตน

ข้อสังเกต คดีนี้ศาลไม่ได้ห้ามเจ้าหน้าที่ไม่ให้ขึ้นไปบนรถเมล์และพูดกับผู้โดยสาร ไม่ได้ห้ามเจ้าหน้าที่ในการขอความยินยอมในการตรวจค้นตัวบุคคล ศาลพิพากษาว่า หากเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารโดยไม่มีความสงสัยที่มีเหตุผลสมควรเลยว่ากระเป๋าใบนั้นจะมีพยานหลักฐานที่ใช้ในการกระทำความผิดอาญา การตรวจกระเป๋าเป็นการฝ่าฝืน Fourth Amendment[81]

ประเทศสหรัฐอเมริกาวางหลักการการตรวจค้นตัวบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายไว้ว่า

1. ก่อนที่จะหยุดผู้ต้องสงสัยเจ้าพนักงานจะต้องมีความสงสัยที่สมเหตุสมผลว่าอาจมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น

2. เจ้าพนักงานจะต้อง**มีความสงสัยที่สมเหตุสมผลว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีอาวุธ**

3. เจ้าพนักงานแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธที่ซุกซ่อนในร่างกายของผู้ต้องสงสัยเพื่อปกป้องตัวเองจากอาวุธ (pat down) ไม่ใช่เพื่อพบสิ่งผิดกฎหมายหรือหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิดทางอาญา

จะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลถูกเรียกให้หยุดแล้วไม่สามารถตรวจค้นตัวในอัตโนมัติได้ทุกกรณี แต่การตรวจค้นตัวบุคคลจะต้องเกิดหลังจากที่มีการเรียกให้หยุดโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่านั้น

ในคดี Terry v. Ohio ศาลเห็นความสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม ดังนั้นแม้กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าจะกระทำความผิด (probable cause) เพื่อที่จะทำการจับ(arrest) ศาลจึงให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการเรียกให้หยุดและทำการตรวจค้นตัวบุคคลได้ ขณะเดียวกันศาลก็ตระหนักว่าการตรวจค้นตัวเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอย่างรุนแรง และกระทบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสร้างความไม่พอใจแก่ผู้ถูกตรวจค้นตัวอย่างมาก ศาลสูงจึงจำกัดขอบเขตในการตรวจค้นตัวบุคคล(frisk)เพื่อป้องกันดังนี้

---

[81]คดี Bond v. United Stated ,529 U.S. 334 (2000)

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจค้นตัวเพื่อหาอาวุธได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า เขากำลังข้องเกี่ยวกับบุคคลที่มีอาวุธและอาจเป็นอันตราย โดยไม่ต้องคำนึงว่ามีเหตุที่จะจับหรือไม่[82] เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดแล้วไม่สามารถตรวจค้นตัวบุคคลได้เสมอไป แต่เจ้าหน้าที่ที่จะทำ*การตรวจค้นตัวได้*ต้องมีเหตุน่าเชื่อว่ากำลังเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอาวุธหรือเป็นอันตราย ซึ่งศาลเรียกมาตรฐานนี้ว่า ***"เหตุอันควรสงสัย"***(reasonable suspicion) มาตรฐานเหตุอันควรสงสัยนี้เจ้าพนักงานไม่ต้องมีความมั่นใจอย่างสูงสุดว่าบุคคลนั้นมีอาวุธ **ดังนั้นการตรวจค้นตัวบุคคล** (frisk) **จึงถูกควบคุมโดยมาตรฐานทางภาวะวิสัยเหมือนกับมาตรฐานที่ควบคุมการเรียกให้หยุด**(stop) **เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องให้เหตุผลในการเรียกให้หยุดและการตรวจค้นตัวบุคคลโดยแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงและข้อเท็จจริงที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการกระทำความผิด โดยอาศัยการวิเคราะห์จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เอง**[83]

ข้อเท็จจริงต่างๆจะถูกนำมาพิจารณารวมกันในการตัดสินใจว่า มีการกระทำความผิดพอที่ทำการตรวจค้นตัวบุคคลได้หรือไม่ บางปัจจัยต้องมีน้ำหนักมากพอตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่คนนั้น ข้อเท็จจริงที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์บางส่วนในการตัดสินใจว่าจะทำการตรวจค้นตัวบุคคลหรือไม่[84]

1) การกระทำความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ

2) ผู้ต้องสงสัยมีท่าทางกระสับกระส่ายเมื่อถูกเรียกให้หยุด

3) มีสิ่งของนูนออกมาจากเสื้อผ้าของผู้ต้องสงสัย

4) ผู้ต้องสงสัยเอามือซุกในเสื้อ

5) ผู้ต้องสงสัยไม่แสดงบัตรเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานหรือไม่มีเหตุผลเพียงพอในการบรรยายการกระทำที่ต้องสงสัย

6) พื้นที่เกิดเหตุเป็นที่รู้จักกันดีว่าบุคคลในบริเวณนั้นมักพกพาอาวุธ

7) ผู้ต้องสงสัยแสดงการขัดขืนขณะถูกเรียกให้หยุด

8) เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีอาวุธจากการกระทำความผิดครั้งก่อน

ความสมเหตุสมผลในการตรวจค้นตัวบุคคลต้องมีปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบโดยประเมินจากประสบการณ์และความรู้ของเจ้าหน้าที่

---

[82] *supra note 20*, p.285.

[83] *Ibid*, p.287.

[84] *Ibid.*

3.3.1.2 **อังกฤษ**[85]

วางหลักการการเรียกให้หยุดและตรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะว่าเจ้าพนักงานจะต้องกระทำด้วยความเคารพและให้เกียรติแก่ผู้ที่ถูกตรวจค้น และกำหนดไว้ในCode A ข้อ3 ดังนี้

1. แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าต้องถูกควบคุมเพื่อทำการตรวจค้น

(1.1) บอกเขาว่าถูกตรวจค้นเพราะวัตถุประสงค์ใด

(1.2) แจ้งชื่อเจ้าพนักงานผู้ตรวจค้น(ยกเว้นในกรณีที่สอบสวนการก่อการร้ายหรือกรณีที่ถ้าบอกชื่อไปแล้วเจ้าพนักงานผู้ตรวจค้นจะได้รับอันตราย) และชื่อสถานีตำรวจ

(1.3) เหตุแห่งการใช้อำนาจตรวจค้น

2. อธิบายเหตุทางกฎหมายที่อนุญาตให้ตรวจค้นได้

(2.1) วัตถุประสงค์ตรวจค้นหาสิ่งของที่ต้องการพบ

(2.2) เหตุอันควรสงสัย ในกรณีที่การตรวจค้นนั้นต้องมีเหตุอันควรสงสัย

(2.3) เหตุที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจค้น ในกรณีที่การตรวจค้นนั้นไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย

3. ในกรณีที่ผู้จับไม่ได้แต่งเครื่องแบบ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวตำรวจ

4. ก่อนทำการตรวจค้นต้องแจ้งแก่ผู้ถูกตรวจค้นด้วยว่าเขามีสิทธิได้รับสำเนาบันทึกการตรวจค้น และมีสิทธิร้องขอบันทึกดังกล่าวได้ภายใน 12 เดือนหลังจากการตรวจค้นเสร็จสิ้น และแจ้งให้ทราบถึงอำนาจของตำรวจในการเรียกให้หยุดและตรวจในพฤติการณ์ดังกล่าว

5. ถ้าบุคคลที่จะถูกค้นไม่เข้าใจการแจ้งของตำรวจเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ตำรวจจะต้องดำเนินการให้เขาได้รับทราบสิทธินั้นก่อน หรือถ้าบุคคลนั้นเป็นคนหูหนวกหรือไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ และมีเพื่อนมาด้วย ตำรวจมีสิทธิที่จะร้องขอให้ผู้นั้นเป็นล่ามเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ถูกค้นเข้าใจได้

3.3.1.3 **นิวซีแลนด์**

1) Arm Act 1983

---

[85] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่14*, น.45-46 .

ทั้งการตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยว่าครอบครองอาวุธปืนหรือผู้ต้องสงสัยตามพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัว เจ้าหน้าที่ต้อง

(1)แนะนำตัวก่อนเข้าตรวจค้น

(2) บอกผู้ถูกตรวจค้นว่าใช้อำนาจตามกฎหมายใด มาตราใด

(3)ถ้าไม่ได้ใส่เครื่องแบบให้แสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าพนักงานเมื่อถูกร้องขอ[86]

2) Aviation Crimes Act 1972

กรณีที่ตำรวจ เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยทางการบิน เจ้าพนักงานศุลกากร เป็นผู้ตรวจบุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ตรวจค้นตัวหรือสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง เจ้าพนักงานต้องแสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานต่อผู้ถูกตรวจค้น ต้องบอกว่าใช้อาจตรวจค้นตามกฎหมายฉบับนี้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานไม่สวมเครื่องแบบต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นตำรวจ[87]

3) Crimes Act 1961

มีกระบวนการก่อนตรวจค้นเฉพาะกรณีครอบครองอาวุธร้ายแรงหรือกรณีครอบครองอาวุธอันตรายหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททำให้ไม่รู้สึกตัว โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานต้องแสดงตัวต่อบุคคลทุกคนที่ถูกตรวจค้น บอกว่าใช้อำนาจตรวจค้นตามกฎหมายฉบับนี้ กรณีที่เจ้าพนักงานไม่ได้สวมเครื่องแบบ เมื่อมีการร้องขอให้แสดงพยานหลักฐานการเป็นตำรวจ[88]

4) Customs and Excise Act 1996

การตรวจค้นตัวบุคคลเฉพาะเรื่อง

4.1) การตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาของที่ถูกซ่อน สิทธิของบุคคลที่ถูกตรวจค้นตัว

(1) เจ้าพนักงานต้องแจ้งสิทธิของผู้ถูกตรวจค้น ว่าเขาจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้างและแจ้งต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ได้รับอำนาจจาก Chief Executive หรือต่อ Justice of the Peace หรือต่อ Community Magistrate (เรียกว่า ผู้ทบทวน(reviewer))

---

[86] Arm Act 1983 section 60 (3)

[87] Aviation Crimes Act 1972 section 13(3)

[88] Crimes Act 1961 section 202B

(2) ถ้าผู้ถูกควบคุมตัวอยากไปหา Reviewer ให้เจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจพาไปหาในทันที

(3) ในกรณีถูกควบคุมตัวตาม149B(1)ถ้ามี*เหตุอันควรสงสัย*ว่าบุคคลนั้นได้ซ่อนสิ่งของหนีภาษีตาม 149B(1)(2)(3) ให้อำนาจ Reviewer *ตรวจค้นตัวบุคคลนั้น*ได้ แต่ถ้าไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยตาม 149B(1)(2)(3) ก็ให้ปล่อยตัวไป

ในกรณีบุคคลนั้นถูกควบคุมตัว 149B (2)(3) Reviewer สามารถ*ตรวจค้น*ตัวบุคคลนั้นได้ ถ้ามี*เหตุอันควรเชื่อ*ว่าได้ซ่อนสิ่งของเพื่อหลบเลี่ยงมีเจตนาไม่ต้องเสียภาษีหรือการนำเข้าหรือส่งออกของโดยไม่ผ่านศุลกากรของประเทศนิวซีแลนด์หรือมีความพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ว่าด้วยประการใด[89] แต่ถ้าไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยตาม 149B(1)(2)(3) ก็ให้ปล่อยตัวไป[90]

กฎหมายกำหนดให้มี “ Reviewer ” เพื่อเป็นคนกลางในการตัดสินว่าการกระทำของเจ้าพนักงานมีมูลเหตุเพียงพอในการตรวจค้นตัวบุคคลหรือไม่ ในอีกมุมหนึ่งการที่จะพาผู้ถูกตรวจค้นไปหา “Reviewer” เป็นการทำให้ผู้ถูกตรวจค้นตัวถูกล่วงละเมิดสิทธิมากขึ้นเพราะเวลาในการควบคุมตัวถูกขยายออกไป New Zealand Law Comissionจึงเสนอแนวทางให้แก้ไขบทบัญญัติเรื่อง “Reviewer’’ เป็นการแนะนำว่าเขามีสิทธิที่จะมีทนายความแทน[91]

5) Misuse of Drugs Act 1975[92]

เจ้าพนักงานต้องแนะนำตัวแก่ผู้ที่ถูกตรวจค้นกับผู้ที่สงสัยอำนาจของเจ้าพนักงานต้องบอกว่าได้อำนาจตรวจค้นตามกฎหมายฉบับนี้ และในกรณีที่เจ้าพนักงานทำการตรวจค้นโดยไม่สวมเครื่องแบบกฎหมายกำหนดให้แสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าพนักงาน

6) Misuse of Drugs Act 1978[93]

---

[89] Customs and Excise Act 1996 section 149B(1)(2)(3)

[90] Customs and Excise Act 1996 section 149D

[91] New Zealand Law Commission ,*supra note 13*, p. 238.

[92] Misuse of Drugs Act 1975 section 18(4)

[93] Misuse of Drugs Act 1978 section 12C

เจ้าพนักงานต้องแนะนำตัวแก่ผู้ที่ถูกตรวจค้นและบอกด้วยว่าเขาถูกตรวจค้นเนื่องจากเจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นครอบครองยาเสพย์ติดที่ถูกควบคุมหรือสารที่ใช้ผลิตยาเสพย์ติดขณะที่อยู่ภายใต้การขนส่งยาเสพย์ติด

3.3.1.4 **ฝรั่งเศส**

ไม่ปรากฏว่ามีกระบวนการก่อนการตรวจค้นทั้งในกฎหมายลายลักษณ์อักษรและคำพิพากษาศาลฎีกา

โดยสรุป **ประเทศสหรัฐอเมริกา**และ**ประเทศฝรั่งเศส** ไม่ได้มีการกำหนดขั้นตอนในเรื่องการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกตรวจค้นตัวเอาไว้ ซึ่งแตกต่างจาก**ประเทศอังกฤษ**[94] ในการเรียกให้หยุดและตรวจค้นในที่สาธารณสถานนั้นตำรวจต้องแจ้งแก่ผู้ถูกค้นให้ทราบถึงเหตุในการค้น ซึ่งได้แก่อำนาจตามมาตรา 1 ของ PACE ว่าเป็นการตรวจค้นโดยอาศัยเหตุอย่างหนึ่ง และแจ้งว่าเหตุที่ผู้นั้นถูกเรียกให้หยุดเป็นเพราะตำรวจประสงค์จะให้ตรวจค้นในเรื่องอะไร เช่น ต้องการค้นสิ่งของที่ถูกลักมา เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้เป็นการแจ้งให้ทราบถึงเหตุของการค้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

กรณีที่สอง การแจ้งในกระบวนการของการค้น ได้แก่ การแจ้งว่าผู้นั้นจะถูกควบคุมอยู่เพื่อการค้น แต่ไม่ได้เป็นการจับ และแจ้งว่าหากเขาไม่ได้รับความร่วมมือในการค้น ตำรวจอาจใช้อำนาจบังคับเท่าที่จำเป็นในการตรวจค้นได้

กรณีที่สาม การแจ้งชื่อผู้ค้นและสถานีตำรวจที่สังกัด หากเป็นเจ้าพนักงานที่แต่งเครื่องแบบ แต่ถ้าเป็นตำรวจที่ไม่แต่งเครื่องแบบต้องแสดงบัตรประจำตัว ในการแจ้งชื่อและสถานีตำรวจนั้นมีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการแจ้งแล้วจะเป็นอันตรายในกรณีค้นผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

กรณีที่สี่ แจ้งและอธิบายให้ผู้ถูกค้นทราบถึงสิทธิที่จะได้รับสำเนาการค้น

จะเห็นได้ว่า ในแต่ละขั้นตอนของการแจ้งดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจของผู้ค้นและผู้ถูกค้นว่า ตนจะถูกตำรวจค้นในเรื่องใดและผู้ค้นได้รับการค้นจากตำรวจชื่ออะไรหรือสถานีใดและผู้ถูกค้นจะได้รับสิทธิอย่างใดบ้าง อันทำให้ประชาชนได้รับความเข้าใจในการปฏิบัติงานของตำรวจได้ดียิ่งขึ้น

---

[94] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่14*, น.46-47.

ส่วน**ประเทศนิวซีแลนด์** แม้มิได้มีกระบวนการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกตรวจค้นอย่างครบถ้วนอย่างประเทศอังกฤษ แต่อย่างน้อยในกฎหมายหลายฉบับ[95]ได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานต้องแจ้งต่อผู้ถูกตรวจค้นอย่างน้อย 3 ประการ คือ

1. ต้องแนะนำตัวแก่ผู้ที่ถูกตรวจค้นหรือกับผู้ที่สงสัยอำนาจของเจ้าพนักงาน
2. ต้องบอกว่าได้อำนาจตรวจค้นตามกฎหมายฉบับใด
3. ถ้าไม่ใส่เครื่องแบบกฎหมายกำหนดให้แสดงหลักฐานว่าเป็นตำรวจ

3.3.2 **<u>กระบวนการระหว่างตรวจค้น</u>**

3.3.2.1 **สหรัฐอเมริกา**

การใช้กำลังในการตรวจค้น ทำได้เพียงเพื่อให้เจ้าพนักงานได้ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะว่ามีพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือมีสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่ แต่ไม่อาจใช้กำลังถึงขั้นทำให้ตายเหมือนในกรณีที่ผู้ถูกจับขัดขืนการจับและใช้กำลังต่อสู้ขัดขืนพนักงานผู้จับ[96] ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาศาลได้วางแนววินิจฉัยไว้ดังนี้[97]

1. จำนวนเจ้าพนักงานและและรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง
2. ลักษณะของความผิดและเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องสงสัยมีอาวุธในความครอบครอง
3. ความมั่นใจของเจ้าพนักงานในหลักฐานการตรวจค้น
4. ความจำเป็นต้องตรวจค้นในทันที
5. พฤติกรรมของผู้ถูกตรวจค้นที่เจ้าพนักงานได้สังเกตเห็น
6. โอกาสของเจ้าพนักงานที่จะเรียกให้หยุดโดยไม่ต้องใช้กำลังบังคับ

1) **<u>ขอบเขตของการตรวจค้นตัวบุคคล</u>**

*การตรวจค้นตัวบุคคล*มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิดแต่เพื่อให้เจ้าพนักงานติดตามการสอบสวนโดยไม่ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายและเพื่อความ

---

[95] Arm Act 1983 section 60(3),Aviation Crimes Act 1972 section 13(3), Crimes Act 1961 202B,Custom and Excise Act 1996 section 149B,Misuse of Drug Act 1975 section 18(4), Misuse of Drug Act 1978 section 12C

[96] John N. Ferdico,*supra note 20* ,p 310.

[97] คดี United Atates v. Seelye , 815 F.2d. 48, 51 (8th Cir. 1987)

ปลอดภัยของผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณนั้น ดังนั้นขอบเขตของการตรวจค้นจึงจำกัด*ในขั้นต้น*เพียงแค่ **การแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธ**(pat down)เท่านั้น ดังนั้นการตรวจค้นตัวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น พยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อหามูลเหตุในการตรวจค้นตัวบุคคลจึงเป็นการตรวจค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลพิพากษาว่าการที่ตำรวจรู้ว่าของนั้นเป็นของที่ผิดกฎหมายซึ่งเกิดภายหลังที่มีการตรวจค้นต่อไป จึงเป็นการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ใช่กรณีที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีหมายและไม่ใช่ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องการหมายด้วย การตรวจค้นต่อไปในกระเป๋าเสื้อของจำเลยไม่ได้ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญ โคเคนจึงไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้ตามหลักดอกผลของต้นไม่มีพิษเพราะเจ้าพนักงานทำเกินเลยไปกว่าหาอาวุธ[98]

แต่ผู้ต้องสงสัยอาจถูกตรวจค้นตัวได้ในบางสถานการณ์โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าเขามีอาวุธได้ ซึ่งมีกรณีเดียว คือ ตำรวจต้องนำตัวผู้ต้องสงสัยขึ้นรถ เหตุผลก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าพนักงาน

1.1) เวลา

ในคำพิพากษาของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา **ไม่ได้กำหนดเวลาที่จำกัดไว้แน่นอน** ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเรียกให้หยุด ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียกให้หยุด

ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา วินิจฉัยว่า ในการประเมินระยะเวลาต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีวิธีในการติดตามการสอบสวนด้วยความขยันขันแข็งเพื่อยืนยันหรือทำให้หมดไปซึ่งความสงสัยอย่างรวดเร็ว และในสถานสถานการณ์นั้นมีความจำเป็นต้องควบคุมตัวจำเลยยาวนานแค่ไหน เพียงใด[99] แต่โดยหลักการเรียกให้หยุด**ต้องเป็นระยะเวลาที่สั้น** เพราะบุคคลนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ถูกจับ ในการประเมินว่าการควบคุมตัวเป็นไปในระยะเวลาสั้นหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าการเรียกให้หยุดเพื่อการสอบสวนมีความสมเหตุสมผล(reasonableness)หรือไม่ การกระทำของตำรวจสามารถทำทางอื่นเพื่อให้ล่วงละเมิดสิทธิน้อยที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ และในสถานการณ์นั้นตำรวจมีความสมเหตุสมผลที่จะทำการสอบสวนต่อไป[100]

---

[98]คดี Minnesota v. Dickerson , 508 U.S. 366 (1993)

[99]คดี United State v. Place , 462 U.S. 696 (1983)

[100]คดี U.S. v.Shape and Savage , 470 U.S. 675 (1985).

กรณีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงที่ชี้ว่ายานพาหนะบรรทุกแรงงานต่างด้าว ศาลพิพากษาว่าการเรียกให้หยุดในเวลาสั้นและการสอบถามโดยที่ไม่มีprobable cause สามารถทำได้เพราะการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ การแย่งงานของคนในประเทศและเกิดการเรียกร้องทางบริการสังคมเพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรเกิน 1 นาที (รวมการเรียกให้หยุดแล้ว) การถามคำถามก็ต้องไม่มากไปกว่าการสอบถามในเวลาอันสั้น[101]

การสอบสวนอาจมีการล่าช้าในบางกรณี คดีนี้เจ้าหน้าที่มีเหตุในการเรียกให้รถบรรทุกในบริเวณที่เพิ่งเกิดการย่องเบาให้หยุด เพราะสังเกตว่าคนในรถเอาเบาะฝั่งคนขับเอนลงเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะให้สอบสวน ตำรวจจึงขับรถผ่านรถบรรทุกช้าๆ ดูจากกระจกข้างรถตำรวจสังเกตเห็นรถบรรทุกเคลื่อนออกจากจุดที่จอดและติดตามรถตำรวจมา หลังจากที่ได้รับแจ้งให้ทราบว่าไม่มีตำรวจอื่นๆดักจับรถบรรทุกได้ ตำรวจจึงได้เรียกให้หยุดใน 2-3 นาทีต่อมาหลังจากการสังเกตในตอนแรก ศาลวินิจฉัยว่า ความล่าช้าในการเรียกให้หยุดไม่ได้ทำให้ความสงสัยของเจ้าหน้าที่หมดไป เพราะรถบรรทุกยังคงอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา[102] หรือกรณีความล่าช้าในการสอบสวนเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่เทนเนสซีไม่สามารถมาถึงได้จนกระทั่งวันต่อมา ความล่าช้าเกิดเพราะเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถทำได้เร็วกว่านั้นแล้ว[103]

เหตุอื่นๆ ที่สามารถขยายเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ได้แก่ เจ้าพนักงานพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลต่อไปตามที่ได้รับมาจากวิทยุสื่อสารหรือจากบุคคลอื่น หรือกรณีเจ้าพนักงานต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานอื่น การที่เจ้าพนักงานต้องใช้เวลาในการเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ การให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ การหาวิธีจัดการกับผู้ต้องสงสัยที่พยายามขัดขืนการถูกเรียกให้หยุด

คำพิพากษาที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นระยะเวลาที่สั้น

---

[101]คดีUnited States v. Brignoni-Ponce, 422 U.S. 873 (1975),

[102]คดี State v. Cyr , 101 Conn.App. 701, 706-709 923 A.2d 772 (2007).

[103]คดี United Stated v. Van Leeuwen 397 U.S.249,90 S.Ct.1029,25 L.Ed.2d 282 (1970)

กรณีที่ศาลพิพากษาว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นเวลานานถึง 20-25 นาทีทำไม่ได้เพราะเกินไปกว่าการเรียกให้หยุด ทำให้เป็นการจับแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมี probable cause[104]

กรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้จำเลยหยุดและตรวจค้นตัวเป็นเวลา 15 นาทีหลังเกิดความสงสัย เป็นการเรียกให้หยุดที่ไม่ชอบเพราะความสงสัยหมดไปแล้ว[105]

การควบคุมตัวเพื่อการสอบสวนและการยึดสัมภาระของจำเลยไปตรวจเป็นเวลากว่า ๙๐ นาที โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแจ้งให้จำเลยทราบว่ากระเป๋าของจำเลยจะถูกส่งไปที่ไหนเป็นเวลานานเท่าใด และจะได้กระเป๋าคืนอย่างไร[106] ทำให้การยึดสัมภาระของจำเลยเพื่อไปสอบสวนเป็นการกระทำเกินไปกว่าอำนาจเพราะต้องยึดถือในระยะเวลาที่สั้นตามความสงสัยที่มีเหตุผล[107]

นอกจากนี้การค้นต้องกระทำด้วยความสุภาพและไม่ทำให้ผู้ถูกหยุดเกิดความโกรธที่ต้องประสบกับการใช้กำลังบังคับให้ถูกค้นตัว หากมีความจำเป็นที่จะต้องเวลาในการตรวจค้นนานกว่าที่มีเหตุอันควร เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรเชื่อเพื่อยืดเวลาในการตรวจค้นว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะที่จะได้สิ่งของที่ต้องการตรวจค้น[108]

1.2)สถานที่

ต้องทำ ณ สถานที่หรือที่ที่ก่อให้เกิดมูลเหตุการสอบสวน (on the spot) หรือใกล้กับสถานที่หยุด หากมีความจำเป็นสามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยจากสถานที่เกิดเหตุไปที่สถานีตำรวจได้ เช่น บริเวณถนนมีคนมุงดูมาก และตัวผู้ถูกตรวจค้นเองก็ไม่ยอมเปิดให้ดูว่าเป็นห่ออะไร[109] หรือกรณีอื่นที่สามารถนำตัวไปสถานที่เกิดเหตุได้[110]

---

[104]คดี United stated v.Quinn , 230 F.3d 862, 864 (6th Cir.2000)

[105]คดี United stated v.Place, 462 U.S.696 1983

[106]*Supra note 101.*

[107]Retrieved from http://uspcak9.com/training/introsearchandseizure.shtml

[108]สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่14*, น.65.

[109]คดี People v. Courtney , 90 Cal.Rptr.370 (Cal.Ap.3d 1970).

[110]คดี U.S. v.McCargo , 464 F.3d 192 (CA2 N.Y.2006).

กรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้จำเลยหยุดและค้นตัวขณะที่พบตัวจำเลยห่างจากที่เกิดเหตุไป 15 ไมล์ การเรียกให้หยุดที่ไม่ชอบแล้วเพราะความสงสัยหมดไปแล้ว[111]

กรณีเรียกให้หยุดบริเวณชายแดนเม็กซิโก การเรียกให้หยุดต้องทำในเวลาสั้นและสอบถามตรงบริเวณด่านตรวจถาวร[112]

2)วิธีการของการเรียกให้หยุดและค้นตัวบุคคล

วิธีการสอบสวนสามารถมีได้ตั้งแต่ระดับล่วงละเมิดที่น้อยที่สุด จนถึงการใช้กำลังบังคับ แต่โดยหลักวิธีการสอบสวนต้องล่วงละเมิดน้อยที่สุดและมีอยู่ตามจำเป็นที่จะยืนยันความสงสัยของเจ้าพนักงานหรือทำให้ความสงสัยของเจ้าพนักงานหมดไป ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกให้จำเลยหยุดด้วยการใช้กำลังและใช้อาวุธปืนในทันทีจึงเป็นการเรียกให้หยุดที่ไม่ชอบ การสุ่มตรวจค้นตัวทำไม่ได้ เพราะการตรวจค้นตัวทำได้เพียงวัตถุประสงค์เดียวคือคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าพนักงานและผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการกระทบกับสิทธิของประชาชนอย่างมาก[113]

ตราบใดที่ข้อเท็จจริงและสถานการณ์มันมีเหตุอันควรสงสัย เจ้าพนักงานสามารถสั่งให้ผู้ต้องสงสัยนิ่ง(Freeze)ในขณะนั้น และการสั่งสามารถสั่งได้นานตราบเท่าที่ให้เจ้าพนักงานได้ข้อมูลที่จะจับผู้ต้องสงสัย ถ้าเจ้าพนักงานไม่สามารถหาข้อมูลได้ต้องปล่อยไป[114]

กรณีเรียกให้ยานพาหนะหยุดได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาจสั่งให้คนขับรถและผู้โดยสารออกจากยานพาหนะ แม้เจ้าหน้าที่จะไม่มีเหตุสงสัยว่าผู้ที่อยู่ในรถได้ทำผิดกฎหมายในเวลาที่ทำการเรียกให้หยุด[115] เจ้าพนักงานสามารถสั่งให้คนขับรถออกจากรถเพื่อตรวจค้นตัวได้ ถ้าเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีอาวุธและมีลักษณะก่ออันตรายและได้รับความยินยอมในการตรวจค้นรถยนต์ ไม่ว่าเจ้าพนักงานประสงค์จะจับหรือออกใบสั่งจราจรหรือไม่ก็ตาม[116] ต่อมามีแนวคำวินิจฉัยของศาลสูงสุด

---

[111]คดี United stated v.Posey ,501 F.2d 998, 1002 (6th Cir.1974)

[112]คดี *United States v. Martinez-Fuerte*, 428 U.S. 543,(1976)

[113]คดี United Stated v. Valentine , 299 U.S. 5 (1936)

[114]คดี U.S. v.Shape and Savage , 470 U.S. 675 (1985)

[115]คดี Pennsylvania v.Mimms ,434 U.S. 106 (1977)

[116]คดี Ohio v. Robinete 519 U.S.33(1996)

สหรัฐอเมริกาว่า หากมีการตรวจค้นแล้ว พบว่าผู้ที่ถูกเรียกให้หยุดและตรวจค้นไม่มีบัตรประจำตัวมาแสดงตามที่กฎหมายกำหนด ผู้นั้นอาจถูกจับในฐานที่ไม่มีบัตรประจำตัวได้[117]

เจ้าพนักงานอาจตรวจค้นกระโปรงหลังของยานพาหนะเพื่อหาอาวุธ ถ้าเจ้าพนักงานมีความสงสัยที่สมเหตุผลว่ายานพาหนะนั้นมีอันตรายและผู้ครอบครองอาจใช้อาวุธนั้นได้ทันที เจ้าพนักงานอาจยึดของผิดกฎหมายที่เจ้าพนักงานสามารถมองเห็นได้(plain view)ในระหว่างการตรวจค้นได้[118]

กรณีการเรียกให้หยุดเพราะฝ่าฝืนกฎหมายจราจร เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจดูใบขับขี่ และคู่มือจดทะเบียน การซักถามถึงที่หมายและวัตถุประสงค์ที่จะไป [119]

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาและไม่สามารถที่จะขอหมายจากเจ้าพนักงานตุลาการได้ทัน กรณีนี้การปล่อยลมยางรถที่ตรวจสอบทางทะเบียนแล้วว่าเป็นของจำเลยที่เพิ่งก่อคดีย่องเบาร้านรักษาสัตว์โดยไม่มีการตรวจค้นต่อไป เป็นวิธีการตรวจค้นที่ชอบแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ เพราะถ้าไม่ปล่อยลมยางผู้ต้องสงสัยก็ต้องเคลื่อนย้ายรถและของที่ลักออกไป[120]

เจ้าพนักงานสามารถตรวจค้นตัวภายหลังการเรียกให้หยุดโดยไม่ต้องถามคำถามได้ ถ้าเจ้าพนักงานเชื่อว่าตนเองหรือผู้อื่นจะมีอันตราย เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องถามก่อน[121]

กรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าสัมภาระและทรัพย์สินอื่นๆจะมีอาวุธซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่สามารถยึดถือทรัพย์สินไว้ชั่วคราวตราบเท่าที่มีความสงสัยที่มีเหตุผลว่ามันซ่อนของผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานในการกระทำความผิดทางอาญา

ขณะเดียวกันผู้ต้องสงสัยมี*สิทธิที่จะไม่ตอบคำถาม* ดังนั้นเจ้าพนักงานจะใช้กำลังเพื่อให้ตอบคำถามไม่ได้ แต่การปฏิเสธที่จะตอบเป็นเหตุเพียงพอที่จะตรวจค้นตัวเพราะเจ้า

---

[117]สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่14*, น.66.

[118]John N. Ferdico,*supra note20,* p.288.

[119]*คดี* United Stated v. Bloomfield

[120]โปรดดู คดี state v. Burgess , 553 U.S. 124 (2008)

[121]Roland V. Carmen , Criminal Procedure Law and Practice ,5 ed, (Belmont, California : Wadsworth/Thomson Learning, 2001) ,pp. 113-127.

พนักงานไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะปลอดภัยหรือไม่ ดังนั้น**ถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยมาก่อนการเรียกให้หยุดและการตรวจค้น แม้ต่อมาการตรวจค้นจะพบอาวุธก็เป็นการตรวจค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย**[122]

ขอบเขตในการถามคำถามและความจำเป็นในการดำเนินการสืบสวนต่อไปขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เจ้าพนักงานได้รับระหว่างการสอบสวน ถ้าเจ้าพนักงานตรวจค้นพบพยานหลักฐานที่มีความเป็นไปว่าอาจมีการกระทำความผิด เจ้าพนักงานอาจขยายคำถามออกไปได้ ในทางกลับกันเจ้าพนักงานจะไม่สามารถสืบสวนต่อไปได้ถ้าเจ้าพนักงานพบว่าตนได้ตีความพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยผิดไป[123]

การตรวจค้นกระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์[124]หรือสัมภาระอื่น ทำได้เพียงแต่สัมผัสภายนอกว่ามีอาวุธหรือไม่ ไม่สามารถจะเปิดกระเป๋าดูได้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะรู้สึกว่ามีอาวุธ

นอกจากนี้**การตรวจค้นตัวบุคคลโดยเจ้าพนักงานที่มีเพศเดียวกับผู้ถูกค้น** เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องเจ้าพนักงานว่ามีการทำร้ายร่างกาย หรือการกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบในทางเพศ และการตรวจค้นต้องไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุความแตกต่างทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิวด้วย[125]

2.1)การใช้กำลังเพื่อตรวจค้น

ผู้พิพากษาจะพิจารณาจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดเหตุ ลักษณะความร้ายแรงของอาชญากรรมที่ใช้เพื่อความจำเป็นในการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและเพื่อรักษาสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่ในขณะที่ทำการเรียกให้หยุด[126]

ระดับของการใช้กำลังต้องคำนึงถึงลักษณะของการกระทำความผิด และระดับการล่วงละเมิดสิทธิของผู้ต้องสงสัยต้องสมดุลกับประโยชน์ของรัฐบาล การกระทำของเจ้าหน้าที่จะสมเหตุสมผลหรือไม่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ โดยไม่คำนึงถึงความตั้งใจหรือมูลเหตุ

---

[122]คดี Illinois v. Wardlow , 528 U.S. 119 (2000).

[123]คดี State v. Garland 286, 957 P.2d 9.

[124]คดี United Stated v. CruZ , 909 F.2d 422

[125]สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 14*, น.66-67.

[126]คดี United Stated v. Hensley , 469 U.S. 221 (1985).

จูงใจ[127] ซึ่งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อาจพิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระทำความผิด ผู้ต้องสงสัยได้แสดงการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือไม่ และผู้ต้องสงสัยมีความกระตือรือร้นพยายามที่จะหลบหนีจากการเรียกให้หยุดหรือไม่

ในการวินิจฉัยว่าเป็นการใช้กำลังที่มีเหตุสมควรหรือไม่ ศาลจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ประกอบ[128]

1. จำนวนเจ้าพนักงานและรถของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประเภทของอาชญากรรมและมีเหตุเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยมีอาวุธหรือไม่
3. ความหนักแน่นของข้อเท็จจริง และข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ในสถานการณ์นั้นๆ
4. ความจำเป็นในการปฏิบัติการในทันทีของเจ้าหน้าที่
5. ความมีอยู่หรือความไม่มีอยู่ของพฤติกรรมที่ต้องสงสัย หรือการเคลื่อนไหวของบุคคลภายใต้สถานการณ์นั้นๆ
6. เจ้าหน้าที่มีโอกาสที่จะทำการเรียกให้หยุดในสถานการณ์ที่มีความอันตรายน้อยที่สุดหรือไม่

การใช้กำลังโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่มีแม้แต่ความสงสัยว่าทรัพย์สินนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน Fourth Amendment[129]

2.2)<u>การใช้สุนัขดมกลิ่น</u> (canine sniff)

การใช้สุนัขตำรวจในการหายาเสพย์ติด เป็นวิธีการสอบสวนที่ล่วงละเมิดน้อยที่สุด เพราะสุนัขตำรวจไม่ได้เปิดสัมภาระของผู้ต้องสงสัย[130] แต่การรอเพื่อนำสุนัขมาถึงอาจเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบตาม Fourth Amendment[131] เพราะไม่เป็นการสอบสวนในระยะเวลาสั้น

ในกรณีที่ใช้สุนัขตำรวจในการตรวจสอบพัสดุเกรดเอที่ไปรษณีย์ การใช้สุนัขตำรวจเพื่อหายาเสพย์ติด ไม่ถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิที่ไม่มีเหตุสมควร เป็นวิธีการสืบสวนที่ทำได้[132] แต่ทำได้ในที่สาธารณสถานเท่านั้น เพราะในที่รโหฐานมีการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่เข้มงวด[133]

---

[127]John N. Ferdico,*supra note20*, p.284.

[128]คดี United Stated v. Seelye , 815 F.2d 48, 50 (8th Cir.1987)

[129]John N. Ferdico,*supra note20*,p.308.

[130]คดี United stated v. Hardy, 451 F.2d 905

[131]John N. Ferdico,*supra note20*,p.283.

[132]คดี State v. Phaneuf , 597 A.2d 55 (Me.1991)

3.3.2.2 อังกฤษ

1) หลักการ[134]

1.1) การใช้อำนาจในการเรียกให้หยุดและการตรวจค้นต้องกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยให้ความเคารพต่อผู้ที่ถูกตรวจค้นและไม่เลือกประติบัติ ทั้งนี้เพราะ The Race Relations (Amendment) Act 2000 ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากตำรวจใช้อำนาจในการตรวจค้นตัวบุคคลโดยเลือกปฏิบัติเพราะเหตุเชื้อชาติ สีผิว กำเนิดของชนเผ่า สัญชาติ

1.2) การค้นตัวบุคคลจะต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและรบกวนเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด

1.3) ตำรวจต้องไม่ดำเนินการค้นหากไม่มีเหตุที่จะค้นได้ตาม PACE แม้ว่าผู้ที่ถูกค้นจะยินยอมให้ตรวจค้นก็ตาม นอกจากมีเหตุพิเศษ เช่น การค้นตัวบุคคลที่จะเข้าชมในการแข่งกีฬา หรือในเคหสถานของผู้อื่นโดยความยินยอมของผู้นั้น

1.4)การใช้กำลังใช้ต่อเมื่อผู้กระทำไม่ประสงค์ให้ความร่วมมือและขัดขืนการเข้าตรวจค้น และต้องกระทำเป็นมาตรการสุดท้ายในกรณีที่จำเป็นเพื่อตรวจค้นหรือควบคุมตัวบุคคลหรือหยุดยานพาหนะเพื่อตรวจค้น

2) กระบวนการตรวจค้นตัว[135]

2.1)ในกฎหมายประเทศอังกฤษ PACE กำหนดไว้ในมาตรา 2 ดังนี้

ตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวบุคคลหรือยานพาหนะเพื่อตรวจค้น ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในมาตรา 1 นอกจากนี้ยังมีอำนาจกระทำการอื่นๆดังนี้

(1)ตรวจค้นตัวบุคคลโดยยังไม่ต้องจับ

(2)ตรวจค้นยานพาหนะโดยยังไม่ต้องจับผู้ขับขี่ยานพาหนะ

ตำรวจอาจไม่ดำเนินการตรวจค้น หากเห็นว่าไม่จำต้องตรวจค้นหรือการตรวจค้นไม่อาจกระทำได้ (มาตรา2(1))

---

[133]คดี United States v. Thomas 757 F2d 1359(2d Cir.1985)

[134]สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่14*, น.43.

[135]*เพิ่งอ้าง*,น.44-47.

2.2)สำหรับการดำเนินการค้นของประเทศอังกฤษตามCode A PACE ข้อ 3 กำหนดรายละเอียดของการดำเนินงานไว้ดังนี้

(1) การเรียกให้หยุดและการค้นตัวบุคคลนั้นจะต้องกระทำด้วยความเคารพ และให้เกียรติแก้ผู้ที่ถูกตรวจค้น และกรณีนี้ถือเป็นผลทำให้สังคมเชื่อถือการปฏิบัติงานของตำรวจ นอกจากนี้ในการค้นที่ตำรวจดำเนินการเพราะมีเหตุอันสมควร จะก่อให้เกิดผลทำให้ประชาชนไม่มีความตื่นตระหนกในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ (ข้อ3.1)

(2) ในการตรวจค้นทุกครั้งจะต้องอธิบายผู้ที่ถูกค้นให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการค้น การใช้กำลังเพื่อค้นตัวบุคคลจะต้องใช้ต่อเมื่อผู้ที่ถูกค้นตัวไม่ประสงค์จะให้ความร่วมมือและต้องการขัดขืนการเข้าตรวจค้นและการใช้กำลังเพื่อตรวจค้นดังกล่าวจะต้องกระทำเป็นมาตรการสุดท้ายในกรณีที่จำเป็นเพื่อค้นหรือคุมตัวบุคคลหรือหยุดยาพาหนะเพื่อตรวจค้น (ข้อ3.2)

ระยะเวลาในการตรวจค้นตัวบุคคลและยานพาหนะ ต้องใช้เท่าที่จำเป็นและใช้เวลาน้อยที่สุด

สถานที่จะตรวจค้น ต้องตรวจค้น ณ ที่นั้นหรือใกล้กับสถานที่ที่บุคคลหรือยานพาหนะถูกสั่งให้หยุดหรือสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ดังกล่าว

ขอบเขตของการตรวจค้น ตำรวจไม่มีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกค้นถอดเสื้อผ้าเพื่อการตรวจค้น ยกเว้นการถอดเสื้อชั้นนอกเท่านั้น (outer coat)เสื้อแจ็คเกตหรือถุงมือ(ข้อ3.5) เว้นแต่จะเป็นการตรวจค้นตามพระราชบัญญัติก่อการร้าย ค.ศ. 2000(ให้เอาสิ่งที่ปกคลุมบนหัวและรองเท้าออก) และมาตรา มาตรา 60AA ของ Criminal Justice and Public Order Act 1994 (ให้ถอดวัตถุใดก็ได้ที่ปกปิดเพื่อไม่บ่งบอกรูปพรรณ)

(3)ในกรณีที่มีเหตุอันควรที่มีความจำเป็นจะต้องตรวจค้นอย่างละเอียดโดยต้องให้ถอดเสื้อเชิ้ต การค้นตัวต้องทำในที่ลับที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ เช่น ในรถของตำรวจหรือสถานีตำรวจในถิ่นแถวใกล้เคียงและการตรวจค้นดังกล่าว ต้องทำโดยเจ้าพนักงานที่เพศเดียวกับผู้ที่ถูกตรวจค้นเท่านั้นเว้นแต่ผู้ที่ถูกค้นจะร้องขอเป็นพิเศษ (ข้อ3.6)

(4) การค้นโดยนำส่วนประกอบของร่างกายของผู้ถูกค้นจะกระทำมิได้โดยอาศัยอำนาจของการตรวจค้นมาตรานี้ แต่ถ้าจะต้องดำเนินการจะต้องกระทำในที่ลับและไม่ใช่ในรถของตำรวจและต้องปฏิบัติตามหลักการในCode C ของPACE

(5) ในกรณีที่บุคคลที่จะถูกตรวจค้นตัวอยู่ในที่สวนหรือสนามซึ่งใช้ในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือในที่ดินซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตำรวจจะทำการตรวจค้นไม่ได้ เว้นแต่

1) บุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในที่พัก

2) บุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของที่พักสงวนไว้ในการใช้ที่ต้องขออนุญาตในการเข้าพัก

(6) ในกรณีที่ตำรวจจะตรวจค้นตัวบุคคลในยานพาหนะซึ่งจอดในสวนหรือสนามซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ดินซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตำรวจจะทำการตรวจค้นไม่ได้ เว้นแต่

1) บุคคลนั้นมิได้อยู่ในที่พัก

2) ยานพาหนะนั้นมิได้อยู่ในสถานที่ซึ่งจะต้องขออนุญาตเพื่อการเข้าพักมาตรา 1(5)

(7) ในการตรวจค้นตัวเพื่อหาของที่กำหนด ตำรวจมีอำนาจดำเนินการดังนี้

1) มีอำนาจตรวจค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะ

2) เป็นสิ่งของที่อยู่ในตัวบุคคลหรือยานพาหนะ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้น มาตรา 1(2)

3.3.2.3. **นิวซีแลนด์**

1) Arm Act 1983

(1)ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลที่อยู่ในที่สาธารณะถือหรือครอบครองอาวุธกรณีทั่วไป ตำรวจสามารถตรวจค้นตัวบุคคล สิ่งของ ยานพาหนะ พัสดุหรือสิ่งใดที่อยู่ในความครอบครองรวมถึงอาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ เพื่อทำการตรวจค้นตัว ควบคุมบุคคล และยึดอาวุธที่ได้จากการตรวจค้น[136]

(2)ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยในการตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยและยึดอาวุธปืนกรณีความรุนแรงในครอบครัว

(2.1) ตำรวจสามารถเข้าไปในสถานที่และตรวจค้นตัวบุคคลหรือตรวจค้นสถานที่

(2.2) ควบคุมตัวบุคคลเพื่อตรวจค้นหาอาวุธ

(2.3) ยึดอาวุธปืนขนาดเล็ก ปืนอัดลม ปืนพก เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน

---

[136] Arm Act 1983 section 60

เจ้าพนักงานใช้กำลังตามสมควรในการเข้าไปในยานพาหนะ หรือแกะสิ่งของหรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้อง หรือใช้กำลังในการควบคุมตัวบุคคลและยึดวัตถุอันตราย ถ้าจำเป็นสามารถหยุดยานพาหนะและตรวจค้นตัวบุคลที่อยู่ในยานพาหนะได้[137]

2) Aviation Crimes Act 1972

1)กรณีเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยทางการบิน เจ้าพนักงานศุลกากร

1.1)กรณีไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย และได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารให้ทำการตรวจค้นได้[138] ตำรวจ เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยทางการบิน เจ้าพนักงานศุลกากร ตรวจค้นตัวบุคคลหรือสัมภาระของบุคคลเพื่อสอบสวนว่าวัตถุหรือสารเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของยานบินก่อนที่ผู้โดยสารขึ้นยานบินในนิวซีแลนด์

1.1.1) กรณีที่เจ้าพนักงานหรือพนักงานของผู้ขนส่ง เป็นผู้ทำการตรวจค้น สั่งให้ผู้โดยสารถอดได้เพียงเสื้อโค้ช

1.1.2) กรณีที่ตำรวจ เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยทางการบิน เจ้าพนักงานศุลกากร เป็นผู้ทำการตรวจค้น สามารถเรียกให้ผู้โดยสาร

(1)ถอด ถลก ดึงลง เปิดเสื้อด้านนอกรวมถึงเสื้อโค้ช เสื้อชั้นนอก เสื้อถักไหมพรมเสื้อขนสัตว์ หรือสิ่งคล้ายกันที่ผู้โดยสารสวมใส่อยู่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจค้น ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีเสื้อชั้นนอก หรือมีแต่เสื้อข้างใน(underclothing)

(2) ถอดสิ่งคลุมเท้า (รวมถึงถุงเท้า , ถุงน่อง) สิ่งคลุมหัว เข็มขัด เครื่องประดับ หรือเครื่องประดับอื่นๆออก

(3) ตำรวจ เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยทางการบิน เจ้าพนักงานศุลกากร หรือพนักงานหรือตัวแทนโดยได้รับอำนาจจากผู้ขนส่ง แตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธที่ซุกซ่อนในร่างกาย (pat down) เพื่อตรวจค้น

ถ้าผู้ถูกตรวจค้นเป็นผู้หญิง ต้องให้ผู้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น เว้นแต่ว่าการตรวจค้นทำด้วยอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน

---

[137] Arm Act 1983 section 60(2)

[138] Aviation Crimes Act 1972 section 12

เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยทางการบิน เจ้าพนักงานศุลกากร หรือพนักงานหรือตัวแทนโดยได้รับอำนาจจากผู้ขนส่ง สามารถตรวจสินค้าก่อนที่สินค้านั้นจะถูกโหลดขึ้นเครื่องบิน ในนิวซีแลนด์

ตำรวจ เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยทางการบิน เจ้าหน้าที่ศุลกากร อาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้การตรวจค้นสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงสุนัข สารเคมี การเอ็กซเรย์ เครื่องมือถ่ายภาพ เครื่องมือไฟฟ้า แต่ไม่สามารถใช้เครื่องมือเพื่อให้ปรากฏภาพเรือนร่างที่ไม่ใส่เสื้อผ้าได้

เพื่อวัตถุประสงค์การแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธที่ซุกซ่อนในร่างกาย (pat down) หมายถึง

(1) การตรวจค้นเสื้อชั้นนอกของบุคคลนั้นระหว่างการตรวจค้นอาจตรวจค้นทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้

(1.1)การตบหรือเลื่อนมือบนร่างกายของบุคคลที่ถูกตรวจค้นไม่ว่าจะทำด้านในหรือด้านนอกเสื้อ ที่ไม่ใช่ใต้เสื้อโค้ช

(1.2)สอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ (ที่ไม่ใช่ใต้เสื้อด้านใน)

(1.3)ในการตรวจค้นโดยใช้สายตา กำหนดให้ผู้ที่ถูกตรวจค้นต้องทำทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้

(1.3.1)อ้าปาก

(1.3.2)แสดงฝ่ามือ

(1.3.3)แสดงฝ่าเท้า

(1.3.4)ยกหรือลูบผม

(2) รวมทั้งอำนาจในการตรวจค้น

(2.1)วัตถุหรือสารใดๆที่นำเข้ามาหรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้น

(2.2) ให้ถอด ถลก ดึงลง หรือเปิดเสื้อชั้นนอก

(2.3)ให้เอาสิ่งคลุมหัว ถุงมือ สิ่งคลุมเท้า(รวมถุงเท้า ถุงเท้ายาว) ออก

1.2 กรณีไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย และผู้โดยสารไม่ยินยอมให้ตรวจค้น

ผู้ขนส่งปฏิเสธที่จะให้ผู้นั้นหรือสัมภาระของพวกเขาขึ้นเครื่องได้ เมื่อตำรวจมีเหตุเชื่อว่า การกระทำความผิดจะเกิดหรือกำลังเกิดที่เกี่ยวข้องกับยานบิน โดยบุคคลนั้นหรือบุคคลใดๆ โดยไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย[139]

ตำรวจสามารถตรวจค้นตัวบุคคลหรือสัมภาระโดยไม่ต้องมีหมาย และสามารถควบคุมบุคคลนั้น และอาจครอบครองอาวุธหรือวัตถุที่เป็นอันตรายหรือร้ายแรง หรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกับกระสุนดินปืน หรือสารระเบิด หรือวัตถุหรือสารอื่นๆที่ใช้ทำอันตรายความปลอดภัยของยานบินหรือบุคคลที่อยู่บนยานบิน หรือสิ่งเทียมวัตถุหรือสารที่กล่าวไปข้างต้น[140]ที่พบในระหว่างทำการตรวจค้น

การที่บุคคลปฏิเสธไม่ยอมให้ตรวจค้นตัวหรือสัมภาระแต่เพียงอย่าง*เดียว*ไม่ก่อให้เกิดมูลเหตุในการสงสัยว่าการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้กำลังเกิด หรือจะเกิด

เมื่อมีความจำเป็น ตำรวจอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อช่วยในการตรวจค้น ซึ่งรวมถึงสุนัข สารเคมี การเอ็กซเรย์ หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องมืออื่นๆ

2.กรณีที่ผู้บังคับบัญชาการบิน (aircraft commander) เป็นผู้ใช้อำนาจ สามารถมอบอำนาจให้ ลูกเรือที่ทำงานบนเรื่องบิน (crew of the aircraft) หรือใครก็ตามที่ทำงานบนเครื่องบินที่ผู้บังคับบัญชาการบินมอบอำนาจ ตรวจค้นตัวบุคคล หรือตรวจค้นสัมภาระ หรือยึดพัสดุใดที่พบว่าถูกใช้หรือสามารถถูกใช้กระทำความผิดที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัตินี้[141]

3) Crimes Act 1961[142]

1)กรณีครอบครองอาวุธอันตรายหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ทำให้ไม่รู้สึกตัว

(1) ตำรวจอาจเรียกให้หยุดและตรวจค้นตัวบุคคลนั้น และสิ่งของหรือสัมภาระใดๆที่เขานำติดตัวมาด้วย และอาจควบคุมตัวผู้นั้นตราบเท่าที่มีเหตุจำเป็นในการตรวจค้น

---

[139] Aviation Crimes Act 1972 section 12(2) , 13

[140] Aviation Crimes Act 1972 section 11 (1)

[141] Aviation Crimes Act 1972 section 17

[142] Crimes Act 1961 section 202B

(2)ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่ายานพาหนะนั้นจะมีมีดหรืออาวุธที่กระทำความผิดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททำให้ผู้เสพไม่รู้สึกตัวอยู่ เจ้าพนักงานมีอำนาจเรียกให้หยุดและตรวจค้นยานพาหนะที่บุคคลนั้นใช้เดินทางและควบคุมตัวผู้นั้นตราบเท่าที่เหตุจำเป็นเพื่อการตรวจค้น และในกรณีเช่นนี้ตำรวจสามารถยึดมีดหรืออาวุธที่กระทำความผิดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ทำให้ไม่รู้สึกตัวที่พบในขณะทำการตรวจค้นไปได้

2) กรณีขโมยสินค้าที่อยู่ระหว่างการเดินทาง (in transit)[143]

เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจค้น ตู้คอนเทนเนอร์ ภาชนะ เครื่องบิน เรือ เรือเฟอรี่ รถไฟ ยานพาหนะและควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีหมายค้น การตรวจค้นจำกัดเฉพาะสินค้าที่อยู่ระหว่างการเดินทางที่ถูกบรรจุอยู่และเพื่อพบวัตถุที่ถูกลักเท่านั้น หรือใช้กับผู้กระทำความผิดที่กระทำความผิดคล้ายกันหรือที่เป็นภัยต่อสาธารณะ[144]

เจ้าพนักงานมีอำนาจเรียกให้ยานพาหนะหยุดและหากพบของที่ลักขโมยมาหรือของที่ผิดกฎหมายในระหว่างการตรวจค้นสามารถยึดได้ ถ้าจำเป็นมีอำนาจตรวจค้นตัวบุคคลที่อยู่ในยานพาหนะได้

การใช้กำลังในกรณีจำเป็นเพื่อพังตู้คอนเทนเนอร์ หีบห่อ ภาชนะหรือเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบิน เรือ รถไฟหรือยานพาหนะ

4) Customs and Excise Act 1996

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การใช้อุปกรณ์ช่วยในการตรวจค้นตัวเบื้องต้นและการตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง

(1)การใช้อุปกรณ์ช่วยในการตรวจค้นตัวเบื้องต้น

หมายถึง การสัมผัสทางกายเพียงเล็กน้อยหรือการไม่สัมผัสเลยระหว่างผู้ตรวจค้นและผู้ถูกตรวจค้น หรือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการตรวจ เช่น สุนัข สารเคมี การเอ็กซเรย์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์เมคคานิคอื่นๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยต้องไม่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางร่างกายมากกว่าที่กล่าวไป[145]

---

[143] Crimes Act 1961 section 224

[144] New Zealand Law Commission, *supra note 3*, p.247.

[145] Customs and Excise Act 1996 section 149A

หลังจากตรวจค้นตัวบุคคลเบื้องต้นแล้วเจ้าพนักงานศุลกากรหรือตำรวจมี**เหตุอันควรสงสัย**ว่าบุคคลซ่อน (ก) สินค้าที่มิได้เสียภาษี ของต้องห้าม ของต้องกำกัด สินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านด่านศุลกากร หรือ (ข) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าต่างๆดังกล่าว หรือ (ค) สิ่งของใดๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นพยานหลักฐานของการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้วิธีการตรวจค้นตามการตรวจค้นตัวบุคคลเฉพาะเรื่อง[146]

(2)การตรวจค้นตัวบุคคลเฉพาะเรื่อง

(2.1)ตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาวัตถุที่ถูกซ่อน[147]

กรณีที่จำเป็นอาจใช้กำลังได้ตามสมควรในการควบคุมและหรือตรวจค้นตัวบุคคล และถ้าจำเป็นสามารถให้บุคคลอื่นช่วยทำการตรวจค้นได้

สามารถไปทำการตรวจค้นที่อื่นได้ถ้าบริเวณที่ถูกตรวจค้นไม่เหมาะสมที่จะตรวจค้นในขณะนั้น

(2.2) ตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาวัตถุอันตราย[148]

การใช้กำลังอาจทำได้ในกรณีที่จำเป็นในการควบคุมตัว ในการตรวจค้นตัวบุคคลสามารถตรวจค้นตัวบุคคลตามมาตรานี้ได้โดยไม่ต้องเกิดจากกรณีใช้อุปกรณ์ช่วยในการตรวจค้นตัวเบื้องต้นหรือการตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาวัตถุที่ถูกซ่อน

การตรวจค้นตามพระราชบัญญัตินี้ ใช้กับบุคคลที่อยู่ในด่านตรวจคนเข้าเมือง พื้นที่ควบคุมศุลกากรเท่านั้น[149] และเฉพาะการตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาวัตถุที่ถูกซ่อนขยายไปถึงการค้นตัวบุคคลที่อยู่ในที่สาธารณะสถานในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าสิ่งของถูกซ่อนในตัวบุคคล แต่จำกัดเฉพาะบุคคลที่เข้ามาในนิวซีแลนด์ไม่เกิน 24 ชั่วโมงในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่เขตศุลกากร หรือกำลังจะออกไปจากนิวซีแลนด์ที่ไม่ใช่เขตศุลกากรไปยังสถานที่อื่น[150]

5) Misuse of Drugs Act 1975[151]

---

[146] Customs and Excise Act 1996 section 149A

[147] Customs and Excise Act 1996 section 149B

[148] Customs and Excise Act 1996 section 149 BA

[149] New Zealand Law Commission,*supra note 3*, p.245.

[150] *Ibid, p245.*

[151] Misuse of Drugs Act 1975 section 18

ควบคุมตัวบุคคลและตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อยึดยาเสพย์ติดและสารที่ใช้ผลิตยาเสพย์ติด ในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้ตรวจค้นตัวบุคคลได้ ตำรวจอาจหยุดยานพาหนะเพื่อทำการตรวจค้นตัวบุคคลที่อยู่ในยานพาหนะและยานพาหนะนั้นได้

6) Misuse of Drugs Act 1978[152]

ตรวจค้นตัวและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการขนส่งยาเสพย์ติด ยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติดหรือสารที่ใช้ผลิตยาเสพย์ติด(precursor substance) หรือพัสดุที่เจ้าพนักงานศุลกากรได้แทนที่ด้วยยาเสพย์ติดหรือสารที่ใช้ผลิตยาเสพย์ติดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือพยานหลักฐานที่ commission of an offence ตามกฎหมาย Principal Act มาตรา 6(1)A หรือ มาตรา12AB

ในกรณีจำเป็นอาจใช้กำลังได้ตามสมควรในการตรวจค้นตัวบุคคล ควบคุมตัวบุคคลหรือยึดสิ่งของดังกล่าว

3.3.2.4 ฝรั่งเศส

หลักการ เนื่องจากการค้นตัวบุคคลเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสได้กำหนดไว้ในภาคทั่วไปว่าเจ้าพนักงานต้องใช้อำนาจโดยคำนึงถึงหลักความจำเป็นและหลักการได้สัดส่วนตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ การใช้อำนาจต้องได้สัดส่วนกับความรุนแรงของความผิด และไม่กระทบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์[153]

1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส

ในความผิดซึ่งหน้า ตำรวจสามารถค้นยานพาหนะที่จอดหรือแล่นอยู่โดยไม่ต้องมีหมาย เว้นแต่เป็นสำนักงานทนายความ คลินิก ที่ทำการสื่อมวลชน ต้องให้อัยการจังหวัดหรือตัวแทนของอัยการจังหวัดเป็นผู้ทำการค้น[154]

กรณีมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ต้องขอความยินยอมจากผู้ตรวจค้น ตำรวจจะทำการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน ถ้าผู้นั้นไม่ให้ความยินยอมเจ้าพนักงานต้องขอหมายจากศาล

2) ประมวลกฎหมายศุลกากรฝรั่งเศส

---

[152] Misuse of Drugs Act 1978 section 12A

[153] Serge Guinchard,Jacques Buisson,*supra note 11*,p.512.

[154] *Ibid*,p. 512.

ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจค้นพัสดุสินค้า ยานพาหนะ และตรวจค้นตัวบุคคล[155]

3) ประมวลกฎหมายการเดินอากาศ

ตรวจค้นตัวบุคคลได้ทุกกรณี รวมถึงสัมภาระ ไปรษณีย์ พัสดุ เครื่องบิน ยานพาหนะที่อยู่ในบริเวณสนามบิน และให้ทำการตรวจค้นตัวบุคคลโดยเพศเดียวกัน[156]

4)คำพิพากษาของศาล

ตรวจค้นตัวบุคคลภายนอกตามเสื้อผ้าเพื่อตรวจดูอาวุธและวัตถุอันตรายและต้องทำในที่ที่เกิดเหตุอันควรสงสัย[157] และเมื่อพบของผิดกฎหมายสามารถยึดได้แต่อยู่ภายใต้หลักความจำเป็นและหลักการได้สัดส่วน[158]

โดยสรุป ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักการทั่วไป คือ ห้ามเลือกปฏิบัติในการตรวจค้นตัวบุคคลเพราะพิจารณาว่าผู้ถูกตรวจค้นยังไม่ได้เป็นผู้ถูกจับ กล่าวคือ ผู้ถูกค้นยังไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด แม้กระทั่งผู้ต้องหายังถูกสันนิษฐานไว้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่ศาลจะพิพากษา ผู้ถูกตรวจค้นยิ่งต้องได้รับการปฏิบัติที่ไม่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากไปกว่าผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

การสุ่มตรวจจึงทำไม่ได้เพราะการตรวจค้นตัวต้องเกิดจากความสงสัยในตัวผู้ต้องสงสัยเป็นรายบุคคลที่เกิดในขณะนั้น ถ้าเป็นผู้หญิงให้ตำรวจหญิงเป็นผู้ทำการตรวจค้น ถ้ามีความจำเป็นสามารถใช้กำลังได้ตามสมควรกับพฤติการณ์

ขอบเขต การแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธ (pat down) บนตัวของผู้ถูกตรวจค้น แต่ไม่สามารถล้วงเข้าในกระเป๋าเสื้อและกางเกง เว้นแต่เมื่อpat down ไปแล้วจะรู้สึกว่ามีอาวุธ จึงจะสามารถล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อและกางเกงเพื่อยึดอาวุธนั้นได้ นอกจากนี้เจ้าพนักงานสามารถ pat down ไปถึงกระเป๋าถือ หรือสัมภาระหรือวัตถุที่อยู่ในความครองครองของบุคคลนั้น และหมายรวมถึงการตรวจค้นยานพาหนะของบุคคลนั้น

---

[155] ประมวลกฎหมายศุลกากรฝรั่งเศส มาตรา 60

[156] ประมวลกฎหมายการเดินอากาศ มาตรา 282-8

[157] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 14*, น.28.

[158] Serge Guinchard,Jacques Buisson,*supra note 11,p*.515.

อาวุธที่พบระหว่างตรวจค้นเจ้าพนักงานทำการยึดได้ และยังขยายไปถึงวัตถุผิดกฎหมายอื่น เช่น ยาเสพย์ติด หรือ ทรัพย์ที่ลักมาแต่ต้องพบในระหว่างการตรวจค้นตัวเพื่อหาอาวุธเท่านั้น

ในแง่เวลา ไม่ได้กำหนดแน่นอนขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของแต่ละกรณี แต่การตรวจค้นทำได้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อหาอาวุธ

ในแง่สถานที่ ต้องตรวจค้นตัวบุคคลนั้นในที่ที่ทำการหยุด(on spot) หรือใกล้กับสถานที่ที่หยุด

ประเทศอังกฤษ ให้ความสำคัญกับวิธีการตรวจค้นว่าต้องกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยให้ความเคารพต่อผู้ที่ถูกตรวจค้นและไม่เลือกปฏิบัติเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

<u>ขอบเขต</u> มีความแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ตำรวจมีอำนาจให้ถอดเสื้อได้เฉพาะเสื้อชั้นนอก (outer coat) เสื้อแจ็คเกตหรือถุงมือ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาทำได้เพียงการแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อพบอาวุธบนร่างกายของผู้ถูกตรวจค้นเท่านั้น จะเรียกให้ถอดไม่ได้ และเจ้าพนักงานสามารถตรวจค้นอย่างละเอียดได้ในกรณีที่มีเหตุอันควรจำเป็นแต่จะต้องทำในที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ จะต้องทำโดยเจ้าพนักงานที่เพศเดียวกับผู้ที่ถูกตรวจค้นเท่านั้นเว้นแต่ผู้ที่ถูกตรวจค้นร้องขอ

การตรวจค้น ยังขยายไปถึงยานพาหนะหรือสิ่งของที่อยู่ในตัวบุคคลหรือยานพาหนะเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ในแง่เวลา ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แต่ละกรณีแต่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและใช้เวลาน้อยที่สุด

ในแง่สถานที่ ต้องตรวจค้นตัวบุคคล ณ จุดที่ทำการหยุดหรือใกล้กับสถานที่ทำการหยุด

ประเทศนิวซีแลนด์ มีหลักการเช่นเดียวกับกฎหมายระบบคอมมอนลอว์จึงให้ความสำคัญกับสิทธิของบุคคลที่ถูกล่วงละเมิด

<u>ขอบเขต</u> การตรวจค้นตัวบุคคล ไม่ได้มีวิธีการที่ชัดเจน กฎหมายเพียงแต่ให้อำนาจเจ้าพนักงานการค้นตัวบุคคลได้ แต่*โดยทั่วไป*ไม่สามารถเรียกถอดเสื้อผ้าได้ แต่อาจทำได้ในบางกรณีเท่านั้น เช่น เจ้าพนักงานสงสัยว่ามียาเสพย์ติดซุกซ่อนอยู่ตามร่างกาย ฯลฯ และต้องกระทำในสถานที่ที่มิดชิดด้วย[159] มีเพียง Aviation Crimes Act 1972 ที่กำหนดขอบเขตการตรวจค้นตัว

---

[159] New Zealand Law Commission , *supra note 3*, p.263.

บุคคลว่าการตรวจค้นตัวบุคคล ให้ใช้วิธีการ pat down โดยกำหนดความหมาย pat down อย่างละเอียดซึ่งมีความหมายที่ต่างจากของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกาให้เจ้าพนักงานเพียงแต่แตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธนั้น ไม่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เอามือเข้าไปในเสื้อแม้เป็นเสื้อชั้นนอกก็ตามแต่ Aviation Crimes Act 1972 ให้ทำได้ รวมถึงให้อำนาจเจ้าพนักงานในการเรียกให้ผู้ถูกตรวจค้นอ้าปากได้ซึ่งของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษยังไม่มีแนวคำพิพากษาหรือการกำหนดให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจในลักษณะนี้ได้

การตรวจค้นตัวบุคคลนอกจากตรวจค้นบนร่างกายของบุคคลนั้นแล้ว ยังรวมถึงสัมภาระ สิ่งของ ยานพาหนะและบุคคลที่อยู่ในยานพาหนะที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้น ในกรณีพิเศษอาจใช้เครื่องมือในการตรวจตัวบุคคลเบื้องต้นได้ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า สุนัข การเอ็กซเรย์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์เมคคานิค เพราะเวลาที่จำกัดทำให้ไม่สามารถตรวจค้นบุคคลจำนวนมากได้อย่างละเอียด เมื่อตรวจเบื้องต้นแล้วสงสัยบุคคลใดเป็นพิเศษจึงดำเนินการตรวจค้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง[160]

ในแง่สถานที่ กระทำได้ในสถานที่ที่ถูกตรวจค้น รวมถึงสถานที่อื่นต่อมาแต่เจ้าพนักงานต้องติดตามบุคคลที่จะถูกตรวจค้นจากสถานที่ที่เกิดการใช้อำนาจในทันที และต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลยังมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นอยู่[161]

ประเทศฝรั่งเศส

หลักการ การค้นตัวต้องกระทำตามหลักความได้สัดส่วนและความจำเป็น

<u>ขอบเขต</u> เจ้าพนักงานสามารถตรวจค้นตัวบุคคลนั้น รวมถึงสิ่งของ สัมภาระ และถ้าอยู่บนยานพาหนะก็อาจถูกเรียกตรวจค้นยานพาหนะได้ นอกจากนี้ศาลฎีกาฝรั่งเศสจึงยอมรับการหลักการเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การตรวจค้นตัวโดยแตะต้องตัวบุคคลด้านนอก(La Palpation Sommaire)เพื่อหาอาวุธและวัตถุอันตราย

3.3.3 กระบวนการหลังทำการตรวจค้น

3.3.3.1 อังกฤษ[162]

---

[160] Customs and Excise Act 1996 Section 4

[161] New Zealand Law Commission , *supra note 3*, p.249.

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องทำบันทึกการตรวจค้นและการตรวจสอบเหตุแห่งการตรวจค้นไว้ภายหลังจากการสิ้นสุดการตรวจค้นเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยกำหนดไว้ใน PACE มาตรา 3 ดังนี้

1)การทำบันทึกต้องระบุชื่อของผู้ที่ถูกตรวจค้น(ถ้าตำรวจทราบ) แต่ถ้าไม่ทราบตำรวจไม่มีอำนาจที่จะควบคุมตัวบุคคลผู้ถูกตรวจค้นเพื่อจะทราบชื่อของผู้นั้น และในกรณีที่ไม่ทราบชื่อของผู้ถูกตรวจค้น ให้บันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวกับรูปพรรณของผู้ถูกตรวจค้นเท่าที่จะทำได้ การบันทึกการตรวจค้นยานพาหนะ ให้ระบุลักษณะของยานพาหนะนั้น

2)บันทึกการตรวจค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะ จะต้องประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

2.1) วัตถุประสงค์

2.2) เหตุแห่งการตรวจค้น

2.3) วันเวลาที่ดำเนินการตรวจค้น

2.4) สถานที่ตรวจค้น

2.5) สิ่งของที่ตรวจค้นได้

2.6) สิ่งของที่เสียหายหรือถูกทำลายหรือบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผลจากการตรวจค้น

2.7)ชื่อตำรวจที่ทำการตรวจค้น

บันทึกจะต้องมอบสำเนาการตรวจค้นให้แก่ผู้ที่ถูกตรวจค้น หรือเจ้าของยานพาหนะที่ตรวจค้น หากผู้นั้นร้องขอภายในเวลา 12 เดือนนับแต่วันค้น

3)แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน Code A ข้อ 4 ดังนี้

3.1) เจ้าหน้าที่ที่บันทึกการค้นตัวบุคคลต้องจัดทำบันทึกในเวลาที่ทำการค้น เว้นแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ในกรณีที่มีการก่อความวุ่นวาย หรือกรณีที่การค้นในกรณีฉุกเฉินและจะต้องดำเนินการภายในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือในกรณีที่ไม่อาจบันทึกได้เสร็จสิ้นเพราะขาดข้อมูลบางประการ เจ้าพนักงานต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นหลังจากได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว (ข้อ 4.1)

3.2) เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อาจทำบันทึกได้เสร็จในทันที เจ้าพนักงานผู้ค้นต้องมอบสำเนาให้แก่ผู้ถูกค้นหรือเจ้าของยานพาหนะที่ค้น และในทุกกรณีเจ้าพนักงานผู้ค้นต้องถามชื่อ ที่

---

[162] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 14*,น.47-50.

อยู่ วันเดือนปีเกิดของผู้ถูกค้น แต่บุคคลดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องตอบคำถามเหล่านี้และเจ้าพนักงานไม่มีอำนาจควบคุมตัวไว้จนกว่าจะตอบ

3.3) ในกรณีที่มีการบันทึกการตรวจค้นทางอิเลคทรอนิกส์ เจ้าพนักงานยังไม่ได้บันทึกในกระดาษ กรณีนี้เจ้าพนักงานมอบบันทึกด้วยอิเลคทรอนิกส์ได้ แต่ถ้าผู้ถูกค้นประสงค์จะได้บันทึกในกระดาษก็สามารถร้องขอได้ (ข้อ 4.2) แต่จะขอทั้งที่เป็นอิเลคทรอนิกส์และกระดาษไม่ได้

3.4) ในการบันทึกการค้น ต้องมีชื่อของตำรวจที่ทำการค้น เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายให้สามารถปกปิดได้เพราะเหตุที่เจ้าพนักงานอาจเป็นอันตรายหากเปิดเผยชื่อ และในกรณีที่ต้องแสดงบัตรประจำตัว ในบันทึกต้องบันทึกว่ามีการแสดงบัตรดังกล่าว (ข้อ 4.4)

3.5) ในกรณีที่มีการค้นตัวบุคคลหลายคนหรือมีการค้นยานพาหนะ ต้องทำบันทึกแยกแต่ละคนหรือแต่ละยานพาหนะ เว้นแต่เป็นการค้นในเหตุเดียวกัน จึงบันทึกการค้นในบันทึกเดียวกันได้ ในกรณีที่มีการค้นบุคคลหลายคนในยานพาหนะ บันทึกการค้นจะต้องแยกแต่ละคนและในการค้นยานพาหนะ จะต้องบันทึกชื่อและสัญชาติของคนขับด้วย (ข้อ 4.5)

3.6) การบันทึกจะต้องมีเหตุแห่งการค้นโดยย่อ โดยมีข้อความที่อธิบายเหตุผลในการที่เกี่ยวพันกับผู้ที่ถูกค้นตัวโดยอ้างอิงพฤติการณ์และสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.7) บันทึกต้องระบุสถานีตำรวจที่ตำรวจสังกัดอยู่ และแนบคำร้องขอค่าเสียหายหากผู้ถูกค้นได้ร้องขอ (ข้อ 4.9)

4) การตรวจสอบการค้นโดยผู้บังคับบัญชา

เพื่อให้การปฏิบัติงานของตำรวจได้รับความเชื่อถือ และโปร่งใสในการทำงาน กฎหมายอังกฤษได้กำหนดให้จัดทำรายงานการตรวจค้นในรายงานประจำปีของตำรวจทั้งการค้นตัวบุคคลและการค้นยานพาหนะ โดยมี Commissioner of the Police Metropolitan เป็นผู้ดำเนินการ และรายงานดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดเพื่อประกอบด้วย

จำนวนในการค้นแต่ละเดือน และจำนวนสิ่งของที่ตรวจค้นได้ จำนวนคนที่ถูกจับอันเนื่องมาจากการตรวจค้น และจำนวนการตรวจค้นยานพาหนะในการตรวจค้นและเหตุในการตรวจค้นยานพาหนะ และผลการตรวจค้น (PACE มาตรา 5)

สำหรับรายงานประจำปีที่กฎหมายอังกฤษกำหนดไว้นี้ เห็นได้ชัดว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เห็นถึงสถิติการดำเนินการและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการตรวจค้นว่าสามารถตรวจค้นได้โดยมีเหตุอันควรค้นหรือไม่ เพราะหากมีจำนวนสิ่งของที่ตรวจค้นหรือจำนวนคนที่ถูกจับน้อยกว่าจำนวนที่ตรวจค้นแสดงว่าการตรวจค้นของตำรวจอาจจะไม่รัดกุมในการดำเนินการเพียงพอ

นอกจากนี้ใน Code A ข้อ 5 กำหนดให้หัวหน้าตำรวจ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นมาตรการในการควบคุมการค้นของตำรวจอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะเป็นการค้นที่ไม่ต้องขอหมายค้นจากศาล จึงไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานระดับ supervising officer ต้องกับดูแลการใช้อำนาจเรียกให้หยุดและค้นตัวบุคคลว่าได้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่เพียงใด และจะต้องตรวจสอบบันทึกการค้นว่าได้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และมีเหตุในการตรวจค้นเพียงใด นอกจากนี้ยังต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่ดำเนินการทั้งในระดับท้องถิ่นหรือในระดับกลุ่มที่มีการค้นเป็นกรณีเฉพาะเพื่อให้ทราบข้อมูลในการดำเนินการทั้งหมดและเพื่อให้การดำเนินการเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนและชี้แจงสถิติการดำเนินการค้นและเหตุที่ทำการค้นในภาพรวมให้แก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นทราบด้วย (ข้อ 5.2-5.4)

3.3.3.2 นิวซีแลนด์

1) Arm Act 1983

เมื่อเจ้าพนักงานได้ทำการตรวจค้นตัวบุคคลแล้ว หลังจากการตรวจค้นภายใน 3 วัน ต้องเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ Commissioner ถึงการใช้อำนาจและสถานการณ์ที่นำไปสู่การตรวจค้นตัว[163]

2) Customs and Excise Act 1996

การตรวจค้นตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องกรณีเพื่อหาวัตถุอันตราย ภายใน 3 วันหลังจากทำการตรวจค้นต้องเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสถานการณ์การตรวจค้น และมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุอันควรเชื่อในการตรวจค้นต่อ Chief Executive ในกรณีที่เป็นเจ้าพนักงานศุลกากรเป็นผู้ทำการตรวจ หรือต่อ Commissioner of Police ในกรณีที่เป็นตำรวจ[164]

3 Misuse of Drugs Act 1975

---

[163] Arm Act 1983 section 60(4)

[164] Customs and Excise Act 1996 section 149BA

ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์ไปยัง Commissioner of police เกี่ยวกับการใช้อำนาจและสถานการณ์ที่เป็นที่มาแห่งการใช้อำนาจ ภายใน 3 วันหลังจากทำการตรวจค้นตัวบุคคล[165]

4) Misuse of Drugs Act 1978

ภายใน 3 วันหลังจากทำการตรวจค้น ต้องทำรายงานการตรวจค้นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสถานการณ์การตรวจค้นได้และมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุอันควรเชื่อในการค้นต่อ Commissioner of Police กรณีตำรวจผู้ทำการตรวจค้น และ Chief Executive of the New Zealand Customs Service ถ้าเจ้าพนักงานศุลกากรเป็นผู้ทำการตรวจค้น[166]

โดยสรุป ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่มีกระบวนการหลังค้นสมบูรณ์กว่าทุกประเทศโดยมีการกำหนดให้เจ้าพนักงานต้องมอบสำเนาการตรวจค้นแก่ผู้ถูกตรวจค้น ในบันทึกจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ทำการค้น ผู้ถูกตรวจค้น พยานหลักฐานที่พบระหว่างการตรวจค้น เหตุแห่งการใช้อำนาจ นอกจากนี้ยังมีการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดทำเป็นสถิติการใช้อำนาจและรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจค้น ทำให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานได้โดยตรงเพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการการตรวจค้นทำให้ประชาชนได้รับการล่วงละเมิดน้อยที่สุด

ขณะที่ประเทศนิวซีแลนด์ กฎหมายพิเศษบางฉบับกำหนดให้เจ้าพนักงานผู้ใช้อำนาจจัดทำบันทึกการตรวจค้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีการสำเนาแก่ผู้ที่ถูกตรวจค้น ขณะที่**ประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส** ไม่มีกระบวนการหลังตรวจค้นใดๆเนื่องจากผู้ต้องสงสัยยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ถูกจับ

3.4 ผลของการตรวจค้นโดยไม่ชอบกฎหมาย

3.4.1 ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานในชั้นพิจารณา

---

[165] Misuse of Drugs Act 1975 section 18(6)

[166] Misuse of Drugs Act 1978 section 12A

3.4.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า Fourth Amendment มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานในกรณีต่างๆและเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อแนวคิดการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมาตรา 4 บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีความปลอดภัยมั่นคงในร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และวัตถุสิ่งของ ต่อการค้น การยึด การจับที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกล่วงละเมิดมิได้ และห้ามมิให้มีการออกหมาย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรซึ่งได้มาโดยการสาบาน หรือปฏิญาณตนและหมายนั้นจะต้องระบุเฉพาะเจาะจงถึงสถานที่ซึ่งจะถูกค้น ตัวบุคคลที่จะถูกจับและสิ่งของที่จะถูกยึด”

ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยในคดี Weeks v. United State ว่าพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นที่มิชอบด้วยมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ จะใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีมิได้ โดยศาลอ้างว่าถ้ายอมให้รับฟังได้บทบัญญัติมาตรา 4 ที่ห้ามการค้นการยึดโดยไม่มีเหตุอันควรจะไร้ผล หลักการไม่ยอมรับฟังพยานวัตถุหรือพยานเอกสารที่ได้มาโดยวิธีการจับ ค้น ยึดอันมิชอบจึงเริ่มเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยศาลฎีกาเป็นผู้นำมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 เป็นต้นมา[167] แต่ใช้เฉพาะคดีที่ขึ้นสู่ศาลสหรัฐเท่านั้น ส่วนมลรัฐมีสิทธิที่จะเลือกยึดถือตามหลักคอมมอนลอว์เดิมคือ ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เสมอโดยไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการได้มา

ต่อมาในคดี Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961)ได้วางหลักการสำคัญและมีผลบังคับจนถึงทุกวันนี้คือศาลได้ตีความขยายว่า หลัก Exclusionary Rule ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (Fourth Amendment)[168] จึงห้ามศาลมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ การค้น การยึดโดยมิชอบโดยเด็ดขาดไม่ว่าศาลสหรัฐหรือศาลมลรัฐก็ตาม

---

[167] เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,“ หลักการไม่ยอมรับฟังพยานวัตถุ พยานเอกสาร ซึ่งได้มาโดยการจับ การค้น การยึด ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในสหรัฐอเมริกา,”วารสารนิติศาสตร์,เล่ม3,ปีที่ 9,น.122(2520-2521).

[168] จิรนิติ หะวานนท์ , “หลักการไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ : เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอเมริกันและกฎหมายเยอรมัน,” ดุลพาห,เล่ม3,ปีที่ 31,น.37 (พฤษภาคม-มิถุนายน2527).

ด้วยเหตุนี้ หลักการไม่รับฟังพยานดังกล่าวจึงเริ่มใช้ทั่วทุกแห่งในตั้งแต่ปีค.ศ.1961 เรื่อยมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้[169]

หลัก Exclusionary Rule เน้นเรื่องการได้พยานหลักฐานมาด้วยวิธีการอันมิชอบเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับรองในรัฐธรรมนูญ เป็นหลักที่ศาลสร้างขึ้นโดยศาลปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาที่ฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญ[170] นอกจากพยานหลักฐานที่เกิดจากการตรวจค้นที่มิชอบจึงรับฟังไม่ได้[171]แล้วยังขยายไปถึงพยานหลักฐานอื่นที่ *เกี่ยวเนื่อง* มาจากพยานหลักฐานที่ได้มาจากการตรวจค้นมิชอบก็รับฟังไม่ได้เช่นเดียวกัน หลักการนี้เรียกว่า “ Fruit of the Poisonous Tree ”[172] เพื่อมุ่งหวังที่จะยับยั้งไม่ให้เจ้าพนักงานกระทำการโดยไม่ชอบ เพราะถ้าเจ้าพนักงานตระหนักดีว่า การกระทำที่มิชอบของตนจะมีผลทำให้พยานหลักฐานทุกชิ้นที่ได้มารับฟังไม่ได้หมดแล้ว เจ้าพนักงานอาจไม่กระทำการเช่นนั้นอีก[173]

(1)ตัวอย่างคำพิพากษาที่วินิจฉัยว่าไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐาน

คดีนี้มีข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานตำรวจได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ดูแลความเรียบร้อยในสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีวัยรุ่นตั้งกลุ่มทะเลาะวิวาทไล่ยิงกันเป็นประจำ ขณะที่รถของตำรวจขับไปในสถานที่นั้นในคืนวันหนึ่งเวลาประมาณสองทุ่ม เจ้าพนักงานตำรวจพบชายวัยรุ่นสามคนจึงหยุดรถและเดินเข้าไปหาชายทั้งสาม ชายคนหนึ่งเมื่อเห็นเจ้าพนักงานเดินเข้ามาจึงผละออกไปจากชายอีกสองคนดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจจึงเรียกจำเลยซึ่งอยู่ในกลุ่มนั้นให้มาหา เมื่อจำเลยเดินเข้ามาใกล้ตำรวจจึงคลำที่เสื้อโค้ชและบริเวณเข็มขัดพบวัตถุชิ้นหนึ่งยื่นออกมา ต่อมาพบว่าวัตถุชิ้นนั้นเป็นปืนเถื่อน ศาลพิพากษาว่าการค้นตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลไม่ยอมรับฟังอาวุธปืนของกลางเป็นพยานหลักฐานโดยศาลให้ความเห็นว่า ในขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจทำการตรวจค้นจำเลยนั้น เจ้าพนักงานไม่ทราบมาก่อนว่าจำเลยกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าสงสัยว่าจำเลยมีอาวุธติดตัว ทั้งตำรวจก็ไม่ทราบมาก่อนด้วยว่า จำเลยและพรรค

---

[169] เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่167*,น.123.

[170]มโน ซอศรีสาคร, “การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ ตรวจค้น ยึด โดยมิชอบ ศึกษาเฉพาะกรณีพยานวัตถุหรือพยานเอกสาร,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2539), น. 29.

[171]คดี Week v. United Stated , 232 U.S.383 (1914)

[172]คดี Siverthorne Lumber Co. V. United State ,252 U.S.385(1920)

[173]คดี Nardone v. United State 308 U.S. 341(1040)

พวกของจำเลยอีกสองคนเป็นสมาชิกลุ่มอันธพาลหรือเกี่ยวพันในการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มอันธพาลโดยขณะที่จำเลยถูกเรียกให้เข้ามาหา และขณะที่ถูกค้นตัวจำเลยไม่ได้แสดงอากัปกิริยาอย่างใด อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานได้ว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ในขณะนั้น การที่จำเลยไม่เชื่อฟังเจ้าพนักงานตำรวจและไม่ได้เข้าไปในทันทีที่ถูกเรียกไม่เพียงพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจในการค้นตัวจำเลยเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานใดๆจากร่างกายจำเลยได้[174]

3.4.1.2 ประเทศอังกฤษ

แม้ประเทศอังกฤษจะใช้กฎหมายระบบแบบคอมมอนลอว์เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาแต่หลักในการรับฟังพยานหลักฐานนั้นศาลอังกฤษมีดุลยพินิจ(discretion)ในการรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานใดๆมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและในการใช้ดุลยพินิจของศาลที่จะไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น ศาลจะใช้ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการไม่ยุติธรรมเท่านั้น ซึ่งในการใช้ดุลยพินิจการไม่รับฟังเป็นไปอย่างจำกัดและมุ่งที่จะใช้กับสถานการณ์ที่พิเศษจริงๆ

การที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากกฎหมายอังกฤษมีหลักว่า พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับในประเด็นแห่งคดีย่อมรับฟังได้ ดังนั้นหากพยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานอันเป็นสาระสำคัญแห่งคดีแล้วศาลย่อมรับฟังไม่ว่าโดยไม่คำนึงว่าพยานหลักฐานนั้นได้มาโดยวิธีการใด ดังเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา 78 ของ The Police and Criminal Evidence Act 1984[175] ที่บัญญัติว่า

“ (1) ในกระบวนพิจารณาใด ศาลอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานซึ่งโจทก์ประสงค์จะอ้างอิง หากปรากฏต่อศาลซึ่งได้คำนึงถึงพฤติการณ์ทั้งปวงรวมทั้งพฤติการณ์ที่ได้พยานหลักฐานนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบความเป็นธรรมของกระบวนพิจารณาคดีถึงขนาดที่ศาลไม่ควรรับฟังพยานหลักฐานนั้น

---

[174]คดี In re Harvey 295A.2d 93(1972)

[175]ชลลดา จินตเสถียร, “ข้อยกเว้นการห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบตามมาตรา226/1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), น.107-108.

(2) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติต่างๆของกฎหมายซึ่งบังคับให้ศาลไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐาน[176] "

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นให้อำนาจศาลในการใช้ดุลยพินิจที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานใด เงื่อนไขสำคัญที่ต้องคำนึง คือพฤติการณ์ที่ได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นด้วย ดังนั้นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ เช่น พยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ ค้น ยึดโดยมิชอบ ศาลก็อาจใช้ดุลยพินิจที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นก็ได้[177]

ตัวอย่างคำพิพากษาของศาลอังกฤษที่วินิจฉัยว่ารับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

"ไม่สำคัญว่าได้พยานหลักฐานมาได้อย่างไร แม้จะขโมยมาพยานหลักฐานก็รับฟังได้"[178]

ผู้พิพากษา Mellor ได้กล่าวว่า "ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นอุปสรรคอันตรายอย่างใหญ่หลวงในการประสิทธิประสาทความยุติธรรม หากจะถือว่าเพราะเหตุแห่งการได้มาซึ่งพยานหลักฐานโดยวิธีการอันมิชอบ ทำให้พยานหลักฐานนั้นไม่สามารถนำมาต่อสู้กับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดอาญาในเรื่องนั้น"[179]

ตำรวจได้ทำการค้นตัวจำเลยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในการค้นนั้นได้พบยาเสพย์ติด ศาลก็ยังคงที่จะรับฟังยาเสพย์ติดที่ได้มาจากการค้นนั้นฟังลงโทษจำเลยได้[180]

---

[176](1) In any proceedings the court may refuse evidence on which the prosecution proposes to rely to be given if it appears to the court that, having regard to all the circumstances , including the circumstances in which the evidence was obtained, the admission of the evidence would have such and adverse effect on the fairness of the proceedings that the court ought not to admit it.

(2) Nothing in this section shall prejudice any rule of law requiring the court to exclude evidence.

[177]ปวีณา พันธุ์ธนุสร,"ปัญหาการรับฟังถ้อยคำของผู้ถูกจับในชั้นจับกุม,"(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551) , น.43-44.

[178]คดี R v. Leathum 8 Cox CC 498 (1861)

[179]Andrews&Hirst,CriminalEvidence,3rdEdition(London:Sweet&Maxwel, 1997)p.441.

[180]คดี King v. R (1961) AC 304

คดีนี้จำเลยถูกฟ้องข้อหาว่ามีเครื่องกระสุนดินปืนและวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยเจ้าพนักงานค้นพบของกลางในกระเป๋าของจำเลย แต่การค้นดังกล่าวเป็นการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการค้นโดยเจ้าพนักงานที่มียศต่ำกว่าตามที่กฎหมายกำหนด ศาลสูงของอังกฤษได้วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานดังกล่าวยังคงที่จะรับฟังได้ เหตุผลที่สำคัญที่ศาลได้ให้เหตุผลไว้ในคดีนี้คือ หากพยานหลักฐานนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่า จำเลยกระทำความผิดก็สามารถที่จะรับฟังเพื่อใช้ลงโทษจำเลยได้ โดยมิต้องคำนึงว่าวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นจะได้มาอย่างไร[181]

จากคำพิพากษาที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า โดยหลักแล้วพยานหลักฐานที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองและเกี่ยวกับประเด็นย่อมสามารถที่จะรับฟังได้ทุกกรณี แม้วิธีการแห่งการได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้น เจ้าพนักงานของรัฐจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม ดังที่ศาสตราจารย์ David Fledman ได้กล่าวสรุปถึงแนวทางปฏิบัติในกรณีเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่า

“ กฎหมายประเทศอังกฤษไม่มีหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งโดยแท้จริงแล้วพยานหลักฐานที่ได้มาอย่างเหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ทำให้พยานหลักฐานนั้นไม่สามารถรับฟังได้หรือจะต้องถูกตัดออกไป หากแต่ศาลจะพิจารณาอย่างระมัดระวังในการที่จะตัดพยานหลักฐานก็แต่โดยเฉพาะกรณีที่หากรับฟังพยานหลักฐานนั้นแล้วจะทำให้กระบวนพิจารณาเกิดความไม่เป็นธรรม”[182]

และสิ่งที่ประเทศอังกฤษจะมุ่งพิจารณาเป็นสำคัญคือคุณค่าในความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานเป็นสำคัญ[183] การที่ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเป็นธรรมโดยถือเป็นข้อยกเว้นจริงๆเท่านั้น เช่น การที่เจ้าพนักงานตำรวจได้แสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีการล่อซื้อ หรือกรณีได้รับคำรับสารภาพมาโดยมิชอบศาลประเทศอังกฤษจะไม่รับฟังอย่างเคร่งครัด[184]

3.4.1.3 ประเทศนิวซีแลนด์

---

[181] คดี Kuruma v. R (1955) AC 197 (PC)

[182] ฐานิศร์ วรรณสุข,“ ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานที่มิชอบด้วยกฎหมาย,”(สารนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550),น. 62-63.

[183] คดี Mason (2002) 1 WLR 139.

[184] The Police and Criminal Evidence Act 1984 มาตรา 76(1)(2)ข้อ(a)และ(8)

หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบปรากฏในมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติพยานหลักฐาน (Evidence Act 2006)และมีปัจจัยต่างๆหลายประการในการพิจารณาเพื่อที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ[185]

The New Zealand Bill of Rights Act 1990 (BORA) มาตรา 21 ที่บัญญัติหลักการว่า บุคคลต้องไม่ถูกตรวจค้นและยึดหากไม่มีเหตุอันสมควรว่ามีการกระทำความผิดต่อร่างกาย ทรัพย์สินหรืออื่นๆ ทำให้เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันสมควร(reasonableness) ว่ามีการกระทำความผิดทุกครั้งก่อนจะใช้อำนาจในการตรวจค้นตัวบุคคล แม้ BORA จะไม่มีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์ และศาลไม่เคยอ้างเพื่อใช้ในการยกเลิกกฎหมายฉบับอื่นที่ไม่ให้การคุ้มครองสิทธิตามที่ BORA คุ้มครอง แต่ทั้งฝ่ายบริหารและตุลาการกลับใช้BORAเป็นเครื่องมือในการตีความเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่กำหนดไว้ใน BORA เพื่อเป็นการยืนยัน ปกป้อง สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ และเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการละเมิดสิทธิทางร่างกายหรือบุคคลใด[186] เมื่อเจ้าพนักงานทำการตรวจค้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายศาลได้สร้างบรรทัดฐานว่าการละเมิดสิทธิของบุคคลตามที่ New Zealand's Bill of Rights Act 1990 ให้การคุ้มครองพยานหลักฐานที่ได้มาจากการล่วงละเมิดสิทธิรับฟังไม่ได้ตามหลัก Exclusionary Rule[187] แต่เมื่อไม่นานมานี้ศาลได้แทนที่ Exclusionary Rule ด้วย “วิธีการชั่งน้ำหนัก” (Balancing Approach) โดยอาจยอมรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดโดยไม่ชอบโดยชั่งน้ำหนักระหว่างความยุติธรรมกับประโยชน์ที่ได้จากการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ[188]

3.4.1.4 ประเทศฝรั่งเศส

---

[185] ชลลดา จินตเสถียร,*อ้างแล้งเชิงอรรถที่175*, น.106.

[186]Justice Susan Glazebrook, Natalie Baird and Sasha Holden,” New Zealand: Country Report on Human Rights,” Victoria University of Wellington Law Review,(June, 2009), Retrieved from Westlaw

[187]คดี R V.Maihi,[2002] 19 C.R.N.Z. 453 (C.A.),R v. Shaheed, [2002] 2 N.Z.L.R. 377 (C.A.). R v Jefferies(R v Jefferies [1994] 1 NZLR 290 (CA) and R. v Grayson [1997] N.Z.L.R. 399 (CA (NZ)).

[188]คดี R v. Butcher, [1992] 2 N.Z.L.R. 257, 266 (C.A.) (Cooke, P.). *See also* R v. Kirifi, [1992] 2 Retrieved from Westlaw

เป็นประเทศที่มีระบบ civil law จึงมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการรับฟังพยานหลักฐานอย่างกว้างขวางแตกต่างจาก ประเทศ common law ซึ่งมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานและบทตัดพยาน (Exclusionary Rule)อย่างเคร่งครัด เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสเป็นการนั่งพิจารณาโดยผู้พิพากษาอาชีพที่มีหน้าที่ในการตรวจค้นหาความจริงจากพยานหลักฐานต่างๆทั้งที่คู่ความนำเสนอและศาลเรียกเข้ามาสืบเอง โดยไม่มีบทตัดพยานทำให้พยานหลักฐานทุกชิ้นเข้าสู่สำนวนและจะถูกพิจารณาโดยละเอียดตอนเข้าสู่การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานชิ้นใดควรมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด[189]

การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญามี 2 หลัก[190] คือ

1.หลักเสรีภาพในการรับฟังพยานหลักฐาน (La liberté dans la recevabilité de la preuve) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 427 บัญญัติว่า “เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติเป็นอย่างอื่น ความผิดอาญาถูกพิสูจน์ได้ด้วยพยานหลักฐานทุกประเภท(tout mode de preuve)” ทำให้ศาลอาญาฝรั่งเศสสามารถรับฟังพยานหลักฐานได้ทุกประเภท ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดประเภทพยานหลักฐาน

2.หลักความชอบด้วยกฎหมายในการรับฟังพยานหลักฐาน (La légalité dans l’administration de la preuve) กฎหมายไม่ยอมรับฟังพยานบางกรณีที่ขัดกับหลักการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ของจำเลย (droit de la défense) เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสมาตรา 432 กำหนดว่า “ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานเอกสารที่เกิดจากการสนทนาระหว่างจำเลยกับทนายความ”

นอกจากนี้ศาลฎีกาฝรั่งเศสกำหนดแนวทางการไม่ยอมฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่สุจริต ตาม “หลักความสุจริตของพยานหลักฐาน” (loyauté des preuves)

1) พยานหลักฐานที่เจ้าพนักงานหลอกลวง ข่มขู่ ให้สัญญา หรือการกระทำด้วยประการใดๆให้บุคคลให้ถ้อยคำโดยไม่สมัครใจ ไม่อาจรับฟังได้

2) พยานหลักฐานที่เกิดจากการที่เจ้าพนักงานไปกระตุ้น (provoquer) ให้มีการกระทำความผิด

---

[189] เข็มชัย ชุติวงศ์,คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน,พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุภาการพิมพ์,2543),น.2.

[190] ปกป้อง ศรีสนิท, “พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบในคดีอาญา”.

3) **พยานหลักฐานที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ** (détournement de pouvoir) ศาลได้พิพากษาในคดีเรื่องหนึ่งว่า ตำรวจ C.R.S. ไม่มีอำนาจในการค้นรถบรรทุกสินค้า พนักงานศุลกากร(douanier) ไม่มีอำนาจในคดีจราจร ตำรวจ C.R.S. ขอให้พนักงานศุลกากร เข้าไปค้นรถบรรทุกเพื่อค้นหาเครื่องตรวจจับสัญญาณเรดาร์ในรถบรรทุก ศาลฎีกาฝรั่งเศสลงวันที่ 18 ธันวาคม 1989 B.C.,n°845 ไม่รับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว เพราะเป็นพยานที่เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ

3.4.2 เจ้าหน้าที่ผู้กระทำการค้นโดยมิชอบได้รับโทษทางวินัย

3.4.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าพนักงานมีความรับผิดทางวินัย[191]

3.4.2.2 ประเทศอังกฤษ เจ้าพนักงานมีความรับผิดทางวินัย[192]

3.4.2.3 ประเทศฝรั่งเศส เจ้าพนักงานมีความรับผิดทางวินัย[193]

3.4.3 เจ้าพนักงานอาจถูกฟ้องทางแพ่งหรืออาญา

3.4.3.1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรการอื่นๆที่ห้ามปรามเจ้าหน้าที่มิให้กระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 14(Fourthteenth Amendent) ให้สิทธิผู้เสียหายให้เรียกร้องทางแพ่ง[194] ทางอาญา แต่ทำได้อย่างจำกัดเพราะในคดีอาญาพนักงานอัยการอาจมีความเห็นใจเจ้าพนักงานดังกล่าวจึงไม่ฟ้องร้องคดีอาญาโดยอาจเห็นว่าเจ้าพนักงานอาจกระทำผิดพลาดอย่างบริสุทธิ์ใจหรือแม้จะฟ้องร้องเจ้าพนักงานผู้นั้นก็อาจส่งผลให้ลูกขุนที่ทำการพิจารณาคดีอาจเห็นใจไม่เอาผิดต่อเจ้าพนักงานก็ได้ ซึ่งในคดีแพ่งก็เช่นเดียวกัน การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็เป็นไปได้ยากไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (punitive damages)เพราะโจทก์ต้องพิสูจน์ถึงเจตนาร้าย(ill will)ของเจ้าพนักงานผู้เป็นจำเลยให้ได้เสียก่อน

---

[191] Joel Samaha , *saupra note34*,p. 374 .

[192] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 14,* น.50.

[193] George A.Berman,Etienne Picard,Introduction to French law, (Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2008),p.133.

[194] "Damage remedies against municipality for constitutional violations," Harvard Law Review, p.922(1976) Retrived from http://www.jstor.org/pss/1340187.

ซึ่งโจทก์อาจพิสูจน์ได้ยากเพราะการที่เจ้าพนักงานกระทำโดยมิชอบ เช่นการค้นโดยไม่มีหมายอาจเป็นเพราะเจ้าพนักงานวินิจฉัยข้อเท็จจริงเฉพาะหน้าคลาดเคลื่อนไป[195]

เมื่อศาลยึดถือหลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานอย่างเคร่งรัดจนเกินไปส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรม ศาลจึงพิพากษาว่าศาลจะไม่นำหลัก Exclusionary Rule มาตัดพยานหลักฐานในกรณีที่การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิ เสรีภาพของจำเลยเป็นการกระทำที่เจ้าพนักงานได้เชื่อโดยสุจริตอย่างมีเหตุผลว่า เจ้าพนักงานผู้นั้นมีอำนาจกระทำได้[196] แต่การเรียกให้หยุดที่ไม่มีเหตุอันควรสงสัยยังเป็นการเรียกให้หยุดที่ไม่ชอบตาม Fourth Amendment แม้เจ้าหน้าที่จะเรียกให้หยุดด้วยความสุจริตก็มีผลเพียงเป็นข้อต่อสู้ในความรับผิดทางแพ่งเท่านั้น แต่ไม่ทำให้การเรียกให้หยุดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับกลายเป็นการเรียกให้หยุดที่ชอบด้วยกฎหมาย[197]

3.4.3.2 ประเทศอังกฤษ เจ้าหน้าที่ตรวจค้นโดยมิชอบอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง อาจถูกฟ้องคดีอาญา[198] และหากการตรวจค้นโดยมิชอบเกิดจากการเลือกปฏิบัติตาม Civil Rights Act 1964 เกิดจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ชาติกำเนิด เพศ ศาสนา ผู้เสียหายสามารถส่งคำร้องไปกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อไป[199]

3.4.3.3 ประเทศนิวซีแลนด์ บุคคลทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมีสิทธิได้รับชดใช้ทางแพ่ง[200](คดี Baigent's case, above n 36, NZLR 711, 714; HRNZ 96, 100 Gault J.) โดยได้มีการออกกฎหมาย The Human Rights Act 1993 (HRA) ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับล่าสุดที่ออกเพื่อคุ้มครองและต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการปฏิบัติการของเจ้าพนักงานรัฐโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายฉบับนี้ คือ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลที่

---

[195] ฐานิศร์ วรรณสุข,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่182,*น.47-48.

[196] คดี United State v. Leon 468 U.S. 897(1984)

[197] John N. Ferdico,*Supra note20* p.301

[198]Retrieved from http://www.ehow.co.uk/facts_5448232_typespolicemisconduct.html#ixzz0qw886XU0

[199]Retrieved from http://www.ehow.co.uk/way5780649remedypolicemisconduct.html#ixzz 0qw7Dt99a

[200] Petra Butler," Human Rights and Parliamentary Sovereignty in New Zealand",Victoria University of Wellington Law Review ,(August, 2004)

ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจในการเลือกปฏิบัติอันเกิดจาก เพศ สถานภาพการสมรส ความเชื่อศาสนา เผ่าพันธุ์ ความสามารถของบุคคล อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางการงาน สถานะทางครอบครัวและความชอบทางเพศ

3.4.3.4 ประเทศฝรั่งเศส เจ้าพนักงานถูกเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้และมีความผิดอาญาฐานบุกรุก[201]

[201] Serge Guinchard, Jacques Buisson,*supra note 11*,p.514.

บทที่ 4

หลักเหตุอันควรสงสัยและแนววินิจฉัยของศาล

4.1 <u>ความหมายของ “ เหตุอันควรสงสัย ”</u>

<u>4.1.1Black's Law Dictionary</u>[1]

Black's Law Dictionary ได้ให้ความหมายของคำว่า “เหตุอันสมควร” หรือ “Reasonable” ไว้ว่า

“เหตุอันสมควร”[2] หมายถึง 1.เป็นกลาง เหมาะสม หรือ ปานกลางภายใต้สถานการณ์ที่สมควร 2. เหตุผล(ที่สมเหตุสมผลแต่ไม่น่าเชื่อถือ) “มันยากที่จะอ้างว่าสิ่งที่

---

[1]RetrivedMay6,2009,from<u>http://international.westlaw.com/result/default.wl?vr=2.0&tf=507&sv</u>=Split&cxt=RL&utid=17&fmqv=s&rlti=1&ss=CNT&tc=1&rs=WLIN10.10&eq=search&db=BLACKS&cnt=DOC&fn=_top&rlt=CLID_QRYRLT4810221621810&n=1&scxt=WL&spa=THAMM2002&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rltdb=CLID_DB6388301621810&origin=Search&mt=WLIGeneralSubscription&service=Search&query=REASONABLENESS&method=TNC

[2] reasonable, *adj.* - 1. Fair, proper, or moderate under the circumstances < reasonable pay>. 2. According to reason <your argument is reasonable but not convincing>.“It is extremely difficult to state what lawyers mean when they speak of ‘reasonableness.’ In part the expression refers to ordinary ideas of natural law or natural justice, in part to logical thought, working upon the basis of the rules of law.” John Salmond, *Jurisprudence* 183 n.(u) (Glanville L. Williams ed., 10th ed. 1947). “In one sense the word [*reasonable*] describes the proper use of the reasoning power, and in another it is no more than a word of assessment. Reasoning does not help much in fixing a reasonable or fair price or a reasonable or moderate length of time, or in estimating the size of a doubt. Lawyers say a reasonable doubt, meaning a substantial one; the Court of Appeal has frowned upon the description of a reasonable doubt as

ทนายความพูดเป็น “ เหตุอันสมควร ” ด้านหนึ่งอ้างถึงความคิดทั่วไปของกฎหมายธรรมชาติหรือความยุติธรรมทั่วไป อีกด้านหนึ่งจอห์น แซลมอนกล่าวว่า เป็นความคิดที่มีเหตุผล อยู่บนรากฐานของหลักนิติธรรม ”

ในบางความหมาย เหตุอันสมควรอธิบายถึงการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม และอีกทางหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยในการตีความอะไร แต่เป็นเพียงการประเมินว่าอย่างไรเป็นการใช้อำนาจที่เหมาะสม มันไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอะไรคือเหตุอันสมควร

Black's Law Dictionary[3]

Black's Law Dictionary ได้ให้ความหมายของคำว่า “เหตุอันควรสงสัย” หรือ “Reasonable Suspicion” ไว้ว่า

“ ความสงสัย[4] ” หมายถึง การรับรู้หรือการจินตนาการว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นโดยอยู่บนพยานหลักฐานที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือมีพยานหลักฐานเพียงเล็กน้อย หรือแม้กระทั่งไม่มี

---

one for which reasons could be given.” Patrick Devlin, *The Judge* 134 (1979). 3. (Of a person) having the faculty of reason <a reasonable person would have looked both ways before crossing the street>. 4. *Archaic*. Human <criminal homicide is traditionally called the unlawful killing of a “reasonable person”>. — reasonableness, *n.*

[3]http://international.westlaw.com/result/default.wl?vr=2.0&tf=507&sv=Split&cxt=RL&utid=17&fmqv=s&rlti=1&ss=CNT&tc=1&rs=WLIN10.10&eq=search&db=BLACKS&cnt=DOC&fn=_top&rlt=CLID_QRYRLT9783193521810&n=1&scxt=WL&spa=THAMM2002&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rltdb=CLID_DB6388301621810&origin=Search&mt=WLIGeneralSubscription&service=Search&query=%22REASONABLE+SUSPICION%22&method=TNC

[4]suspicion. - The apprehension or imagination of the existence of something wrong based only on inconclusive or slight evidence, or possibly even no evidence.reasonable suspicion particularized and objective basis, supported by specific and articulable facts, for suspecting a person of criminal activity. • A police officer must have a reasonable suspicion to stop a person in a public place. See STOP AND FRISK. Cf. PROBABLE CAUSE. [Cases: Arrest %4 E63.5.]

พยานหลักฐานเลย **เหตุอันควรสงสัย**อยู่บนรากฐานที่เป็นภาวะวิสัยหรือมีความเฉพาะเจาะจง สนับสนุนโดยข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าบุคคลได้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีเหตุอันควรสงสัยในการเรียกบุคคลให้หยุดในที่สาธารณสถาน

4.1.2 ความหมายตามคำพิพากษาของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา

" เหตุอันควรสงสัย " ศาลไม่ได้ให้คำนิยามไว้ชัดเจน เพียงแต่บอกว่าความรู้สึกปริมาณ เนื้อหา ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะมีระดับต่ำกว่ามีพยานหลักฐานเชื่อแน่ว่ามีการกระทำความผิด (probable cause) และไม่สามารถอยู่บนลางสังหรณ์(hunch) หรือแม้แต่ความสงสัยทั่วไป(general suspicion) เพราะการค้นตัวเป็นการกระทำที่กระทบกับสิทธิทางชีวิตร่างกายของบุคคล ดังนั้นเหตุอันควรสงสัยต้องมาจากข้อเท็จจริงทางภาวะวิสัยที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายคดีไป[5] แต่หลักการเรื่องนี้สหรัฐอเมริกายังไม่มีการจัดวางไว้อย่างเหมาะสม[6]

" ศาลสูงสุดสหรัฐอมริกาไม่ได้นิยามเหตุอันควรสงสัยอย่างตายตัว อย่างไรก็ตามเหตุอันควรสงสัยไม่เพียงแต่มีระดับความต้องการข้อมูลทั้งแง่ปริมาณหรือเนื้อหาน้อยกว่าที่probable cause กำหนดให้ต้องมีเหตุอันควรสงสัยยังสามารถเกิดขึ้นจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือน้อยกว่าที่กำหนดให้มีใน probable cause[7] "

เหตุอันควรสงสัย มีระดับข้อเท็จจริงน้อยกว่า มีพยานหลักฐานเชื่อแน่ว่ามีการกระทำความผิด(probable cause)[8]

4.1.3 ระดับการพิสูจน์[9]

ระดับการพิสูจน์	ระดับความแน่นอน	รูปแบบของการพิจารณา
มั่นใจแน่นอนว่าผิด(absolute	100%	ไม่จำเป็นต้องใช้ในกรณีใดๆใน

[5]คดี Terry v. Ohio , 392 U.S. 1 (1968).

[6]คดี Illinois v.Gates 462 U.S. 213 (1983)

[7]คดี Alabama v. White ,496 U.S.325(1990)

[8]คดี United Stated v. Sokolaw 490 U.S.1(1989)

[9] Rolando v. del Carmen,Criminal Procedure Law and Practice,5th ed(Belmont.Calif:Wadworth/Thomson Learning,2001), p.72.

certainty)		กระบวนพิจารณา
พิสูจน์การกระทำความผิดโดยปราศจากข้อสงสัย(guilt beyond a reasonable doubt)	95%	ลงโทษผู้ถูกกล่าวหา ใช้ในการพิสูจน์ทุกองค์ประกอบในความผิดทางอาญา
มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ (clear and convince evidence)	80%	ปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวในบางรัฐ หรือใช้ยกข้อต่อสู้ว่าตนเป็นคนวิกลจริต
มีพยานหลักฐานเชื่อแน่ว่ามีการกระทำความผิด (probable cause)	มากกว่า 50%	ใช้ออกหมาย ได้แก่ หมายค้น หมายยึด และจับโดยไม่มีหมาย หรือฟ้องคดี
พยานหลักฐานที่มีน้ำหนัก (preponderance of the evidence)	มากกว่า 50%	ศาลพิพากษาให้ชนะคดีแพ่ง หรือ ยืนยันข้ออ้างในคดีอาญา
เหตุอันควรสงสัย (reasonable suspicion)	**30%**	**ตำรวจเรียกให้หยุดหรือตรวจค้นตัวบุคคล**
ความสงสัย(suspicion)	10%	เป็นจุดเริ่มต้นที่ตำรวจหรือคณะลูกขุนใช้ในการสอบสวน
มีข้อสงสัย (reasonable doubt)	5%	ยกฟ้องผู้ถูกกล่าวหา
ลางสังหรณ์(hunch)	0%	ไม่เพียงพอในการดำเนินคดีใดๆ
ไม่มีข้อมูล(no information)	0%	ไม่เพียงพอในการดำเนินคดีใดๆ

4.2 **<u>ความเห็นของนักวิชาการ</u>**

การพิจารณาว่าข้อเท็จจริงอย่างใดเป็นเหตุอันควรสงสัย ***ศาสตราจารย์ LA FAVE*** ได้ให้ข้อพิจารณาอีก 6 ประการ[10]

1. ลักษณะของผู้กระทำความผิดหรือยานพาหนะที่ใช้หลบหนี
2. บริเวณพื้นที่ที่อาจพบตัวผู้กระทำความผิด โดยอนุมานเอาจากเวลาที่เกิดการกระทำความผิดและเวลาที่เจ้าพนักงานเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ
3. จำนวนของบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่เกิดเหตุ
4. ช่องทางที่ผู้กระทำความผิดจะหลบหนีหรือจะกระทำความผิด
5. การกระทำของบุคคลที่จะเรียกให้หยุดที่มีข้อผิดสังเกต
6. ลักษณะของผู้ที่ต้องสงสัยหรือยานพาหนะที่จะเรียกให้หยุดโดยพิจารณาถึงรูปแบบของการกระทำความผิดที่เคยเกิดขึ้น

หลักทั้งหกประการนี้ ศาลของสหรัฐอเมริกาในคดี State v.Guzy,407 N.W.2d548(Wis. 1987) นำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้นหรือไม่ โดยเพิ่มข้อพิจารณาที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาหกประเด็น อีกสามข้อ[11] คือ

ประการแรก มีแนวทางอื่นที่เจ้าพนักงานสามารถที่จะได้ข้อมูลในการเรียกให้หยุดหรือไม่

ประการที่สอง โอกาสที่จะสืบสวนต่อไปหากไม่มีการเรียกให้หยุด

ประการสุดท้าย ลักษณะของผู้กระทำความผิดที่เจ้าพนักงานจะทำการตรวจค้นรวมถึงความร้ายแรงของความผิดที่ได้รับการรายงานมา

---

[10] John N.Ferdico, <u>Criminal procedure for the criminal justice professional</u>,9th ed(Belmont: : Thomson Wadsworth, 2002),p.278.

[11] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,<u>โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการค้นตัวบุคคลศึกษาเปรียบเทียบกับนานาประเทศ</u>,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา,2553),น.65.

Joel Miller[12] กล่าวว่า “ เหตุอันควรสงสัย เน้นถึงข้อมูลที่มาจากหลายๆแหล่งและมีความแม่นยำจากหน่วยข่าวกรองที่ทันสมัย ”

ผู้พิพากษา Lord Scott of Foscote[13] กล่าวว่า “ ความสงสัยต้องมีมูลเหตุที่แน่ชัดและมีเป้าหมายบนข้อเท็จจริงเฉพาะเจาะจง การตัดสินใจจะ*ต้องไม่อยู่บนความเชื่อ*ของแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่ได้สืบสวน ความสงสัยที่เกิดจากการคาดเดาหรือไม่มีเป้าหมายถือว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท”

4.3 <u>แนวคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ</u>

4.3.1 แนวคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัย

(1) คดีนี้เป็นคลาสิกของสหรัฐอเมริกาที่ศาลได้สร้างหลักเรื่องการเรียกให้หยุดและค้นตัวบุคคล เกิดประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทของ Fourth Amendment ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

<u>ข้อเท็จจริง</u> เจ้าหน้าที่ Martin McFadden ให้การว่า ขณะที่เขาลาดตระเวนในเมือง Cleveland ด้วยชุดนอกเครื่องแบบเวลาประมาณบ่าย 02.30 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1963 เขาสะดุดกับชายสองคน เขาไม่รู้สาเหตุที่มองแต่ด้วยประสบการณ์การเป็นตำรวจและการเป็นนักสืบมา 35 ปีจึงถูกส่งมาให้ลาดตระเวนที่ Cleveland สอดส่องดูพวกขโมยของตามร้านและพวกชอบล้วงกระเป๋า เขาอธิบายว่ากิจวัตรประจำวันของเขาคือการสังเกตบุคคลที่เดินไปมาในระหว่างวันมาหลายปี ในคดีนี้เมื่อเขามองชายสองคนนั้น(Terry,Chilton)ชายทั้งสองคนไม่กล้ามองมาที่เขาในตอนนั้น ทำให้เขาเกิดเอะใจและยืนสังเกตการณ์ตรงทางเข้าของร้านห่างจากชายสองประมาณ300-400 เมตร คิดว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้น เขาเห็นว่าชายคนหนึ่งเดินไปจากชายอีกคนมุ่งหน้าตรงไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ไปทางถนน Huron ผ่านร้านค้าหลายร้าน ชายคนนั้นหยุดประมาณ 2 นาทีแล้วมองเข้าไปที่กระจกร้านค้า หลังจากนั้นก็เดินไปอีกซักระยะ

---

[12]Joel Miller,” STOP AND SEARCH IN ENGLAND A Reformed Tactic or Business as Usual?,” <u>British Journal of Criminology</u>,(September2010).

[13]คดี Manifest Shipping Co Ltd v Uni-Polaris Insurance Co Ltd [2003] 1 AC 469,

และเดินวนกลับมาที่หัวมุมหยุดอีกครั้งหนึ่ง แล้วมองไปที่กระจกร้านค้าร้านเดิม เขากลับมาหาเพื่อนของเขาที่หัวมุมและพวกเขาก็คุยกัน

หลังจากนั้นชายคนที่สองก็เคลื่อนไหวแบบที่ชายคนแรกทำคือ เดินไปตามถนน Huron มองเข้าไปในกระจกร้านค้าเดินไปเดินมาแล้วมาหาชายคนแรกที่หัวมุม

ขณะที่คนที่สองมาอยู่ที่หัวมุมก็มีชายอีกสามคนมาร่วมด้วยแล้วก็เดินจากไป หลังจากที่ชายสามคน คนเดินจากไป ชายสองคนแรกก็เดินไปตามทางที่ชาย 3 คนเดินไป

จากที่สังเกตการณ์ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ McFadden มั่นใจว่าพวกเขากำลังจะก่ออาชญากรรมและเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องสอบสวน แต่เขากลัวว่าพวกนั้นจะมีปืน เขาจึงตาม Terry และ Chilton ไป เห็นTerry และ Chilton หยุดคุยกับชายสามคน เขาจึงมั่นใจว่าเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงเข้าแสดงตัวกับชายสามคนบอกว่าเขาเป็นตำรวจและถามชื่อของพวกเขา แต่ชายสามคนนั้นไม่ตอบ เมื่อชายสามคนพึมพำบางอย่างในการตอบคำถาม McFadden คว้าตัวTerry ล็อกแขน และให้ Terry หันหน้าไปหาผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆ แล้วทำการค้นตัวโดยแตะต้องตัวTerryด้านนอกเพื่อหาอาวุธ(pat down) บริเวณกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายของTerry เจ้าหน้าที่ McFadden รู้สึกว่าเป็นปืน เขาจึงล้วงไปในเสื้อด้านในแต่ไม่สามารถเอามันออกมาได้ เขาสั่งให้ชายสามคนเข้าไปในร้าน Zucker's ขณะที่ชายสามคนเดินเข้าไปในร้าน McFadden เอาปืนพก. 38ออกจากเสื้อ Terry และสั่งให้ชายสามคนหันหน้าเข้ากำแพงโดยให้ยกมือขึ้นแล้วก็ทำการตบเสื้อนอกเพื่อหาอาวุธ เขาไม่พบอาวุธที่ตัวของชายสามคนนั้น พบแต่ปืนพกในเสื้อของ Chilton

เจ้าหน้าที่ McFadden ให้การว่าเขาเพียงแต่ทำการแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธไม่ได้เอามือล้วงไปในเสื้อข้างในทั้งTerry และ Chiltonจนกระทั่งกว่ารู้สึกว่ามีปืน McFadden ยึดปืน Chilton และให้เจ้าของร้านเรียกตำรวจเพื่อนำชายสามคนไปสถานี Terry และ Chilton ถูกฟ้องฐานพกอาวุธปืนในเมือง ศาลพิพากษาว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ McFadden มีเหตุอันควรสงสัยที่จะเรียกให้หยุดเพราะพฤติการณ์ของ Terry และ Chilton ที่น่าสงสัยว่ากำลังจะก่ออาชญากรรมและค้นตัวทั้งสองคนเพราะเมื่อแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกแล้วรู้สึกว่ามีปืน [14]

<u>ความคิดเห็นของผู้พิพากษาในคดีนี้</u>

Fourth Amendment ให้ความคุ้มครองโดยครอบคลุมถึง การควบคุมตัวบุคคล (seizure of the person) โดยไม่มีเหตุอันควร Terry มีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการเดินอยู่

---

[14]คดี Terry v. Ohio ,392 U.S.1(1968),cited by Joel Samaha,<u>Criminal Procedure</u>,7th ed (Belmont: Thomson/Wadsworth, 2008),pp.88-91.

บนถนนในเมือง ส่วนเจ้าหน้าที่ McFaddenมีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอที่จะทำการควบคุมตัว Terry และแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธ จึงเป็นการกระทำที่มีเหตุผลที่จะเข้าไปแทรกแซงสิทธิของเขา แต่ประเด็นคือตำรวจมีสิทธิที่จะทำการสอบสวนโดยการแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธได้เพียงใด แล้วการที่ตำรวจค้นแล้วไม่พบอาวุธถือว่าไม่มีเหตุสมควรเสมอไปหรือไม่ หรือการที่ไม่ได้ค้นเพื่อหาอาวุธหรือไม่มีเหตุในการจับกุม(arrest) จะมีเหตุอื่นไหมที่จะเป็นเหตุอันควรสงสัยได้

ศาลให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในการค้นตัวบุคคลได้ถ้ากระทำไปเพื่อรักษาความสงบของบ้านเมือง ป้องกันอาชญากรรมและสืบสวนอาชญากรรมซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีการกระทำที่เหมาะสมและสถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวนการกระทำความผิดทางอาญาแม้ว่าจะไม่มีพยานหลักฐานที่เชื่อแน่ว่ามีการกระทำความผิด(probable cause)ที่จะจับ คดีนี้ชายสองคนมองที่กระจกร้านค้า 24 ครั้ง และไปร่วมกับเพื่อนอีกสามคน เมื่อตำรวจเห็นอย่างนั้นแล้วถ้าไม่ทำอะไรก็จะเป็นตำรวจที่แย่ ส่วนวิธีการค้นตัวบุคคล(frisk)ที่แตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธเป็นวิธีที่ล่วงละเมิดน้อยที่สุดแล้ว

หลักของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่การสืบสวนพฤติกรรมอันน่าสงสัยขอTerry แต่เป็น<u>ความเป็นสมเหตุสมผลในการแทรกแซงสิทธิส่วนตัวของประชาชนโดยการค้นตัวบุคคลเพื่อหาอาวุธ</u> ดังนั้นการประเมินว่าเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลหรือไม่ ต้องมีการ

1)กำหนดขอบเขตของการค้นตัวของผู้ต้องสงสัยให้ชัดเจนนั่นคือการค้นตัวเพื่อหาอาวุธและเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าพนักงาน

2)กำหนดว่าเจ้าพนักงานกระทำการอย่างมีเหตุอันสมควรในสถานการณ์นั้นหรือไม่ น้ำหนักของข้อเท็จจริงที่เหมาะสมและต้องไม่เริ่มด้วยลางสังหรณ์ และต้องมีการประเมินทางภาวะวิสัย

<u>(2)ข้อมูลที่ได้รับจากคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์</u>สามารถเป็นเหตุอันควรสงสัยที่สมเหตุสมผลในการค้นตัวบุคคลได้ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการสังเกตของเจ้าพนักงานเสมอไปโดยศาลให้เหตุผลว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้อื่นเหมือนกับร่องรอยหรือหลักฐานที่ตำรวจจะพบในที่เกิดเหตุอาจหลากหลาย มีคุณค่าและเชื่อถือได้ [15]

<u>(3)ภาพรวมทั้งหมดของเหตุการณ์</u>ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้กระทำความผิดนั้นและสมมติฐานทางภาวะวิสัย การติดตามพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด การคำนวณเวลาที่

---

[15]คดี Adams v. William , 407 U.S. 143 (1972).

ใกล้เคียงกับการกระทำของผู้กระทำความผิดอย่างแม่นยำ และที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบนำคนเข้าเมืองที่สำคัญพื้นที่หนึ่งซึ่งตรงกับลักษณะของการกระทำความผิดของผู้ต้องสงสัย[16]

(4)การเรียกให้หยุดที่เกิดจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้นิรนามใช้ได้ ถ้าคำบอกเล่าของผู้นิรนาม ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงาน ศาลวินิจฉัยว่าอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยได้ถ้ามีความน่าเชื่อถือเพียงพอ[17]

อีกคดีหนึ่งคำบอกกล่าวจากผู้นิรนามที่จะก่อให้เกิดเหตุอันควรสงสัย ศาลได้วิเคราะห์ไว้ว่าหนึ่ง ถึงแม้ว่าข้อมูลทุกๆข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลจะไม่ถูกต้องทั้งหมด เช่น ชื่อของผู้หญิงที่ออกจากตึก หรือไม่ได้ออกจากอพาร์ตเม้นที่มีชื่อตรงกับที่ได้รับมา เจ้าหน้าที่ได้แสวงหาพยานหลักฐานว่าผู้หญิงออกจากตึกและไปในรถคันหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปในตึกทันทีที่มีการโทรมาบอก และจำเลยก็ปรากฏตัวหลังจากนั้นไม่นาน การออกจากตึกอยู่ในเวลาที่คาดหมายได้ ระยะทาง 4 ไมล์ เป็นทางตรงที่ไปถึงโรงแรมแม้ว่าจะต้องเลี้ยวหลายเลี้ยว การคาดหมายจุดมุ่งหมายของจำเลยเป็นข้อสนับสนุนได้แม้ว่าจำเลยจะยังไปไม่ถึงที่หมาย ยิ่งกว่านั้นการคาดเดาพฤติกรรมของจำเลยของผู้แจ้งมีความใกล้เคียงกับการกระทำของจำเลย เมื่อการคาดเดาของผู้แจ้งเป็นจริงในหลายแง่ ภายใต้สถานการณ์ทั้งหมดจึงทำให้คำบอกกล่าวของผู้นิรนามเป็นคำบอกกล่าวที่เชื่อถือได้ และเป็นการแจ้งข้อมูลอย่างดี ทำให้เจ้าหน้าที่มีเหตุอันสมควรในการเรียกให้หยุดเพื่อการสอบสวนยานพาหนะของจำเลย[18] เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้หยุดโดยอาศัยข้อมูลจากการบอกเล่าของผู้อื่น ฟังประกอบกับการสอบสวนที่เป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเพียงพอจะฟังได้ว่าเกิดเหตุอันควรสงสัยในการกระทำความผิด

(5)ข้อมูลที่ได้รับจากเขตอำนาจอีกรัฐหนึ่ง ศาลวินิจฉัยว่า ตำรวจอาจเรียกให้ผู้ต้องสงสัยที่ต้องการจากรัฐอื่นหยุดได้ [19]

(6) การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบริเวณชายแดนระหว่างประเทศเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ฐานลักลอบขนยาเสพติด เป็นการเรียกให้หยุดที่มีเหตุอันสมควรเพราะความจำเป็นในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐสำคัญกว่าสิทธิส่วนบุคคล[20]

---

[16]คดี U.S. v.Cortez , 449 U.S. 411 (1981)

[17]คดี Alabama v. White , 496 U.S. 325(1990)

[18] *Supra note 10*, p.276.

[19] คดี United states v.Hensley ,469 U.S.221(1965)

(7) ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลกับตำรวจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเขาหรือบุคคลที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ข้อมูลจึงน่าเชื่อถือเพราะผู้ให้ข้อมูลไม่น่าจะโกหกเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากผู้ที่ถูกกล่าวอ้าง[21]

(8) ประชาชนผู้แจ้งความว่ามีการกระทำความผิดแก่ตำรวจมีความน่าเชื่อถือเพราะมิฉะนั้นจะเป็นการแจ้งความเท็จ[22]

(9) ศาลว่าข้อเท็จจริงต่อไปนี้เพียงพอที่จะค้นแล้ว หนึ่งคนขับแสดงใบอนุญาตในการขับรถยนต์ สอง ผู้ต้องสงสัยยอมรับว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานมาทางวิทยุ สาม เจ้าหน้าที่จำได้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่ย่องเบา สี่ เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัยเพียงผู้เดียวในเวลากลางคืน[23]

(10) ศาลตัดสินว่าหลังจากเรียกให้หยุดยานพาหนะเพราะจำเลยขับขี่รถเร็วเกินอัตราเป็นสถานการณ์ที่มีเหตุเชื่อได้ว่าจำเลยมีอาวุธเพราะเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานจากวิทยุว่า จำเลยเป็นผู้ต้องสงสัยในการปล้นธนาคารที่ไปกระทำความผิด 1 ชั่วโมงก่อนหน้านั้นและเจ้าหน้าที่คุ้นหน้าจำเลยเพราะเพิ่งพบและรู้ว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายเพราะขัดขืนการจับกุมและข่มขู่ตำรวจ[24]

(11) นายอำเภอแจ้งให้โรงรับจำนำทราบถึงรูปพรรณของนักย่องเบาที่ขโมยเหรียญดอลล่าร์ เมื่อโรงรับจำนำรายงานบุคคลที่ตรงกับรูปพรรณที่พยายามขายเหรียญดอลล่าร์ นับสืบจึงรีบมาที่โรงจำนำและเห็นผู้ต้องสงสัยที่พยายามจะขายเหรียญดอลล่าร์ ชายดังกล่าวใส่เสื้อโค้ชขนแกะยาวทั้งที่เป็นเวลากลางวัน มีท่าทางลุกลี้ลุกลนและเหงื่อออก นักสืบสังเกตเห็นห่อในกระเป๋าเสื้อโค้ช และเมื่อนักสืบอีกคนหนึ่งค้นตัวชายผู้นั้น เขารู้สึกถึงก้อนวัตถุที่อาจเป็นปืนหรือมีดเล็ก จึงดึงออกมาปรากฏว่าเป็นไปป์ที่ใช้เสพยาเสพติด

ศาลตัดสินว่า การเรียกให้หยุดและการค้นตัวบุคคลชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลที่ทำให้บุคคลในร้านเชื่อว่าเป็นนักย่องเบา มีมูลเหตุเพียงพอที่จะทำการหยุดผู้ต้องสงสัยเพื่อถามเพื่อยืนยันหรือทำให้ความสงสัยหมดไป เมื่อเขาเห็นห่อที่อยู่ในเสื้อโค้ช นักสืบมีเหตุสมควรที่จะกลัว

---

[20]คดี Montoya de Hernandez , 473 U.S. 531 381 (1985)

[21]คดี United Stated v. Christmas 222 F.3d 141 (2000)

[22]คดี Illinois v. Gates 462 U.S. 213 (1983)

[23]คดีStated v. Tharpe 973 F.2d 619

[24]คดี United Stated v. Bullock 454 F.3d 637

อันตรายและทำการค้นตัวบุคคลเพื่อหาอาวุธต่อไป ประกอบกับพฤติการณ์ที่ใส่เสื้อโค้ชยาว มีท่าทางลุกลี้ลุกลน เหงื่อแตก นำมาพิจารณาประกอบในการเรียกให้หยุดและค้นตัวได้[25]

(12) การเรียกให้หยุดที่มีสาเหตุมาจากการทำผิดกฎหมายจราจรเพราะการที่รถยนต์ใช้ป้ายทะเบียนชั่วคราว และการค้นตัวเพราะตำรวจสังเกตเห็นวัตถุยื่นออกมาจากเสื้อแจ็กเก็ตและบุคคลที่ถูกค้นพยายามที่จะหยิบวัตถุนั้นระหว่างที่ตำรวจทำการ pat down จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว[26]

(13) ตำรวจไปค้นที่อพาร์ตเม้นแห่งหนึ่งตามหมายค้น จากการรายงานทราบว่าผู้ที่ขนส่งยาเสพติดมีอาวุธ และบริเวณที่อพาร์ตเม้นตั้งอยู่เป็นที่เกิดอาชญากรรมเป็นประจำ ขณะที่ตำรวจเข้าไปในอาคารพบจำเลยกำลังเอามือซุกกระเป๋ากางเกงและวิ่งออกไปจากล็อบบี้ ตำรวจจึงรีบวิ่งตามออกไปจับกุมจำเลย ตำรวจบังคับจำเลยนอนราบและให้เอามือออกจากกระเป๋ากางเกงเมื่อจำเลยทำตามก็พบห่อโคเคนตกอยู่

ศาลวินิจฉัยว่ามีเหตุเพียงพอในการเรียกให้หยุดและการค้นตัวบุคคล และการใช้กำลังในการเรียกให้หยุดและการค้นตัวมีเหตุผลเพียงพอแล้วเพราะการบังคับให้นอนราบกระทำเพื่อป้องกันไม่ให้จำเลยหลบหนีหรือการให้เอามือออกมาเพราะเจ้าพนักงานเชื่อว่าจำเลยมีอาวุธ

การพิจารณาว่าการเรียกให้หยุดเพื่อการสอบสวน การค้นตัวบุคคลโดยใช้กำลัง ว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่ ต้องคำนึงถึงเวลาในการกระทำความผิด ลักษณะของการกระทำความผิดนั้นๆ คำบอกกล่าวของผู้ให้ข้อมูลว่าบุคคลนั้นอาจมีอาวุธ พฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยที่พยายามจะหลบหนี

ในคดีนี้พบว่าจำเลยมีพฤติกรรมหลบหนี มีการเอามือซุกในกระเป๋ากางเกง ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยจะมีอาวุธและสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวแล้ว[27]

(14) จำเลยซื้อสารเคมีหลายชนิด เจ้าพนักงานสอบสวนยาเสพติด(DEA) จึงเรียกรถของจำเลยให้หยุดด้วยเหตุที่ว่า ไม่มีกฎหมายให้อำนาจในการให้บุคคลนำสารเคมีต่างๆมาใช้รวมกัน ศาลวินิจฉัยว่าการเรียกให้หยุดยานพาหนะสมเหตุสมผลแล้วเมื่อเจ้าพนักงานได้กลิ่นสารเสพย์ติด การควบคุมตัวผู้ขับรถเพื่อสอบสวนต่อไปก็สมเหตุผล ดังนั้นแม้ไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย

---

[25]คดี State v. Simmons , 504 N.E.2d 575 (Ind. 1987)

[26]คดี United Stated v. Barnes , 412 U. S. 837

[27]คดี United Stated v. Laing ,423 U.S. 161 (1976

แต่เมื่อใช้ประสบการณ์และความรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะของการกระทำความผิดประกอบกับความสงสัยของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จึงมีเหตุอันสมควรที่จะเรียกให้หยุด[28]

(15)การเรียกให้หยุดเพราะทำผิดกฎหมายจราจร ถ้าเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดโดยมาจากการสังเกตว่ารถคันนั้นได้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรในการกระทำความผิดเล็กน้อย เช่น ไม่ติดป้ายทะเบียน หรือ ไฟท้ายแตกแล้วไม่ยอมซ่อม กระจกข้างร้าว ไม่ส่งสัญญาณไฟเมื่อมีการเปลี่ยนช่องถนน เจ้าพนักงานอาจเรียกคนขับรถให้หยุดได้ ซึ่งการเรียกให้หยุดในลักษณะนี้เรียกว่า “pretextual stop” มีวัตถุประสงค์เดียวกับการเรียกให้หยุดในคดี Terry คือเรียกให้หยุดเพื่อการสอบสวน จึงอยู่ภายใต้ Fourth Amendment และการเรียกให้หยุดโดยอาศัยเหตุต่างๆเหล่านี้เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยแล้ว[29]

(16) ในขณะที่เรียกให้หยุดผู้ต้องสงสัยมี*สิทธิที่จะไม่ตอบคำถาม*ได้ ดังนั้นเจ้าพนักงานจะใช้กำลังเพื่อให้ตอบคำถามไม่ได้ แต่การปฏิเสธที่จะตอบอาจเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะตรวจค้นตัวบุคคลเพราะเจ้าพนักงานไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะปลอดภัยหรือไม่[30]

(17) ตำรวจได้รับเบาะแสจากวิทยุว่ามีการปล้นทรัพย์ ตำรวจจึงรีบมาที่เกิดเหตุ พบชายคนหนึ่งตรงกับที่ระบุรูปพรรณสัณฐานจึงเรียกให้หยุด ชายสองคนถูกสั่งให้ลงจากรถ ไม่มีการถามตอบ แต่ตำรวจคนหนึ่งรีบไป pat down ตัวจำเลยพบลูกกระสุนปืน ศาลวินิจฉัยว่า การเรียกให้หยุดชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อเจ้าพนักงานมีความสงสัยว่ามีอาชญากรรมร้ายแรง แม้เจ้าพนักงานไม่มีเหตุเชื่อแน่ว่ามีการกระทำความผิด(probable cause) ที่จะจับ แต่เจ้าหน้าที่จึงมีเหตุผลที่จะรักษาความปลอดภัยของตัวเองโดยการ pat down ทันทีเพื่อหาอาวุธโดยไม่ต้องมีการถามก่อนเพราะคำตอบอาจเป็นกระสุนปืน[31] เจ้าหน้าที่จึงไม่ถูกบังคับให้ต้องถามคำถามก่อนค้นตัวบุคคล(frisk) ถ้าธรรมชาติของอาชญากรรมประเภทที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนมีความรุนแรงและสมเหตุสมผลที่ทำให้กลัวความปลอดภัย[32]

---

[28]คดี United Stated v. Martinez,184 U. S. 441

[29]คดี United Stated v. Botero , 589 F.2d 430

[30]คดี Illinois v. Wardlow , 528 U.S. 119 (2000).

[31]คดี People v. Anthrony ,cited in http:// statecases .justia.com/.../2005-04953-htm-people-v-anthony-linnen/

[32] *Supra note 10,* p.300.

(18) ศาลพบว่าเหตุอันสมควรในการค้นตัวบุคคล คือ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าตนอยู่ในอันตราย คดีนี้ตำรวจควบคุมตัวจำเลยเพราะจำเลยมีรูปพรรณสัณฐานตรงกับที่ได้รับรายงานจากวิทยุ ตำรวจจึงเริ่มค้นบริเวณเอว จำเลยรีบคว้าบนกระเป๋าเสื้อแจ็กเกตด้านนอกทันที ตำรวจจึงเอามือจำเลยออก และเมื่อสัมผัสจากภายนอกพบว่าเป็นวัตถุทรงกระบอกกลม จึงเข้าใจว่าเป็นปืนลูกปรายขนาดจุดหนึ่งสอง จึงล้วงเข้าไปในเสื้อพบบุหรี่ยัดไส้กัญชาที่ใส่ในกล่องลิปสติกแทน

ศาลว่าการเรียกให้หยุดชอบด้วยเหตุผลแล้ว เพราะเจ้าหน้าที่มีหน้าที่สืบสวนจำเลยตามรายงานที่ได้รับมา และเจ้าพนักงานมีเหตุเชื่อได้เจ้าหน้าที่กำลังตกอยู่ในอันตราย[33]

(19) ตำรวจสืบสวนสอบสวนยาเสพติด(DEA) มีเหตุสงสัยเพียงพอที่จะเรียกให้หยุด แต่ไม่ได้ทำการเรียกให้หยุดเอง แต่สั่งให้ตำรวจนิวยอร์กเป็นผู้ทำการหยุด จำเลยจึงสู้คดีว่าการเรียกให้หยุดโดยตำรวจนิวยอร์กเป็นผู้ทำการหยุด จึงเป็นการไม่สมเหตุสมผล ศาลวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่า เจ้าพนักงานที่ทำการหยุดอาจได้รับข้อมูลมาจากการสอบสวนใดๆ เมื่อข้อมูลจาก DEA มีความสงสัยที่สมเหตุสมผลแล้ว แม้ว่าเจ้าพนักงานผู้ที่เรียกให้หยุดจะไม่ใช่เจ้าพนักงานที่เกิดความสงสัยด้วยตนเอง ก็เป็นการเรียกให้หยุดที่ชอบด้วยกฎหมาย[34]

(20) ในพื้นที่ที่มีการใช้ยาเสพติดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เป็นประจำ เจ้าพนักงานมีเหตุสมควรที่จะทำการเรียกให้หยุดผู้ต้องสงสัยที่อยู่คนเดียวในรถ ในเวลาหลังเที่ยงคืน ผู้ต้องสงสัยเอนตัวเข้ากับคอนโซลเหมือนพยายามที่จะซ่อนบางอย่างเมื่อตำรวจเดินเข้ามาใกล้ ตำรวจให้เหตุผลว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นปัจจัยสำคัญที่เจ้าพนักงานเรียกให้หยุดเพื่อทำการสอบสวน ศาลยังกล่าวด้วยว่า ในสถานการณ์นี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประสบการณ์และความรอบคอบของเจ้าพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีแล้วในการเรียกให้หยุด[35]

(21) ความสัมพันธ์ของผู้ต้องสงสัยกับพ่อค้าขายยาเสพติด เป็นมูลเหตุเพียงพอในการเรียกให้หยุดและค้นตัวบุคคลภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

ประการแรก การพบจำเลยกำลังเดินอยู่กับชายคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นพ่อค้าขายยาเสพติดซึ่งกำลังติดต่อกับตัวแทนให้ส่งโคเคนจำนวน 15 กรัม

ประการที่สอง ลักษณะของความผิดประเภทขนส่งยาเสพติดเป็นอาชญากรรมที่มีความร้ายแรง และ

---

[33]คดี People v. Atmore , 13 Cal.App.3d. 244, 247 (1970)

[34]คดี States v. Rodriquez,383 N.J. Super.66(App.Div 2006)

[35]คดี United Stated v. Stanley ,915 F.2d54

ประการสุดท้าย เพื่อนของจำเลยได้ติดต่ออยู่กับพ่อค้าคนหนึ่งที่ตัวแทนได้แลกเปลี่ยนเอาโคเคนให้ 1 กิโลกรัม

ศาลวินิจฉัยว่า การเรียกให้หยุดของเจ้าหน้าที่มีเหตุสมควรแล้วเพราะจำเลยได้เดินไปและหยุดหน้ารถที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นตัวแทนขายยาเสพติดเพื่อแลกเปลี่ยนโคเคนกัน จึงเป็นพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดและผู้ร้ายประเภทนี้มักมีอาวุธอยู่เสมอ ประกอบกับอยู่ในแหล่งค้ายาเจ้าพนักงานจึงมีสิทธิที่จะทำการค้นตัวบุคคลเพื่อปกป้องตัวเองจากอาวุธที่ซ่อนอยู่หรือเพื่อไม่ให้ตนเองหรือผู้อื่นเป็นอันตราย การที่เจ้าหน้าที่ค้นกระเป๋าสตางค์จึงมีเหตุอันสมควรแล้ว[36]

(22) ตำรวจเรียกให้หยุดเพราะขับรถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หลังจากการไล่ล่าตำรวจเรียกให้จำเลยออกจากรถ ก่อนลงจากรถจำเลยถอดเสื้อโค้ชออกแล้ววางไว้ที่เบาะคนขับ ตำรวจเอะใจจึงเอาเสื้อหยิบโค้ชขึ้นมาปรากฏว่าปืนพกหล่นออกมาจากเสื้อ ตำรวจจึงยึดปืนพก ศาลว่าทั้งการเรียกให้หยุดและการค้นตัวบุคคล ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ประเด็นคือ ตำรวจกระทำการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ที่เข้าไปในรถของจำเลยและหยิบเสื้อโค้ชขึ้นมา ศาลวินิจฉัยว่าตำรวจกระทำถูกต้องแล้วที่เรียกให้ชายลงจากรถเพราะในสถานการณ์นั้นเจ้าพนักงานมีสิทธิที่จะแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธและจำเลยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการpat down โดยการถอดเสื้อโค้ชออก ตำรวจไม่มีหน้าที่เสี่ยงว่าพวกเขาจะกลับไปที่รถอีกหรือไม่ การที่เจ้าพนักงานเข้าไปตรวจดูเสื้อโค้ชจึงเป็นวิธีการที่มีเหตุผลในการคุ้มครองความปลอดภัยของตัวเองจากบุคคลที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ [37]

(23)มาตรฐานความสงสัยอาจจะไม่ขนาดต้องพิสูจน์ได้จริงและเป็นความสงสัยโดยสุจริตของเจ้าหน้าที่ก็เพียงพอแล้ว[38]

(24) ตำรวจปฏิบัติการตามข้อมูลที่ได้รับมาว่ามีคนสองคนเช่ารถเพื่อขนยาเสพติด จึงทำการหยุดยานพาหนะแต่พบบุคคลที่สาม(จำเลย)ซึ่งตำรวจไม่มีข้อมูลมาก่อน จำเลยถูกควบคุมตัวและค้นรถ พบสารที่จะนำไปผลิตเป็นกัญชาใต้เบาะที่จำเลยนั่ง ตำรวจจึงค้นตัวเขาโดยไม่ขอความยินยอมและพบมีดในถุงที่บรรจุสารที่จะนำไปผลิตกัญชา จำเลยถูกฟ้องฐานครอบครองกัญชาโดยมีเจตนาที่จะจำหน่าย ศาลสูงพิพากษาว่าแม้ข้อมูลของตำรวจจะไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่

---

[36]คดี United Stated v. CruZ , 909 F.2d 422

[37]คดี Modesto v. State 258 A.2d 287

[38]คดี Jarrett v Chief Constable of the West Midlands,cited in Westlaw

ตำรวจพบ(จำเลย) แต่รถคันดังกล่าวก็ใช้ในการบรรทุกยาเสพติด ตำรวจจึงมีเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้หยุด และมีอำนาจที่จะควบคุมตัวบุคคล และค้นตัวบุคคลได้[39]

(25) ตำรวจได้รับข้อมูลจากผู้นิรนามว่ามีบุคคลกำลังทำผิดกฎหมายยาเสพติด และเมื่อตำรวจไปถึงได้พบจำเลยที่นั่น แต่จำเลยปฏิเสธว่าไม่ได้ทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ให้การโดยสมัครใจว่าเมื่อก่อนเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อค้นตัวพบกัญชา ศาลพิพากษาว่า สถานการณ์ทั้งหมดนำมารวมเข้าด้วยกันจึงเพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยได้[40]

(26) ปัญหาว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ที่ถูกควบคุมเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่ “ศาลต้องพิจารณาเหตุอันควรสงสัยจากข้อมูลทั้งหมดซึ่งระดับข้อเท็จจริงของเหตุควรสงสัยต่างจากระดับข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดให้เป็นภาระการพิสูจน์”

เหตุอันควรสงสัย ในขั้นแรกยากที่จะกำหนดว่าข้อเท็จจริงใดเป็นหรือไม่เป็น และจำเป็นที่จะต้องคำนึงข้อเท็จจริงที่ตามมาด้วย มันยากที่จะกล่าวว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวแสดงว่าเขาได้เกี่ยวพันกับการก่อการร้าย ดังนั้นการตัดสินต้องตั้งขึ้นและประเมินจากมูลเหตุชักจูงใจหรือเจตนาที่ปรากฏในขณะนั้น ศาลจึงต้องนำการข้อเท็จจริงจากผู้ที่ถูกควบคุมมารวมพิจารณาด้วย[41]

(27)ผู้ต้องสงสัยถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ารถที่กำลังเขาขับอยู่ เชื่อว่าถูกขับโดยชายสองคนที่ทำผิดเกี่ยวกับอาวุธที่เมืองลิเวอร์พูล เจ้าหน้าที่มีรูปของรถและรูปของคนร้าย (A) ในขณะเกิดเหตุที่เมืองลิเวอร์พูล มีการบรรยายเกี่ยวกับผู้โดยสาร เมื่อรถถูกพบอีกครั้งที่เมืองพาร์ทเม้าส์ เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าคนขับเป็นบุคคลคนเดียวกับที่เมืองลิเวอร์พูล ตำรวจไม่ได้เรียกให้หยุดจนกระทั่งวันต่อมาในวันที่ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ขับ ซึ่งตำรวจก็รู้ว่าผู้ต้องสงสัยไม่ใช่คนที่ขับรถที่เมืองลิเวอร์พูล แต่ตำรวจสงสัยว่าเขาเป็นผู้โดยสาร

ประเด็นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเหตุอันควรสงสัยที่จะเรียกให้ผู้ต้องสงสัยหยุดหรือไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ตำรวจมีความเชื่ออย่างสุจริตว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้โดยสาร โดยคำนวณจากระยะทางระหว่างเมืองลิเวอร์พูลและเมืองพาร์ทเม้าส์ หรือช่วงเวลาหรือการระบุลักษณะของคนร้าย(A)ที่ตรงกันทำให้มีความเชื่อมโยงระหว่างรถและคนร้าย ในทางกลับกันถ้าความเชื่อมโยงระหว่างรถและผู้ต้องสงสัยหมดลงแล้วทำให้ไม่มีเหตุอันควรสงสัยการกระทำของตำรวจจะไม่ชอบ

---

[39]คดี Campbell (Duncan McNeil) v HM Advocate,cited in Westlaw

[40]คดี Weir v Jessop,cited in Westlaw

[41]คดี Secretary of State for the Home Department v. NNCase , cited in Westlaw

ด้วยกฎหมายทันที ในกรณีนี้เหตุอันควรสงสัยจึงมีได้เพราะเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้โดยสารหรือไม่

(28) เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายพบจำเลยซึ่งรู้จักกันดีว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยใกล้ๆกับบ้านที่เชื่อว่าใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อตำรวจสองคนเข้าไปใกล้ได้แจ้งให้จำเลยทราบว่าจะทำการค้นตัวและควบคุม จำเลยวิ่งหนี ก่อนที่ตำรวจจะจับจำเลยได้ ตำรวจสังเกตเห็นว่าจำเลยได้เอาบางอย่างใส่เข้าไปในปาก เจ้าหน้าที่สั่งให้คายออกมาแต่จำเลยไม่ทำและกลืนเข้าไป

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า 1) พฤติกรรมที่น่าสงสัยของจำเลยทั้งประวัติเก่าและสถานที่ที่เกิดเหตุ มีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยได้ครอบครองยาเสพติดแล้วและ 2) เมื่อจำเลยถูกควบคุมตัวและค้นตัวบุคคล เขาได้วิ่งหนีและใส่บางสิ่งเข้าไปในปาก สถานการณ์มันแน่ชัดแล้ว ไม่ใช่เพียงแต่มีเหตุอันควรสงสัย ตำรวจจึงสามารถใช้อำนาจได้ตามมาตรา 23Misuse of Drugs Act 1971[42]

(29) จำเลยทั้งสามอายุ 15 14 และ12 ปี ถูกจับเพราะสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถตู้ขับรถชนผู้เสียหายที่เดินอยู่ริมถนนแล้วหนี ทำให้ผู้เสียหายเสียชีวิต ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าพบจำเลยทั้งสามวิ่งออกมาจากที่เกิดเหตุและเข้าไปดูรถตู้ที่จอดทิ้งไว้แล้วB เป็นผู้ขับรถออกไป ซึ่งเป็นน้องชายของพวกเขาและตำรวจรู้จักดีว่าBเป็นพวกอาชญากรรมรถยนต์ ตำรวจจึงไปที่บ้านของ B ที่พวกเขาอาศัยอยู่กับมารดา ตำรวจได้ถามเกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นตอนเย็น พวกเขาถูกจับและถูกควบคุมตัวจนกระทั่งวันต่อมา ผู้อุทธรณ์ทั้งสามคนในที่นี้ B อุทธรณ์ว่าจับไม่ชอบเพราะไม่มีเหตุอันควรสงสัย ศาลพิพากษาว่าการจะดูว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ ไม่ได้พิจารณาแยกเป็นแต่ละองค์ประกอบของแต่ละบุคคลถึงความมีอยู่ของเหตุอันควรสงสัย แต่ต้องพิจารณารวมกันในเวลานั้นๆ ความสัมพันธ์ของ B กับพี่ชายผู้ที่ก่ออาชญากรรมรถยนต์เป็นประจำ และความสงสัยในความเกี่ยวพันกับบุคคลหนึ่งที่เคยใช้รถแวน ก่อให้เกิดเหตุอันควรสงสัยที่ชอบด้วยกฎหมาย ตำรวจสามารถอ้างอิงถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นได้เพื่อให้เกิดเหตุอันควรสงสัยว่า B เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การตัดสินใจจับ B จึงมีเหตุอันควรสงสัยและการกระทำที่ต่อมาจากนั้นชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน[43]

(30)มีการกล่าวหาต่อตำรวจว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นและมีการบรรยายลักษณะของผู้กระทำความผิดว่าผู้กระทำเป็นผู้ชายอายุประมาณ 19 ปีหรือต่ำกว่านั้น มีโครงสร้างเล็ก ผมสี

---

[42]คดี Barr (Stewart Martin) v Vannet ,cited in Westlaw

[43]คดี Buckley v Chief Officer of Thames Valley,cited in Westlaw

น้ำตาลและโกนหนวดอย่างเกลี้ยงเกลา และบอกว่าผู้กระทำความผิดต้องการให้ผู้เสียหายเรียกเขาว่า แดลเนียล ไม่ใช่แดนนี่ หลังจากการประทุษร้าย ผู้กระทำผิดได้ขโมยของในกระเป๋าสะพายของเหยื่อ เจ้าหน้าที่สืบสวนที่รู้จักครอบครัวของจำเลยเพราะลักษณะที่เหยื่อบรรยายเหมือนกับลักษณะของจำเลยและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าคืนนั้นจำเลยทำงานเป็นคนเปิดประตูที่สถานบริการ และสถานบริการก็อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยได้แต่งกายที่เหมือนกับที่บรรยาย ประกอบกับผู้กระทำความผิดเคยถูกศาลพิพากษาเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์มาแล้ว 2 ครั้ง และเป็นที่รู้จักชื่อว่า แดลเนียล จากข้อมูลที่กล่าวมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงจึงสรุปว่าเขามีเหตุอันควรสงสัย จึงจับจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนอย่างไม่เหมาะสมในการจับกุมจำเลยและไม่มีเหตุอันควรสงสัยในการจับจำเลยเพราะจำเลยอายุ 20 ปีแล้ว ไม่ได้โกนหนวดและมีโครงสร้างที่ใหญ่ ศาลปฏิเสธว่าเหตุผลอื่นๆ เช่น การที่จำเลยชอบให้เรียกชื่อว่าแดลเนียลและอยู่ในระยะทางที่สามารถเดินไปที่เกิดเหตุได้ ยังไม่สมเหตุสมผลเพียงพอที่จะทำการจับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ศาลชั้นต้นกำหนดระดับความสงสัยสูงเกินไป <u>รายละเอียดของการสอบสวนมีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด</u> กรณีนี้มีเหตุสมควรที่จะปฏิบัติการเพราะเจ้าหน้าที่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ จำเป็นต้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันอันตรายอย่างอื่นที่อาจเกิดขึ้นและรักษาไว้ซึ่งพยานหลักฐาน ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้รับมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กับการบรรยายลักษณะของผู้เสียหายกับคนร้ายอย่างสอดคล้องกัน [44]

(31) เจ้าพนักงานผู้ทำการจับให้การว่าเขาเข้าไปในภัตตาคารพบผู้ต้องหาอยู่ในอาการมึนเมากำลังก่อกวนและบอกให้เขาออกไปจากภัตตาคาร ตำรวจเห็น"วัตถุ"<u>ยื่นออกมาจากเสื้อคลุมที่ผู้ต้องหา</u>พยายามซ่อน จึงเกิดความสงสัยว่าผู้ต้องหาอาจครอบครองอาวุธร้ายแรง ตำรวจจึงทำการค้นตัว ศาลพิพากษาว่า เมื่อจำเลยได้<u>ลุกขึ้นในภัตตาคารอย่าง " ลุกลี้ลุกลน "</u> จึงเป็นเหตุสมควรเพียงพอแล้ว เพราะ"สิ่งของ"ที่อยู่ในเสื้อของจำเลยและท่าทางที่ลุกออกจากที่นั่งแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยครอบครองสิ่งของอันตรายแล้ว[45]

(32) มีโทรศัพท์นิรนามโทรมาที่สถานีตำรวจบรรยายลักษณะรถโดยให้ที่อยู่ของรถไว้

---

[44]คดี Chief Constable of West Yorkshire v Armstrong(CA (Civ Div)Court of Appeal (Civil Division) ,cited in Westlaw

[45]คดี Miller v Jamieson ,cited in Westlaw

และระบุว่าคนขับรถอยู่ในอาการมึนเมา อีกสี่นาทีต่อมาตำรวจมาถึงพบรถแต่ไม่มีคนอยู่ในรถ ต่อมาตำรวจพบจำเลยเดินขึ้นรถกับบุคคลหนึ่งและขับรถออกไป จำเลยโต้แย้งว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างโทรศัพท์นิรนามและสิ่งที่ตำรวจสังเกตเห็น ตำรวจต้องมีข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระเพื่อก่อให้เกิดความสงสัยตามมาตรา 5(1)(a)Road Traffic Act 1988 ว่าจำเลยขับรถขณะมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ศาลพิพากษาว่าตำรวจมีเหตุอันควรสงสัยที่จะเรียกให้จำเลยหยุดเพื่อตรวจระดับแอลกอฮอล์ เพราะช่วงเวลาที่มีโทรศัพท์นิรนามโทรแจ้งกับเวลาที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไม่มีจุดสิ้นสุดของความต่อเนื่อง[46]

(33) มาตรา 60 ของ the Civic Government (Scotland) Act 1982 ให้อำนาจตำรวจค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลครอบครองของที่ลักขโมยมา คดีนี้ตำรวจหยุดรถที่ผู้ต้องหาขับ เมื่อค้นยานพาหนะพบของที่ถูกลัก ตำรวจจึงฟ้องจำเลย การค้นเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสังเกตว่าผู้ต้องหาได้เอาบางอย่างไว้ใต้แผงหน้าปัดรถยนต์ สิ่งที่ทำให้ตำรวจเกิดความสงสัยคือตำรวจสงสัยว่าอาจมีทรัพย์สินหายหรือยาเสพติดซุกซ่อน ผู้อุทธรณ์(จำเลย)ฎีกาต่อศาลสูงว่า ความสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุอันควรสงสัยในการค้นตามมาตรา 60 ศาลพิพากษาว่า การสงสัยว่าวัตถุนั้นเป็นของที่ถูกลักมาและเมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่าเขาเห็นสิ่งของนั้นอาจเป็นของที่ถูกลักมาหรือเป็นยาเสพติด กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอที่ตำรวจจะทำการค้นโดยชอบด้วยกฎหมาย [47]

(34)ตำรวจพบจำเลยในแหล่งค้ายา เมื่อจำเลยพบตำรวจเขาหยุดและหันกลับไป เขาบอกตำรวจว่าเขามองหา “ นก ” ตำรวจจึงทำการค้นตัวจำเลยและพบยาเสพติด ระหว่างการพิจารณามีการคัดค้านการรับฟังพยานหลักฐานว่าการค้นพบยาเสพติดของตำรวจไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยได้ครอบครองยาเสพติด

ศาลสูงพิพากษาว่าในการตัดสินว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ คดีนี้เจ้าพนักงานพิจารณาถึงความใกล้ชิดกับแหล่งค้ายาเสพติด ความกำกวมในการตอบคำถามของจำเลยและพฤติกรรมที่เห็นตำรวจแล้วหันกลับเพียงพอทำให้เกิดเหตุอันควรสงสัยแล้ว[48]

(35) จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดตามมาตรา5(2) ของ Misuse of Drugs Act 1971 และการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นตัวจำเลยโดยมิชอบเพราะ

---

[46]คดี Thomson v Ritchie, cited in Westlaw

[47]คดี Druce v HM Advocate,cited in Westlaw

[48]คดี Stark (John) v Brown ,cited in Westlaw

เจ้าหน้าที่ออกหมายค้นสถานที่ที่มีบุคคลอื่นเป็นผู้ครอบครองอยู่ ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการค้น จำเลยถูกสั่งให้หันหน้าเข้ากำแพง และถูกค้นโดยตำรวจและพบกัญชาในกระเป๋าเสื้อ ตำรวจไม่มีสิทธิที่จะค้นตัวจำเลยตามมาตรา23(2) ของ Misuse of Drugs Act 1971 เพราะไม่มีข้อเท็จจริงทางภาวะวิสัยที่ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดเหตุอันควรสงสัย ว่าจำเลยได้ครอบครองยาเสพติดในเวลานั้น ศาลสูงพิพากษาว่าการพิจารณาว่าเป็นอัตตะวิสัยหรือเป็นภาวะวิสัยหรือไม่ไม่สำคัญ ความสำคัญอยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงและสถานการณ์นั้นทำให้เจ้าหน้าที่เกิดเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ คดีนี้เมื่อตำรวจมีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานที่นั้นมียาเสพติด และจำเลยไม่มีเหตุผลที่จะแก้ตัวได้ว่าทำไมถึงอยู่ในสถานที่นั้น ทำให้เจ้าหน้าที่จึงมีเหตุอันควรสงสัย[49]

(36) บ่ายวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2000 จำเลยได้ขับรถจากัวร์มาตามถนน Waione ทางซ้ายกับเพื่อนเพื่อไปส่งลูกชายสองคนที่สนามบินไปซิดนีย์ จำเลยขับรถข้ามสะพานมาระหว่างนั้นมีเส้นสีขาวขีดกั้นฝั่งขวาและซ้าย จำเลยได้ขับมาทางที่ไม่มีเส้นสีขาวขั้นถนนแต่มีเครื่องกั้นวางอยู่หลังจากที่จำเลยขับรถผ่านมาได้สักพัก ตำรวจได้ขับตามรถจำเลยมาและบอกให้หยุดเพื่อขอตรวจใบขับขี่ แต่จำเลยไม่มีจึงให้ชื่อและที่อยู่และข้อมูลส่วนตัวไป ตำรวจจึงกลับที่รถเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจังหวะนั้นเองจำเลยได้ขับรถออกไป ตำรวจจึงไล่ตามโดยกระพริบสัญญาณไฟและเปิดสัญญาณวอร์ จำเลยจึงได้หยุดรถอีกครั้งตำรวจและจำเลยเกิดปากเสียงและจบลงด้วยการที่จำเลยให้เพื่อนขับรถไปส่งลูกชายที่สนามบินและจำเลยตามตำรวจไปที่สถานีตำรวจระหว่างนั้นจำเลยได้ทำคำร้องเกี่ยวกับการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของตำรวจผู้นี้

จำเลย(ผู้อุทธรณ์)ต่อสู้ว่าตำรวจไม่มีอำนาจเรียกให้หยุด การเรียกให้หยุดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมด เช่น การควบคุมและการค้นตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ศาลพิพากษาว่าตามมาตรา 114 ของ Land Transport Act 1998 ตำรวจมีอำนาจเรียกให้ยานพาหนะหยุด หรือ ให้แสดงชื่อและที่อยู่ แต่ใช้กับกรณียานพาหนะบนท้องถนนเท่านั้น และการเรียกให้ยานพานะหยุดไม่จำเป็นต้องเป็นความสงสัยว่าได้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เพียงอย่างเดียว(เกี่ยวกับกฎหมายจราจร) แต่อาจเป็นความสงสัยทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายยานพาหนะเลย

มาตรา 114 ให้อำนาจอย่างกว้างขวางแก่ตำรวจที่กระทำในหน้าที่โดยสุจริต เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยบนถนน และขณะทำการควบคุมตัวตำรวจต้องให้เหตุผล

---

[49]คดี Guthrie (James) v Hamilton ,cited in Westlaw

แก่ผู้ขับขี่ว่าทำไมถึงเรียกให้เขาหยุด และต้องไม่ให้เหตุผลที่เป็นความเท็จ ดังนั้นเมื่อตำรวจกระทำตามนี้แม้จะกระทำโดยโดยเข้าใจผิดก็จะได้รับการคุ้มครอง แต่ตำรวจที่สร้างเหตุผลเท็จในการเรียกผู้ขับขี่ให้หยุดจะไม่ได้รับการคุ้มครอง[50]

4.3.2 แนวคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัย

(1)คำบอกเล่าของผู้นิรนามนำมาสนับสนุนความสงสัยที่มีสมเหตุสมผลไม่ได้ ถ้าไม่มีใครรู้เกี่ยวกับผู้ให้เบาะแสเลย แม้จะพบคนที่มีลักษณะตามที่บอกเล่าไว้ก็ตาม และขณะที่พบไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญา ไม่เห็นอาวุธปืน ไม่มีลักษณะที่ผิดปกติ ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานเข้าไปค้นตัวเขาและยึดอาวุธปืนจากกระเป๋าเสื้อของเขา ศาลสูงสุดรัฐฟลอริดาวินิจฉัยว่า การค้นไม่สามารถทำได้ เพราะคำบอกกล่าวจากผู้นิรนามไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะเป็นเหตุอันควรสงสัย

(2)กรณีที่ตำรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยด้วยข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวคือพวกเขาเป็นคนเม็กซิกันศาลให้เหตุผลว่าเชื้อชาติไม่สามารถเป็นเหตุผลเดียวที่ก่อให้เกิดเหตุอันควรสงสัย การเรียกให้หยุดโดยสุ่มเอาเองจึงไม่สามารถทำได้

(3)การหลบหนีในเขตที่เป็นแหล่งยาเสพติดในพื้นที่เกิดมีอาชญากรรมสูง ตำรวจจะอ้างเหตุผลนี้เพียงเหตุเดียวสนับสนุนเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้หยุดเพื่อสอบสวนไม่ได้[51]

(4)การเรียกให้หยุดที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลประวัติการค้ายาเสพติดแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัย ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงต่อไปว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่จะกระทำความผิดต่อไป[52]

(5) เจ้าหน้าที่ไม่รู้การสนทนาของจำเลยกับคนอื่นๆ ไม่เห็นว่าพวกเขาส่งอะไรให้กันที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปเพราะข้อเท็จจริงเพียงว่าคนอื่นๆที่จำเลยติดต่อด้วยเป็นคนติดยา ซึ่งข้อเท็จจริงเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัย นอกจากนี้ไม่มีข้อมูลที่ชี้ว่าเจ้าหน้าที่คิดว่าจำเลยอาจมีอาวุธหรืออาจเป็นอันตราย ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงไม่มีเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้

---

[50]คดีRobert Edward Jones v. Her Majesty's Attorney-General Sued on Behalf of New Zealand Police,cited in Westlaw

[51]คดี Illinois v. Wardlow , 528 U.S. 119 (2000).

[52]คดี U.S. v. sokolaw , 490 U.S. 1 (1989).

หยุดหรือค้นตัวบุคคลเพื่อปกป้องตนเอง เฮโรอีนที่ยึดได้ในคดีนี้จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้[53]

(6) เจ้าหน้าที่ให้การว่า " รู้สึกว่ามีหลายอย่างผิดปกติ " ไม่เพียงพอที่จะเป็นข้อเท็จจริงที่จะชี้ว่ามีการกระทำความผิดอันจะเป็นเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้หยุดได้[54]

(7) คำบอกกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยมีอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายในครอบครองไม่เป็นเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้หยุดเพื่อการสอบสวนและค้นตัวบุคคลในทันที[55]

นอกจากนี้ในสถานการณ์การเรียกให้หยุดและการค้นตัวบุคคล อาจไม่มีการกระทำผิดเกิดขึ้น แต่อาจมีความเป็นไปได้ว่าการกระทำความผิดอาจกำลังเกิด บางทีอาจอยู่ในขั้นวางแผน แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องมีข้อเท็จจริงที่ชี้ไปได้ว่าการกระทำความผิดอาจเกิดขึ้น[56]

(8) เจ้าหน้าที่เรียกให้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของผู้ต้องสงสัยหยุดบนทางด่วนในเวลากลางวัน โดยไม่มีคำบอกกล่าวหรือการสังเกตว่าผู้ต้องสงสัยมีอาวุธหรือเป็นอันตราย เป็นการเรียกให้หยุดที่ไม่มีเหตุอันควรสงสัย[57]

(9) เพียงแค่เจ้าพนักงานเข้าใกล้บุคคล บุคคลมีสิทธิเพิกเฉยและทำกิจของตนต่อไปและการปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือใดๆ ไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยที่จะทำให้ตำรวจเกิดอำนาจที่จะควบคุมตัว(detention and seizure)ได้[58]

(10)ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ไม่สามารถเป็นตัวบ่งบอกว่าจะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นได้

1) จำเลยมาจากแหล่งค้ายาเสพติด
2) จำเลยปรากฏตัวในเวลาเช้าตรู่
3) จำเลยหรือเพื่อนจำเลยพยายามปกปิดข้อเท็จจริงว่าเขากำลังจะเดินทางไปด้วยกัน
4) ไม่มีกระเป๋าอื่นใด นอกจากประเป๋าสะพายไหล่

---

[53]คดี Sibron v. New york ,392 U.S.40(1968)

[54]คดี United v. Pavelski , 789 F.2d 485 (7th Cir. 1986)

[55]คดี Florida v, J.L. 529 U.S. 266 (2000)

[56] John N. Ferdico,*Supra note10,* p.273.

[57]คดี United Stated v. Melendez – Garcia , 28 F.3d 1046

[58]คดี Florida v.Royer , 460 U.S. 491 (1983)

ความเชื่อของเจ้าพนักงานว่าจำเลยและเพื่อนของเขากำลังจะเดินทางไปด้วยกัน ความเชื่อเป็นแค่ลางสังหรณ์ และเป็นความสงสัยที่ไม่สามารถบ่งบอกอะไรได้มากกว่าจะเป็นการสรุปที่มาจากประสบการณ์ของเจ้าพนักงาน ความเชื่อจึงไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัย[59]

(11)การสุ่มตรวจยานพาหนะ ตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการคาดเดาจากข่าวลือ จากการตรวจดูใบอนุญาต คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ไม่เป็นมูลเหตุที่จะทำให้เกิดการเรียกให้หยุดได้[60]

ศาลวินิจฉัยว่าการอ้างข้อเท็จจริงว่าความสงสัยว่าคนขับมอเตอร์ไซด์ไม่มีใบขับขี่ หรือยานพาหนะนั้นไม่ได้จดทะเบียน การหยุดรถยนต์และการกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้ขับขี่ เพื่อที่จะตรวจสอบใบขับขี่ และการจดทะเบียนนั้น ถือว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะกระทำได้ตาม Fourth Amendment ศาลวินิจฉัยว่าการสุ่มตรวจค้นยานพาหนะ แสดงออกถึงการใช้อำนาจโดยอำเภอใจของเจ้าหน้าที่และการใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติ[61]

(12) เจ้าพนักงานลาดตระเวนไปในพื้นที่ที่มีการขายยาเสพติด เรียกรถจำเลยให้หยุดขณะที่เขากำลังเดินจากกับเพื่อน เจ้าพนักงานเห็นว่าสถานการณ์น่าสงสัยและไม่เคยเห็นบุคคลนั้นมาก่อน ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยว่า การเรียกให้หยุดไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่จำเลยอยู่ในบริเวณที่เกิดอาชญากรรมสูงการขายยาเสพติดเป็นประจำแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่สมมติฐานที่จะสรุปว่าจำเลยพัวพันกับการกระความผิดทางอาญา พฤติกรรมของจำเลยไม่แตกต่างจากคนเดินถนนทั่วไปในย่านนั้น คดีนี้ต่างจาก**คดี** Illinois v.Wardlow ซึ่งศาลได้ย้ำว่าการปรากฏว่าเป็นอาชญากรรมสูงประกอบกับความน่าสงสัยเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ ทำให้เป็นการเรียกให้หยุดที่ชอบด้วยกฎหมายได้[62]

(13) ตำรวจสองคนได้รับรายงานจากวิทยุว่ามีการยิงกัน ระบุรูปพรรณของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นชายผิวดำสองคนที่ใส่เสื้อโค้ชสีเข้มและชายเปอโตริโกที่ใส่เสื้อโค้ชสีอ่อน ตำรวจรีบไปยังที่เกิดเหตุและพบชายสองคนที่มีลักษณะตามที่ระบุในวิทยุเดินอยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุ แต่ไม่มีการกระทำที่เป็นพิรุธใดๆ ข้อเท็จจริงเดียวที่โยงตำรวจเข้ากับชายสองคนคือการที่มีผิวสีและชาย

---

[59]คดี Reid v. Georgia , 448 U. S. 438

[60]John N. Ferdico,*Supra note 10,* p.293.

[61]คดี Delaware v.Prouse , 440 U.S. 648 (1979).

[62]คดี Brown v. Texus 443 U.S. 47, 99 S.Ct.2637

เปอเตอริโกที่ใส่เสื้อสีอ่อน และกำลังเดินใกล้ๆกับที่เกิดเหตุ ตำรวจจึงหยุดชายทั้งสองคนและค้นตัวในที่เกิดเหตุ พบปืนในเข็มขัดของจำเลย

ศาลให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า สถานการณ์ต่างๆในคดีนี้ไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าความปลอดภัยของตนเองหรือของผู้อื่นอยู่ในอันตราย เพราะมิฉะนั้นชายเปอเตอริโกที่ใส่เสื้อโค้ชสีอ่อน ที่เดินอยู่ในถนนละแวกนั้นก็เป็นผู้ต้องสงสัยหมด คดีนี้ตำรวจจึงตรวจค้นโดยไม่มีเหตุผล[63]

(14) ข้อเท็จจริงเพียงว่า บุคคลนั้นจับกระเป๋าสะพายไหล่ไว้แน่นและปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ไม่มีมูลเหตุในการเรียกให้หยุดและสถานการณ์รอบตัวไม่มีข้อเท็จจริงที่จะก่อให้เกิดความสงสัยว่าบุคคลนั้นมีอาวุธและเป็นอันตราย[64]

(15) คดีนี้เหตุเกิดที่สนามบินในไมอามี ตำรวจสืบสวนสอบสวนยาเสพติดของนิวยอร์กเชื่อว่า จำเลยอาจขนยาเสพติด เมื่อจำเลยมาถึงทางเข้าสนามบิน ตำรวจได้เข้าไปหาและแสดงความสงสัย เรียกให้จำเลยแสดงบัตรประจำตัว เมื่อจำเลยปฏิเสธที่จะให้ค้นสัมภาระของเขา ตำรวจคนหนึ่งพูดว่าเขาจะเอาสัมภาระไปนี้ไปเพื่อไปขอหมายจากศาล และตำรวจได้ส่งกระเป๋าไปยังสนามบินแห่งอื่นโดยให้สุนัขดมกลิ่น (sniff dog)ตรวจหา และสุนัขดมกลิ่นได้แสดงปฏิกิริยากับกระเป๋าใบหนึ่ง หลังจากที่ตำรวจได้ยึดกระเป๋าใบนี้มาจากจำเลยเป็นเวลา 90 นาทีหลังจากที่ตำรวจจะได้หมายค้นจากศาล พบโคเคนในกระเป๋าจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามคดีนี้ขอบเขตในการควบคุมตัวเพื่อการสอบสวน สัมภาระและการยึดสัมภาระของจำเลยที่เป็นเวลากว่า 90 นาที ทำให้การยึดไม่มีเหตุอันสมควร ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแจ้งให้จำเลยทราบว่ากระเป๋าของจำเลยจะถูกส่งไปที่ไหน จำเลยต้องรอนานเท่าใด และการดำเนินการภายหลังได้กระเป๋าคืนกรณีการสอบสวนไม่ทำให้เจ้าหน้าที่หายสงสัย สรุปคือการยึดสัมภาระของจำเลยเพื่อไปสอบสวนตำรวจทำเกินไปกว่าอำนาจเพราะต้องยึดถือในระยะเวลาที่สั้นตามความสงสัยที่มีเหตุผล[65]

(16) ตำรวจคนใดเริ่มการค้นตัวบุคคลโดยคำนึงถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ชาติกำเนิดมากกว่าพฤติกรรมเป็นรายบุคคลและข้อมูลที่ตำรวจใช้โยงไปสู่พฤติกรรมที่น่าสงสัยของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทางอาญา[66]

---

[63]คดี Commonwealth v. Berrios , 263 A.2d 342,343

[64]คดี United Stated v. 37,590.00 736 F.Supp.(S.D.N.Y.1990)

[65]คดี United Stated v. Place , 462 U.S. 696 (1983)

[66] John N. Ferdico,*supra note 10*,p.297.

(17) ตำรวจเห็นจำเลยทำงานในบริษัทที่สงสัยว่าดำเนินธุรกิจค้ายาเสพติด ซึ่งบริษัทตั้งอยู่ใกล้สถานบริการที่ตำรวจสงสัยว่ามีการค้ายาเสพติดเกิดขึ้น ตำรวจนายหนึ่งได้รับคำสั่งจากตำรวจระดับสูงว่าให้ควบคุมตัวจำเลยไว้ จำเลยถูกค้นตัวและเจอยาบ้าซึ่งจำเลยก็ยอมรับว่าจะเอาไปจำหน่าย จำเลยถูกฟ้องว่ามียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจะจำหน่าย ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุอันควรสงสัยก่อนที่จะเข้าควบคุมตัวจำเลยทำให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การจับจำเลยเกิดขึ้นบนท้องถนน ไม่มีเหตุการณ์ที่เชื่อมจำเลยเข้ากับสถานบริการและจำเลยไม่มีพฤติกรรมที่ต้องสงสัย[67]

(18)จำเลยถูกฟ้องข้อหานำเข้าโคเคนโดยใส่ไว้ในกระเป๋าโน็ตบุ๊คผ่านสนามบินเมืองแมนเชสเตอร์มาจากประเทศเวเนซุเอลา ประเด็นในคดีนี้คือจำเลยตั้งใจใช้กระเป๋าบรรจุจำนวนโคเคนตามที่ถูกกล่าวหาและพยายามที่จะนำยาเสพติดเข้ามาในสหราชอาณาจักรหรือไม่ ข้อเท็จจริงมีว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้เรียกให้จำเลยที่ไม่ผ่านช่องตรวจให้หยุดและทำการตรวจสิ่งของสี่อย่างของจำเลย คือ หนังสือเดินทาง กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ และแปรงสีฟันของจำเลย โดยใช้ผงสีขาวที่ใช้ในตรวจสอบโคเคนในกระเป๋าของจำเลยและผงได้แสดงปฏิกิริยา จำเลยจึงถูกจับ

จำเลยอ้างในคำแถลงการณ์สองประเด็นด้วยกัน คือ หนึ่ง เจ้าหน้าที่อ้างความสงสัยจากตัวของเธอว่าเธอมาจากเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นแหล่งของโคเคน และเธอได้ไปนั่นสี่ครั้ง สองการที่มีการทดสอบใช้สารตอบสนองต่อโคเคน เธอกล่าวว่าเธอเคยสัมผัสโคเคนสามสัปดาห์ก่อนหรือสามเดือนก่อนหน้านี้ และการสัมภาษณ์ที่ต่อมาจำเลยยอมรับว่าเคยใช้โคเคนแต่ไม่บ่อย ใช้แค่ครั้งละหนึ่งกรัม เจ้าหน้าที่จึงใช้เหตุดังกล่าวเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือเชื่อว่าผลการตรวจสอบต้องตอบสนองกับผู้เดินทางที่มาจากแหล่งโคเคน

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาพิพากษาว่าหลังจากที่ได้รับฟังพยานหลักฐานมาทั้งหมด แค่การใช้น้ำยาตรวจหาว่าเป็นผงโคเคนหรือไม่ ยังไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัย เพราะเหตุอันควรสงสัยเกิด***หลัง***จากที่มีการน้ำยาตรวจหาว่าเป็นผงโคเคน[68]

(19)วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2005 Hilda Gondwe Da Silva ถูกฟ้องว่า ได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นในการแสวงหาผลประโยชน์จากการกระทำความผิด โดยรู้หรือสงสัยว่าบุคคลนั้นเป็นหรือ

---

[67]คดี Houston (David) v Carnegie ,cited in Westlaw

[68]คดี Regina v. Elizabeth Minto,cited in Westlaw

ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาตามมาตรา 93A(1)(a) ของ the Criminal Justice Act 1988 ระหว่างการพิจารณาศาลได้แนะให้คณะลูกขุนใช้ความหมายของ“ความสงสัย” ตามพจนานุกรม ซึ่งหมายความว่า การมโนภาพสิ่งต่างๆโดยปราศจากพยานหลักฐาน หรือ มีหลักฐานน้อย หรือความระแคะระคาย ความไม่เชื่อใจ และความระแคะระคาย ความไม่เชื่อใจว่าบุคคลนั้นได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญา ในการตีความ “ความสงสัย”ตามมาตรา 93A(1)(a)

ซึ่งถ้าเป็นแค่ระดับความสงสัยตามพจนานุกรมผู้พิพากษาสามารถพิพากษาได้ว่าจำเลยมีเหตุอันควรสงสัยในการกระทำความผิดแล้ว

ทนายฝ่ายจำเลยกล่าวถึงต้นร่างของมาตรา 93(A)ที่ได้รับต้นแบบมาจาก มาตรา 24 ของ the Drug Trafficking Offences Act 1986 ซึ่งสภาได้ละเลยการบัญญัติในช่วงแรกแต่ต่อมาจึงได้แก้ไขใหม่ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า “ เหตุอันควรสงสัย ” ดังนั้น มาตรา 93(A) จึงต้องแปลความในทำนองเดียวกัน ทนายฝ่ายจำเลยได้อ้างถึงความไม่ถูกต้องที่จะพิพากษาว่าจำเลยผิดถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา และไม่ควรที่จะฟ้องจำเลยได้ด้วยซ้ำ และถึงแม้ว่าได้ฟ้อง คณะลูกขุนต้องไม่ตัดสินว่าจำเลยผิดหากไม่มีเหตุอันควรสงสัย

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาได้ตั้งคำถามในคดีนี้ดังนี้

<u>หนึ่ง</u> ผู้พิพากษามีสิทธิที่จะแนะนำให้คณะลูกขุนใช้นิยามโดยเฉพาะความหมายตามพจนานุกรมคำว่า “ความสงสัย”หรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ผู้พิพากษาอาจสมัครใจช่วยเหลือลูกขุนในการชี้แนวทางในการแปลได้ และการที่ศาลเริ่มต้นความหมายด้วยพจนานุกรมก็เป็นการเริ่มที่มีเหตุผลเพราะในพจนานุกรมไม่มีความหมายทางอาญาจึงต้องเริ่มด้วย “ความสงสัย” ในทางแพ่ง และบางครั้งใช้ความหมายแพ่งในบริบทของเหตุอันควรสงสัยกับตำรวจมากกว่า “ความสงสัย” เพียงอย่างเดียวในบริบทของแพ่งความสงสัยต้อง “ชัดเจน”หรือ “มีมูลเหตุที่แน่นอน” ดังนั้นความสงสัยต้องมีความแข็งแกร่งบ้าง ความสงสัยเป็นคำที่ใช้บรรยายสภาวะแห่งจิตที่อาจจะไม่มากไปกว่าความรู้สึกที่สงสัยหรือสะท้อนความเชื่อที่มั่นใจในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวพันในขณะนั้น

ในความเห็นของผู้พิพากษา Lord Scott of Foscote เหตุอันควรสงสัย<u>ต้องมีมูลเหตุที่แน่ชัดและมีเป้าหมายบนข้อเท็จจริงเฉพาะเจาะจง</u> การตัดสินใจ<u>จะต้องไม่อยู่บนความเชื่อของแค่บุคคลใด</u>บุคคลหนึ่งโดยไม่ได้สืบสวนความสงสัยที่เกิดจากการคาดเดาหรือไม่มีเป้าหมายก่อให้เกิดความเพิกเฉย ในทางตรงกันข้ามความรู้สึกกำกวมไม่เพียงพอเพราะ<u>ความสงสัยต้องมีมูลเหตุที่แน่ชัดและมีเป้าหมายบนข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง</u>

สอง ความหมายตามพจนานุกรมที่ผู้พิพากษาได้แนะนำการตีความตามมาตรา 93(A) นั้นถูกต้องหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า คำว่า “ ความสงสัย ”(เหตุอันควรสงสัย) ตามมาตรา 93(A) ต้องคิดว่ามีความเป็นไปได้ ไม่ใช่เพียงการนึกขึ้นเองอย่างไม่มีเหตุผล ความรู้สึกว่าไม่แน่ว่าจะใช่หรือไม่จึงไม่เพียงพอ แต่ในตัวบทไม่มีกำหนดว่าต้องมีมูลเหตุ “ ชัดแจ้ง ” หรือ “ แน่นอน ” และมีเป้าหมายบนข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง หรืออยู่บน “เหตุอันควรสงสัย” ดังนั้นศาลพิจารณาว่าการฟ้องคดีตามมาตรา 93A(1)(a) ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยได้ช่วยเหลือการแสวงหาผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทำความผิดทางอาญาของบุคคลอื่นโดยจำเลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ ไม่ใช่นึกขึ้นเองอย่างไม่มีเหตุผลที่บุคคลนั้นได้เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากการกระทำความผิดทางอาญา ดังนั้นถ้าผู้พิพากษาคิดว่ามันเหมาะสมที่จะช่วยลูกขุนเกี่ยวกับคำ “ เหตุอันควรสงสัย” การชี้แนะก็เพียงพอและถูกต้องแล้ว[69]

(20) S และ M ถูกจับเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 S เป็นภรรยา M เป็นพี่น้องของ L ผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย มีหลักฐานว่า S ออกนอกประเทศกับ L ในเวลาที่ L อาจถูกส่งไปฝึกกับผู้ก่อการร้าย S ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 4 วันครึ่ง และ M ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 41 ชั่วโมง ทั้ง S และ M ไม่ถูกฟ้อง และถูกปล่อยหลังจากสอบปากคำและควบคุมตัว ประเด็นคือเจ้าหน้าที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดเหตุอันควรสงสัยว่า S และ M เป็นผู้ก่อการร้ายตามTerrorism Act 2000 มาตรา 41(1) หรือไม่

ขณะที่ทำการจับ S S ไม่ใช่ภรรยาของผู้ต้องสงสัยว่าก่อการร้าย แต่เป็นภรรยาของ L เพื่อนต่างชาติซึ่งในเวลานั้นเชื่อว่าร่วมกันในการฝึกฝนเพื่อโจมตี ตำรวจจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า ถ้า L เกี่ยวข้อง S น่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดการกระทำความผิดด้วย

เจ้าหน้าที่คิดว่า M เป็นผู้ต้องสงสัย M ถูกจับเพราะเขาเป็นพี่น้องของผู้ต้องสงสัยจึงเป็นผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มูลเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะทำให้การจับสมเหตุสมผล และ ตามกฎหมายอังกฤษการจับจะไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าผู้ถูกจับไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลที่สมควรขณะถูกควบคุมตัวหรือในเวลาที่ถูกจับหรือในทันทีที่สามารถแจ้งได้ ทั้ง S และ M ไม่ได้ถูกแจ้งให้ทราบในขณะที่ถูกจับว่าถูกจับเพราะสาเหตุใด ตำรวจมีเพียงความสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ การเตรียมการ การยุยง ศาลพิพากษาว่าเจ้าหน้าที่จึงไม่มีความจำเป็นใดหรือเหตุอัน

---

[69]คดี Regina v. Da Silva[2006] EWCA Crim 1654 ,cited in Westlaw

ควรสงสัยที่จะจับได้[70]

(21) เมื่อตำรวจเข้าใกล้ยานพาหนะ ผู้ต้องสงสัยรีบขับรถหนีออกไปด้วยความเร็วสูง หลังจากนั้นไม่นานผู้ต้องสงสัยลงจากรถและเข้าไปในบ้านโดยพยายามที่จะซ่อนกระเป๋า และผู้ต้องสงสัยออกจากบ้านโดยไม่มีกระเป๋า บนข้อเท็จจริงนี้ตำรวจได้ขอหมายเพื่อค้นในที่รโหฐานภายใต้มาตรา 23 Misuse of drugs act 1971[71]ผู้ต้องสงสัยแย้งว่าตำรวจไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าตนมีสารเสพย์ติดไว้ในความครอบครอง แม้ตำรวจมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องสงสัยพยายามที่จะปกปิดสิ่งที่เขาถืออยู่ แต่ก็ไม่มีข้อมูลก่อนหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้ต้องสงสัยกับยาเสพติด ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระเป๋าของผู้ต้องสงสัยจะบรรจุยาเสพติด[72]

(22) เจ้าพนักงานเข้าหยุดรถที่ขับหนีมาจากการสถานที่เพิ่งเกิดการลักทรัพย์ตามมาตรา114 Land Transport Act 1998(LTA) จำเลยนั่งที่ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า เจ้าพนักงานส่องไฟฉายเข้าไปในรถและเห็นวัตถุเรืองแสงเข้าใจว่าเป็นอาวุธ เจ้าพนักงานจึงใช้อำนาจค้นโดยไม่มีหมายเพื่อหาอาวุธตามมาตรา 202B Crimes Act1961 จำเลยพยามยามที่จะซ่อนอาวุธและไม่ร่วมมือและถูกจับข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน การค้นต่อมาปรากฏว่าวัตถุที่ต้องสงสัยเป็นกระติ๊กน้ำร้อน อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงานได้ทำการค้นรถต่อไปและพบยาบ้า (ซึ่งทำให้เจ้าพนักงานมีอำนาจค้นตามมาตรา 18 Misuse of Drug Act) โทรศัพท์มือถือซึ่งในนั้นมีข้อความ

---

[70]คดี Raissi v Commissioner of Police of the Metropolis [2007] EWHC 2842 (QB) ,cited in Westlaw

[71] มาตรา 23(2) ตำรวจเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดๆมียาเสพติดที่ฝ่าฝืนตามกฎหมายนี้ไว้ในความครอบครอง ตำรวจมีสิทธิ

(a) ค้นตัวบุคคลนั้น และควบคุมเขาเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้น

(b) ค้นยานพาหนะ หรือ เรือเดินสมุทรที่ตำรวจสงสัยว่ายาเสพติดนั้นอาจซ่อนอยู่และเพื่อให้การค้นยานพาหนะบรรลุผลสามารถเรียกให้ยานพาหนะนั้นหยุดได้

(c) ยึดและควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายนี้ สิ่งใดที่ถูกพบในระหว่างที่ทำการตรวจค้นสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานของเพื่อพิสูจน์ความผิดได้

“ เรือเดินสมุทร ” รวมถึง เรือที่แล่นได้อย่างรวดเร็วเหนือน้ำตามความหมายของ Hovercraft Act 1968 และ อำนาจตามมาตรานี้จะไม่ขัดหรือแย้งกับอำนาจในการค้นหรือยึดหรือควบคุมทรัพย์สินโดยตำรวจที่ไม่ใช่อนุมาตรานี้

[72]คดี Don (Joanne) v Donnelly, cited in Westlaw

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพบว่ากระติกน้ำร้อนภายในบรรจุห่อกัญชา

ประเด็นแรกคือ เจ้าพนักงานใช้อำนาจตามมาตรา114 LTAที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการสุ่มหยุดยานพาหนะเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย แล้วเจ้าพนักงานเรียกให้หยุดเพื่อบังคับการไปตามกฎหมายหรือไม่ ศาลแสดงความเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานได้ทำการหยุดแล้ว ไม่มีเหตุขัดขวางไม่ให้ตำรวจสอบถามเกี่ยวกับการลักทรัพย์ต่อไป แม้ว่าเจ้าพนักงานไม่มีอำนาจบังคับให้ตอบคำถาม หลังห้านาทีผ่านไปศาลพิจารณาต่อว่าขณะนั้นเจ้าพนักงานสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 317A Crimes Act ให้อำนาจเจ้าพนักงานหยุดยานพาหนะเพื่อจะทำการจับ ศาลตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจต้องมี “เหตุอันควรสงสัย” กรณีนี้การเคลื่อนไหวของยานพาหนะทำให้เกิดเหตุอันควรสงสัยแล้วหรือไม่ ศาลพิจารณาว่ากรณีนี้ยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอ ดังนั้นเจ้าพนักงานจึงไม่มีอำนาจเรียกให้ยานพาหนะหยุดตามมาตรา 317A และมาตรา 114(ให้อำนาจเจ้าพนักงานสอบสวนตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้รู้ว่าคนขับเป็นใครแต่ต้องไม่เกิน15นาที) แต่การเรียกให้หยุดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ทำให้เกิดการจับไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ผู้ต้องสงสัยทั้งสองขัดขวางเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้ต่อเนื่องมาจากการจับ และการเรียกให้หยุดกับการจับสัมพันธ์กันเพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุผลทั้งสองประการจึงทำให้เจ้าพนักงานมีเหตุฉุกเฉินในเวลากลางคืนข้างถนนทำให้คิดว่าวัตถุที่ต้องสงสัยนั้นเป็นอาวุธแล้ว

ศาลพบว่าอำนาจในการค้นเบื้องต้นเพื่อหาอาวุธ(initial search for weapons)ไม่รวมการค้นยานพาหนะ ดังนั้นพยานหลักฐานที่ได้จากการค้น ได้แก่ ยาบ้า กระติ๊กน้ำร้อน โทรศัพท์ จึงไม่ชอบแต่ไม่ได้ทำให้พยานหลักฐานรับฟังไม่ได้[73]

4.4 <u>การกำหนดขอบเขตในพระราชบัญญัติหรือระเบียบข้อบังคับ</u>

แนวทางในการพิจารณาตาม**กฎหมายอังกฤษ**ว่า กรณีใดถือว่ามีเหตุอันควรตรวจค้นเพื่อพบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น กำหนดไว้ใน Code A[74] ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แนบท้าย PACE และแม้จะไม่ใช่หลักเกณฑ์ของกฎหมาย แต่เป็นแนวทางที่ถือปฏิบัติ

---

[73] R v.Moreton(2009)NZCA121 ,cited by Bernard Robertson,“ Search and seizure,” <u>New Zealand Law Journal</u>,p.15-16.(February 2010).

[74] Code A ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2008

เพื่อการดำเนินงานของตำรวจ โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีสิ่งของที่จะตรวจค้นตามมาตรา 1 ดังนี้[75]

1.เหตุอันควรสงสัยในการตรวจค้น

(1)ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละกรณี ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อมูล และหรือข้อมูลที่ได้รับจากการสืบสวน แต่ความมีเหตุสมควรนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวบุคคล ดังนั้นการที่จะสงสัยเพราะเหตุที่ว่าบุคคลนี้มีประวัติอาชญากรรมหรือเพราะพยานได้แจ้งรูปพรรณ สัณฐานได้ตรงกับลักษณะของผู้นั้นหรือเพราะเขามีเชื้อสาย อายุ ศาสนา หรือลักษณะที่ตรงกับลักษณะการกระทำความผิดที่ตรวจค้นหา ไม่อาจเป็นข้อเท็จจริงที่นำเป็นเหตุตรวจค้นได้ตามลำพังจะต้องมีหลักฐานจากข้อมูลอื่นมาประกอบด้วย

(2)เหตุอันควรสงสัยอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีข้อมูลจากการสืบสวนก็ได้ เช่น การที่บุคคลในเวลากลางคืนและกำลังเดินบนถนนแต่เห็นได้ชัดว่า ดำกำลังซ่อนสิ่งของบางอย่าง ตำรวจสามารถเข้าไปเพื่อขอตรวจค้นว่าสงสัยจะมีของที่ลักมาได้ หรือในกรณีที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้าย หากผู้นั้นไปปรากฏตัวในบริเวณที่ตำรวจสืบทราบว่าจะมีการวางระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวและพฤติการณ์ที่น่าพิรุธ ก็ถือเป็นเหตุอันควรสงสัยได้

(3)อย่างไรก็ดี เหตุอันควรสงสัย ควรสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มาจากการสืบสวนหรือจากข้อมูลด้านอื่นๆประกอบ เช่น ข้อมูลที่ระบุถึงรูปพรรณสัณฐานของสิ่งของที่ซุกซ่อน โดยดูจากบุคคลผู้ต้องโทษที่ระบุ หรือบุคคลที่พบเห็นสิ่งของที่ถูกลักในบริเวณดังกล่าว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การตรวจค้นตัวบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความยุ่งยากในการตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร อันเป็นการรบกวนประชาชนที่อยู่หรือเดินทางไปในที่สาธารณะนั้น หลักการนี้จะเป็นมาตรการป้องกันมิให้มีการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะโดยยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยเกิดขึ้น นอกจากนี้การที่มีการปรับปรุงข้อมูลที่ได้มาจากการสืบสวนหรือข่าวจากสายลับนั้นควรนำมาปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อทำให้การค้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(4)ในกรณีที่เป็นการสืบสวนอันน่าเชื่อได้ว่า สมาชิกในองค์กรอาชญากรรมที่กำลังจะกระทำความผิดหรือเป็นองค์กรที่พกอาวุธเป็นประจำ จะสวมเสื้อผ้าที่มีลักษณะเฉพาะหรือสัญลักษณ์เป็นพิเศษ ติดอยู่ที่เสื้อผ้าหรือที่ที่สังเกตได้ หากตำรวจได้พบเสื้อผ้าหรือสัญลักษณ์เฉพาะนั้น ก็ถือเป็นเหตุสมควรที่ตรวจค้นได้

---

[75] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 11*,น.43-44.

(5) ตำรวจไม่อาจที่จะควบคุมผู้ที่ถูกเรียกให้หยุดเพื่อหาเหตุแห่งการค้นตามมาตรา 1 ของ PACE

บทที่ 5

หลักเกณฑ์การค้นของไทยและแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานปรากฏทั้งในกฎหมายแม่บทอย่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าว โดยการอธิบายเนื้อหาจะเรียงลำดับตามผู้ใช้อำนาจ เงื่อนไขในการใช้อำนาจ กระบวนการใช้อำนาจ ซึ่งมีทั้งกระบวนการก่อนค้น กระบวนการระหว่างค้นและกระบวนการหลังค้น เพื่อศึกษาว่าหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานที่มีในกฎหมายไทยมีกระบวนการและขั้นตอนที่เพียงพอกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนมากน้อยเพียงใดโดยนำไปศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของต่างประเทศเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกฎหมายไทยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5.1 หลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานตามกฎหมายไทย

ความหมายของ “การค้น”

มีอยู่ 2 ประเภท[1] คือ ความหมายโดยทั่วไป กับความหมายทางเทคนิค

(1) ความหมายโดยทั่วไป การค้นคือการที่เจ้าพนักงานล่วงล้ำสิทธิส่วนตัวของบุคคลโดยอาศัยอำนาจกฎหมายเพื่อหาสิ่งของหรือบุคคล

เงื่อนไขประการแรกคือต้องมีการล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคล เราจะเห็นว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนตัวมากกว่าสิทธิในทรัพย์สิน ประการที่สองคือต้องอาศัยอำนาจของกฎหมายและต้องกระทำโดยเจ้าพนักงาน ประการที่สามคือค้นหาสิ่งของหรือบุคคล ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69 ระบุเหตุออกหมายค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของ

(2) ความหมายทางเทคนิค ต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าบทบัญญัติที่ว่าด้วยการค้นมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองอะไร แต่เดิมเข้าใจว่าหลักการค้นคุ้มครองเคหสถาน คุ้มครอง

---

[1] จิรนิติ หะวานนท์,สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ,พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543),น.19.

ทรัพย์สินเพราะฉะนั้นการเข้าไปค้นเป็นการบุกรุกอย่างหนึ่ง เพียงแต่ว่าเจ้าพนักงานมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปได้ แต่เดิมการค้นจึงยึดหลักบุกรุกเพราะเข้าใจว่าการค้นจะต้องมีการกระทำอันเป็นบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของบุคคล ถ้าเราเข้าใจกันว่าการค้นเป็นการบุกรุก การดักฟังโทรศัพท์ก็ไม่ใช่การค้น เพราะการดักฟังโทรศัพท์ไม่ได้เข้าไปในบ้านของบุคคลแต่ต่อโทรศัพท์ที่ชุมสายโทรศัพท์ (คดี Olmstead v.U.S.)

การตรวจค้นตัวบุคคลนั้นมาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้รับรองว่าการใช้อำนาจในการค้นต้องใช้อำนาจแห่งกฎหมาย และเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นเพราะการค้นตัวเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อไม่ให้ปัจเจกชนถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยอำเภอใจ จึงกำหนดให้ต้องมีการออกกฎหมายซึ่งกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญในเรื่องการค้นตัวบุคคล คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานของรัฐในการค้นเพื่อหาพยานหลักฐานและรวบรวมพยานหลักฐาน

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดวัตถุประสงค์แห่งการค้นออกเป็น 5กรณี คือ เพื่อหาพยานหลักฐาน เพื่อหาของกลาง เพื่อช่วยบุคคล เพื่อจับบุคคล เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษา ในทางตำราโดยแบ่งการค้นออกเป็น ๒ ประเภท[2] คือ

(1)การค้นสถานที่ ได้แก่ การค้นในที่รโหฐาน การค้นในพระราชวัง มีวัตถุประสงค์ในการหาสิ่งของซึ่งเป็นการกระทำเพื่อหาพยานหลักฐาน หรือหาตัวบุคคลซึ่งเป็นการกระทำเพื่อจับบุคคลหรือเพื่อช่วยบุคคล

(2)การค้นตัวบุคคล ได้แก่ การค้นตัวผู้ต้องหา หรือการค้นตัวบุคคลอื่น ซึ่ง*การค้นตัวผู้ต้องหาและการค้นตัวบุคคลอื่น*มีความแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี ผู้ต้องหาอาจถูกตรวจตัว รวมตลอดถึงการถ่ายภาพ การจำลอง หรือการพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเท้า หรือการตรวจสภาพจิต การค้นตัวผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เมื่อเจ้าพนักงานผู้จับรู้ตัวผู้ถูกจับไว้ ก็มีอำนาจที่จะค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ *ส่วนการค้นตัวบุคคล*อื่นนั้นคือ การค้นตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเจ้าพนักงานจะค้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย เป็นการกระทำเพื่อระงับเหตุร้ายหรือเพื่อปราบปรามอาชญากรรม

---

[2]ยุพาภรณ์ วงศ์วิกรานต์, “การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,”(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547),น.20-21.

การค้น[3] หมายถึง มาตรการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เจ้าพนักงานได้กระทำตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ในอันที่จะทำให้การสืบสวนสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลให้บังเกิดผลสมควรตามมุ่งหมาย

ส่วนที่ " สาธารณสถาน " ในประมวลกฎหมายอาญา ได้ให้คำนิยามไว้ในมาตรา 1(3) ว่า สถานที่ใดๆซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้

5.1.1 **ผู้ใช้อำนาจค้น**

1) <u>ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา</u>

"พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ"[4]ซึ่งหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม[5]

2) <u>พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469</u>

พนักงานศุลกากร หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร และเจ้าพนักงานทหารเรือ(เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการนำของที่หนีศุลกากร สืบสวนและสอบสวนทางทะเลและทางน้ำ) ชั้นสัญญาบัตรประจำตำแหน่งมีอำนาจตามกฎหมายศุลกากรในฐานะเจ้าพนักงานศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[6]

---

[3] จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช,<u>คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก จับ ค้น(ควบคุม) ขัง จำคุก ปล่อย(ปล่อยชั่วคราว),</u>(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร,2548)น.157.

[4] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(16)

[5] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93

[6] ชูชาติ อัศวโรจน์, <u>คำอธิบายกฎหมายศุลกากร</u>, พิมพ์ครั้งที่ 2(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2542),น. 244.

3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงาน ให้ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ถ้าเจ้าพนักงานได้ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลนั้นมีอำนาจช่วยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานได้[7]

4) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

"พนักงานเจ้าหน้าที่" ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ จากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าพนักงานฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าพนักงานฝ่ายทหาร[8]

5.1.2 เงื่อนไขการใช้อำนาจ

1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า[9] บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง

ก.เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือ

ข.ซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิด หรือ

ค.ซึ่งมีไว้เป็นความผิด

จากบทดังกล่าวสรุปได้ว่า โดยหลัก กฎหมายห้ามการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน แต่มีข้อยกเว้นว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้[10]

---

[7] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14 และมาตรา 14 ตรี

[8] พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 4 และมาตรา 5

[9] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93

[10] เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,คำอธิบายว่าหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา ,พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : หจก.สำนักพิมพ์พลสยามพริ้นติ้ง(ประเทศไทย), 2553), น. 435.

(1)เมื่อเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด อาวุธที่นายแดงเตรียมไว้จะใช้ในการทำร้ายนายดำ หรืออุปกรณ์ที่นายแดงเตรียมไว้ในการงัดรถของนายดำ สิ่งของเหล่านี้หากอัยการมีคำขอ ศาลก็มีอำนาจริบได้ตามป.อ.มาตรา 33 อนุมาตรา1 โดยอัยการจะขอให้ศาลริบก็ต่อเมื่ออัยการขอให้ศาลดำเนินการเรียกประกันทัณฑ์บนแก่ผู้จะก่อเหตุร้ายตามป.อ.มาตรา 46

(2)เมื่อเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้สิ่งของมาโดยการกระทำความผิด หมายความว่าได้มาโดยผิดกฎหมายโดยตรง เช่น ทรัพย์ของผู้เสียหายที่ผู้ต้องหาไปขโมยมา แต่ไม่รวมถึงทรัพย์ซึ่งได้มาโดยผิดกฎหมายทางอ้อม เช่น ขโมยเงินมาแล้วเอาเงินไปซื้อรถยนต์ รถยนต์ที่ซื้อมาจากคนที่ขโมยมานั้นไม่ใช่ของที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือ

(3)เมื่อเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด สิ่งของโดยสภาพเป็นสิ่งของเป็นความผิดอยู่ในตัวของสิ่งของนั้นเอง เช่น ยาเสพติดให้โทษชนิดต่างๆ ปืนที่ไม่มีทะเบียน เป็นต้น สิ่งของเหล่านี้เมื่อเจ้าพนักงานตรวจพบก็สามารถยึดไว้ได้ทั้งสิ้น

ข้อสังเกต หากเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองอันเป็นสิ่งของที่ “ ได้ใช้ ” ในการกระทำความผิด ก็จะค้นตามมาตรา 93 ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเหตุออกหมายค้นตามมาตรา 69(2) แต่การค้นตัวเพื่อหาสิ่งของในตัวบุคคลนั้น ในกรณีที่บุคคลนั้นอยู่ในที่สาธารณสถานไม่มีการออกหมายค้นเพราะตามป.วิ.อ. มาตรา 57 และมาตรา 60(4)(ค)มุ่งหมายให้ออกหมายค้นกรณีที่เป็นการค้นสถานที่อันเป็นที่รโหฐาน “**เพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของ**”(ดูป.วิ.อ มาตรา 57 วรรคหนึ่ง) เท่านั้น ไม่มีกรณีที่จะออกหมายค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานเพื่อหาสิ่งของในตัวบุคคลนั้น

หากเจ้าพนักงานผู้ค้นต้องการได้สิ่งของที่ “ ได้ใช้ ” ในการกระทำความผิดอาจจะต้องจับก่อนแล้วทำการตรวจค้นผู้ถูกจับตามอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 เพราะการค้นตัวผู้ถูกจับหลังการจับแล้ว จะค้นโดยอาศัยอำนาจใดๆก็ได้ กรณีการค้นตามมาตรา93 เป็นเรื่องของการ “**ค้นก่อนจับ**” ส่วนมาตรา 85 เป็นเรื่องของการ “**จับก่อนค้น**”[11]

---

[11]*เพิ่งอ้าง*, น.453-454.

แต่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่มีการให้คำจำกัดความ “ เหตุอันควรสงสัย ” ไว้ในบทนิยาม แต่มี**แนวคำพิพากษาของศาลฎีกา**[12]ได้ตัดสินว่าสถานการณ์ใดเป็นเหตุอันควรสงสัย

ฎีกาที่ 1082/2507 เจ้าพนักงานตำรวจค้นตัวจำเลยกับพวกขณะยืนซุบซิบกันหลังสถานีรถไฟ โดยผู้ค้นได้ติดตามคนร้ายปล้นทรัพย์หนีข้ามท้องที่มาและได้ร่วมกับตำรวจท้องที่ติดตามและมีเหตุอันควรสงสัยที่จะทำการค้นคือ *สงสัยว่าจะมีอาวุธหรือของผิดกฎหมาย* เช่นนี้ตำรวจทำการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น

ฎีกาที่ 1152/2521 วัยรุ่นห้าถึงหกคนกำลังเดินอยู่ในทางสาธารณะ คนหนึ่งเป็นผู้ต้องหาของตำรวจมีผู้แจ้งว่าบุคคลเหล่านั้นจะไปกระทำความผิด *เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าความผิดและมีอาวุธที่จะนำไปใช้ทำผิด* นายตำรวจค้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 จำเลยขัดขวางโดยยิงตำรวจเป็นความผิดตามมาตรา 140 , 289 , 80 ลงโทษตามมาตรา 279 , 80 ซึ่งเป็นบทหนัก

คำพิพากษาฎีกาที่กล่าวข้างต้นได้มี**ความเห็นของนักวิชาการ**[13] ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในคำพิพากษาฎีกา 1082/2507 ว่า “ **เหตุอันควรสงสัย** ” **ต้องมีอยู่** “ **ก่อน** ”การค้น สิ่งของที่ได้มาจากการค้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือยืนยันถึงความถูกต้องของสิ่งนั้น ตามหลักที่ว่า “The end does not justify the means” ซึ่งหมายความว่า แม้จะเผอิญได้ของผิดกฎหมาย ก็มิได้หมายความว่าการ”ค้น” ตั้งแต่ต้นเป็นการค้นโดยมี “เหตุอันควรสงสัย” เพราะ“ เหตุอันควรสงสัย ” ต้องมีอยู่ ” ก่อน” การค้น เพียงแต่ตำรวจเห็นคนสองคน**พูดจาซุบซิบกันมีพิรุธ** เพียงเท่านี้ไม่น่าจะถือว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเข้ากรณีตามมาตรา 93 แม้จะติดตามคนร้ายปล้นทรัพย์ที่หลบหนีมาก็ตาม

และได้ตั้งข้อสังเกตคำพิพากษาฎีกาที่ 1152/2521 ข้อเท็จจริงระบุว่า “ มีผู้แจ้งว่าบุคคลเหล่านั้นจะไปกระทำผิด ” ประเด็นก็คือ **ใครแจ้ง และผู้รับแจ้งเชื่อถือคำกล่าวของผู้แจ้งได้เพียงใด** ผู้รับแจ้งต้องพิสูจน์โดยแสดงว่า **เหตุใดจึงเชื่อถือผู้แจ้ง ในอดีตผู้แจ้งรายนี้ (ซึ่งอาจเป็นสายลับของตำรวจ) เคยให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมาแล้วหลายครั้ง** หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อาจตอบคำถามเหล่านี้ได้ การค้นนั้นอาจเป็นการค้นที่ไม่ชอบซึ่ง

---

[12] ณรงค์ ใจหาญ,หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1,พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2550), น. 256-257.

[13] เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 10*,น.455.

อาจส่งผลให้พยานหลักฐานที่ได้รับฟังไม่ได้ตามหลัก Exclusionary Rule กล่าวคือ หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ เหตุผลที่ไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ**มิใช่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกค้นคนนั้นที่เป็นคนผิด** แต่เพื่อเป็นการลงโทษเจ้าพนักงานทางอ้อมให้ได้ทราบว่าหากยังคงฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานโดยไม่มีเหตุอันควรสงสัย การค้นนั้นก็จะไร้ผลเพราะของกลางที่ได้จากการค้นนั้น “ รับฟังไม่ได้ ” โดยหวังว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและประชาชนที่สัญจรไปมาในสาธารณสถานจะมิได้ถูกละเมิดสิทธิโดยไม่มีเหตุอันควร

ตัวอย่างคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 93

(1) ร้อยตำรวจเอกนิตย์และดาบตำรวจบุญมีเบิกความว่าหลังจากสายลับได้นำเมทแอมเฟตามีนที่ล่อซื้อได้จากจำเลยจำนวน 1 เม็ดมามอบให้ร้อยตำรวจเอกนิตย์แล้ว พยานทั้งสองกับพวกได้เข้าตรวจค้นจับกุมจำเลยที่แผงขายก๋วยเตี๋ยวโดยแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยล้วงกระเป๋าทุกกระเป๋าออกมา เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจมีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจค้นจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 และเมื่อตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนอยู่ในครอบครองของจำเลย การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดซึ่งหน้า เจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจจับจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 (1) การตรวจค้นและจับกุมจึงชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน”

ศาลฎีกาเห็นว่า การทำบันทึกการจับกุมที่ไหนหาได้เป็นสาระสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ แต่เนื้อหาของบันทึกการจับกุมต่างหากที่อาจแสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่[14]

(2) คดีนี้ร้านที่เกิดเหตุเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเล่นเกมต่างๆ เมื่อสิบตำรวจสุรเชษฐ์เป็นผู้ทำการตรวจค้น และสิบตำรวจตรีสุรเชษฐ์กับนายพิเนตต่างเบิกความยืนยันว่า แผ่นซีดีเกมของกลางอยู่ในตะกร้าซึ่งอยู่ในตู้สามารถมองเห็นได้ โดยนายพิเนตยืนยันด้วยว่า แผ่นซีดีเกมของกลางดังกล่าวละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วม เพราะลักษณะภายนอกของแผ่นซีดีของกลางต่างจากของโจทก์ร่วมอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นกรณีของการค้นในที่สาธารณสถานโดยเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าร้านที่เกิดเหตุมีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด การค้นดังกล่าวจึงเป็นไป

[14] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3751/2551

ตามกฎหมายแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นตามที่จำเลยอุทธรณ์แต่อย่างใด ทั้งเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจสามารถจับจำเลยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 (1) ประกอบมาตรา 80 วรรคหนึ่ง การค้นและจับจึงชอบด้วยกฎหมาย[15]

(3)โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับนายอาคม รักษาสกุล ผู้ตายได้ร่วมกันกระทำผิดหลายกรรมต่างกันคือ จำเลยกับผู้ตายร่วมกันมีอาวุธปืนสั้น ไม่มีเครื่องหมายทะเบียน มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยว่าจำเลยได้กระทำผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่และพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือไม่

ก่อนเกิดเหตุพยานได้รับคำสั่งจากร้อยตำรวจเอกปรีดาเปี่ยมวารี รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอ่างทองให้ไปสืบสวนเกี่ยวกับผู้โทรศัพท์แจ้งว่ามีชายสองคนใช้ผ้าผูกปิดหน้าตั้งแต่จมูกลงมาถึงคางขับรถจักรยานยนต์และนั่งซ้อนท้ายแล่นวนเวียนอยู่บริเวณหน้าโรงแรมซีแอลการ์เดนท์สงสัยว่าจะมาก่อเหตุร้าย ระหว่างทางพบนางจงกลนี วิชัยศรขอร้องให้พยานพาไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างสถานีตำรวจประมาณ 500 ถึง 600 เมตร ขณะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเกิดเหตุจำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์มีผู้ตายนั่งซ้อนเข้ามาบริเวณปั๊มน้ำมันโดยจำเลยและผู้ตายใช้ผ้าผูกปิดหน้าตั้งแต่จมูกลงมาถึงคางและมีวิทยุมือถือติดอยู่หน้ารถจักรยานยนต์ด้วย พยานมีความสงสัยจึงเข้าไปสอบถามว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจหรือไม่ โดยบอกจำเลยและผู้ตายว่าพยานเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ขอดูใบอนุญาตใช้วิทยุมือถือและขอตรวจค้น ผู้ตายได้ลงจากรถจักรยานยนต์ไปยืนอยู่ห่างประมาณ 2 เมตร พยานเข้าไปคลำดูบริเวณเอวจำเลยซึ่งนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์อยู่ พบอาวุธปืนจึงสั่งให้ผู้ตายหันหน้าออกไปแล้วยกมือขึ้น พยานจึงมีอำนาจตรวจค้นและจับจำเลยกับผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78(1) (2), 93 การที่จำเลยใช้มือกดอาวุธปืนไม่ให้สิบตำรวจเอกไพฑูรย์ดึงออกมาจากเอวจำเลยเพื่อยึดเป็นของกลาง จึงเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันมาชอบแล้ว[16]

(4)โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งเจ็ดเป็นเจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

โจทก์ฎีกาว่า จำเลยร่วมกันตรวจค้นรถโจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2ที่ 3 และที่ 6 กระทำไปโดยมีเจตนากลั่นแกล้ง ไม่มีเหตุอันสมควรจะตรวจค้น การตรวจค้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ

---

[15] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6894/2549

[16] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9212/2539

ชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในข้อหานี้เป็นการไม่ชอบนั้น ในข้อนี้จำเลยมีนางสาวสุภาพร ทองสมัคร มาเบิกความยืนยันว่า เห็นโจทก์หยิบอาวุธปืนสั้นออกมาจากรถโจทก์ นางสาวสุภาพรเห็นดังนั้นจึงบอกให้นางสาวรพีพรรณไปแจ้งตำรวจ เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3และที่ 6 มาดูที่เกิดเหตุ นางสาวสุภาพรก็แจ้งให้จำเลยดังกล่าวทราบ นอกจากนี้จำเลยก็ยังมีนางสาวรพีพรรณ ทองสมัคร และนางสาวสุนีย์ จิตราช ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุมาเบิกความสนับสนุนอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวสุนีย์ไม่เคยรู้จักโจทก์มาก่อน จึงไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่านางสาวสุนีย์จะแกล้งเบิกความปรักปรำโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางสาวสุภาพรได้บอกแก่จำเลยที่ 1ที่ 2 ที่ 3 และที่ 6 ว่าโจทก์หยิบอาวุธปืนสั้นออกมาจากรถโจทก์ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 6 ตรวจค้นรถโจทก์จึงเป็นการกระทำโดยมีเหตุอันสมควรที่จะตรวจค้น มิใช่เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อนี้จึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น[17]

(5) ขณะเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ 21 นาฬิกา เป็นเวลาที่หญิงโสเภณีรอรับแขกที่มาเที่ยว ประตูห้องโถงเปิด เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจตามจำเลยไปที่ซ่องโสเภณีดังกล่าว พบจำเลยยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องโถง พอจำเลยเห็นเจ้าพนักงานก็หลบเข้าไปนั่งที่ม้ายาวในห้องโถง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะทำการค้นตัวจำเลยในห้องโถงของซ่องโสเภณีโดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าสงสัยจำเลยเป็นคนร้าย เจ้าพนักงานตำรวจจึงมีอำนาจค้นและจับจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93 และ 78(3) และจำเลยย่อมมีความผิดฐานมีและใช้อาวุธปืนต่อสู้และขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ และพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ [18]

(6) โจทก์นำสืบว่า ร้อยตำรวจโทพัฒน์และจ่าสิบตำรวจโอภาศติดตามจับคนร้ายซึ่งหลบหนีเข้ามาในท้องที่อำเภอห้วยแถลง ได้เห็นจำเลยทั้งสองกับนายประกอบยืนพูดซุบซิบกันที่หลังสถานีรถไฟเป็นพิรุธ จึงบอกตำแหน่งแล้วขอค้น เพราะมีเหตุสงสัยอันควรที่จะทำการค้น คือสงสัยว่าจะมีอาวุธปืนและของผิดกฎหมายจึงทำการค้นจำเลยได้โดยไม่จำต้องมีหมายค้น และเห็น

---

[17] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2281/2534

[18] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1152/2521

ว่าการที่โจทก์มีคำขอมาในท้ายฟ้องอ้างมาตราที่ลงโทษผู้ที่กระทำผิดต่อบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานมาด้วยนั้น หาทำให้ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่เคลือบคลุมไม่ จึงเป็นการค้นโดยมีเหตุอันควรสงสัยแล้ว[19]

(7)การที่ตำรวจที่ลาราชการไปธุระต่างท้องที่คงเป็นตำรวจอยู่นั่นเองเมื่อไปทำการตรวจค้นบุคคลใดในที่สาธารณะย่อมได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93[20]

จากคำพิพากษาศาลฎีกาพบว่าเมื่อเจ้าพนักงานค้นตัวบุคคลโดยมีเหตุอันควรสงสัยในการเข้าตรวจค้นตามมาตรา 93 แล้วพบสิ่งของมีไว้เป็นความผิด เช่น ยาเสพติด ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ อาวุธปืน สามารทำการจับได้เพราะเป็นกรณีความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา 78(1),80 ประกอบ 93 หรือกรณีที่ค้นตัวบุคคลนั้นแล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายโดยมีเครื่องมือหรืออาวุธอันสามารถใช้ในการกระทำความผิด สามารถจับได้ตามมาตรา78(2),93[21]หรือกรณีมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นแต่ไม่อาจขอหมายได้ทัน เมื่อเจ้าพนักงานสามารถจับได้มาตรา 78(3),93[22]

ดังนั้นการค้นตัวตามมาตรา 93 จึงนำไปสู่การจับโดยไม่มีหมายได้หากเข้าเหตุตามมาตรา 78(1)-(4)

ตัวอย่างเช่น กรณีเจ้าพนักงานค้นตัวบุคคลเพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ “มีไว้” เป็นความผิด เช่น ยาเสพติด เจ้าพนักงานสามารถทำการจับได้ตามมาตรา 78(1) เพราะเป็นกรณีมีการกระทำความผิดซึ่งหน้า หรือกรณีเมื่อค้นตัวไปแล้วพบปืน เจ้าพนักงานสามารถทำการจับได้เพราะเป็นอาวุธที่อาจใช้ในการกระทำความผิดเพื่อก่ออันตรายต่อบุคคลได้ตามมาตรา 78(2)(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9219/2539)หรือบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าน่าจะนำเอาอาวุธไปใช้ในการกระทำความผิดมาแล้วหรือจะนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม เจ้าพนักงานทำการจับได้เช่นกันตามมาตรา 78(3) ถือเป็นกรณีมีเหตุที่จะออกหมายจับแต่ไม่สามารถขอศาลออกหมายได้ทัน

---

[19] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1082/2507

[20] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 640/2492

[21] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9219/2539

[22] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1152/2521

กรณีที่เจ้าพนักงานค้นตัวบุคคลเพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ “ได้มา” จากการกระทำความผิด เช่น ทรัพย์ที่ถูกลักทรัพย์หรือถูกชิงทรัพย์ หากเจ้าพนักงานค้นตัวแล้วพบสิ่งของดังกล่าว เจ้าพนักงานไม่สามารถทำการจับได้เพราะผู้ต้องสงสัยไม่ได้ลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์ต่อหน้าเจ้าพนักงานตามมาตรา 78(1) และไม่สามารถอ้างเหตุตามมาตรา78(2) เพราะมาตรา 78(2)ต้องเป็นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีวัตถุที่จะไปก่อเหตุร้าย ไม่ใช่กรณีได้วัตถุมาจากการก่อเหตุ แต่อาจเข้ามาตรา 78(3) เพราะเมื่อพบทรัพย์ที่ถูกลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์ และผู้ต้องสงสัยอาจหลบหนีเพื่อพาทรัพย์นั้นไปตามมาตรา 66 (2)

กรณีที่เจ้าพนักงานค้นตัวบุคคลเพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ “จะใช้” ในการกระทำความผิด เช่น ปืนที่จะเตรียมไปฆ่าคนหรือน้ำมันและไฟแช็คที่จะเตรียมไปวางเพลิง หากเจ้าพนักงานค้นพบวัตถุเหล่านี้ สามารถจับได้ตามมาตรา 78(2) หากมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยและมีสิ่งของที่อาจนำไปใช้ในการกระทำความผิด หรือกรณีมีผู้แจ้งแก่เจ้าพนักงานว่านายดำกำลังเตรียมการจะไปวางเพลิงและมีอุปกรณ์ครบ เจ้าพนักงานจึงเข้าตรวจค้นพบน้ำมันไฟแช็ค เจ้าพนักงานสามารถทำการจับได้ เพราะมีพยานหลักฐานตามสมควรว่านายดำกำลังจะไปก่อเหตุร้าย หรือมีเหตุเชื่อว่าจะหลบหนีและมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอหมายจับได้ทันตามมาตรา 78(3)

สรุป การค้นโดยเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ “ มีไว้ ” เป็นความผิด เจ้าพนักงานสามารถจับได้ถ้าเข้าเหตุตามมาตรา 78(1)-(3) แล้วแต่กรณี

การค้นโดยเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ “ ได้มา ” จากการกระทำความผิด เจ้าพนักงานสามารถจับได้ถ้าเข้าเหตุตามมาตรา 78 (3)

การค้นโดยเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ “ จะใช้ ” ในกระทำความผิด เจ้าพนักงานสามารถทำการจับได้หากเข้าเหตุตามมาตรา 78(2),(3)

ซึ่งตัวอย่างข้างต้นจะเป็นคนละกรณีกับจับก่อนค้นตามมาตรา 85 คือเมื่อมีการจับแล้ว เจ้าพนักงานสามารถทำการค้นตัวผู้ถูกจับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ไม่จำกัดเฉพาะมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่มีไว้ ได้มา จะใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 93 เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น การจับโดยมีหมาย กรณีมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลน่าจะกระทำความผิดซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกินสามปีตามมาตรา 66(1) หรือมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลน่าจะกระทำความผิดอาญาตามและมีเหตุเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่นตามมาตรา 66(2) เมื่อออกหมายจับแล้ว สามารถค้นตัวบุคคลนั้นได้ตามมาตรา 85 ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะสงสัยว่าผู้ถูกจับจะมีสิ่งของที่ตั้งใจ“จะใช้” “มี

ไว้” “ได้มา” หรือ “ได้ใช้” ในการกระทำความผิดเพราะการค้นหลังการจับเป็นการค้นโดยอาศัยเหตุใดก็ได้ แม้นอกเหนือจากเหตุแห่งการค้นตามมาตรา 93

การจับโดยไม่มีหมาย กรณีความผิดซึ่งหน้า มาตรา 78(1) สามารถค้นตัวเพื่อพบสิ่งของหรือวัตถุที่มีไว้ ได้มา จะใช้ หรือได้ใช้ในกากรระทำความผิดตามมาตรา 85 ได้ทั้งสิ้นเพราะเป็นการค้นขณะความผิดเกิด พยานหลักฐานที่พบจึงอาจเป็นวัตถุที่จะใช้ในการกระทำความผิดหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

กรณีมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะก่อเหตุร้ายกับทรัพย์สินหรือบุคคลและมีเครื่องมือหรืออาวุธที่จะนำไปก่อเหตุตามมาตรา 78(2) การค้นตามเหตุนี้จึงเป็นการค้นเพื่อยึดวัตถุหรือสิ่งของที่ “จะใช้” หรือ “มีไว้”เป็นความผิด เนื่องจากเป็นการจับและค้นตัวก่อนไปกระทำความผิด จึงไม่เข้าเหตุบุคคลมีสิ่งของที่ “ได้ใช้” หรือ “ได้มา ” จากการกระทำความผิด

กรณีมีเหตุออกหมายจับ แต่มีความจำเป็นไม่สามารถออกหมายได้ทันตามมาตรา 78(3)ซึ่งการค้นตามเหตุนี้ เป็นการค้นเพื่อหาพยานหลักฐานที่ได้กระทำความผิดมาแล้ว คือสิ่งของที่ “ได้มา” หรือ “ได้ใช้” ในการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่กำลังจะไปกระทำความผิด เช่น สิ่งของที่ “มีไว้” หรือ “จะใช้” ในการกระทำความผิด

ข้อสังเกต แม้เจ้าพนักงานจับแล้วทำการค้นตัวบุคคลโดยมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ “ได้ใช้” ในการกระทำความผิดซุกซ่อนในร่างกาย เจ้าพนักงานทำการค้นได้ตามมาตรา 85 เพราะการค้นหลังการจับมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าพนักงานไม่ให้ถูกทำร้ายหรือได้รับอันตรายจากวัตถุที่อยู่ในตัวของผู้ถูกจับ และเพื่อป้องกันพยานหลักฐานอาจถูกทำลายหรือสูญหาย

2) <u>พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469</u>

2.1) พื้นที่ทั่วไป

พนักงานศุลกากรมี**เหตุอันสมควรสงสัย**ว่าบุคคลนั้น ๆ มีหรือพาไปกับตนซึ่งของอันยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม จึงให้ตรวจค้นได้[23] ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือการส่งออก[24]

ของต้องห้ามและของต้องจำกัดมีความหมายที่แตกต่างกัน [25] คือ

---

[23] พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2548 มาตรา 18

[24] ชูชาติ อัศวโรจน์, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 6*, น.216.

" ของต้องจำกัด " หมายถึง ของที่จะนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวกับของนั้นๆมาก่อน หากนำเข้ามาก่อนได้รับอนุญาต เป็นความผิดตามกฎหมายเฉพาะและตามมาตรา 27 แห่งกฎหมายฉบับนี้[26] เช่น พระราชบัญญัติการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นต้น

" ของต้องห้าม " หมายถึง สิ่งของมีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นบทบัญญัติที่ห้ามเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้น เพราะหากมีข้อยกเว้นว่า "เว้นแต่ได้รับอนุญาต" จะเป็นของที่ต้องจำกัดไป ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 เป็นต้น

ส่วน " ของที่ยังไม่ได้เสียภาษี " หมายถึง ของที่พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 กำหนดให้เสียภาษี เช่น รถยนต์ เป็นต้น[27]

2.2 เขตควบคุมศุลกากร

เมื่อเห็นเป็นการสมควรกำหนดเขตท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมศุลกากร ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศุลกากร เมื่อพนักงานศุลกากรมี " **เหตุอันสมควร** " ว่าบุคคลนั้น ๆ มีหรือพาไปกับตนซึ่งของอันยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม จึงให้ตรวจค้นตัวบุคคลที่สัญจรไปมาในเขตนั้น[28]

3) <u>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519</u>

---

[25] ชูชาติ อัศวโรจน์,<u>ปัญหากฎหมายศุลกากรและข้อวิเคราะห์</u>, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544), น.371-373.

[26] ชูชาติ อัศวโรจน์, <u>อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานทหารเรือในการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร</u>, กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยกองทัพเรือ นทน.วทร.รุ่นที่ 25,2536),น.24.

[27] *เพิ่งอ้าง*, น. 24.

[28] พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 12

เมื่อเจ้าพนักงานมี “เหตุอันควรสงสัยตามสมควร” ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย[29]

4) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ไม่มีการบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานให้ค้นตัวบุคคลได้จึงต้องกลับไปใช้หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

5.1.3 กระบวนการในการค้น

1) กระบวนการก่อนค้น

1.1) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469

แบ่งตามการใช้อำนาจในการค้นตามท้องที่ที่เกิดการค้น ออกเป็น 2 ประเภท คือ

(1)พื้นที่ทั่วไป [30]

บุคคลผู้นั้นอาจร้องขอให้นำตนอย่างเร็วตามควรแก่เหตุไปยังพนักงานศุลกากรผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสารวัตรหรือนายด่าน นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือหัวหน้าสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด ส่วนพนักงานที่มีผู้นำบุคคลเช่นนี้มาส่งนั้นจะต้องวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอหรือไม่ และควรให้ตรวจค้นหรือไม่

ถ้าผู้ที่ถูกตรวจค้นไม่ขอ พนักงานศุลกากรย่อมตรวจค้นผู้นั้นได้เลย

(2) เขตควบคุมศุลกากร [31]

ต้องแสดงบัตรประจำตัวว่าเป็นพนักงานศุลกากร

2) กระบวนการระหว่างค้น

2.1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[32]

---

[29] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14(2)และ 14(5)

[30] พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2497 มาตรา 18

[31] พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2497 มาตรา 12

[32] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน ดังนั้น กระบวนการค้นตัวบุคคลจึงไม่มีวิธีปฏิบัติในการค้นตัว แต่มี**ความเห็นของนักวิชาการ**[33]ที่ให้ความเห็นว่าให้นำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการค้นตัวผู้ถูกจับหรือการค้นในที่รโหฐานมาใช้บางประการ ได้แก่

(1) การค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น ตามมาตรา 85 วรรคสอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(2) ถ้าบุคคลดั่งกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไป ในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้ มาตรา 94 วรรคสอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและผู้นั้นอาจมีความผิดฐานต่อสู้เจ้าพนักงานได้หากทำการขัดขวาง แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานเข้าตรวจค้นในที่เปลี่ยวโดยไม่ได้แต่งเครื่องแบบหรือแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ผู้ถูกตรวจค้นขัดขวางไม่มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน (ฎีกาที่ 148/2513)

(3) ก่อนการค้นตัวบุคคลนั้น เจ้าพนักงานอาจแสดงความบริสุทธิ์ให้เขาดูเท่าที่สามารถจะทำได้จะเป็นการดี เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าพนักงานเอง ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและชอบธรรมได้ และก็จะเป็นการป้องกันการครหาในภายหลังว่าเจ้าพนักงานนั้นกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ แต่อย่างไรก็ตามมีคำพิพากษาที่ตัดสินเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ว่าเจ้าพนักงานไม่จำต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการค้นตัวบุคคล

ฎีกาที่ 2024/2497 สถานที่บนขบวนรถไฟไม่ใช่ที่รโหฐาน แต่เป็นที่สาธารณสถาน เจ้าพนักงานสรรพสามิตค้นจับฝิ่นในที่ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น ไม่จำต้องค้นในเวลากลางวัน หรือแสดงความบริสุทธิ์ก่อนตามมาตรา 96,102 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[34]

2.2) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469[35]

(1) พื้นที่ทั่วไป

---

[33] จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3* ,น.191-194.

[34] พิพัฒน์ จักรางกูร,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ,(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ,2546),น.169.

[35] พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2497 มาตรา 12 และมาตรา 18

พนักงานศุลกากรค้นบุคคลใดๆได้ แต่บุคคลนั้นต้องอยู่ในเรือและเรือนั้นต้องอยู่ในเขตท่า หรือ บุคคลที่ขึ้นจากเรือกำปั่นลำใด ๆ ที่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือ ที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องอยู่ในเขตท่าก็ได้[36]

ถ้าบุคคลนั้นเป็นหญิงก็ให้ใช้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น นอกจากนี้ยังมีอำนาจสั่งให้ยานพาหนะหยุด และค้นยานพาหนะเพื่อให้ทราบว่ามีของลักลอบหนีศุลกากร รวมถึง ตรวจค้นและกักหีบห่อของคนโดยสารที่เข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักร

(2) เขตควบคุมศุลกากร

พนักงานศุลกากรมีอำนาจค้นตัวบุคคลซึ่งสัญจรไปมาภายในเขตนั้น ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืน และโดยไม่ต้องมีหมาย และถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร พนักงานศุลกากรสามารถจับได้โดยไม่มีหมาย

มีอำนาจตรวจค้นโรงเรือนหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

มีอำนาจตรวจค้นยานพาหนะ ซึ่งเข้าหรือออกไป หรือพักอยู่ หรือผ่านเขตควบคุมศุลกากรนั้น

2.3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519[37]

ค้นบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อต้องการได้ทรัพย์สินที่อาจริบได้หรือมีเหตุอันควรสงสัยในการกระทำความผิด[38]

2.4) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

แบ่งออกเป็น 2 กรณี[39] คือ

(1)กรณีประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน

(2) กรณีสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือ

---

[36] ชูชาติ อัศวโรจน์, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 6*, น.246.

[37] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14

[38] ณรงค์ ใจหาญ,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 12*, น.239.

[39] พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 5

ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เท่าที่มีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทำการหรือร่วมมือกระทำการใด ๆ อันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง [40]

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้ง 2 กรณีไม่ได้ให้อำนาจการค้นตัวบุคคล ดังนั้นถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 มาใช้ในฐานะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการค้นตัวบุคคล

3)กระบวนการหลังการค้น

3.1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มี**ความเห็นของนักวิชาการ**ให้ความเห็นว่าให้นำหลักเกณฑ์การค้นในที่รโหฐานมาใช้บางประการ ได้แก่

(1)สิ่งของที่ยึดได้ในการค้นให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตราไว้ มาตรา 101 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[41]

(2)เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดทำบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและส่งบันทึกและสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนตามมาตรา 103 104 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[42]

3.2) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469[43]

กรณีที่เจ้าพนักงานทหารเรือเป็นผู้ค้น ต้องทำบันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจค้นให้ส่งไปดังนี้

ในกรณีที่มีการตรวจค้นโดยไม่มีการยึดของหรือจับกุม ให้ผู้ทำบันทึกเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานและส่งสำเนาไปยังกรมศุลกากรเพื่อทราบ

ในท้ายคำสั่ง มีแบบฟอร์ม “ บันทึกการตรวจค้น ยึด และจับกุม ” ไว้สำหรับเจ้าพนักงานเป็นแนวทางในการเขียนบันทึก และมี “ คำรับรองผลการตรวจค้น ” ไว้ให้ผู้ที่ถูกตรวจค้นเพื่อเป็นพยานหลักฐาน แก่ผู้ที่ถูกตรวจค้นและเจ้าพนักงานที่ใช้อำนาจในการตรวจค้นด้วย

---

[40] พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 11

[41] จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3* ,น.194.

[42] ณรงค์ ใจหาญ,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่12,* น.247.

[43] ชูชาติ อัศวโรจน์, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 6* ,น.373.

3.3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519[44]

ให้เลขาธิการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้รายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน และผลสำเร็จของการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

5.1.4 ผลของการค้นโดยมิชอบ

1) ผลในทางอาญาและทางแพ่ง[45]

1.1)ผู้จะถูกค้นต่อสู้หรือขัดขวางการค้น ไม่มีความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน (ฎีกาที่ 575/2483 , 4812491 , 244/2491 , 1035/2536 , 9212/2539)

1.2)ผู้จะถูกค้นกระทำการโต้ตอบต่อผู้ค้นก็อ้างป้องกันได้ (ฎีกาที่ 1035/2536)

1.3)ผู้ค้นผิดฐานบุกรุก (ฎีกาที่ 754/2498) และอาจผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 157 ด้วย

1.4ผู้ถูกค้นมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ของตนหากได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5(เทียบฎีกาที่ 5824/2543)

2) ผลในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เกิดผลทางกฎหมายดังต่อไปนี้

2.1) พยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นโดยมิชอบรับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดไม่ได้ ตามหลัก Exclusionary Rule ในปัจจุบันกฎหมายไทยได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ[46]ว่า ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบนี้ แต่ก็มีข้อยกเว้นให้รับฟังได้ถ้าการรับฟังพยานหลักฐานจะเป็นประโยชน์แก่การอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

---

[44] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14

[45] เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่10*, น.459-460.

[46] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/1

ในการใช้ดุลยพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดี โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วย

(1) คุณค่าในเชิงพิสูจน์

(2) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี

(3) ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ

(4) ผู้ที่กระทำการโดยมิชอบเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด

“ พยานหลักฐานที่เกิดโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำที่มิชอบ ” หมายถึง พยานหลักฐานที่โดยตัวของมันเองแล้วดำรงอยู่หรือเกิดขึ้นโดยไม่มีผู้ใดไปกระทำการเสริมแต่งให้เกิดขึ้น แต่พยานหลักฐานที่เกิดโดยชอบนั้นในเวลาที่จะนำใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ซึ่งแม้พยานเหล่านี้จะได้มาโดยไม่ชอบความผิดของจำเลยนั้นได้มีการใช้วิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้น ซึ่งแม้พยานเหล่านี้จะได้มาโดยไม่ชอบ แต่คุณค่าในการพิสูจน์ความจริงของพยานมิได้ลดลงไป[47]

ดังนั้นการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานโดยไม่มี “เหตุอันควรสงสัย” ตามมาตรา 93 เป็นการค้นโดยมิชอบ[48] โดยหลักจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานอาจรับฟังไม่ได้ เพราะพยานวัตถุ พยานเอกสาร ที่ได้มาจากการค้นมิชอบ เป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทำที่มิชอบตามมาตรา 226/1 แต่ศาลอาจใช้ดุลยพินิจรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 226/1[49]

อย่างไรก็ตาม การที่เจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติหลักเกณฑ์ในกฎหมายบางประการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีผลต่อการรับฟังพยานหลักฐาน กล่าวคือ พยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นรับฟังได้ ดังกรณีต่อไปนี้[50]

---

[47] ชลลดา จินตเสถียร, “ข้อยกเว้นการห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบตามมาตรา 226/1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), น.64.

[48] *เพิ่งอ้าง*,น.69.

[49] *เพิ่งอ้าง*,น.72.

[50] *เพิ่งอ้าง* ,น.73.

1)มีอำนาจค้นแต่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 102 และมาตรา 103 คือได้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ค้นได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 837/2483 วินิจฉัยว่าข้อปฏิบัติในบทมาตรา 102 และมาตรา103 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นแต่กำหนดวิธีการอันหนึ่งที่เจ้าพนักงานจะต้องกระทำ มิได้บังคับว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นแล้ว จะไม่ให้ฟังเสียเลยว่าการค้นของกลางได้ที่บ้านจำเลย จริงอยู่การไม่มีบันทึกให้จำเลยรับรู้ไว้แล้ว ศาลจำต้องระมัดระวังพยานบุคคลที่โจทก์นำมาสืบได้ของกลางที่บ้านจำเลย แต่เฉพาะคดีนี้ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ศาลฟังได้ปราศจากการระแวงสงสัยว่าจับของกลางได้ที่บ้านจำเลยทั้งสิ้น ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นพร้อมกับพิพากษากลับศาลอุทธรณ์ให้บังคับคดีไปตามศาลชั้นต้นทุกประการ

ดังนั้นการค้นที่มิได้กระทำในเรื่องรายละเอียด กล่าวคือมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา102 และ 103 คือไม่ได้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ได้จากการค้น ซึ่งศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่ได้มารับฟังได้ คำพิพากษาเรื่องนี้จึงเป็นบรรทัดฐานว่า หากมีอำนาจค้น แต่การค้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องปลีกย่อยบางประการ พยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นนั้นรับฟังได้

ข้อสังเกต แม้ฎีกานี้เป็นการวินิจฉัยในกรณีค้นที่รโหฐาน แต่การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดทำบันทึกตามมาตรา 102 103 104 เช่นกัน[51] ดังนั้นในกรณีที่เจ้าพนักงานค้นตัวในที่สาธารณสถานโดยไม่จัดทำบันทึก พยานหลักฐานที่ได้จากการค้นตัวบุคคลสามารถรับฟังได้อยู่

2)การค้นที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าบุคคลสองคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 102 บัญญัติไว้[52]

คำพิพากษาฎีกาที่ 395/2519 วินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานตำรวจค้นบ้านผู้ต้องหาต่อหน้าคนในบ้านคนหนึ่งซึ่งตาบอดทั้งสองข้างและหูหนวก กับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เชิญมาเป็นพยานในการตรวจค้นด้วยนั้น เมื่อไม่ได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจสามารถทำการค้นต่อหน้าคนอื่นนอกจากที่กล่าวได้แล้ว จึงอาจเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจกระทำเท่าที่สามารถจะกระทำได้และไม่อาจหาบุคคลอื่นมาเป็นพยานในการค้นมากไปกว่านั้น ถือได้ว่าเป็นการค้นที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 102 แล้ว

---

[51]ณรงค์ ใจหาญ,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่12,* น.247.

[52]ชลลดา จินตเสถียร,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่47,* น.74.

ข้อเท็จจริงตามฎีกานี้เจ้าพนักงานตำรวจถูกฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 157,362,365 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลให้ยกฟ้อง ซึ่งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืน มีข้อสังเกตว่า แม้ศาลฎีกาจะไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นเพราะไม่มีประเด็นให้ศาลต้องวินิจฉัย แต่เมื่อเทียบกับฎีกาที่ 837/2483 ข้างต้น ก็น่าจะถือได้ว่าพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นตามฎีกาที่395/2519 นี้รับฟังได้เช่นเดียวกับกรณีตาม 837/2483 ข้างต้น

3)การค้นโดยมิชอบ ไม่มีผลกระทบไปถึงการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและอำนาจฟ้องของคดีของอัยการ[53]

คำพิพากษาฎีกาที่ 6539/2550 การตรวจค้นเพื่อยึดของกลางและการสอบสวนเป็นการดำเนินการคนละขั้นตอนกัน แม้การตรวจค้นเพื่อยึดของกลางอาจมิชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวเป็นอีกเรื่องต่างหาก หามีผลให้การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยไม่ โจทก์บรรยายฟ้องว่ามีการสอบสวนแล้ว จำเลยมิได้ฎีกาว่าการสอบสวนไม่ชอบเพียงแต่อ้างว่าการหยุดรถจักรยานยนต์ของกลางในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องถือว่าการสอบสวนในความผิดที่กล่าวหาตามฟ้องชอบแล้ว

5.2 หลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่รโหฐานตามกฎหมายไทย

5.2.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การค้นในที่รโหฐานนี้เพื่อการค้นหา 2 ประการ คือ **หาบุคคลและหาสิ่งของ** การค้นเพื่อหาบุคคลได้แก่บุคคลซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังในที่รโหฐานนั้นหรือบุคคลที่มีหมายให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมาย ส่วนการค้นหาสิ่งของ ได้แก่ สิ่งของที่อาจเป็นวัตถุพยานหรือพยานเอกสารก็ได้ หรือซึ่งมีไว้หรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือใช้ในการกระทำความผิด หรือต้องถูกยึดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล[54]

1) วิธีการและขอบเขตค้นตัวบุคคลในที่รโหฐาน[55]

มาตรา 100 ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับทำให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแล

---

[53] เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่10*, น.472.

[54] ณรงค์ ใจหาญ,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่12* ,น.225.

[55] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ของเจ้าพนักงานในขณะที่ทำการค้นเท่าที่จำเป็น เพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับทำให้การค้นนั้นไร้ผล

ถ้ามี**เหตุอันควรสงสัย**ว่าบุคคลนั้นได้*เอา**สิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย*** เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจค้นตัวผู้นั้นได้ดั่งบัญญัติไว้ตามมาตรา 85

มาตรา 85 เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

การค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

จากการศึกษาพบว่าแนวคิดในการคุ้มครองตัวบุคคลกับแนวคิดในการคุ้มครองในที่รโหฐาน ต่างกันกล่าวคือ ในที่รโหฐานนั้นบุคคลมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง การตรวจค้นเคหสถานจะกระทำมิได้[56] ขณะที่การค้นตัวบุคคลกฎหมายมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางร่างกาย การค้นตัวบุคคลจะกระทำมิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ[57] เมื่อพิจารณาการ**ค้นตัวบุคคลในที่รโหฐาน**[58] กับกรณีการ**ค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน**ตามมาตรา 93[59] เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นที่รโหฐานหรือที่สาธารณสถานหากเป็นการค้นตัวบุคคล กฎหมายบัญญัติเงื่อนไขก่อนที่เจ้าพนักงานจะใช้อำนาจต้องมีมาตรฐานเดียวกันคือ “ เหตุอันควรสงสัย ” แต่เหตุในการสงสัยแตกต่างกัน กล่าวคือ เหตุในการค้นตัวบุคคลที่รโหฐาน เมื่อเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นได้*เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนใน*ร่างกาย แต่เหตุอันควรสงสัยกรณีค้นตัวบุคคลใน

---

[56] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 33

[57] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 32

[58] มาตรา 100 วรรค 2 บัญญัติว่า “ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจค้นตัวผู้นั้นได้ดั่งบัญญัติไว้ตามมาตรา 85 ”

[59] มาตรา 93 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน เว้นแต่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นใน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยมีการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด”

ที่สาธารณสถานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมี*สิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยมีการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด* ในประเด็นนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่าเหตุแห่งการค้นตัวบุคคลในที่รโหฐานมีขอบเขตที่กว้างกว่าการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานเพราะ คำว่า *"สิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย"* คือสิ่งของที่บุคคลมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในที่รโหฐานหรือตัวบุคคลที่อยู่ในที่รโหฐานตามมาตรา 92(4)นั่นเอง ขณะที่มูลเหตุในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน เจ้าพนักงานจะต้องสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของเพื่อจะใช้ ได้มา หรือมีไว้ เป็นความผิดเท่านั้น ทำให้เมื่อเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ "ได้ใช้"ในการกระทำความผิด ก็จะค้นตามมาตรา 93 ไม่ได้ นอกจากนี้มี**รายงานการวิจัย**[60]เห็นว่าเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของมีไว้ในการครอบครองเพื่อจะใช้ ซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิด หรือสิ่งมีไว้เป็นความผิด เป็นสิ่งของที่เกี่ยวพันความผิดที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วและเป็นสิ่งของที่ศาลมีอำนาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และ 33 แต่ไม่รวมถึงสิ่งของที่อาจเป็นพยานหลักฐานอื่นในคดีอาญา

ผู้เขียนเห็นว่า คำว่า สิ่งของที่"ได้ใช้" บางครั้งอาจตีความเป็นสิ่งของที่ "มีไว้"เป็นความผิด เช่น ปืนที่ใช้ในการฆ่าคน ปืนเป็นวัตถุที่ใช้ในการฆ่าคน และในขณะเดียวกันปืนก็เป็นวัตถุที่มีไว้เป็นความผิด แม้เจ้าพนักงานไม่สามารถเรียกให้ตรวจค้นโดยอาศัยอาศัยเหตุว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดได้ แต่เจ้าพนักงานสามารถเรียกตรวจค้นโดยอาศัยเหตุว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด

สิ่งของที่ "ได้ใช้" ยังสามารถตีความเป็นสิ่งของที่ "จะใช้" ในการกระทำความผิดในอนาคตได้ ถ้าวัตถุนั้นโดยสภาพเป็นอาวุธ เช่น หากนายแดงใช้มีดไปกรรโชกทรัพย์ของนายเหลือง มีดเป็นวัตถุที่นางแดงใช้ในการกรรโชก มีดจึงเป็นวัตถุที่ "ได้ใช้"ในการกระทำความผิด แม้เจ้าพนักงานไม่สามารถค้นตัวบุคคลเพราะเหตุเนื่องจากสงสัยว่าบุคคลนั้นมีวัตถุที่ "ได้ใช้"ในการกระทำความผิดมาแล้วได้ แต่เจ้าพนักงานสามารถค้นตัวบุคคลโดยใช้เหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีวัตถุที่ "จะใช้"ในการกระทำความผิดในอนาคตเพราะมีดเป็นวัตถุที่สามารถใช้ในการประกอบอาชญากรรมในอนาคตได้

---

[60] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการค้นตัวบุคคล:ศึกษาเปรียบเทียบกับนานาประเทศ,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์เดือนตุลา,2553),น.74.

กรณีวัตถุที่นายแดงนำไปใช้ไม่ใช่วัตถุโดยสภาพ จึงไม่เป็นสิ่งของที่ “จะใช้” ในการกระทำความผิดได้ เช่น ไฟแช็คที่จะนำไปเผาเพื่อทำลายทรัพย์ของผู้อื่น โดยสภาพไฟแช็คไม่ใช่อาวุธที่จะนำไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้ หากถือว่าไฟแช็คเป็นวัตถุที่จะใช้ในการกระทำความผิดต่อไปทุกคนที่พกไฟแช็คจะถูกตรวจค้นได้หมด แต่ถ้าจะพิจารณาในแง่ที่ว่าผู้ต้องสงสัยจะนำไฟแช็คไปใช้ในการเผาทรัพย์ของผู้อื่นต่อไปก็อาจจะมองได้

ผู้เขียนจึงเห็นว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าวัตถุนั้นจะเป็นวัตถุที่มีไว้ ได้มา หรือจะใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่ แต่เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นตั้งใจจะเอาไฟแช็คไปใช้กับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆต่อไป เพราะลำพังการพิจารณาวัตถุในการกระทำความผิดอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะอ้างเป็นเหตุในการค้นตัวบุคคลได้ แต่ต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยกับวัตถุที่ต้องสงสัยเป็นสำคัญ เพราะหากเจ้าพนักงานไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่ชัดเจนและบ่งชี้ได้เพียงพอว่าวัตถุนั้นเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้ถูกค้นว่าเขาได้กระทำความผิดหรือจะไปกระทำความผิด เจ้าพนักงานก็ไม่สามารถทำการค้นตัวบุคคลนั้นได้

ในกรณีที่วัตถุที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ และผู้กระทำความผิดตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดครั้งเดียว เช่น นำไฟแช็คไปเผาทรัพย์ของผู้อื่นครั้งเดียว เจ้าพนักงานไม่สามารถค้นตัวบุคคลนั้นได้เพราะไฟแช็คไม่สามารถตีความเป็นวัตถุที่ “ มีไว้ ” เป็นความผิดหรือวัตถุที่ “ จะใช้ ” ในการกระทำความผิด ดังนั้นกรณีที่เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ “ ได้ใช้ ” ในการกระทำความผิดซุกซ่อนอยู่ในร่างกายเจ้าพนักงานจะทำอย่างไร ประเด็นนี้อาจอาศัยการตีความโดยการเทียบเคียงจากมาตรา 92(4) เพราะมาตรา92(4) เป็นบทบัญญัติที่ใช้ในการค้นในที่รโหฐานซึ่งรวมถึงค้นตัวบุคคลที่อยู่ในที่รโหฐานนั้นด้วย เมื่อเจ้าพนักงานทำการค้นโดยมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ “ได้ใช้” ในการกระทำความผิดรวมอยู่ด้วย มาตรา 93 จึงน่าจะตีความไปในทำนองเดียวกันเพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถใช้อำนาจเมื่อมีพยานหลักฐานว่าบุคคลมีวัตถุที่ได้ใช้และได้มาในการกระทำความผิดไปแล้วได้ เนื่องจากมาตรา 92(4) เพิ่งมีการแก้ไขบทบัญญัติใน พ.ศ. 2547 จากเดิม “เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าสิ่งของที่**ได้มา**โดยการกระทำผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายเสียก่อน ” โดยการแก้ไขมีการเพิ่มเหตุแห่งการค้นในอนุมาตรา 4 ว่า “ เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่**มีไว้**เป็นความผิดหรือ**ได้มา**โดยการกระทำความผิดหรือ**ได้ใช้**หรือมีไว้เพื่อ**จะใช้**ในการกระทำความผิดหรือ**อาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิด**ได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมี

เหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน รวมทั้งต้องส่งมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทำบันทึกแสดงเหตุผลที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น " การแก้ไขเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้พยานหลักฐานถูกทำลายหรือทำให้เสียหายและเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของนั้นก่อนที่จะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้[61] ผู้เขียนจึงเห็นว่า การแก้ไขในมูลเหตุแห่งการค้นตัวบุคคลเพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถใช้อำนาจในการสอบสวนการกระทำความผิดได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็ให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยการจัดทำสำเนาบันทึกการตรวจค้นส่งมอบแก่ผู้ครอบครองสถานที่ มาตรา 93 จึงน่าจะตีความไปในทำนองเดียวกันโดยให้เจ้าพนักงานสามารถใช้อำนาจสอบสวนเมื่อมีพยานหลักฐานว่าบุคคลมีวัตถุที่ได้ใช้และเพื่อพบพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์การกระทำความผิดทางอาญา

อีกประเด็นหนึ่งการค้นตัวบุคคลในที่รโหฐานโดยมีหมายค้น หากเจ้าพนักงานพบบุคคลอื่นอยู่ในสถานที่รโหฐานแต่เจ้าพนักงานสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของอื่น(ซึ่งไม่ใช่สิ่งของที่ต้องการค้นตามที่ระบุในหมาย)ในความครอบครอง เจ้าพนักงานไม่มีอำนาจค้นตัวบุคคลนั้นตามหมาย หรือกรณีเป็นการค้นโดยไม่มีหมายหากต้องการค้นสิ่งของที่ไม่ใช่สิ่งของที่ต้องการค้น เจ้าพนักงานจะค้นบุคคลนั้นในที่รโหฐานจะอาศัยอำนาจตามมาตราใดเนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้กำหนดไว้ ผู้เขียนเห็นว่าเจ้าพนักงานสามารถค้นตัวบุคคลที่อยู่ในที่รโหฐานนั้นได้แต่เจ้าพนักงานผู้ทำการค้นต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลที่อยู่ในที่รโหฐานนั้นมีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด ได้มาโดยการกระทำความผิด หรือจะใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 93 เช่นกัน เนื่องจากขอบเขตในการค้นจำกัดเพียงค้นหาสิ่งของหรือบุคคลตามที่ระบุในหมาย และถ้าสิ่งของที่ต้องการค้นอยู่ในตัวบุคคลเจ้าพนักงานสามารถค้นตัวบุคคลเพื่อหาสิ่งของนั้นได้เพราะมีมาตรา 100 วรรคสองให้อำนาจไว้ แต่การค้นหาสิ่งของที่อยู่ในตัวคนที่นอกขอบเขตเจ้าพนักงานไม่มีอำนาจทำการค้นได้ แต่ไม่ใช่ว่าเจ้าพนักงานไม่สามารถค้นตัวบุคคลที่อยู่ในที่รโหฐานที่อยู่นอกขอบเขตได้เลย แต่เจ้าพนักงานสามารถทำการค้นตัวได้ทันทีเพราะการค้นในที่รโหฐานแม้มีการออกหมายค้นหรือกรณีที่สามารถทำการค้นได้โดยไม่มีหมาย หากเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้น มีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด ได้มาโดยการกระทำความผิด หรือจะ

---

[61] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา," ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(เรื่องเสร็จที่ 64/2545)",น.4.

ใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 93 เจ้าพนักงานสามารถค้นตัวบุคคลนั้นได้โดยใช้มาตรา 93 เช่นกันเนื่องจากการค้นตัวบุคคลแม้อยู่ในที่รโหฐานก็กระทบกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในร่างกายของผู้ถูกค้นเช่นกัน เจ้าพนักงานจึงไม่สามารถค้นบุคคลในที่รโหฐานได้ตามอำเภอใจ เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรสงสัยเสียก่อนเช่นเดียวกับกรณีค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน สอดคล้องกับความเห็นนักวิชาการ[62]ที่เห็นว่าต้องอาศัยมาตรา 93 เช่นกันคือ ต้องมี " เหตุอันควรสงสัย " มิใช่จะค้นได้ตามอำเภอใจ และความเห็นของ Newzealand Law Commission เสนอว่าเจ้าพนักงานควรมีเหตุอันควรเชื่อ(reasonable for believing)ว่าวัตถุซึ่งอาจเป็นพยานหลักฐานอยู่ในตัวบุคคลไม่ใช่ว่าจะอาศัยความเป็นไปได้(possible)ในการเข้าค้นตัวบุคคล[63] นอกจากนี้กฎหมายประเทศอังกฤษได้กำหนดไว้ใน PACE ว่าเหตุอันควรสงสัยในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะนั้นรวมถึงการค้นตัวบุคคลในที่รโหฐานในกรณีที่บุคคลหรือยานพาหนะไม่ได้อยู่ในบริเวณหรือส่วนที่เจ้าของสงวนไว้ในการเข้าพัก[64]

2) การตรวจสอบหลังการปฏิบัติการตามหมายค้น

มาตรา 63 บัญญัติว่า เมื่อเจ้าพนักงานได้จัดการตามหมายอาญาแล้ว ให้บันทึกรายละเอียดในการจัดการนั้น ถ้าจัดการตามหมายไม่ได้ ให้บันทึกพฤติการณ์ไว้ แล้วให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลซึ่งออกหมายโดยเร็ว

และข้อบังคับของประธานศาลฎีกากำหนดว่า[65]

"เมื่อเจ้าพนักงานได้จัดการตามหมายค้นแล้ว ให้บันทึกรายละเอียดแห่งการจัดการนั้นว่าได้จัดการตามหมายหรือไม่ แล้วให้ส่งบันทึกไปยังศาลที่ออกหมายโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 15 วัน นับแต่วันจัดการตามหมาย ทั้งนี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ตามหมายค้นจะร้องขอให้ศาลออกหลักฐานการตรวจค้น พร้อมสำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจ

---

[62] เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่10,* น.334.

[63]New Zealand Law Commission,Search and Survillance Powers,(Wellington 2007),Chapter 8,p.241.

[64] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 60,*น.41-42.

[65] คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,พิมพ์ครั้งที่ 7(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา,2549),น.301.

ค้นนั้นให้ก็ได้"

มาตรา 92 วรรคสอง บัญญัติว่า ในการใช้อำนาจตามมาตรา92(4) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้ค้นส่งมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้นแต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทำได้และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

มาตรา 103 บัญญัติว่า ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมีบัญชีรายละเอียดไว้

บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จำเลย ผู้แทนหรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้

มาตรา 104 บัญญัติว่า เจ้าพนักงานที่ค้นโดยมีหมาย ต้องรีบส่งบันทึกและบัญชีดั่งกล่าวในมาตราก่อนพร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมา ถ้าพอจะส่งได้ ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กำหนดไว้ในหมาย

ในกรณีที่ค้นโดยไม่มีหมายโดยเจ้าพนักงานอื่นซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวน ให้ส่งบันทึก บัญชีและสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซึ่งต้องการสิ่งเหล่านั้น

ข้อน่าสังเกต การค้นโดยมีหมายหรือไม่มีหมายค้น เจ้าพนักงานยังคงต้องดำเนินการตามมาตรา102 103 104 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยต้องจัดทำบัญชีการค้นหรือบัญชีทรัพย์สิน และบันทึกการค้น แต่มิได้ต้องมีมาตรการที่ต้องส่งให้แก่ผู้ครอบครอง ดังเช่นวรรคท้ายของมาตรา92[66]

แม้เจ้าพนักงานทำการค้นโดยไม่จัดทำบันทึก ไม่ทำให้เป็นการค้นที่มิชอบ แต่ส่งผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเท่านั้น ดังคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

เจ้าพนักงานเข้าไปตรวจค้นของกลาง แต่ไม่ได้บันทึกรายละเอียดของกลางนั้นไว้ มาตรา 102 และ 103 เป็นแต่การกำหนดวิธีการอันหนึ่งที่เจ้าพนักงานต้องกระทำ ไม่ได้บังคับว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นแล้ว จะไม่ให้ฟังเสียเลยว่า ได้ค้นของกลางได้ที่บ้านจำเลย จริงอยู่การที่ไม่มีบันทึกให้จำเลยรับรู้ไว้แล้ว ศาลจำต้องระมัดระวังพยานบุคคลที่โจทก์นำสืบในข้อได้ของกลางที่บ้านจำเลย แต่คดีนี้พยานบุคคลของโจทก์ฟังได้โดยปราศจากการสงสัยว่าจับของกลางได้ที่บ้านของจำเลยทั้งสิ้น(ฎีกาที่ 837/2482)

เจ้าพนักงานศุลกากรตรวจค้นของกลางแล้วมิได้ทำบันทึกการตรวจค้นตามมาตรา

---

[66] ณรงค์ ใจหาญ,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่12,* น.247.

103 นั้น โจทก์นำพยานบุคคลที่รู้เห็นมาสืบการที่เจ้าพนักงานศุลกากรพบของกลางนั้นได้เพราะเป็นการกระทำโดยอำนาจเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร**มิใช่เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐาน** เพื่อพิสูจน์ความผิดตามวิธีการแห่งกฎหมายดังกล่าว(ฎีกาที่ 779/2487)[67]

ค้นของกลางในบ้านผู้ต้องหา ผู้ต้องหาไม่อยู่ ได้ของกลางแล้วมิได้จัดทำบันทึกให้ภริยาผู้ต้องหาลงชื่อรับรองนั้น เป็นการไม่ชอบด้วยมาตรา 103 (ฎีกาที่ 857/2482)[68]

กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำบันทึกการจับกุมในสถานที่ที่จับกุมหรือตรวจค้น อีกทั้งได้ความว่าจำเลยกับพวกถูกจับกุมในสถานที่ที่จับกุมในสถานที่ต่างกันเวลาไล่เลี่ยกัน การทำบันทึกการจับกุมที่สถานีตำรวจจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วและเนื่องจากเป็นการบันทึกการจับกุมมิใช่บันทึกการตรวจค้น จึงไม่ต้องบันทึกของกลางที่ตำรวจตรวจพบไว้โดยละเอียด เพียงแต่บันทึกของกลางที่ตรวจพบหรือทำบัญชีของกลางไว้ก็เพียงพอแล้ว ไม่เป็นการขัดต่อมาตรา 103(ฎีกาที่ 2892/2536)[69]

ดั่งนี้แสดงว่าตามความเห็นของศาลฎีกา บทบัญญัติแห่งมาตรา 103 นี้ก็เป็น “บทบัญญัติที่เป็นข้อปฏิบัติ”(Ordnungsvorschrift) มิใช่บทบัญญัติที่เป็นบทบังคับอันจะมีผลให้พยานหลักฐานที่ได้มานั้นเป็นพยานหลักฐานที่มิชอบและห้ามรับฟังตามาตรา 226[70]

5.3 เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ

ผู้เขียนได้ทำการศึกษาหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานทั้งกฎหมายคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์พบว่ากฎหมายต่างประเทศได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในระหว่างการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานไว้อย่างละเอียด สามารถสรุปออกได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

5.3.1 เหตุอันควรสงสัย

---

[67] พิพัฒน์ จักรางกูร,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 34*,น.168.

[68] สมชัย ฑีฆาอุตมากร, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิพมพ์พลสยามพริ้นติ้ง(ประเทศไทย,2547),น.103.

[69] *เพิ่งอ้าง*,น.103.

[70] คณิต ณ นคร,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่65* ,น.364.

การค้นตัวบุคคลตามมาตรา 93 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ใช่การจับ (arrest) แต่เป็นหลักเกณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถทำการสอบสวนพฤติกรรมที่ต้องสงสัยว่าบุคคลนั้นกำลังจะกระทำความผิดหรือได้กระทำความผิดโดยที่ยังไม่มีการจับ เพราะการจับต้องอาศัยข้อมูลที่ถึงระดับมีพยานหลักฐานเชื่อแน่ว่ามีกากระทำความผิด หรือ probable cause ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการออกหมายจับและหมายค้น ดังนั้นเมื่อเจ้าพนักงานไม่มีพยานหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอที่จะชี้ว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิด แต่มีข้อเท็จจริงที่อยู่ในระดับต่ำลงมาแต่สงสัยว่าบุคคลนั้นได้เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม เจ้าพนักงานต้องใช้หลักเกณฑ์การเรียกให้หยุดและการตรวจค้นตัวบุคคลตามมาตรา 93 เพื่อสอบสวนพฤติกรรมที่ต้องสงสัย การค้นตัวบุคคลตามมาตรา 93 จึงเทียบได้กับ stop and frisk ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ stop and search ของประเทศอังกฤษ เมื่อมาตรา 93 ไม่ใช่การจับ เงื่อนไขในการค้นตัวบุคคลตามมาตรานี้จึงไม่ใช่มาตรฐานระดับ probable cause แต่ลดลงมาเป็นระดับเหตุอันควรสงสัย หรือ reasonable suspicion ดังนั้นเมื่อมีการหลบหนีระหว่างถูกค้นตัวตามมาตรา 93 จึงไม่ผิดหลบหนีที่คุมขัง ตามมาตรา 190 ประมวลกฎหมายอาญา เพราะผู้ถูกค้นตัวยังไม่ใช่ผู้ถูกจับที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงาน และหากเจ้าพนักงานเรียกให้หยุดแล้วค้นโดยไม่มีเหตุอันควรสงสัย เมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่แล้วไม่ตอบไม่ผิดมาตรา 367 ประมวลกฎหมายอาญา

เหตุอันควรสงสัยตามกฎหมายไทย ไม่มีการกำหนดความหมายหรือกรอบของคำว่า “ เหตุอันควรสงสัย ” ทั้งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการค้นตัวบุคคลเพราะก่อนที่เจ้าพนักงานจะใช้อำนาจในการค้นตัวบุคคลลำดับแรกเจ้าพนักงานต้องพิจารณาก่อนว่ามีเหตุอันควรสงสัยที่จะค้นตัวบุคคลที่กำลังจะถูกค้นหรือไม่ เมื่อพิจารณา*แนวคำพิพากษาศาลฎีกาไทย*เกี่ยวกับการค้นตัวบุคคลตามมาตรา 93 นี้ผู้เขียนสรุปแนวทางการตัดสิน “ เหตุอันควรสงสัย ”ออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้

1)เมื่อปรากฏว่าผู้จะถูกค้นมีสิ่งของที่จะใช้หรือมีไว้เป็นความผิด เจ้าพนักงานสามารถค้นตัวบุคคลได้ตามมาตรา 93

2)พิจารณาเหตุอันควรสงสัยในการค้นตัวจากพยานหลักฐานที่พบในตัวผู้ถูกค้นเป็นสำคัญโดยไม่มีการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัย “ก่อน” ทำการค้นตัวบุคคลหรือไม่

เปรียบเทียบกับคำพิพากษาคดี Regina v. Elizabeth Minto ศาลพิพากษาว่าหากไม่มีเหตุอันควรสงสัยก่อนทำการตรวจค้น แม้ต่อมาพบว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ไม่ทำให้กลายเป็นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยได้ เพราะเหตุอันควรสงสัยต้องพิจารณาก่อนทำการค้น

3)เหตุอันควรสงสัยเกิดจากการที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้จะถูกค้นประกอบการตัดสินใจของเจ้าพนักงานก่อนทำการค้น

กรณีที่ได้รับแจ้งมาจากบุคคลอื่น เจ้าพนักงานต้องมีจะต้องมีข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาประกอบเพื่อยืนยัน แม้ว่าได้พบบุคคลที่ตรงตามที่ได้รับแจ้งก็ตาม ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาพิพากษาว่าแม้พบบุคคลตามที่ได้รับแจ้งก็ไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัย แต่เจ้าพนักงานต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งชี้ไปได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทำความผิด(คดี Florida v.J.L.529 U.S.266 2000)

4)พิจารณาสถานการณ์ทั้งหมดว่ามี “ เหตุอันสมควร ” ในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานแล้ว

การพิจารณาจากสถานการณ์ทั้งหมดต้องมีความชัดเจนและเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมที่ต้องสงสัยและผู้ต้องสงสัยเข้าด้วยกัน แต่ไม่ต้องถึงขนาดรู้ว่าผู้ต้องสงสัยชื่ออะไร ไปโรงแรมชื่ออะไร แต่พฤติกรรมทั้งหมดต้องสามารถเชื่อมโยงการกระทำที่ต้องสงสัยได้ ข้อเท็จจริงในคดี U.S. v Cortez,449 U.S. 411(1981) เจ้าพนักงานเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยจนสามารถคาดการณ์พฤติกรรมได้อย่างแม่นยำทั้ง จำนวนผู้กระทำความผิดเวลาที่ผู้นั้นได้กระทำความผิด ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิด รูปแบบที่ผู้กระทำความผิดใช้ในการกระทำความผิดครั้งก่อนๆ สถานการณ์ทั้งหมดจึงเพียงพอพิจารณาไปได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยซึ่งปัจจัยที่นำมาคำนึงนั้นได้สอดคล้องกับปัจจัยที่ศาสตราจารย์ LA FAVE เสนอไว้

5) พิจารณาจากผู้ใช้อำนาจในการค้น หากเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การค้นนั้นชอบด้วยกฎหมายมาตรา 93

ในคำพิพากษาของศาลหรือความเห็นของนักวิชาการต่างประเทศ ปัจจัยในการพิจารณาว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพื่อค้นตัวบุคคล ไม่สามารถพิจารณาได้จากผู้ใช้อำนาจในการค้น แต่ต้องพิจารณาเป็นสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์(ข้อมูลทางภาวะวิสัย)และพฤติกรรมของบุคคล(ข้อมูลทางอัตตะวิสัย)ประกอบกัน ไม่มีการพิจารณาจากตัวผู้ใช้อำนาจแต่อย่างใด

6) ใช้ “ ความสงสัย ” ของเจ้าพนักงาน เป็นเหตุผลในการเข้าตรวจค้น

โดยปกติความสงสัยทั่วไปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เจ้าพนักงานจะใช้ในการสอบสวน แต่ไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการค้นตัวบุคคลได้ในทันที ศาลต่างประเทศพิพากษาว่าความสงสัยทั่วไปที่ไม่มีพยานหลักฐานใดมายืนยันไม่ต่างอะไรกับการคาดเดาซึ่งไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยได้

นอกจากนี้คำพิพากษาของศาลต่างประเทศและความเห็นของนักวิชาการ เห็นว่าเหตุอันควรสงสัยต้องมีอยู่ “ก่อน” การค้นถึงจะเป็นการค้นที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้เผอิญได้สิ่งของผิดกฎหมายก็มิได้หมายความว่าการค้นตั้งแต่ต้นเป็นการค้นที่ชอบ ผลของการค้นโดยไม่มีเหตุอันควรสงสัยทำให้เป็นการค้นที่มิชอบ ศาลจะไม่รับฟังพยานหลักฐาน เนื่องจากเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนผู้ถูกตรวจค้นอย่างร้ายแรงมาก

ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญว่าอย่างไรเป็นเหตุอันควรสงสัย แม้ไม่ได้กำหนดให้แน่นอนขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละคดีเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานมีความยืดหยุ่น จึงเพียงแต่วางหลักเกณฑ์ไว้อย่างกว้างๆว่าไม่สามารถเกิดจากลางสังหรณ์(hunch) หรือความสงสัยทั่วไป (general suspicion) ทำให้การค้นตัวของเจ้าพนักงานจึงไม่สามารถกระทำได้โดยง่าย แต่ต้องมีข้อเท็จจริงจากพฤติการณ์แวดล้อม(ทางภาวะวิสัย)ที่หนักแน่นพอสมควรประกอบกับพฤติการณ์ที่น่าสงสัยของผู้จะถูกค้น ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินไว้ในคดีหลายคดีว่าการกระทำใดบ้างเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ ซึ่งมีคำพิพากษาเกือบทุกเรื่อง[71]มีหลักว่าเหตุอันควรสงสัยต้องมีมา “ก่อน” การค้นตัวบุคคลและต้องมีข้อเท็จจริงอื่นประกอบกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้จะถูกค้น หากไม่มีเหตุอันควรสงสัยจะเป็นการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทันที เปรียบเทียบกับคำพิพากษาศาลฎีกาไทยที่พิจารณา “เหตุอันควรสงสัย” จากพยานหลักฐานที่ได้ภายหลังการค้นหรือจากข้อมูลจากการได้รับแจ้งแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้จะถูกค้น ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาเคยมีคำพิพากษาว่าข้อมูลจากผู้รับแจ้งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัย

จะเห็นได้ว่าเหตุอันควรสงสัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ต้องมีระดับสูงกว่าความสงสัยโดยทั่วไปหรือลางสังหรณ์ แต่ไม่ต้องสูงกว่าระดับprobable cause และต้องประกอบด้วยข้อมูลจากตัวผู้ต้องสงสัยและสถานการณ์แวดล้อม ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับกากระทำความผิดต่างจากกฎหมายไทยที่ไม่มีหลักเกณฑ์และไม่มีคำพิพากษาที่กำหนดกรอบในการพิจารณาว่าอย่างใดเป็น ” เหตุอันควรสงสัย”เจ้าพนักงานจึงมักใช้ความสงสัยโดยทั่วไป หรือลางสังหรณ์ หรือการสุ่มตรวจในการปฏิบัติงาน

ส่วนประเทศอังกฤษ มีการกำหนดกรอบ “ เหตุอันควรสงสัย ” คล้ายกับประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศอังกฤษมีความชัดเจนกว่าโดยการกำหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

---

[71]คดี Terry v Ohio , 392 U.S. 1, (1968),คดี U.S. v. sokolaw , 490 U.S. 1 (1989).

ดังที่ปรากฏ PACE ซึ่งเป็นระเบียบให้ตำรวจปฏิบัติทำให้การทำงานของเจ้าพนักงานมีความชัดเจนและใช้อำนาจไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น ซึ่งเหตุอันควรสงสัยคล้ายกับกฎหมายไทยแต่กฎหมายอังกฤษจะครอบคลุมกว่า คือ จะรวมสิ่งของที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิดหรือกำลังกระทำความผิดด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นตัวเพื่อพบพยานหลักฐานได้ครอบคลุมกว่า กรอบของเหตุอันควรสงสัยของประเทศอังกฤษกำหนดไว้ชัด คือ ต้องเกิดจากข้อเท็จจริงหรือสภาพแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ โดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวบุคคล ได้แก่ บุคลิกลักษณะของบุคคลของผู้ที่แจ้ง หรือประวัติอาชญากรรม และตำรวจไม่อาจที่จะควบคุมตัวผู้ที่ถูกเรียกให้หยุดเพื่อหาเหตุแห่งการค้นได้ ต่างจากคำพิพากษาของไทยที่ศาลมุ่งพิจารณาตัวผู้ถูกค้นเป็นหลักโดยเชื่อมโยงเบาะแสของผู้แจ้งเข้ากับบุคคลที่มีลักษณะตรงกับที่ได้รับแจ้งใช้อ้างเป็นเหตุในการใช้อำนาจค้นตัวบุคคลโดยไม่ได้สังเกตพฤติกรรมของผู้จะถูกค้นอีก หรือการตรวจค้นโดยไม่มีสาเหตุเนื่องจากดูรูปพรรณ ท่าทางจะเป็นคนร้ายเพียงอย่างเดียว ทำให้เห็นได้ว่า กฎหมายประเทศอังกฤษให้ความคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนโดยมีการกำหนดกรอบการทำงานของเจ้าพนักงานที่เป็นรูปธรรมและใช้ไปในแนวทางเดียวกัน

5.3.2 **เงื่อนไขในการค้นตัวบุคคล**

ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีเหตุอันควรสงสัย 2 ประการ คือ ในการเรียกให้หยุดเมื่อเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดหรือกำลังจะไปกระทำความผิด และเหตุอันควรสงสัยในการค้นตัวบุคคล เมื่อเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้มีอาวุธไว้ในความครอบครอง

ส่วนเหตุอันควรสงสัยของประเทศอังกฤษพนักงานตำรวจผู้ค้น จะต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นจะมีสิ่งของที่ได้ลักมาหรือมีสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่ระบุไว้ในมาตรา8(A)ซึ่งเป็นสิ่งของที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิดหรือกำลังกระทำความผิด หรือจะกระทำความผิดตามมาตรา 139 แห่ง Criminal Justice Act 1988 หรือมีสิ่งของที่มีไว้เพื่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

เหตุอันควรสงสัยของประเทศฝรั่งเศส เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ขับขี่รถหรือผู้โดยสารได้กระทำความผิดหรือครอบครองวัตถุที่มีไว้เป็นความผิด หรือกรณีความผิดซึ่งหน้า เมื่อเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ขับขี่รถหรือผู้โดยสารได้กระทำความผิดหรือครอบครองวัตถุที่ครอบครองเป็นความผิดไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้กระทำความผิดเองหรือผู้ร่วมกระทำความผิด

ส่วนประเทศนิวซีแลนด์เหตุอันควรสงสัยเป็นไปตามกฎหมายพิเศษ เช่น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้หลบเลี่ยงในเรื่องหรือเกี่ยวกับสินค้าที่มิได้เสียภาษี หรือเมื่อมีเหตุอันควร

เชื่อว่าบุคคลนั้นครอบครองยาเสพติดที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานพบพยานหลักฐานที่ซ่อนอยู่ตัวผู้กระทำความผิด

ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศสกำหนดเงื่อนไขในการค้นตัวบุคคลเพื่อป้องกันอาชญากรรม และเพื่อพบพยานหลักฐานในการกระทำความผิดหรือสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิด ซึ่งในกฎหมายไทยบัญญัติเงื่อนไขในการค้นตัวบุคคลในที่รโหฐานว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายซึ่งหมายถึงสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น

เงื่อนไขในการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานยังจำกัดเพียงแค่ค้นหาสิ่งของที่กฎหมายห้ามมีไว้ในครอบครอง หรือเกี่ยวพันความผิดที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วและเป็นสิ่งของที่ศาลมีอำนาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และ 33 แต่ไม่รวมถึงสิ่งของที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในตัวของบุคคลนั้น

5.3.3 **วิธีการค้น**

กฎหมายไทยบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานในการค้นตัวบุคคลได้ แต่มิได้กำหนดขั้นตอนหรือกระบวนการในการจำกัดอำนาจเจ้าพนักงาน ทำให้เกิดปัญหาในทางทฤษฎีว่าเจ้าพนักงานจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งในต่างประเทศได้กำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการการตรวจค้นตัวบุคคลได้สมบูรณ์และครอบคลุมโดยมีวิธีการที่ไม่ล่วงละเมิดในร่างกายเกินไปกว่าการค้นตัวผู้ถูกจับ

กระบวนการในการค้นตัวบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการค้นตัวต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่เลือกประติบัติต่อบุคคล ส่วนประเทศฝรั่งเศสต้องคำนึงถึงหลักความจำเป็นและหลักการได้สัดส่วน

กระบวนการก่อนการค้นตัวบุคคล ประเทศอังกฤษกำหนดกระบวนการก่อนการค้นตัวบุคคลไว้ในระเบียบตำรวจทำให้เจ้าพนักงานสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ต้องมีการแจ้งชื่อเจ้าพนักงาน อธิบายเหตุทางกฎหมายว่าใช้อำนาจอะไร ตามกฎหมายใด แจ้งด้วยว่าผู้ถูกค้นมีสิทธิได้รับสำเนาบันทึกการตรวจค้นและมีวิธีการตรวจค้นที่กระทบสิทธิบุคคลน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้

กระบวนการระหว่างการค้นตัวบุคคล ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาไว้อย่างชัดเจนว่าเจ้าพนักงานสามารถตรวจค้นได้เพียงการแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธ(pat

down)ถ้าสงสัยว่ามีอาวุธถึงจะล้วงเข้าในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกงได้ ขณะที่ประเทศอังกฤษเจ้าพนักงานสั่งให้ถอดเสื้อชั้นนอกได้(outer coat) ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษและฝรั่งเศสกำหนดให้การค้นตัวต้องทำในระยะเวลาสั้น เพราะการค้นตัวไม่ใช่การจับเจ้าพนักงานจึงไม่สามารถควบคุมตัวบุคคลได้มากไปกว่าความจำเป็นในการสอบสวน และต้องกระทำในสถานที่ที่เกิดมูลเหตุให้ตรวจค้นหรือใกล้กับสถานที่ที่เรียกให้ตรวจค้นเพราะหากทำในสถานที่อื่นถือว่าเหตุอันควรสงสัยในการค้นตัวบุคคลหมดไปและมีผลทำให้การค้นตัวบุคคลไม่ชอบทันที การเรียกให้หยุดต้องจึงต้องเกิด*ขณะที่เริ่ม*พบการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัยหรือขณะที่ความสงสัยยังคงมีอยู่ และมีอยู่ตราบเท่าที่ทำให้ความสงสัยของเจ้าหน้าที่หมดไปหรือทำให้เจ้าหน้าที่แน่ใจว่าบุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หากเรียกให้หยุดหลังจากนี้เป็นการเรียกให้หยุดที่ไม่ชอบตามกฎหมาย รวมถึงสถานที่ที่เรียกให้หยุด ต้องกระทำในสถานที่ที่เกิดความสงสัย หากไกลออกไปถือเป็นการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้การเรียกให้หยุดจะมีเหตุอันควรสงสัยมาแต่แรก ดังนั้นเจ้าพนักงานจึงมีข้อจำกัดในการค้นตัวบุคคลในเรื่องวิธีการ ระยะเวลา สถานที่ ในเรื่องวิธีการเจ้าพนักงานต้องใช้วิธีการที่ล่วงละเมิดน้อยที่สุด

นอกจากนี้สหรัฐอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์กำหนดให้การค้นตัวต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีเพศเดียวกับผู้ถูกค้นเพื่อคุ้มครองผู้ถูกค้นตัวที่เป็นผู้หญิง

กระบวนการหลังค้น ประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ในกฎหมายพิเศษบางฉบับกำหนดให้เจ้าพนักงานผู้ใช้อำนาจจัดทำบันทึกการตรวจค้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีการมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นแก่ผู้ที่ถูกตรวจค้น เหมือนประเทศอังกฤษ ซึ่งการจัดสำเนาให้แก่ผู้ถูกค้นจะช่วยให้ผู้ถูกค้นมีพยานหลักฐานในการเรียกร้องให้เจ้าพนักงานต้องรับผิดในกรณีที่ผู้ถูกตรวจค้นได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ประเทศอังกฤษยังมีกลไกในการให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบบันทึกคำร้องทุกข์และมีรายงานการค้นเป็นประจำเดือนและประจำปี รวมถึงมีตัวแทนของชุมชนเข้ามาตรวจสอบหรือสามารถขอหลักฐานจากหน่วยงานตำรวจได้เป็นมาตรการที่ถือว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานในเรื่องนี้ได้อย่างโปร่งใสอันจะนำมาซึ่งการใช้อำนาจเรียกให้หยุดและตรวจค้นอย่างระมัดระวัง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนประเทศไทยมีการบัญญัติให้มอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นแก่ผู้ถูกค้นในกรณีการค้นตัวในที่รโหฐานตามมาตรา 92(4)และกรณีการค้นในที่รโหฐานโดยมีหมาย ซึ่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกากำหนดว่าให้เจ้าของผู้ครอบครองสถานที่ขอสำเนาบันทึกการตรวจค้นของเจ้าพนักงานจากศาลได้หากมีความประสงค์

กล่าวโดยสรุป หลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลของต่างประเทศการพิจารณาการค้นตัวบุคคลจึงไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะมีเหตุอันควรสงสัยเพียงอย่างเดียว แต่เจ้าพนักงานต้องกระทำภายในขอบเขตของการค้น คือ ในแง่เวลา และสถานที่ด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน*ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93* ยังบกพร่องและมิได้รับการแก้ไขให้มีความชัดเจน ทั้งในแง่เงื่อนไขในการค้นยังไม่ครอบคลุมในการที่เจ้าพนักงานจะแสวงหาพยานหลักฐาน และกระบวนการค้นของเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงเป็นช่องว่างในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกค้นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่มีหลักประกันที่จะไม่ถูกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการตรวจค้น

ส่วนหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคล*ในกรณีพิเศษ* สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี คือ กรณีการสอบสวนเกี่ยวกับยาเสพติด กรณีสอบสวนเกี่ยวกับสินค้าศุลกากร และกรณีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการค้นตัวบุคคล เจ้าพนักงานใช้อำนาจค้นตัวบุคคลได้ ต้องกลับมาใช้หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทำให้เห็นได้ชัดว่ากฎหมายไทยยังมีข้อบกพร่องในเรื่องกระบวนการค้นตัวบุคคลอยู่มาก

ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายไทยยังขาดสาระสำคัญในเรื่องหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน ผู้เขียนขอเสนอให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์วิธีการค้นตัวบุคคลมาตรา93 ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้นใน และส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติงานให้กำหนดในระเบียบปฏิบัติงานของตำรวจ เช่น รายละเอียดการแจ้งสิทธิก่อนเข้าค้นตัวบุคคล ขอบเขตของการค้นตัวบุคคลได้แค่ไหนเพียงไร เพื่อให้หลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลมีความชัดเจนแน่นอนให้กับเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและได้รับหลักประกันสิทธิที่บัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญ

5.4 แนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย [72]

หลังจากผู้เขียนได้ศึกษาหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและได้พิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยทั้งในระบบซีวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์แล้วพบว่า

---

[72] สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 60*, น.109-115.

หลักเกณฑ์ในกฎหมายไทยเรื่องการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานยังมีหลักเกณฑ์ที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอในการประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ถูกตรวจค้น ซึ่งผู้เขียนมองเห็นแนวทางในการแก้ไขออกเป็น 2 แนวทาง คือ

5.4.1 แนวทาง**การตีความ**วิธีการปฏิบัติของมาตรา 93 ให้นำหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่รโหฐานมาใช้กับที่สาธารณสถานเท่าที่จะใช้ได้[73] อาทิเช่น การค้นนั้นจักต้องกระทำด้วยความสุภาพตามมาตรา 85 หรือก่อนเจ้าพนักงานทำการค้นให้แสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน หรือหากผู้ที่ตรวจค้นไม่ยอมให้ทำการตรวจค้น เจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเท่าที่จำเป็นเพื่อเข้าไปในสถานที่ เป็นต้น ข้อดีของวิธีนี้คือไม่ต้องแก้กฎหมายซึ่งหลักเกณฑ์ที่จะนำมาอนุโลมใช้ สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากเป็นการกระทำต่อร่างกายเหมือนกัน กล่าวคือเป็นการค้นตัวบุคคลเช่นเดียวกัน ทำให้สามารถแก้ปัญหาการไม่มีหลักเกณฑ์มาใช้อย่างรวดเร็วเพราะการแก้ไขกฎหมายต้องใช้เวลาดำเนินการนาน การที่อนุโลมเอากฎหมายที่มีอยู่จะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิให้มากขึ้น และศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินคดีซึ่งศาลตีความไปในแนวทางคุ้มครองสิทธิของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันการตัดสินว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาแต่ละคนซึ่งผู้พิพากษาอาจตีความไปในแนวทางที่ไม่คุ้มครองสิทธิของประชาชนก็ได้ เช่น กรณีเจ้าพนักงานต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการค้นตัวบุคคล เคยมีคำพิพากษาฎีกาตัดสินว่า เจ้าพนักงานไม่จำต้องแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน ซึ่งในประเด็นนี้มีนักวิชาการให้ความเห็นต่างออกไปว่าเจ้าพนักงานควรแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนเพื่อป้องกันการครหาในภายหลังว่ามีการกลั่นแกล้งกัน ดังนั้นข้อเสียของวิธีนี้คือขาดหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่แน่นอน ทำให้เจ้าพนักงานผู้ใช้อำนาจในการค้นตัวปฏิบัติต่อผู้ถูกค้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานแต่ละคนว่าตระหนักถึงสิทธิของประชาชนเพียงไร และผู้พิพากษาก็มีการวินิจฉัยในข้อเท็จจริงเดียวกันต่างออกไป ส่งผลเสียต่อประชาชนผู้ถูกค้นตัวเป็นอย่างมาก

5.4.2 แนวทางปรับปรุง**แก้ไขกฎหมาย**ในเรื่องการค้นตัวบุคคล วิธีนี้จะทำให้เจ้าพนักงาน บุคคลผู้ถูกค้นและศาลมีหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลที่แน่นอน ในส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานมีแนวทางให้ปฏิบัติไปในแนวทิศทางเดียวกัน ในส่วนของผู้ถูกค้นเองสามารถรู้ล่วงหน้าว่าตนมีสิทธิอะไรบ้างซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ประชาชนควรจะรู้ว่ากฎหมายให้การคุ้มครองสิทธิของเขาอย่างไร การมีกฎหมายบัญญัติชัดเจนแน่นอนเป็นการสะท้อนกฎหมาย

---

[73] จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช,*อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3*,น.191.

ประเทศนั้นๆว่ามีหลักประกันสิทธิของบุคคลที่ดี เช่น สิทธิที่เจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ทำการตรวจค้น สิทธิที่จะได้รับสำเนาบันทึกหลังการตรวจค้น ในการวินิจฉัยคดีของศาลจะมีกฎหมายที่แน่นอนใช้ในการตัดสินคดีทำให้ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาแต่ละคนเช่นกัน

ข้อเสียของวิธีนี้คือ การแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและอาศัยเวลานาน อีกทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากเกินไป ทำให้บางครั้งการทำงานของเจ้าพนักงานขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้การค้นทั้งหมดกลายเป็นการค้นมิชอบหรือไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

5.4.3 การ**วางแนวปฏิบัติในระเบียบ**ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา 93 ข้อดีของวิธีนี้คือ เป็นวิธีการที่ช่วยไม่ให้มีการบัญญัติรายละเอียดลงในกฎหมายมากเกินไป สามารถแก้ไขหลักเกณฑ์ได้ง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อไม่มีสถานะบังคับเป็นกฎหมาย เมื่อเจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติ ไม่ทำให้การค้นไม่ชอบ ทำให้ศาลมีดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานชิ้นนั้นได้ ส่วนข้อเสียคือ ระเบียบไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย จึงไม่มีสภาพบังคับให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นเพียงแนวทางซึ่งเป็นเรื่องภายในประชาชนจึงไม่ค่อยรู้และเมื่อเจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติ ประชาชนผู้ถูกค้นตัวไม่สามารถกล่าวอ้างความไม่ชอบกับเจ้าพนักงานได้โดยตรง

ผู้เขียนเสนอว่า ควรจะเพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรา 93 ให้มีหลักเกณฑ์รายละเอียดในการค้นมากขึ้น ผู้เขียนเห็นว่า การค้นตัวบุคคลเป็นการกระทบต่อสิทธิทางร่างกาย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ กฎหมายที่จะมากระทบต่อสิทธิทั้งสามนี้จึงควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน และประชาชนควรที่จะรู้ล่วงหน้าว่าเจ้าพนักงานมีหรือใช้อำนาจตามกฎหมายใด และประชาชนผู้ถูกตรวจค้นมีสิทธิหรือจะถูกลิดรอนสิทธิใดได้บ้าง เพราะหากให้การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานขึ้นอยู่กับการตีความ สิทธิของประชาชนจะขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจทั้งกระบวนการตั้งแต่การใช้อำนาจในการเริ่มต้นแสวงหาพยานหลักฐานจนถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานโดยศาล จึงขอเสนอให้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ของมาตรา 93 ให้มีหลักการดังต่อไปนี้

1.การปรับปรุงเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้อำนาจค้นตัวบุคคลของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจให้ชัดเจนและครอบคลุมกรณีต่างๆดังต่อไปนี้

เพิ่มเหตุอันควรสงสัย ให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจในการค้นเมื่อสงสัยว่าบุคคลนั้นมีวัตถุที่ได้ใช้ หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในตัวบุคคลนั้น

เนื่องจากเงื่อนไขการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน มาตรา 93 เดิมเจ้าพนักงานไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานเมื่อสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดซ่อนในตัว ทำให้เจ้าพนักงานค้นตัวได้เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ เมื่อเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของไว้ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการทำผิด กับการปราบปรามหรือกับการกระทำความผิดที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว คือมีพยานหลักฐานที่ได้มา เท่านั้น ทำให้เมื่อสงสัยว่ามีสิ่งของที่ได้ใช้ เจ้าพนักงานไม่สามารถค้นได้ หรือพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ความผิดของที่ได้ซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องสงสัยนั้นได้ การเพิ่มเติมเงื่อนไขจะช่วยให้เจ้าพนักงานสามารถค้นหาพยานหลักฐานใดที่อาจพิสูจน์ความผิดที่เป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากได้กระทำความผิดไปแล้ว หรืออาจเป็นพยานหลักฐานที่ยังไม่เกิดก็ได้ โดยไม่ต้องอาศัยการตีความเทียบเคียงมาตรา 92(4) ประกอบกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการบัญญัติไว้ในการค้นในที่รโหฐานของไทยแล้ว

เพิ่มขอบเขตที่จะค้นโดยสามารถค้นเพื่อหาสิ่งของที่ “ได้ใช้ ” หรือ “ พยานหลักฐานที่อาจเป็นพิสูจน์ความผิดที่ได้ซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องสงสัยนั้นได้” เพื่อให้มีความครอบคลุมเช่นเดียวกับที่หลักเกณฑ์บัญญัติไว้ในมาตรา 92(4) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพราะหากไม่เพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้อำนาจค้นตัวได้ และหากทำการค้นจะเป็นการค้นตัวบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานของศาล และเจ้าหน้าที่อาจถูกดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญา

2. การปรับปรุงแก้ไขวิธีการค้นตัวบุคคลตามกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 ไม่ได้กำหนดวิธีการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานไว้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการก่อนค้น ระหว่างการค้น และหลังทำการค้น

ดังนั้น ผู้เขียนขอเสนอว่าควรกำหนดวิธีการค้นให้ชัดเจน โดยกำหนดวิธีการให้ครอบคลุมเรื่องโดยแบ่งเป็นการกำหนดเพิ่มในมาตรา 93 ในส่วนที่เป็นบทบังคับและในระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตำรวจในส่วนรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1)การค้นต้องกระทำด้วยสุภาพ ไม่กระทบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เลือกปฏิบัติ

เนื่องจากการค้นเป็นการกระทบสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้ถูกค้นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในฐานะใดไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำความผิด ก็

ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรี และควรมีหลักการควบคุมไม่ให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจตามอำเภอใจ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ต่างกำหนดหลักเกณฑ์นี้ไว้

(2)เจ้าพนักงานต้องแจ้งให้ผู้ถูกค้นทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานและใช้อำนาจตามกฎหมายใด อธิบายเหตุแห่งการใช้อำนาจ เหตุใดจึงมีเหตุอันควรสงสัย และในกรณีที่ไม่สวมเครื่องแบบต้องแสดงบัตร

ทำให้ผู้ถูกตรวจค้นลดความสงสัยว่าตนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ใด ผู้ทำการตรวจค้นเป็นเจ้าพนักงานจริงหรือไม่ เพื่อให้ผู้ถูกตรวจค้นมั่นใจว่าเป็นเจ้าพนักงานจริง ทราบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน และรู้ว่าตนทำผิดอะไร รับรู้สิทธิของตนว่ามีสิทธิอย่างไรตามกฎหมาย ในประเทศนิวซีแลนด์ กฎหมายอังกฤษที่เกี่ยวกับการค้นตัวต้องมีการแจ้งชื่ออธิบายเหตุและแสดงตนเพื่อความโปร่งใสและคลายความสงสัยของผู้ถูกค้น

(3)การตรวจค้นต้องมีการทำบันทึกการตรวจค้นและส่งมอบบันทึกให้แก่ผู้ถูกตรวจค้นในทันทีหรือภายใน 14 วันหลังทำการตรวจค้น และแจ้งแก่ผู้ถูกตรวจค้นว่าเขามีสิทธิได้รับสำเนาก่อนทำการค้น

การจัดทำบันทึกการตรวจค้นตามกฎหมายเดิมกำหนดให้ต้องทำบันทึกการตรวจค้นแต่ยังขาดหลักเกณฑ์ที่จะให้ผู้ถูกค้นได้รับสำเนาบันทึก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถูกค้นมีพยานหลักฐานในการฟ้องร้องเจ้าพนักงานในกรณีที่ตนถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย จึงควรมีการกำหนดให้ส่งมอบบันทึกการตรวจค้นให้แก่ผู้ถูกตรวจค้น เนื่องจากในบันทึกจะปรากฏชื่อเจ้าพนักงาน เหตุที่เจ้าพนักงานใช้อำนาจในการค้น ทำให้ผู้ถูกค้นสามารถไล่เรียงในภายหลังได้ ซึ่งการค้นตัวบุคคลในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายตามมาตรา 92(4) ก็ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ให้ส่งมอบสำเนาแก่ผู้ถูกตรวจค้นไว้แล้ว ดังนั้นมาตรา 93 ควรเพิ่มความคุ้มครองของผู้ถูกค้นโดยการแจ้งสิทธิการมีสำเนาแก่ผู้ถูกตรวจค้นเพื่อให้เขารับทราบและเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่บันทึกการค้นไม่ตรงกับความจริง

การกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสำเนาจะช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความในบันทึกเนื่องจากการตรวจค้นเพิ่งเกิดขึ้นทั้งเจ้าพนักงานทำการค้นและผู้ถูกค้นย่อมจำเหตุการณ์และรายละเอียดได้ดี

(4) การตรวจค้นเบื้องต้นทำได้เพียงการแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธเท่านั้น แต่เจ้าพนักงานสามารถตรวจค้นอย่างละเอียดได้ในกรณีที่มีเหตุอันควรจำเป็นแต่จะต้องทำในที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ

เนื่องจากผู้ถูกค้นตามมาตรา 93 ยังไม่มีฐานะเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย เพียงแต่เป็นบุคคลที่เจ้าพนักงานสงสัยว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้น ดังนั้นการตรวจค้นตัวบุคคลประเภทนี้จึงไม่ควรล่วงละเมิดสิทธิจนเกินสมควร กฎหมายสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสให้อำนาจเพียงการแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธ ขณะที่ประเทศอังกฤษตำรวจมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกค้นถอดเสื้อชั้นนอกเพื่อการตรวจค้นเท่านั้น ส่วนกฎหมายนิวซีแลนด์โดยทั่วไปไม่สามารถเรียกให้ถอดเสื้อผ้าได้ ดังนั้นการเรียกให้ถอดเสื้อผ้าหรือการให้นอนราบกับพื้นอันเป็นการลดค่าความเป็นมนุษย์หรือทำให้อับอายเกินสมควรในที่สาธารณสถานจึงไม่สามารถทำได้ การเสนอให้ค้นเบื้องต้นเพียงตรวจบนเสื้อผ้าด้านนอก ผู้เขียนเห็นว่าเป็นวิธีการที่ไม่ล่วงละเมิดร่างกายจนเกินไปและเหมาะสมกับการสอบสวนในเบื้องต้นแล้ว

(5) การตรวจค้นตัวให้กระทำโดยเจ้าพนักงานหญิงหรือบุคคลอื่นที่เป็นเพศหญิง เว้นแต่ไม่อาจทำได้

เพื่อลดปัญหาการกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานล่วงละเมิดทางเพศกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงผู้ถูกค้นโดยการกำหนดให้กระทำโดยเจ้าพนักงานซึ่งมีเพศเดียวกับผู้ถูกค้น เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยมีการกำหนดไว้ในการค้นตัวบุคคลในที่รโหฐานและค้นตัวผู้ถูกจับเช่นเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการคุ้มครองสิทธิสตรี ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากเจ้าพนักงานของรัฐเพราะต้องมีการสัมผัสบนร่างกายของผู้หญิงผู้ถูกค้น และในปัจจุบันเจ้าพนักงานที่เป็นหญิงมีเพิ่มมากขึ้น การให้อำนาจเจ้าพนักงานหญิงในการค้นตัวผู้ถูกค้นที่เป็นหญิงด้วยกันมีความเหมาะสมมากกว่าและลดการอับอายของผู้ถูกค้น อย่างไรก็ตามการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะเป็นการค้นตัวบุคคลที่เกิดขึ้นโดยเจ้าพนักงานไม่มีการเตรียมการค้นมาก่อนเหมือนการค้นที่มีหมายค้น การหาเจ้าพนักงานหญิงจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทำได้ในทันที ดังนั้นการเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ผู้อื่นที่เป็นผู้หญิงมาช่วยเจ้าพนักงานในการค้นตัวจะทำให้ผู้ถูกค้นที่เป็นหญิงได้รับการคุ้มครองทางเพศมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการขอความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหญิงที่อยู่ในบริเวณนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าการหาเจ้าพนักงานหญิง อีกทั้งทำให้เจ้าพนักงานไม่สูญเสียโอกาสในการตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยในทันทีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพยานหลักฐานในการกระทำความผิดทางอาญา

(6)ค้นตัวต้องกระทำในสถานที่เรียกให้หยุดและในระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้ความสงสัยหมดไป ต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคน และให้แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการค้น

เนื่องจากบุคคลที่ถูกค้นตัวตามมาตรา 93 ไม่ใช่ผู้ถูกจับ ดังนั้นในการค้นตัวบุคคลจึงต้องล่วงละเมิดน้อยที่สุด ไม่ใช่แค่วิธีการตรวจค้นแต่การค้นต้องทำในสถานที่และเวลาที่เกิดความ

สงสัยและไม่ใช้เวลามากเกินสมควร กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษระยะเวลาในการตรวจค้นจึงมีอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ความสงสัยของเจ้าหน้าที่หมดไปเท่านั้น หากความสงสัยหมดไปเจ้าพนักงานไม่สามารถอ้างอำนาจใดในการเหนี่ยวรั้งเสรีภาพของผู้ต้องสงสัยได้ และการค้นต้องทำในขณะที่ผู้ถูกค้นมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ดังนั้นจึงต้องทำในสถานที่ที่ทำให้เจ้าพนักงานเกิดความสงสัยเช่นกัน การกำหนดให้ต้องกระทำต่อหน้าพยานและการที่ให้ผู้ทำการค้นแสดงความบริสุทธิ์ จะช่วยลดการโต้เถียงความถูกต้องในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ลดปัญหาการกล่าวหาเจ้าพนักงานว่ายัดพยานหลักฐานในตัวผู้ถูกค้น ให้มีคนกลางมารับรู้การปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้พยานเป็นสักขีพยานแก่ฝ่ายผู้ถูกค้นและฝ่ายเจ้าพนักงานในภายหลังเมื่อมีการฟ้องร้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลว่าไม่ได้มีการใส่ร้าย กลั่นแกล้งประชาชน

(7)ในส่วนรายละเอียดในการตรวจค้นให้กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามแนวที่กำหนดไว้ในกฎหมายประเทศอังกฤษ เพื่อให้มีความชัดเจนในรายละเอียดและเป็นแบบปฏิบัติเดียวกันทั้งประเทศ

3. **กรณีการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน** ให้นำหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานมาตรา 93 มาอนุโลมใช้ในกรณีที่อยู่นอกขอบเขตของการหมายค้นหรือวัตถุประสงค์ของการค้นโดยไม่มีหมาย

4.ส่วน**แนวทางในการพิเคราะห์หลัก "เหตุอันควรสงสัย"**

ในการที่ศาลไทยจะพิจารณาว่าสถานการณ์ใดมี "มีเหตุอันควรสงสัย" หรือไม่ ในการพิพากษาของศาลผู้เขียนเสนอว่าควรนำแนวทางคำพิพากษาของศาลต่างประเทศไปประกอบดุลยพินิจการวินิจฉัยคดี เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิของประชาชนเนื่องจากเจ้าพนักงานยุติธรรมจะมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ดังนี้

คำพิพากษาของศาลต่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 แนวคือ

<u>1)แนวพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัย</u>

พฤติการณ์ที่ศาลพิพากษาเป็นเหตุอันควรสงสัยได้แก่

(1)คำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์

(2)ความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูล

(3)ภาพรวมทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยและสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีความใกล้เคียงกับการกระทำของผู้กระทำความผิด

(4)ข้อมูลที่ได้รับจากผู้นิรนามประกอบกับการสืบสวนของเจ้าพนักงานที่พบว่ามีการกระทำความผิดที่สอดคล้องกับข้อมูลของผู้แจ้งเป็นอันมาก

(5)ข้อมูลที่ได้รับอำนาจจากเขตอำนาจอีกรัฐหนึ่ง

(6) การสงสัยว่าผู้ต้องสงสัยกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(7)เจ้าพนักงานสงสัยว่ามีผู้ต้องสงสัยมีอาวุธ

(8)ข้อมูลที่ได้รับรายงานมาจากวิทยุและพฤติกรรมที่น่าสงสัยขณะที่เจ้าพนักงานทำการสอบสวน

(9)ผู้ต้องสงสัยให้การโดยสมัครใจว่าเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

(10) พบผู้ต้องสงสัยในแหล่งค้ายาเสพติดประกอบกับการตอบคำถามอย่างกำกวม

หากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นมีข้อเท็จจริงอื่นหรือข้อเท็จจริงทางภาวะวิสัยมาประกอบที่เชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยเข้ากับการกระทำความผิด ศาลมีแนวในการวินิจฉัยว่าเพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัย โดยข้อเท็จจริงนั้นไม่ถึงต้องขนาดพิสูจน์ได้จริงแต่ต้องมีความหนักแน่นชัดเจนเพียงพอในระดับหนึ่ง ผู้เขียนจึงเห็นว่าศาลต่างประเทศให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงที่พบจากพฤติการณ์แวดล้อม(ทางภาวะวิสัย)มากกว่าข้อเท็จจริงจากตัวบุคคลผู้ต้องสงสัย(ทางอัตตะวิสัย)เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดอย่างเดียวไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยแต่หากนำมาพิจารณาประกอบกับพฤติการณ์ที่อยู่รอบๆหรือพฤติการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นศาลมีแนวการตัดสินว่าเพียงพอเป็นเหตุควรสงสัยแล้ว

2)<u>แนวพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัย</u> แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้

(1) กรณีที่เจ้าพนักงานมีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพียงเหตุเดียวมาอ้างเป็นเหตุในการตรวจค้น ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว ผู้ถูกค้นเคยมีประวัติค้ายาเสพติด ผู้ถูกค้นเป็นคนติดยา ผู้ถูกค้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้กระทำความผิด ผู้ต้องสงสัยไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ตอบคำถาม

(2) ความสงสัยหรือความเชื่อของเจ้าพนักงานที่ไม่มีข้อเท็จจริงอื่นมาประกอบ

(3) การสุ่มตรวจค้นยานพาหนะของเจ้าพนักงาน

(4) พบผู้ต้องสงสัยตามที่ได้รับรายงานมาแต่ขณะนั้นบุคคลนั้นไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยและไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำความผิดกับผู้ต้องสงสัย

(5) กรณีเหตุอันควรสงสัยเกิดหลังจากเจ้าพนักงานทำการตรวจค้นแล้ว

ส่วนกฎหมายไทย แนวการวินิจฉัยของศาล มุ่งพิจารณาจากสิ่งของที่ได้จากหลังจากการค้นตัวบุคคลแล้ว หรือความสงสัยเจ้าพนักงานที่ไม่มีพฤติการณ์อื่นประกอบ หรือมุ่งพิจารณาผู้ใช้อำนาจในการตรวจค้น ศาลไทยจึงมักพิจารณาว่าเป็นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยแล้ว ซึ่งมีนักวิชาการให้ความเห็นว่า“ เหตุอันควรสงสัย ” ต้องมีอยู่ “ก่อน”การค้น สิ่งของที่ได้มาจากการค้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือยืนยันถึงความถูกต้องของสิ่งนั้น และคำบอกกล่าวของผู้แจ้งข้อมูลแก่ตำรวจ ต้องมีความน่าเชื่อถือเพียงพอถึงจะอ้างการค้นตัวบุคคลได้

ผู้เขียนเห็นว่าเหตุอันควรสงสัยต้องมีอยู่ “ก่อน” ที่เจ้าพนักงานจะทำการค้นตัวบุคคล เพราะการค้นเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกาย แต่เนื่องจากความจำเป็นในการรักษาความสงบในสังคมและการรวมรวบพยานหลักฐานของเจ้าพนักงาน กฎหมายจึงยกเว้นให้อำนาจเจ้าพนักงานในการค้นตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตามแม้มีความจำเป็นในการรักษาความสงบแต่ควรมีหลักการที่เป็นหลักประกันสิทธิของบุคคลผู้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้อำนาจของรัฐ ดังนั้นไม่ใช่เจ้าพนักงานจะสามารถค้นตัวบุคคลได้ทุกคนแต่เจ้าพนักงานจะค้นตัวบุคคลได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยก่อนการค้น เพราะการพิจารณาเหตุอันควรสงสัย*หลัง*จากทำการค้นไม่ต่างกับเป็นการสนับสนุนให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยอำเภอใจ เมื่อพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาในการตัดสินเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัยผู้เขียนพบว่าศาลฎีกาของไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงใดเพียงพอเป็น “เหตุอันควรสงสัย” แต่ศาลจะพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวมว่าหากเจ้าพนักงานเป็นผู้ใช้อำนาจแล้ว และพบของพยานหลักฐานในการกระทำความผิด ศาลจะพิพากษาว่าเป็นการค้นตัวบุคคลโดยมีเหตุอันควรสงสัยแล้ว ส่งผลให้เจ้าพนักงานเข้าทำการค้นตัวบุคคลโดยใช้ดุลยพินิจของแต่ละคน และหากพบพยานหลักฐานที่สามารถใช้เป็นพิสูจน์ความผิดได้ เป็นการค้นโดยมีเหตุอันควรสงสัย

5. ผลของการที่เจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติมาตรา 93 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้เขียนขอเสนอความเห็นออกเป็น 3 แนวทาง คือ

1)กรณีที่ผลเป็นการค้นโดยมิชอบตามมาตรา 226/1 และศาลไม่ควรใช้ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานนั้น ได้แก่ กรณีที่เจ้าพนักงานค้นโดยไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่มีไว้ ได้มา ได้ใช้ หรือจะใช้ในการกระทำความผิด กรณีที่เจ้าพนักงานไม่กระทำค้นในบริเวณที่ถูกเรียกให้หยุดและภายในระยะเวลาสั้น กรณีที่กล่าวมานี้ผู้เขียนมีความเห็นว่าการรับฟังพยานหลักฐานนั้นไม่ประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมเพราะประชาชนถูกละเมิดสิทธิ

เสรีภาพทางร่างกายเกินสมควร และในกรณีที่ไม่ได้ทำต่อเนื่องในขณะที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยทำให้เจ้าพนักงานหมดอำนาจในการสอบสวนเพราะไม่มีเหตุอันควรสงสัยเสียแล้ว ซึ่งในกรณีเช่นนี้ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยว่ากรณีเจ้าพนักงานค้นโดยไม่มีเหตุอันควรสงสัย หรือมีเหตุอันควรสงสัยแต่ไม่กระทำในที่ที่ถูกเรียกให้หยุดหรือไม่ได้ค้นตัวในระยะเวลาสั้น เป็นการค้นโดยมิชอบพยานหลักฐานรับฟังไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่คุ้มครองไม่ให้ประชาชนถูกค้นตัวโดยไม่มีเหตุอันควร หากศาลใช้ดุลยพินิจรับฟังจะส่งผลให้เจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ศาลไทยจึงควรใช้ดุลพินิจไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานเช่นเดียวกับแนวทางของศาลต่างประเทศ เพราะการรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่กล่าวข้างต้นเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในร่างกายของบุคคลอย่างร้ายแรงเมื่อเทียบกับการนำตัวผู้ต้องสงสัยมาลงโทษและการรับฟังจะเป็นการสนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำการค้นโดยมิชอบ

2) กรณีที่ผลเป็นการค้นโดยมิชอบตามมาตรา 226/1 และศาลอาจใช้ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานนั้น ได้แก่ เจ้าพนักงานไม่แสดงความบริสุทธิ์ก่อนทำการตรวจค้น ไม่กระทำโดยผู้ที่มีเพศเดียวกับผู้ถูกตรวจค้น ไม่มีพยานอย่างน้อยหนึ่งคน ไม่จัดทำบันทึก ในกรณีเช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นข้อปฏิบัติในรายละเอียดซึ่งจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นแล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละคดี ซึ่งการไม่ปฏิบัติในรายละเอียดของเจ้าพนักงานมิได้ส่งผลร้ายแรงจนเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับฟังพยานหลักฐานแต่กระทบกับความน่าเชื่อถือของพยานมากกว่าศาลจึงอาจใช้ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานได้ซึ่งศาลฎีกาของไทยเคยพิพากษาประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไม่มีการจัดทำบันทึกหลังการตรวจค้น การไม่ตรวจค้นต่อหน้าพยานสองคนหรือกรณีเจ้าพนักงานไม่แสดงความบริสุทธิ์ก่อนทำการตรวจค้นว่าศาลมีอำนาจไม่มีรับฟังพยานหลักฐานได้

3) กรณีที่เจ้าพนักงานฝ่าฝืนต่อระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าพนักงานอาจได้รับโทษทางวินัยเพื่อให้เจ้าพนักงานมีบทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน

บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 บทสรุป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในคดีอาญาไว้หลายสิทธิหนึ่งในนั้นคือสิทธิของผู้ถูกค้น การใช้อำนาจในการค้นตัวบุคคลกระทบกับสิทธิในร่างกายของผู้ถูกค้นซึ่งโดยหลักการล่วงละเมิดสิทธิในร่างกายจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการค้นตัวบุคคลนั้น ควรจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนเพื่อป้องกันมิให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจตามอำเภอใจ และวิธีการค้นต้องไม่ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มิฉะนั้นการกระทำของเจ้าพนักงานจะขัดกับรัฐธรรมนูญ เมื่อศึกษาหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานของไทยตามมาตรา 93 เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการดังต่อไปนี้

1) เหตุอันควรสงสัย

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่ากฎหมายต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับเหตุอันควรสงสัยและมีการให้คำนิยามไว้อย่างหลากหลายทั้งใน Black's Law Dictionary ความเห็นของนักวิชาการ และคำพิพากษาของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนพบว่าเหตุอันควรสงสัยไม่สามารถกำหนดนิยามให้แน่นอนตายตัว เนื่องจากต้องการให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยืดหยุ่นเหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องๆไป การกำหนดนิยามชัดแจ้งจะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากลำบาก นิยามตามแนวทางของต่างประเทศจึงเป็นออกมาในรูปของการกำหนดกรอบของเหตุอันควรสงสัยที่เสนอแนะข้อเท็จจริงที่จะนำมาพิจารณาว่ากรณีใดบ้างที่เพียงพอเป็นหตุอันควรสงสัย

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทยยังไม่มีกล่าวถึงหลักการเรื่องเหตุอันควรสงสัยมากนัก ทำให้ไม่ปรากฏคำนิยามหรือการเสนอแนะแนวทางเหมือนของต่างประเทศ

2) แนวทางการวินิจฉัยเรื่องเหตุอันควรค้นตัวและแนวคำพิพากษาของศาล

คำว่า "เหตุอันควรสงสัย"(reasonable suspicion) ศาลต่างประเทศได้วางแนวไว้ว่า ระดับของข้อเท็จจริงไม่ต้องมีความแน่นอน ชัดเจนเหมือนอย่างระดับมาตรฐานมีพยานหลักฐานเชื่อแน่ว่ามีการกระทำความผิด(probable cause) แต่ต้องมีข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดมากกว่าความสงสัยโดยทั่วไป หรือลางสังหรณ์ โดยต้องมีข้อเท็จจริงที่เชื่อมโยงตัวผู้ต้องสงสัยกับการกระทำความผิดได้ ซึ่งอาจมาจากข้อมูลทางตรง กล่าวคือเป็นข้อเท็จจริงที่เจ้าพนักงานประสบพบด้วยตนเองก็ได้ หรือจากข้อมูลทางอ้อม กล่าวคือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับจากพยานบอกเล่า หรือจากรายงานการสอบสวน ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงที่แน่ชัดเพียงพอที่จะสงสัยได้ว่าผู้ต้องสงสัยจะกระทำความผิดหรือได้กระทำความผิดมาแล้วศาลต่างประเทศจะถือว่าข้อเท็จจริงนั้นเพียงพอที่จะก่อให้เกิดเหตุอันควรสงสัยแล้ว

อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่จะก่อให้เกิดเหตุอันควรสงสัยต้องประกอบไปด้วยพฤติการณ์จากตัวผู้ต้องสงสัย(อัตตะวิสัย)และพฤติการณ์แวดล้อมอื่นๆ(ภาวะวิสัย)ด้วย หมายความว่าหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้ต้องสงสัยเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีพฤติกรรมแวดล้อมอื่นที่น่าสงสัยว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดหรือจะกระทำความผิด ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว ผู้ถูกค้นเคยมีประวัติค้ายาเสพย์ติด ผู้ถูกค้นเป็นคนติดยา ผู้ถูกค้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้กระทำความผิด ผู้ต้องสงสัยไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ตอบคำถามหรือมีข้อมูลที่ได้รับจากการสอบสวน หรือจากการบอกเล่าแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ปรากฏว่าผู้จะถูกค้นมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย หากปรากฏข้อเท็จจริงเหล่านี้ ศาลมีแนวคำพิพากษาว่าไม่เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยอันทำให้เจ้าพนักงานเกิดอำนาจในการค้นตัวบุคคล

3) กระบวนการค้นตัวบุคคล

กฎหมายต่างประเทศมีการกำหนดกระบวนการไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้

(1)เหตุอันควรสงสัย ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลสูงสุดได้วางเงื่อนไขเหตุอันควรสงสัยไว้ว่าให้เจ้าพนักงานค้นตัวบุคคลเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีอาวุธ ส่วนกฎหมายอังกฤษกำหนดกรอบของเหตุอันควรสงสัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมไว้ในPACEในกรณีที่เจ้าพนักงานสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ได้ลักมาหรือสิ่งของต้องห้ามซึ่งเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดหรือสิ่งของที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือสิ่งของที่มีไว้เพื่อกระทำความผิด เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมายไทยเจ้าพนักงานค้นตัวบุคคลได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ได้มาโดยการกระทำความผิดหรือมีไว้เป็นความผิด หรือเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด

ทำให้ในกรณีที่เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือพยานหลักฐานอื่นซุกซ่อนในร่างกาย เจ้าพนักงานไม่สามารถใช้อำนาจตามมาตรา 93 ได้

(2) กระบวนการก่อนค้นตัวบุคคล ประเทศนิวซีแลนด์กฎหมายบางฉบับกำหนดว่าก่อนการค้นเจ้าพนักงานต้องแจ้งว่าเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจตามกฎหมายใด หากไม่ได้สวมเครื่องแบบต้องแสดงบัตร ส่วนประเทศอังกฤษกำหนดให้เจ้าพนักงานต้องแจ้งแก่ผู้ถูกตรวจค้นด้วยว่าเป็นเจ้าพนักงาน สังกัดหน่วยงานใด ใช้อำนาจตามกฎหมายใด เหตุใดจึงเกิดเหตุอันควรสงสัย และแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกตรวจค้นว่าผู้ถูกค้นมีสิทธิได้รับสำเนาบันทึกการตรวจค้น ทำให้ประเทศอังกฤษมีหลักเกณฑ์อันเป็นการประกันสิทธิแก่ผู้ถูกตรวจค้นดีกว่าประเทศอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยพบว่ามีการกำหนดหลักการให้มอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นในกรณีการค้นในที่รโหฐานเช่นกัน แต่ไม่มีขั้นตอนที่สมบูรณ์เหมือนประเทศอังกฤษ

(3)กระบวนการระหว่างค้น กฎหมายต่างประเทศได้วางหลักการทั่วไปว่าการค้นตัวบุคคลต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้ถูกค้นตัวจนเกินสมควร และจำกัดขอบเขตการค้นตัวบุคคลโดยมีวิธีการค้น เวลา และสถานที่ ซึ่งกฎหมายไทยยังไม่มีการกำหนดขอบเขตการค้นตัวบุคคล ส่งผลให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจค้นตัวบุคคลได้อย่างไม่มีขอบเขตเกิดการกระทบกับสิทธิของผู้ถูกค้นตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ถูกค้นตัวที่เป็นผู้หญิง

(4)กระบวนการหลังค้น กฎหมายพิเศษของไทยและนิวซีแลนด์บางฉบับกำหนดให้เจ้าพนักงานผู้ใช้อำนาจจัดทำบันทึกการตรวจค้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีการกำหนดให้ต้องส่งสำเนาบันทึกการตรวจค้นให้แก่ผู้ถูกตรวจค้นตัวเหมือนกฎหมายประเทศอังกฤษ

(5)หากเจ้าพนักงานกระทำการตรวจค้นตัวบุคคลโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัย หรือการตรวจค้นที่มิได้กระทำในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่ได้ทำการตรวจค้น ณ สถานที่ที่ถูกเรียกให้หยุด ทำให้เป็นการค้นที่มิชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ศาลอาจไม่รับฟังพยานหลักฐานชิ้นนั้นในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกค้น เจ้าพนักงานอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่ง รวมถึงทางวินัยอีกด้วย

4) การค้นตัวบุคคลในที่รโหฐาน

การค้นตัวบุคคลในที่รโหฐาน กรณีนอกขอบเขตของหมายค้นหรือนอกขอบเขตของการค้นโดยไม่มีหมาย เจ้าพนักงานไม่สามารถตรวจค้นตัวโดยใช้วิธีการตามมาตรา 100 วรรคสองได้ เจ้าพนักงานจะอ้างอำนาจใดการตรวจค้น มีความเห็นของนักวิชาการว่าควรใช้หลักเกณฑ์

มาตรา 93 และ Newzealand Law Commission เสนอว่าการตรวจค้นต้องมีเงื่อนไขในระดับ " เหตุอันควรเชื่อ " ในการตรวจค้นเช่นกัน มิใช่ว่าจะทำการค้นตัวได้ในทันที

6.2 ข้อเสนอแนะ

แนวทางการวินิจฉัยเรื่องเหตุอันควรสงสัย ผู้เขียนเสนอว่าศาลไทยควรใช้แนวทางการตัดสินของคำพิพากษาต่างประเทศมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิพากษาคดี

เงื่อนไขของของการค้นตัวบุคคล ผู้เขียนเสนอว่าควรเพิ่มเติมเงื่อนไขในมาตรา 93 ให้ครอบคลุมไปถึงกรณีที่เจ้าพนักงานสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของซึ่ง "ได้ใช้ " หรือ " พยานหลักฐานที่อาจเป็นพิสูจน์ความผิดที่ได้ซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องสงสัยนั้นได้ "

กระบวนการค้นตัวบุคคล ผู้เขียนเสนอว่าควรเพิ่มหลักเกณฑ์ในมาตรา 93 ทั้งกระบวนการก่อนค้น ระหว่างการค้นและหลังการค้นให้มีความสมบูรณ์และเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ถูกค้นตัวมากยิ่งขึ้นตามแนวทางของต่างประเทศ ดังนี้

1. การค้นต้องกระทำด้วยสุภาพ ไม่กระทบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เลือกปฏิบัติ

2.เจ้าพนักงานต้องแจ้งให้ผู้ถูกค้นทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานและใช้อำนาจตามกฎหมายใด อธิบายเหตุแห่งการใช้อำนาจ เหตุใดจึงมีเหตุอันควรสงสัย และในกรณีที่ไม่สวมเครื่องแบบต้องแสดงบัตร

3.การตรวจค้นตัวในเบื้องต้นทำได้เพียงการแตะต้องตัวบุคคลด้านนอกเพื่อหาอาวุธเท่านั้น แต่เจ้าพนักงานสามารถตรวจค้นอย่างละเอียดได้ในกรณีที่มีเหตุอันควรจำเป็นแต่จะต้องทำในที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ

4.ต้องกระทำโดยเจ้าพนักงานหญิงหรือบุคคลอื่นที่เป็นเพศหญิง เว้นแต่ไม่อาจทำได้

5.การตรวจค้นต้องกระทำ ณ บริเวณที่เรียกให้หยุดและในระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้ความสงสัยหมดไป ต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคน และให้ผู้ตรวจค้นแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการค้น

6.เจ้าพนักงานควรจัดทำบันทึกการตรวจค้นและส่งมอบบันทึกให้แก่ผู้ถูกตรวจค้นทันทีหรือภายใน 14 วันดังหลังทำการตรวจค้น และแจ้งแก่ผู้ถูกตรวจค้นว่าเขามีสิทธิได้รับสำเนาก่อนทำการค้น

7.รายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ให้ออกเป็นระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรณีการค้นตัวบุคคลในที่รโหฐาน ให้นำหลักเกณฑ์การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานตามมาตรา 93 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้



บรรณานุกรม

หนังสือ

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายว่าหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา. พิมพ์ครั้งที่ 7 . กรุงเทพมหานครมหานคร :หจก. สำนักพิมพ์พลสยามพริ้นติ้ง(ประเทศไทย), 2553.

เข็มชัย ชุติวงศ์. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน.พิมพ์ครั้งที่ 7.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุภาการพิมพ์,2543.

คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา,2549.

คณิน บุญสุวรรณ. คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2547.

คนึง ฦาไชย. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา .พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานครมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548.

จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช. คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก จับ ค้น(ควบคุม) ขัง จำคุก ปล่อย(ปล่อยชั่วคราว).กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร,2548

จิรนิติ หะวานนท์. สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานครมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544.

จุลสิงห์ วสันตสิงห์. คำอธิบายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาภาค1. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา:,2553.

ชาติ ชัยเดชสุริยะ. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์เตือนตุลา,2549.

ชูชาติ อัศวโรจน์ . คำอธิบายกฎหมายศุลกากร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา,2542.

_____. ปัญหากฎหมายศุลกากรและข้อวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544.

_____. อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานทหารเรือในการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยกองทัพเรือ นทน.วทร.รุ่นที่ 25,2536.

ชัยเกษม นิติศิริ. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน.กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,2551.

ณรงค์ ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเล่ม 1.พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน,2550.

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานของสิทธิละเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. กรุงเทพมหานครมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543.

พิพัฒน์ จักรางกูร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา .กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ,2546.

มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 พร้อมข้อเสนอสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) .พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2549.

สมชัย ฑีฆาอุตมากร. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิพมพ์พลสยามพริ้นติ้ง(ประเทศไทย,2547.

อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ. การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2524. กรุงเทพมหานครมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2544 .

บทความ

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. “หลักการไม่ยอมรับฟังพยานวัตถุ พยานเอกสาร ซึ่งได้มาโดยการจับ การค้น การยึด ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในสหรัฐอเมริกา” .วารสารนิติศาสตร์. ปีที่9.ฉบับที่3.(ธันวาคม 2521): 123.

จิรนิติ หะวานนท์. “หลักการไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ : เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอเมริกันและกฎหมายเยอรมัน”. ดุลพาห.ปีที่ 31.ฉบับที่3. (พฤษภาคม-มิถุนายน2527) :37.

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ฉัตรชัย สลักคำ. “การเลือกปฏิบัติต่อสตรีศึกษาการห้ามสตรีเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของพุทธศาสนสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

ชลลดา จินตเสถียร. “ข้อยกเว้นการห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบตามมาตรา226/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

ธิติ สายเชื้อ. “พยานหลักฐานตามสมควรในการที่ศาลจะออกหมายค้น.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2549.

ฐานิศร์ วรรณสุข. “ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา:ศึกษากรณีสิ่งซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.” สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2550.

ปวีณา พันธุ์ธนุสร. “ปัญหาการรับฟังถ้อยคำของผู้ถูกจับในชั้นจับกุม.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

ปิยวรรณ ดีนาน. “การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญามิให้ต้องรับสารภาพโดยไม่สมัครใจ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ภาคภูมิ โกกะอินทร์. “หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

มโน ซอศรีสาคร. “การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ ค้น ยึด โดยมิชอบ ศึกษาเฉพาะกรณีพยานวัตถุหรือพยานเอกสาร.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.

ยุพาภรณ์ วงศ์วิกรานต์. “การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์.” สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

รุ่งนภา แสนละมะ. “การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายผู้ต้องหา ศึกษากรณีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

อิศราวุธ อ่อนน้อม. “หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ.”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2540.

เอกสารอื่น ๆ

ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ."รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยการติดตามและการประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ความเป็นมนุษย์." กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชานิติศาสตร์.นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการค้นตัวบุคคลศึกษาเปรียบเทียบกับนานาประเทศ.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์เดือนตุลา,2553.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ปกป้อง ศรีสนิท."พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบในคดีอาญา".

http://www.statelessperson.com/

Books

Andrew Ashworth and Mike Redmayne. The Criminal Process.3 ed. Oxford : Oxford University Press,2005.

Andrews & Hirst.Criminal Evidence.3 ed.London : Sweet&Maxwell,1997.

David Fledman . Civil liberties and Human Rights in England and Wales .2 nd . Oxford : Oxford University Press, 2002.

Helen fenwick . Civil liberties .2 ed.London : Cavendish Pub, 1996.

Herbert L,Packer. The limits of the criminal sanction.California: Stanford University Press, 1968.

Joel Samaha. Criminal Procedure .7 ed. Belmont, California : Thomson/Wadsworth,2008.

John L.Worrall .Criminal procedure from the first contact to appeal. 2 ed.Boston : Pearson/Allyn and Bacon, 2007.

John N. Ferdico.Criminal Procedure for the Criminal Justice Professional.9 nd.Belmont : Thomworth,2005.

Roland V. Carmen . Criminal Procedure Law and Practice .5 ed.Belmont, California : Wadsworth/Thomson Learning, 2001.

Serge Guinchard,Jacques Buisson.Procedure penale.4 ed.Paris : Litec,2008.

Articles

Bernard Robertson.“ Search and Seizure”.New Zealand Law Journal.(2010).

Craig M.Bladley. “Mapp Goes Abroad”.Case Western Reserve Law Review.(2001-2002).

Joel Miller.” STOP AND SEARCH IN ENGLAND A Reformed Tactic or Business as Usual?”.British Journal of Criminology(2010).

Justice Susan Glazebrook, Natalie Baird and Sasha Holden. ” New Zealand: Country Report on Human Rights”.Victoria University of Wellington Law Review(2009)

Petra Butler.” Human Rights and Parliamentary Sovereignty in New Zealand”.Victoria University of Wellington Law Review (2004).

Scott Optican. “Lessons From Down Under:A Dialogue on Police Search and Seizure in New Zealand and The United States”. OHIO STATE JOURNAL OF CRIMINAL LAW(2005).

Other Materials

New Zealand Law Commission.Search and Survillance Powers. Wellington 2007,chapter 8.

http://international.westlaw.com/

http://www.uspcak9.com/

ประวัติการศึกษา

ชื่อ	นางสาวจิรสุดา ถาวรสุขสิริ
วันเดือนปีเกิด	4 พฤษภาคม พ.ศ.2528
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี)	- สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 27 - สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตของสำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 62